



II

Wytyczne PPP

Tom I: Przygotowanie Projektów PPP

Tom II: Postępowanie PPP

Tom III: Umowa o PPP

Tom IV: Zarządzanie Umową o PPP



Fundusze
Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Ministerstwo Funduszy
i Polityki Regionalnej

Publikacja Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Warszawa 2025 r., wersja 3.0

Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Opracowanie: grudzień 2024 r.

Warunki korzystania z niniejszej publikacji

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFIPR) oświadcza, że treść opracowania ma charakter informacyjny i pełni funkcję rekomendacji opartych o krajowe i międzynarodowe doświadczenia w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

MFIPR nie odpowiada za błędne interpretacje treści publikacji ani za następstwa czynności i decyzji podjętych w oparciu o niniejsze Wytyczne. W związku z tym użytkownik korzystający z informacji zawartych w niniejszej publikacji czyni to na swoją wyłączną odpowiedzialność. Opracowanie nie powinno być wprost stosowane, bez odpowiedniego dostosowania do konkretnego przedsięwzięcia.

MFIPR upoważnia odbiorców niniejszej publikacji do jej użytkowania, pobierania, wyświetlania, kopiowania i rozpowszechniania, w całości lub w części, ze wskazaniem źródła pochodzenia cytowanych materiałów. Bezwzględnie zabronione jest wykorzystywanie niniejszego dokumentu i jego treści do celów komercyjnych. Dokument może zawierać odesłania do serwisów internetowych podmiotów trzecich. MFIPR nie ponosi odpowiedzialności za takie serwisy, a korzystanie z nich może podlegać szczegółowym warunkom.

Spis treści

Słownik pojęć	5
Wprowadzenie	12
1. Kluczowe czynniki sukcesu Postępowania PPP	14
1.1 Wysoka jakość analiz w ramach Oceny Efektywności i uwzględnienie wniosków z testów rynkowych	15
1.2 Efektywna Komisja Przetargowa i doświadczeni Doradcy Podmiotu Publicznego	17
1.3 Sprawna organizacja i efektywne przeprowadzenie Postępowania	20
1.4 Wysoka jakość Dokumentacji Postępowania	25
1.5 Pozyskanie wiarygodnych Partnerów Prywatnych	26
2. Podstawy prawne oraz tryby wyboru Partnera Prywatnego	28
2.1 Podstawy prawne współpracy w ramach PPP	28
2.2 Jak wybrać Partnera Prywatnego?	37
2.3 Tryby wyboru Partnera Prywatnego	41
2.4 Ustawa o PPP a Ustawa PZP i Ustawa o Umowie Koncesji	49
3. Przygotowanie Postępowania PPP	69
3.1 Czynności przygotowawcze	69
3.2 Harmonogram Postępowania	82
3.3 Strategia negocjacyjna	89
3.4 Projekty pakietowe – grupowanie Projektów PPP	92
4. Ogłoszenie o zamówieniu oraz koncesji	95
4.1 Zakres ogłoszenia w Postępowaniu PPP	95
4.2 Opis Projektu PPP	97
4.3 Kryteria Oceny Podmiotowej	99
4.4 Dokumenty i oświadczenia Partnerów Prywatnych	135
4.5 Kryteria Oceny Ofert	138
4.6 Wadium	149
4.7 Zmiany ogłoszenia i OPiW	152
5. Badanie i ocena wniosków	154
5.1 Postępowanie PZP	154
5.2 Postępowanie Koncesyjne	157
6. Negocjacje	159
6.1 Zakres dokumentacji Podmiotu Publicznego na potrzeby Negocjacji	159
6.2 Zaproszenie do Negocjacji	161
6.3 Zarządzanie procesem Negocjacji	163
6.4 Zasady dokumentowania Negocjacji	172
6.5 Opracowanie ostatecznej Dokumentacji Postępowania	173

7. Ocena ofert	213
7.1 Zaproszenie do składania ofert	213
7.2 Pytania do SWZ oraz Dokumentów Koncesji.....	214
7.3 Metodyka oceny ofert	217
7.4 Wybór oferty najkorzystniejszej	225
7.5 Unieważnienie Postępowania.....	227
8. Środki ochrony prawnej	231
9. Zawarcie Umowy o PPP	233
9.1 Przygotowanie do zawarcia Umowy o PPP	233
9.2 Zamknięcie Finansowe.....	236
10. Zakończenie Postępowania PPP	241

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik Nr 1 – Przykładowy Opis Potrzeb i Wymagań – sektor drogowy

Załącznik Nr 2 – Przykładowy Opis Przedmiotu Umowy Koncesji – sektor wodno-kanalizacyjny

Załącznik Nr 3 – Przykładowy Regulamin Negocjacji

Załącznik Nr 4 – Proponowany harmonogram Negocjacji

Słownik pojęć

Pojęcie	Wyjaśnienie
Analiza Potrzeb i Wymagań	oznacza analizę dokonywaną przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 83 Ustawy PZP
Bankowość	oznacza zdolność do pozyskania finansowania zewnętrznego dla Projektu PPP
BZP	oznacza Biuletyn Zamówień Publicznych
Decyzja Administracyjna	oznacza decyzję, pozwolenie administracyjne, uzgodnienie, zgodę, opinię lub inny akt wydawany przez organy administracji, którego uzyskanie jest niezbędne dla realizacji Projektu PPP
Decyzja Środowiskowa	oznacza decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Dialog Konkurencyjny	oznacza dialog konkurencyjny w rozumieniu Ustawy PZP
Dokumenty Koncesji	oznacza dokumenty koncesji w rozumieniu Ustawy o Umowie Koncesji
Dokumentacja Postępowania	oznacza wszelkie dokumenty przygotowane na potrzeby Postępowania PPP, w tym dokumenty zamówienia w rozumieniu Ustawy PZP
Doradca / Zespół Doradców	oznacza doradców zewnętrznych, w tym m.in. doradców finansowych, prawnych i technicznych zaangażowanych przez Podmiot Publiczny
DUUE	oznacza Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Duży Projekt	oznacza Projekt PPP o szacowanej wartości nakładów inwestycyjnych równej lub wyższej niż 50 mln PLN brutto
Dyrektywy Zamówieniowe	oznaczają łącznie: • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej,

	energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji
EPEC	oznacza Europejskie Centrum Wiedzy o PPP (ang. <i>European PPP Expertise Centre</i>), którego członkami są Komisja Europejska, Europejski Bank Inwestycyjny i państwa członkowskie - udziałowcy Europejskiego Banku Inwestycyjnego
Etap Inwestycyjny	oznacza etap obejmujący projektowanie i budowę Infrastruktury Publicznej
Etap Operacyjny	oznacza etap obejmujący utrzymanie lub zarządzanie Infrastrukturą Publiczną
Etap Przygotowawczy	oznacza etap obejmujący działania w ramach przygotowania organizacyjnego Podmiotu Publicznego, Ocenę Efektywności, Postępowanie PPP, Zamknięcie Komercyjne oraz Zamknięcie Finansowe
Infrastruktura Publiczna	oznacza jakiegokolwiek składnik majątkowy Podmiotu Publicznego, który wykorzystywany będzie na potrzeby realizacji Projektu PPP
Instytucja Finansująca	oznacza podmiot udzielający finansowania na realizację Projektu PPP na zlecenie i ryzyko Partnera Prywatnego
JEDZ	oznacza Jednolity Europejski Dokument Zamówienia stanowiący oświadczenie wstępne wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 2 Ustawy PZP i w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji UE 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
JST	oznacza jednostkę samorządu terytorialnego
Kierownik Projektu	oznacza osobę odpowiedzialną za kierowanie Zespołem Projektowym
KIO	oznacza Krajową Izbę Odwoławczą
Kluczowe Wskaźniki Efektywności (ang. <i>Key Performance Indicators, KPI</i>)	oznaczają wskaźniki stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów założonych w Umowie o PPP lub w umowie w sprawie utrzymania i zarządzania (ang. <i>Operation and Management Agreement, O&M</i>)
Kodeks Cywilny	oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Komisja Przetargowa	oznacza komisję przetargową w rozumieniu Ustawy PZP, jak również zespół o podobnym charakterze, jeżeli został

	ustanowiony w przypadku Postępowań realizowanych na podstawie Ustawy o Umowie Koncesji
Komitety Sterujący	oznacza dedykowany zespół osób Podmiotu Publicznego odpowiedzialny za decyzje strategiczne
Koncepcja Projektowa	oznacza opracowanie projektowe dotyczące planowanej inwestycji, na podstawie którego przygotowywany jest projekt budowlany, mające na celu przedstawienie różnych koncepcji budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektu oraz zestawienie podstawowych danych technicznych
Koncesjonariusz	oznacza koncesjonariusza lub wykonawcę, o którym mowa w przepisach Ustawy o Umowie Koncesji
Kryteria Ewaluacji	oznaczają łącznie Kryteria Oceny Ofert oraz Kryteria Oceny Podmiotowej
Kryteria Oceny Ofert	oznaczają kryteria oceny ofert, o których mowa w przepisach Ustawy PZP oraz Ustawy o Umowie Koncesji
Kryteria Oceny Podmiotowej	oznaczają podstawy wykluczenia, warunki udziału w Postępowaniu oraz kryteria selekcji (jeśli są ustalone) na gruncie Ustawy PZP albo przesłanki wykluczenia, kryteria kwalifikacji oraz kryteria selekcji (jeśli są ustalone) na gruncie Ustawy o Umowie Koncesji
Mały Projekt	oznacza Projekt PPP o szacowanej wartości nakładów inwestycyjnych niższej niż 50 mln PLN brutto
Mechanizm Wynagradzania	oznacza sposób wynagrodzenia Partnera Prywatnego określony w Umowie o PPP, w tym m.in. Opłata za Dostępność, Myto Ukryte lub Opłaty od Użytkowników
Myto Ukryte (ang. <i>Shadow Toll</i>)	oznacza wynagrodzenie obliczane na bazie faktycznego wykorzystania Infrastruktury Publicznej przez Użytkowników, płatne Partnerowi Prywatnemu przez Podmiot Publiczny
Negocjacje	oznacza etap negocjacyjny Postępowania, podczas którego dyskutowane są wszelkie kwestie dotyczące Projektu PPP pomiędzy Partnerami Prywatnymi a Podmiotem Publicznym, bez względu na podstawę prawną prowadzonego Postępowania
Ocena Efektywności	oznacza analizy dotyczące Projektu PPP wykonywane przez Podmiot Publiczny przed wszczęciem Postępowania na wybór Partnera Prywatnego, mające na celu ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia w rozumieniu Ustawy o PPP

Opinia PPP	oznacza opinię dotyczącą zasadności realizacji Przedsięwzięcia wydawaną przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego na podstawie Ustawy o PPP
Opis Potrzeb i Wymagań / OPIW	oznacza opis potrzeb i wymagań Podmiotu Publicznego w rozumieniu Ustawy PZP
Opis Przedmiotu Umowy Koncesji / OPUK	oznacza opis przedmiotu umowy koncesji, o którym mowa w Ustawie o Umowie Koncesji
Opłata za Dostępność / OzD	oznacza wynagrodzenie Partnera Prywatnego płatne przez Podmiot Publiczny uzależnione od dostępności aktywa i jakości świadczonych usług, a nie rzeczywistego wykorzystania składnika Infrastruktury Publicznej
Opłaty od Użytkowników / OoU	oznacza sposób wynagrodzenia Partnera Prywatnego, w którym otrzymuje on prawo do pobierania opłat od Użytkowników za korzystanie z Infrastruktury Publicznej
Partner Prywatny	oznacza partnera prywatnego w rozumieniu Ustawy o PPP albo Koncesjonariusza w rozumieniu Ustawy o Umowie Koncesji lub wykonawcę w rozumieniu Ustawy PZP albo Ustawy o Umowie Koncesji
Partnerstwo Publiczno-Prywatne / PPP	oznacza formę współpracy pomiędzy Podmiotami Publicznymi a Partnerami Prywatnymi, której celem jest realizacja zadań publicznych oparta o podział zadań i ryzyk, regulowana przepisami Ustawy o PPP, Ustawy o Umowie Koncesji
Podmiot Publiczny	oznacza podmiot publiczny w rozumieniu Ustawy o PPP albo zamawiającego w rozumieniu Ustawy PZP albo Ustawy o Umowie Koncesji
Polityka PPP	oznacza "Politykę Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego do roku 2030" stanowiącą załącznik do uchwały nr 177 Rady Ministrów z dnia 25 września 2023 r.
Postępowanie Koncesyjne	oznacza postępowanie na wybór Partnera Prywatnego prowadzone na podstawie Ustawy o Umowie Koncesji
Postępowanie PPP / Postępowanie	oznacza postępowanie na wybór Partnera Prywatnego, bez względu na podstawę prawną współpracy w ramach PPP
Postępowanie PZP	oznacza postępowanie na wybór Partnera Prywatnego prowadzone na podstawie Ustawy PZP
PPP Instytucjonalne	oznacza Przedsięwzięcie realizowane w formie Spółki PPP

Progi Unijne	oznaczają wartości zamówień wskazane w art. 3 ust. 1 Ustawy PZP, ogłaszane przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych
Program Funkcjonalno-Użytkowy / PFU	oznacza program funkcjonalno-użytkowy w rozumieniu Ustawy PZP oraz odpowiednich przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie
Projekt Koncesyjny	oznacza przedsięwzięcie prowadzone na podstawie umowy koncesji na roboty budowlane lub umowy koncesji na usługi w rozumieniu Ustawy o Umowie Koncesji
Projekt Hybrydowy	oznacza Projekt PPP z wykorzystaniem finansowania ze środków europejskich w rozumieniu art. 2 pkt 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej
Projekt PPP / Przedsięwzięcie	oznacza przedsięwzięcie w rozumieniu Ustawy o PPP
Regulamin Postępowania	oznacza dokument opracowywany przez Podmiot Publiczny, udostępniany Partnerom Prywatnym przed Negocjacjami, którego celem jest efektywna organizacja Postępowania
RODO	oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
Rozporządzenie w sprawie Dokumentów	oznacza rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
Rozporządzenie w sprawie Ryzyka	oznacza rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie

Rozporządzenia w sprawie Zakresu i Formy Dokumentacji	oznacza rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego
SWZ	oznacza specyfikację warunków zamówienia w rozumieniu przepisów Ustawy PZP
Specyfikacja Techniczno-Funkcjonalna	oznacza dokumentację Podmiotu Publicznego inną niż PFU przygotowywaną w Postępowaniu Koncesyjnym w celu określenia oczekiwanego od Partnera Prywatnego zakresu robót budowlanych
Sponsor	oznacza podmiot będący współnikiem Spółki Projektowej
Spółka PPP	oznacza spółkę Partnera Prywatnego i Podmiotu Publicznego, o której mowa w Ustawie o PPP
Spółka Projektowa	oznacza spółkę specjalnego przeznaczenia, utworzoną w celu realizacji konkretnego Projektu PPP
Tryb Negocjacyjny Podprogowy	oznacza tryb udzielenia zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż Progi Unijne, o którym mowa w art. 275 pkt 3 Ustawy PZP
Umowa Bezpośrednia	oznacza umowę pomiędzy stronami Umowy o PPP a Instytucjami Finansującymi (lub z wyznaczonym przez Instytucje Finansujące agentem działającym na ich rzecz), na podstawie, której uzgadniane są zasady współpracy z Instytucjami Finansującymi w trakcie realizacji Projektu PPP, a w szczególności w przypadku wypowiedzenia Umowy o PPP w wyniku naruszenia jej postanowień przez Partnera Prywatnego
Umowa o PPP / Umowa	oznacza umowę dotyczącą Projektu PPP, zawieraną pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym
Ustawa o Autostradach Płatnych i KFD	oznacza ustawę z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym
Ustawa o Efektywności Energetycznej	oznacza ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
Ustawa o Finansach Publicznych	oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Ustawa o Gospodarce Komunalnej	oznacza ustawę z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami	oznacza ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
Ustawa o PPP	oznacza ustawę z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
Ustawa o Umowie Koncesji	oznacza ustawę z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi
Ustawa o Zasadach Zarządzania Mieniem Państwowym	oznacza ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Ustawa Prawo Budowlane	oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Ustawa PZP	oznacza ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
Użytkownik	oznacza podmiot korzystający z Infrastruktury Publicznej (użytkownika końcowego)
Value for Money / VfM	oznacza efektywność realizacji projektu w modelu PPP, w porównaniu do tradycyjnej formuły realizacji przez Podmiot Publiczny
Wytyczne Tom I	oznaczają Wytyczne PPP w zakresie przygotowania Projektów PPP
Wytyczne Tom II	oznaczają Wytyczne PPP w zakresie przeprowadzenia Postępowania na wybór Partnera Prywatnego
Wytyczne Tom III	oznaczają Wytyczne PPP w zakresie Umów o PPP
Wytyczne Tom IV	oznaczają Wytyczne PPP w zakresie zarządzania Umową o PPP
Zamawiający	oznacza zamawiającego w rozumieniu Ustawy PZP lub Ustawy o Umowie Koncesji
Zamknięcie Finansowe	oznacza podpisanie umów dotyczących uzyskania przez Partnera Prywatnego finansowania, w łącznej kwocie wystarczającej do należytej realizacji Projektu PPP
Zamknięcie Komercyjne	oznacza zawarcie pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym Umowy o PPP lub umowy koncesji
Zespół Projektowy PPP / Zespół Projektowy	oznacza zespół pracowników Podmiotu Publicznego skierowanych do przygotowania, realizacji i monitorowania Projektu PPP

Wprowadzenie

Wytyczne Tom II dotyczą przeprowadzenia Postępowania PPP od momentu decyzji Podmiotu Publicznego o realizacji Projektu PPP, przez przygotowanie Postępowania na wybór Partnera Prywatnego, przeprowadzenie Negocjacji, aż do momentu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia Umowy o PPP, a następnie – Zamknięcia Finansowego.

Wytyczne Tom II obejmują Postępowania realizowane zarówno na podstawie Ustawy o PPP, jak też Ustawy o Umowie Koncesji. W treści Wytycznych Tom II zasygnalizowano także inne możliwości dokonania wyboru Partnera Prywatnego. Dla potrzeb Wytycznych Tom II przyjęto modelowy sposób przeprowadzania Postępowania PPP oparty o dwuetapowe, negocjacyjne Postępowanie, bez względu na podstawę prawną i tryb wyboru Partnera Prywatnego. Podejście takie umożliwia Zamawiającemu opracowanie Dokumentacji Postępowania dobrej jakości, pozwalającej na otrzymanie wyważonych i rzetelnie skalkulowanych ofert, co w konsekwencji przełoży się na efektywną realizację Projektu PPP.

Najwięcej uwagi poświęcono przy tym Ustawie o PPP, Ustawie PZP i rekomendowanemu trybowi wyboru Partnera Prywatnego, jakim jest Dialog Konkurencyjny. W odniesieniu do Projektów PPP o wartości zamówienia niższej niż Progi Unijne, uwzględniono rekomendowany tryb udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 275 pkt 3 Ustawy PZP (Tryb Negocjacyjny Podprogowy).

Wytyczne Tom II składają się z części podstawowej, obejmującej omówienie zasad przygotowania i przeprowadzenia Postępowania PPP oraz załączników, stanowiących uzupełnienie prezentowanych treści w postaci przykładowych dokumentów, które można wykorzystać w Postępowaniach PPP.

W Wytycznych Tom II znajdują się odniesienia do Wytycznych Tom I, Wytycznych Tom III oraz Wytycznych Tom IV. Odniesienia zawarte są w ramce "Powiązane sekcje Wytycznych PPP Tom I-IV" na początku punktu, którego dotyczą.

Wytyczne Tom II zawierają tabele i ramki wyróżniające określone zagadnienia, oznaczone w następujący sposób:

Tytuł ramki	Ikona	Znaczenie
Dobre praktyki		wskazanie najlepszych praktyk w oparciu o doświadczenia międzynarodowe i krajowe
Małe Projekty		wskazanie różnicy w podejściu do realizacji projektów o niższej wartości
Powiązane sekcje Wytycznych PPP Tom I-IV		wskazanie Części i Punktów w Wytycznych Tom I-Wytycznych Tom IV, w których szczegółowo wyjaśnione są zagadnienia poruszane w Wytycznych Tom II
Przykłady		wskazanie praktycznych przykładów
Uwaga		wskazanie kwestii, na które należy zwrócić szczególną uwagę

Źródła Informacji



wskazanie dodatkowych źródeł informacji
rozszerzających treści zawarte w Wytycznych
Tom II

Umieszczone w Wytycznych Tom II schematy, tabele i innego rodzaju grafiki mają za zadanie uporządkowanie informacji zawartych w tekście i ułatwienie ich analizy. Na wstępie Wytycznych Tom II znajduje się Słownik pojęć, z którego treścią należy zapoznać się przed przystąpieniem do lektury Wytycznych Tom II.

Należy zwrócić uwagę, że Wytyczne Tom II, w tym zawarte w nich przykłady, mają jedynie charakter wskazówek dla Podmiotu Publicznego co do rodzaju zadań oraz sposobu realizacji czynności składających się na Postępowanie PPP i jako takie nie stanowią gotowych rozwiązań, czy też zamkniętego i ostatecznego katalogu działań możliwych do podjęcia przez Podmiot Publiczny i jego Doradców, a także Partnerów Prywatnych uczestniczących w Postępowaniach. Wybór zakresu czynności do wykonania będzie zależał od charakteru i przedmiotu rozważanego Projektu PPP oraz jego uwarunkowań.

1. Kluczowe czynniki sukcesu Postępowania PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część I Punkt 5 - Kluczowe czynniki sukcesu Projektu PPP na Etapie Przygotowawczym

Tom I: Część II Punkt 2.1 – Działania przygotowawcze po stronie Podmiotu Publicznego

Tom I: Część II Punkt 3 – Ocena Efektywności realizacji Przedsięwzięcia w modelu PPP

Tom III: Część I Punkt 1 – Kluczowe czynniki sukcesu Umowy o PPP

Tom IV: Część I Punkt 2 – Kluczowe czynniki sukcesu Zarządzania Umową o PPP

Powodzenie Postępowania PPP uzależnione jest od jego prawidłowego, sprawnego i efektywnego przeprowadzenia oraz doprowadzenia do Zamknięcia Komercyjnego, Zamknięcia Finansowego i rozpoczęcia realizacji Projektu PPP.

Sukces Postępowania zależy w znacznej mierze od działań i przygotowania Podmiotu Publicznego. Poniżej przedstawiono pięć kluczowych czynników sukcesu Postępowania PPP, na które wpływ ma Podmiot Publiczny.

Kluczowe czynniki sukcesu Postępowania PPP to:

- wysoka jakość analiz w ramach Oceny Efektywności i uwzględnienie wniosków z analiz rynkowych;
- efektywna Komisja Przetargowa i doświadczeni Doradcy Podmiotu Publicznego;
- sprawna organizacja i przeprowadzenie Postępowania;
- wysoka jakość Dokumentacji Postępowania, uwzględniająca wnioski z Negocjacji;
- pozyskanie najlepszych merytorycznie Partnerów Prywatnych, gwarantujących wypracowanie optymalnych rozwiązań.

Na jakość Postępowania mają wpływ również inne czynniki, nie zawsze zależne od Podmiotu Publicznego, takie jak:

- otoczenie społeczno-gospodarcze Projektu PPP;
- atrakcyjność Projektu PPP dla rynku Partnerów Prywatnych;
- atrakcyjność Projektu PPP dla rynku Instytucji Finansujących;
- doświadczenie Partnerów Prywatnych uczestniczących w Postępowaniu;
- otoczenie polityczne Projektu PPP.

W kolejnych punktach dokonano syntetycznej charakterystyki kluczowych czynników powodzenia Postępowania PPP.

1.1 Wysoka jakość analiz w ramach Oceny Efektywności i uwzględnienie wniosków z testów rynkowych

Postępowanie PPP powinno zostać poprzedzone przeprowadzeniem analiz typowych dla przygotowania Projektów PPP, składających się na Ocenę Efektywności. Sposób, zakres oraz cel Oceny Efektywności zostały szczegółowo zaprezentowane w Wytycznych Tom I.

W Wytycznych Tom II istotne jest podkreślenie, że wnioski z należycie przeprowadzonej Oceny Efektywności należy uwzględnić przy organizowaniu Postępowania oraz przygotowaniu Dokumentacji Postępowania. Rzetelna Ocena Efektywności Projektu PPP umożliwia podjęcie przez Podmiot Publiczny decyzji o realizacji Projektu PPP. Ponadto, odpowiednio przygotowane analizy w ramach Oceny Efektywności umożliwiają należyte wypracowanie głównych założeń Projektu PPP w sferze technicznej, finansowej, prawnej, podatkowej i organizacyjnej.

Prawidłowo przygotowana Ocena Efektywności pozwoli na:

- podjęcie przez Podmiot Publiczny decyzji o kontynuowaniu projektu w formule PPP;
- realizację przez Podmiot Publiczny rekomendowanych działań;
- podjęcie przez Podmiot Publiczny decyzji w zakresie rodzaju i trybu Postępowania;
- przygotowanie Opisu Potrzeb i Wymagań albo Opisu Przedmiotu Umowy Koncesji.

Dokumentacja Postępowania, w szczególności na etapie ogłoszenia Postępowania, powinna opierać się na wnioskach z analiz prowadzonych w ramach Oceny Efektywności. Dotyczy to zarówno planowanego zakresu Projektu PPP, jego szacowanej wartości, jak też struktury prawno-organizacyjnej, Mechanizmu Wynagradzania i zasad finansowania.

Należy mieć na uwadze, że przeprowadzenie analiz w ramach Oceny Efektywności w sposób niewłaściwy, na przykład poprzez przyjęcie nierealnych lub zbyt optymistycznych założeń, prowadzić będzie do błędnych wyników, a co za tym idzie – może skutkować przyjęciem nieodpowiedniej podstawy prawnej współpracy w ramach Projektu PPP albo brakiem zainteresowania Partnerów Prywatnych lub Instytucji Finansujących.

PRZYKŁAD



Ocena Efektywności Projektu PPP obejmującego budowę, utrzymanie i zarządzanie pływalnią w małej gminie nie obejmowała właściwie przeprowadzonej analizy rynku i wykazała, że projekt ten będzie przedsięwzięciem opłacalnym finansowo.

Zamiast rzetelnie przeprowadzonej analizy rynkowej przyjęto bowiem założenia dotyczące liczby Użytkowników pływalni odbiegające od faktycznego popytu na tę usługę, jak również ceny biletów wstępu istotnie przekraczające dostępność finansową dla Użytkowników w tej gminie.

W efekcie Podmiot Publiczny wszczął Postępowanie w oparciu o Ustawę o Umowie Koncesji z założeniem, że wybrany Koncesjonariusz zaprojektuje, sfinansuje, wybuduje oraz będzie zarządzał i utrzymywał pływalnię w zamian za Opłaty od Użytkowników, bez konieczności dokonywania dopłat ze strony Podmiotu Publicznego. W odpowiedzi na ogłoszenie o koncesji nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu.

Istotny element Oceny Efektywności z punktu widzenia efektywności Postępowania stanowią analizy rynkowe, których zakres, forma i cel zostały szczegółowo omówione w Wytycznych Tom I.

Przeprowadzenie badania rynku Partnerów Prywatnych oraz Instytucji Finansujących może skutkować koniecznością zmiany założeń Projektu PPP lub nawet rezygnacją z realizacji Projektu PPP.

DOBRE PRAKTYKI



Potencjalni Partnerzy Prywatni i Instytucje Finansujące są w stanie wstępnie zweryfikować założenia Projektu PPP. W przypadku braku zainteresowania rynku planowanym Projektem PPP lub w przypadku przedstawienia przez Partnerów Prywatnych lub Instytucje Finansujące innych założeń dla Projektu PPP, należy wziąć je pod uwagę przy wnioskach z przeprowadzonej Oceny Efektywności. Przeanalizowanie postulatów Partnerów Prywatnych i Instytucji Finansujących pozwoli na lepsze przygotowanie Postępowania PPP i zwiększy szansę powodzenia Projektu PPP. Zignorowanie stanowiska rynku może natomiast skutkować stratą czasu i środków finansowych przez Podmiot Publiczny na prowadzenie nieefektywnego Postępowania, w ramach którego nie dojdzie do Zamknięcia Komercyjnego lub Zamknięcia Finansowego.

Warto zwrócić uwagę, że wnioski z Oceny Efektywności będą nadal rewidowane w ramach samego Postępowania PPP. W wyniku ustaleń poczynionych z Partnerami Prywatnymi w toku Postępowania PPP, niektóre założenia lub rozwiązania przyjęte w analizach czasami ulegają zmianom. Dotyczy to w szczególności:

- elementów zakresu Projektu PPP;
- założeń finansowych, w tym nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych;
- standardów utrzymania lub zarządzania;
- matrycy ryzyk;
- zasad finansowania;
- Mechanizmu Wynagradzania lub jego struktury;
- harmonogramu realizacji Projektu PPP.

PRZYKŁAD



W toku Dialogu Konkurencyjnego oraz w wyniku informacji uzyskanych od Partnerów Prywatnych może okazać się, że zakładana w ramach Oceny Efektywności wysokość Opłaty od Użytkowników jest niewystarczająca, aby Partner Prywatny osiągnął oczekiwany zwrot z inwestycji. Tym samym konieczne mogą okazać się zmiany w planowanym Przedsięwzięciu, takie jak np. poniesienie określonych płatności przez Podmiot Publiczny, zmiana zakresu Projektu PPP, przejęcie dodatkowych ryzyk przez Podmiot Publiczny itp.

1.2 Efektywna Komisja Przetargowa i doświadczeni Doradcy Podmiotu Publicznego

Komisja Przetargowa, jako zespół pomocniczy kierownika Zamawiającego, odgrywa kluczową rolę w Postępowaniu PPP. Członkowie Komisji Przetargowej powinni być powoływani przede wszystkim spośród przedstawicieli Zespołu Projektowego, którzy uczestniczyli we wcześniejszych fazach prac nad Projektem PPP. Skład, kompetencje oraz rola Komisji Przetargowej zostały szczegółowo opisane w Wytycznych Tom I.

W praktyce w strukturach Podmiotów Publicznych, w tym w szczególności w JST, mogą działać stałe Komisje Przetargowe. W Postępowaniach PPP skład Komisji Przetargowej jest zwykle poszerzany o osoby posiadające kompetencje w obszarze planowanego Projektu PPP.

Komisja Przetargowa w Postępowaniu PPP, z uwagi na szczególny charakter Projektów PPP, wymagający określonych kompetencji od członków Komisji Przetargowej, ma za zadanie nie tylko dbać o prawidłowe przeprowadzenie Postępowania pod kątem formalnym, lecz również brać aktywny udział w Negocjacjach w celu wypracowania jak najwłaściwszych rozwiązań kontraktowych, które regulować będą współpracę Podmiotu Publicznego oraz Partnera Prywatnego przez cały okres trwania Umowy o PPP.

Dlatego tak ważne jest, aby skład Komisji Przetargowej umożliwiał efektywne prowadzenie Negocjacji. Kompetencje członków Komisji Przetargowej powinny być zatem ściśle określone. W trakcie powierzania członkom Komisji Przetargowej kolejnych obowiązków służbowych należy brać pod uwagę konieczność znaczącego ich zaangażowania w Postępowanie PPP.

Z uwagi na interdyscyplinarny charakter Komisji Przetargowej oraz konieczność nieustannej interakcji tego zespołu z innymi podmiotami zaangażowanymi w Postępowanie PPP (Partnerzy Prywatni, Instytucje Finansujące, Doradcy, organy Podmiotu Publicznego) niezmiennie istotne jest ustanowienie Kierownika Projektu PPP po stronie Podmiotu Publicznego o niezbędnych kompetencjach organizacyjnych i merytorycznych. Często tę funkcję pełni osoba wchodząca w skład kierownictwa Podmiotu Publicznego (np. kierownik państwowej jednostki budżetowej, zastępca prezydenta, sekretarz miasta lub dyrektor wydziału inwestycji). Musi być ona członkiem Komisji Przetargowej, choć niekoniecznie o statusie przewodniczącego. Oprócz koordynowania prac związanych z prowadzonym Postępowaniem, bierze także udział w pracach Komitetu Sterującego i na bieżąco raportuje o postępach prac w ramach Postępowania do organów Podmiotu Publicznego takich jak np. zarząd i organ stanowiący.

PRZYKŁAD



Przykładem złej praktyki jest ograniczenie roli członków Komisji Przetargowej do kwestii formalnych związanych z Postępowaniem i pozostawienie strony merytorycznej Postępowania, w tym Negocjacji w zakresach prawnych, technicznych i finansowych Projektu PPP wyłącznie Doradcom. W praktyce zdarza się, że przedstawiciele Podmiotu Publicznego przyjmują w trakcie Negocjacji rolę bierną. Tymczasem aktywny udział członków Komisji Przetargowej, będących jednocześnie członkami Zespołu Projektowego, uwiarygadnia Projekt PPP w oczach Partnerów Prywatnych, a jednocześnie pozwala na budowanie i rozwijanie kompetencji po stronie Podmiotu Publicznego – od wczesnego etapu Projektu PPP, aż do wykonywania Umowy o PPP.

Wszyscy członkowie Komisji Przetargowej muszą posiadać stosowne umocowanie do uczestniczenia w jej pracach (na podstawie powołania w skład komisji w charakterze członka, biegłego lub innej osoby wykonującej czynności w Postępowaniu).

Komisja powinna składać się z osób o różnych kompetencjach adekwatnych do zakresu Przedsięwzięcia. Niezbędne jest również zaangażowanie osoby odpowiedzialnej za finanse Podmiotu Publicznego, np. skarbnika, który najczęściej będzie kontrasygnował Umowę o PPP przed jej podpisaniem.

DOBRE PRAKTYKI



Przykładowy skład Komisji Przetargowej

Przykładowy skład Komisji Przetargowej w JST może wyglądać następująco:

- zastępca prezydenta/burmistrza lub sekretarz gminy – przewodniczący Komisji Przetargowej;
- dyrektor wydziału inwestycji – członek Komisji Przetargowej odpowiedzialny za zagadnienia związane z etapem projektowania i budowy w ramach Projektu PPP;
- specjalista wydziału inwestycji – członek Komisji Przetargowej odpowiedzialny za zagadnienia związane z etapem utrzymania lub eksploatacji w ramach Projektu PPP;
- skarbnik/główny księgowy – członek Komisji Przetargowej odpowiedzialny za finansowe aspekty przedsięwzięcia;
- specjalista z wydziału środków zewnętrznych – członek Komisji Przetargowej odpowiedzialny za zagadnienia związane z dofinansowaniem Projektu PPP ze środków unijnych lub innych źródeł (jeśli dotyczy);
- specjalista z wydziału zamówień publicznych – członek Komisji Przetargowej odpowiedzialny za formalne aspekty procedury, w tym sporządzanie protokołów z tur negocjacyjnych i protokołu z Postępowania.

Ponadto w pracach Komisji Przetargowej uczestniczyć mogą następujące osoby (w charakterze biegłych lub innych osób wykonujących czynności w Postępowaniu):

- eksperci ds. prawnych (radca prawny, adwokat, doradca podatkowy) – odpowiedzialni za opracowanie i Negocjacje Umowy o PPP, aspekty formalne Postępowania, podatki, finansowanie, inne konieczne zagadnienia;
- eksperci ds. finansowych – odpowiedzialni za aspekty finansowe Projektu PPP, w tym przygotowanie Mechanizmu Wynagradzania, przygotowanie i aktualizację modelu finansowego, służącego do oceny Projektu PPP przez Podmiot Publiczny, wsparcie podczas Zamknięcia Finansowego;
- eksperci ds. technicznych – odpowiedzialni za stronę techniczną i technologiczną inwestycji, w tym opracowanie PFU/Specyfikacji Techniczno-Funkcjonalnej i standardów utrzymania;
- inni eksperci (np. ds. ubezpieczeń, ryzyka, zarządzania obiektem).

PRZYKŁAD



Przykładem złej praktyki jest rozszerzanie składu Komisji Przetargowej o pracowników Podmiotu Publicznego bez przypisanych zadań i kompetencji, których uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowej ma charakter bierny. W praktyce kilkunastoosobowa komisja działać będzie nieefektywnie, a czas takich osób mógłby zostać przeznaczony na inne zadania.

Ponadto, zalecane jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu PPP, w tym różnych aspektów Postępowania, dla wszystkich członków Komisji Przetargowej przed wszczęciem Postępowania lub na wczesnym jego etapie. Takie szkolenie może zostać przeprowadzone przez Doradcę.

W pracach Komisji Przetargowej biorą udział zatem również inne osoby wykonujące czynności w Postępowaniu, w tym przede wszystkim Doradcy. Należy pamiętać, że rolą Doradców w Postępowaniu jest wspomaganie Podmiotu Publicznego na poszczególnych etapach Postępowania. Jak już wskazano, Doradca nie powinien zastępować Podmiotu Publicznego w podejmowaniu wszelkich decyzji dotyczących Projektu PPP. Zespół Doradców powinien posiadać natomiast odpowiednie doświadczenie i kompetencje umożliwiające kompleksowe wsparcie Podmiotu Publicznego w przygotowaniu oraz przeprowadzeniu Postępowania PPP. Zasady wyboru Doradców wskazane zostały w Wytycznych Tom I.

MAŁE PROJEKTY



W przypadku Małych Projektów PPP, w ramach których Podmiot Publiczny dysponuje ograniczonymi środkami finansowymi, co uniemożliwia zaangażowanie Doradców w pełnym zakresie, a Zespół Projektowy PPP nie posiada kompetencji wystarczających do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia Postępowania PPP, zaleca się skorzystanie w największym możliwym stopniu z dobrych praktyk prezentowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej na stronie www.ppp.gov.pl, w tym w Wytycznych Tom I-IV.

W takich przypadkach rekomenduje się również wystąpienie do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z wnioskiem o przeprowadzenie oceny zasadności realizacji Projektu PPP na podstawie przepisów Ustawy o PPP (Opinia PPP).

Zalecane jest również zatrudnienie Doradców przynajmniej w zakresie wybranych aspektów Postępowania PPP, mających kluczowy wpływ na efektywność Projektu PPP (np. opracowanie projektu Umowy o PPP, przygotowanie PFU i standardów utrzymania lub zarządzania, przygotowanie modelu finansowego).

Ponadto, w przypadku Małych Projektów PPP rozważenia wymaga realizacja Przedsięwzięcia jako projektu pakietowego, tj. obejmującego kilka tożsamyh lub podobnych inwestycji. Uzyskanie w ten sposób efektu skali może zwiększyć zainteresowanie Projektem PPP wśród Partnerów Prywatnych i Instytucji Finansujących, ale również umożliwić zaangażowanie doświadczonego zespołu Doradców, zdolnego do obsługi takiego Przedsięwzięcia.

1.3 Sprawna organizacja i efektywne przeprowadzenie Postępowania

Niewątpliwie jednym z kluczowych czynników powodzenia Postępowania PPP jest jego sprawne przeprowadzenie. Pod pojęciem tym należy rozumieć nie tyle szybkość Postępowania, co jego efektywność. Dlatego też, szczególnie na etapie Postępowania, ważna jest rola Kierownika Projektu (może być on jednocześnie przewodniczącym lub członkiem Komisji Przetargowej) oraz kierownika Zespołu Doradców, którzy wspólnie powinni zadbać o sprawny przebieg Postępowania.

Sprawny przebieg Postępowania PPP warunkowany jest między innymi:

- przyjęciem realistycznego harmonogramu Postępowania, uwzględniającego odpowiedni czas na wykonywanie poszczególnych czynności, w tym przeprowadzenie tur negocjacyjnych i pracę nad kolejnymi wersjami Dokumentacji Postępowania;
- sprawnym prowadzeniem Negocjacji, w sposób umożliwiający elastyczne kształtowanie zasad i warunków współpracy w ramach Projektu PPP;
- opracowaniem w oparciu o Negocjacje z Partnerami Prywatnymi wysokiej jakości Dokumentacji Postępowania, na podstawie której zostaną złożone oferty.

Narzędzia wykorzystywane do prawidłowego przygotowania Postępowania, w tym harmonogram Postępowania, zostały opisane w Wytycznych Tom I.

W celu prawidłowej organizacji Postępowania Podmiot Publiczny powinien właściwie zaplanować poszczególne kroki i działania w Postępowaniu i efektywnie wykorzystywać odpowiednie zasoby, w tym Zespół Projektowy, Komitet Sterujący (jeśli dotyczy) i Komisję Przetargową.

W ramach poszczególnych kroków Postępowania PPP można wyróżnić:

Krok 1: Czynności przygotowawcze

Krok 2: Ogłoszenie o zamówieniu/koncesji

Krok 3: Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu (ofert w Trybie Negocjacyjnym Podprogowym)

Krok 4: Negocjacje

Krok 5: Zaproszenie do składania ofert i ich ocena

Krok 6: Zawarcie Umowy o PPP (Zamknięcie Komercyjne)

Krok 1 Czynności przygotowawcze

Wszczęcie Postępowania poprzedzają czynności przygotowawcze, takie jak:

- oszacowanie wartości zamówienia;
- wykonanie Oceny Efektywności (uwzględniającej zakres Analizy Potrzeb i Wymagań);
- ewentualne uzyskanie od ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego opinii na temat zasadności realizacji Przedsięwzięcia w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (Opinia PPP);

- uzyskanie na etapie planowania inwestycji, od ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego, niewiążącej opinii w przedmiocie sposobu realizacji inwestycji, jeżeli planowana kwota finansowania z budżetu państwa takiej inwestycji przekracza 500 mln PLN (Test PPP);
- powołanie Komisji Przetargowej;
- opracowanie Regulaminu Postępowania;
- opracowanie regulaminu Komisji Przetargowej;
- opracowanie strategii negocjacyjnej (jeśli jest planowana);
- opracowanie projektu ogłoszenia, w tym:
 - opracowanie projektu Opisu Potrzeb i Wymagań/Opisu Przedmiotu Umowy Koncesji;
 - opracowanie projektu Kryteriów Oceny Podmiotowej;
 - opracowanie projektu Kryteriów Oceny Ofert;
 - opracowanie projektu harmonogramu Postępowania.

Przepisy prawa nie regulują terminów, w których czynności te powinny zostać wykonane. Czas na przygotowanie Postępowania PPP nie powinien jednak przekraczać 2-3 miesięcy od daty podjęcia decyzji o realizacji Projektu PPP. W przeciwnym razie może dojść do konieczności ponownej weryfikacji wniosków z Oceny Efektywności i przyjętych założeń do Projektu PPP.

Przygotowanie Postępowania omówione zostało w Punkcie 3 Przygotowanie Postępowania PPP.

Krok 2 **Ogłoszenie o zamówieniu/koncesji**

Właściwe Postępowanie wszczynane jest poprzez przekazanie ogłoszenia do DUUE lub zamieszczenie ogłoszenia w BZP (na temat ogłoszenia Postępowania patrz Punkt 4 Ogłoszenie o zamówieniu oraz koncesji).

Już na tym etapie Partnerzy Prywatni mogą zadawać pytania do ogłoszenia lub wnioskować o zmianę warunków zawartych w ogłoszeniu, lub w Opisie Potrzeb i Wymagań. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści OPIW wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu (Dialog Konkurencyjny – do którego zastosowanie ma przepis art. 143 ust. 2 Ustawy PZP). Ta sama zasada dotyczy Trybu Negocjacyjnego Podprogowego, z tym że terminy wynoszą tu odpowiednio 2 i 4 dni oraz odnoszą się do składania ofert podlegających negocjacjom (art. 284 Ustawy PZP).

Ustanowiony termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu nie powinien być zbyt krótki. W szczególności nie zaleca się posługiwania minimalnymi terminami określonymi w Ustawie PZP lub Ustawie o Umowie Koncesji.

Specyfika PPP polega na tym, że w trakcie tego etapu najczęściej podejmowane są decyzje, co do współpracy Sponsorów, w tym uzgadnianie warunki tej współpracy, podział ról i zobowiązań w Projekcie PPP. Tym samym Sponsorzy Projektu PPP muszą uzyskać wewnętrzne zgody korporacyjne na założenie Spółki Projektowej, względnie - przystąpienie do konsorcjum i złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, co zajmuje niejednokrotnie kilka tygodni.

DOBRE PRAKTYKI



Często spotykanym modelem współpracy Sponsorów jest wykorzystanie Spółki Projektowej jako wehikułu inwestycyjnego Sponsorów, który składa wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, a następnie ofertę. Taka spółka zazwyczaj nie posiada samodzielnie niezbędnych zasobów, w tym doświadczenia w celu spełnienia warunków udziału czy kryteriów selekcji. Dlatego też zazwyczaj będzie polegać na potencjale podmiotów trzecich zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy PZP. Poleganie na takim potencjale w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia powoduje z kolei, iż podmioty te powinny zostać podwykonawcą Partnera Prywatnego na etapie realizacji Umowy o PPP (por. art. 118 ust. 2 Ustawy PZP).

Podmiot Publiczny powinien mieć na uwadze, że w postępowaniach dwuetapowych, w których złożenie oferty następuje później niż kwalifikacja podmiotowa wykonawców (np. Dialog Konkurencyjny) Partnerzy Prywatni, którzy dysponowali potencjałem podmiotów trzecich na etapie składania wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, mogą następnie dokonywać zmian w strukturze organizacyjnej Spółki Projektowej. Zmiany te mogą wpłynąć także na posługiwanie się przez Partnera Prywatnego podwykonawcami. Spotykanym przykładem jest nawiązanie współpracy przez Partnerów Prywatnych w toku Dialogu Konkurencyjnego z innymi podmiotami trzecimi, które mają stać się następnie jego podwykonawcami zamiast podmiotów, które udostępniły swoje zasoby Partnerowi Prywatnemu na etapie kwalifikacji podmiotowej. Oznacza to, że w praktyce podmioty dotychczas udostępniające zasoby nie będą realizować części prac w ramach Umowy o PPP. W takim przypadku konieczne jest dokonanie zmiany podmiotów, na potencjale których Partner Prywatny polegał w trakcie składania wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu. Sytuacja ta jest dopuszczalna, jednakże w takim przypadku Partner Prywatny (dokonując zmiany podmiotów, na potencjale których polegał) powinien potwierdzić, że nowy podmiot nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału i kryteria selekcji w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot trzeci.

Oznacza to, że zmiana podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby Partnerowi Prywatnemu jest możliwa nie tylko na etapie realizacji Umowy o PPP (art. 462 ust. 7 Ustawy PZP), ale także na etapie Postępowania. Należy przy tym pamiętać, że Partner Prywatny nie może po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby (art. 123 Ustawy PZP).

Mając na uwadze powyższe, optymalny termin na zgłoszenie wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu to 2-3 miesiące. W praktyce przy realizacji Małych Projektów (w szczególności w Trybie Negocyjnym Podprogowym) terminy te są z reguły krótsze.

Krok 3

Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu/ofert wstępnych

Ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu następuje w oparciu o Kryteria Oceny Podmiotowej przyjęte w ogłoszeniu. Badanie tych kryteriów obejmuje zarówno podstawy wykluczenia podmiotu z Postępowania, jak też analizę spełniania przez wykonawców warunków

udziału w Postępowaniu (w przypadku Projektów Koncesyjnych – tzw. kryteriów kwalifikacji) oraz zastosowanie kryteriów selekcji wykonawców (o ile zostały ustanowione przez Podmiot Publiczny).

Przepisy prawa nie regulują terminów, w których czynność ta powinna zostać wykonana. O ile to możliwe, czas na dokonanie oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu nie powinien jednak przekraczać 1-2 miesięcy od daty ich złożenia. W przypadku Postępowań, do których zgłasza się duża liczba wykonawców może on ulec wydłużeniu.

Należy pamiętać, że na etapie weryfikacji Kryteriów Oceny Podmiotowej Partnerzy Prywatni wzywani się do uzupełniania złożonych dokumentów lub udzielania wyjaśnień. Zdarza się, że dochodzi też do wykluczenia wykonawców z Postępowania, co może skutkować składaniem przez nich odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, a to z kolei wprost przekłada się na czas realizacji tego etapu. Etap oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu kończy się zaproszeniem do Negocjacji tych wykonawców, którzy zostali do nich zakwalifikowani w oparciu o określone w ogłoszeniu Kryteria Oceny Podmiotowej. Z uwagi na zapewnienie konkurencyjności zaleca się, aby liczba zaproszonych Partnerów Prywatnych nie była mniejsza niż 5.

Kwalifikacja Partnerów Prywatnych do Negocjacji została ukształtowana nieco inaczej w Trybie Negocjacyjnym Podprogowym. W tym trybie nie przewidziano etapu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu. W zamian przyjęto, że w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu składana jest oferta podlegająca Negocjacji, którą można określić mianem oferty wstępnej. Oferta ostateczna jest składana po zakończeniu Negocjacji, w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert ostatecznych.

Badanie i ocena wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu lub ofert omówione zostały w Punkcie 5 Badanie i ocena wniosków.

Krok 4 **Negocjacje**

Negocjacje składają się z kilku (średnio 3-5) rund negocjacyjnych i dotyczą technicznych, finansowych i prawnych aspektów Projektu PPP. Przepisy prawa nie wprowadzają ograniczeń dotyczących liczby spotkań ani czasu ich trwania. Z tego powodu, szczególnie na etapie Negocjacji, istotna jest dobra organizacja pracy Komisji Przetargowej i Zespołu Doradców, jak również ściśle przestrzeganie ustalonego wcześniej harmonogramu Postępowania.

Średni okres potrzebny na przeprowadzenie Negocjacji wynosi od 6 do 12 miesięcy. Czas ten zależy w szczególności od stopnia skomplikowania Projektu PPP, liczby uczestniczących wykonawców oraz sprawności działania Podmiotu Publicznego, w tym Komisji Przetargowej i Zespołu Doradców. Po zakończeniu Negocjacji Podmiot Publiczny opracowuje ostateczną wersję Dokumentacji Postępowania, w tym doprecyzowuje Kryteria Oceny Ofert, wskazane wcześniej w ogłoszeniu.

W przypadku Trybu Negocjacyjnego Podprogowego, Negocjacje dotyczą treści złożonych ofert wstępnych.

Szerzej na temat etapu Negocjacji patrz Punkt 6 Negocjacje.

Krok 5

Zaproszenie do składania ofert i ich ocena

Wypracowana przez Podmiot Publiczny, przy wsparciu Doradcy, Dokumentacja Postępowania, przekazywana jest Partnerom Prywatnym wraz z zaproszeniem do składania ofert. Należy dodać, że za formalne przygotowanie Dokumentacji Postępowania odpowiada Podmiot Publiczny.

Okres przewidziany na złożenie ofert będzie różnił się w zależności od wielkości i stopnia skomplikowania Projektu PPP. Powinien być on na tyle długi, aby Partnerzy Prywatni mogli przygotować oferty. Standardowo okres ten wynosi ok. 3-6 miesięcy.

Przy sformułowaniu przez Podmiot Publiczny dodatkowych wymogów, takich jak np. opracowanie przez Partnera Prywatnego koncepcji architektonicznej lub połączenie Zamknięcia Komercyjnego z Zamknięciem Finansowym, okres na złożenie ofert powinien być odpowiednio dostosowany i może on wynieść więcej niż 6 miesięcy (patrz Punkt 9 Zawarcie Umowy o PPP).

Na tym etapie Partnerzy Prywatni zadają pytania do SWZ i składają wnioski o zmianę SWZ (albo do Dokumentów Koncesji w przypadku Postępowania Koncesyjnego). Niewykluczone jest również składanie przez wykonawców odwołań na treść SWZ, o ile wykonawcy stwierdzą jej niezgodność z przepisami Ustawy PZP (albo Ustawy o Umowie Koncesji). Krok ten kończy się złożeniem ofert, a następnie wyborem oferty najkorzystniejszej, względnie – unieważnieniem Postępowania (por. Punkt 7.4 Wybór oferty najkorzystniejszej).

W przypadku Małych Projektów, w tym Przedsięwzięć realizowanych w Trybie Negocjacyjnym Podprogowym, terminy na składanie ofert ostatecznych mogą być krótsze.

Krok 6

Zawarcie Umowy o PPP (Zamknięcie Komercyjne)

Po upływie okresu przewidzianego na skorzystanie z ewentualnych środków odwoławczych przez pozostałych uczestników Postępowania, Podmiot Publiczny zawiera z wybranym Partnerem Prywatnym Umowę o PPP. Moment zawarcia Umowy o PPP jest określany jako Zamknięcie Komercyjne (szerzej na ten temat w Punkcie 9 Zawarcie Umowy o PPP).

Zamknięcie Komercyjne, w przypadku Projektów PPP z Opłatą za Dostępność lub Mytem Ukrytym, poprzedzone jest zapewnieniem środków finansowych w formie właściwej dla danego Podmiotu Publicznego (np. w przypadku JST będzie to wieloletnia prognoza finansowa). Zamknięcie Komercyjne nie może nastąpić wcześniej niż po upływie ustawowych terminów na skorzystanie przez wykonawców z przysługujących im środków ochrony prawnej (por. Punkt 8 Środki ochrony prawnej). W praktyce czas na Zamknięcie Komercyjne wynosi od 15 do 60 dni; w trakcie tego okresu Podmiot Publiczny i Partner Prywatny dokonują niezbędnych czynności organizacyjnych, zmierzających do podpisania Umowy. W przypadku Małych Projektów, w tym Przedsięwzięć realizowanych w Trybie Negocjacyjnym Podprogowym, terminy te są zazwyczaj znacznie krótsze.

Ponadto wejście w życie zasadniczej części Umowy o PPP często warunkowane jest uzyskaniem przez Partnera Prywatnego Zamknięcia Finansowego. W przypadku Projektów Hybrydowych Umowa o PPP może mieć charakter warunkowy i wówczas jej realizacja zależy od podpisania przez beneficjenta umowy o dofinansowanie Projektu PPP. Czynności zmierzające do Zamknięcia Finansowego nie powinny przekraczać 6-12 miesięcy od daty Zamknięcia Komercyjnego (z zastrzeżeniem przypadków, w których Zamknięcie Komercyjne i Zamknięcie Finansowe następują równocześnie).

1.4 Wysoka jakość Dokumentacji Postępowania

Na Dokumentację Postępowania składają się wszelkie dokumenty wypracowywane przez Podmiot Publiczny w Postępowaniu – nie tylko formalne związane z Postępowaniem jak ogłoszenie, SWZ/Dokumenty Koncesji, lecz również dodatkowe, które przekazywane są Partnerom Prywatnym, takie jak np. PFU, Decyzje Środowiskowe, badania geologiczne, dodatkowe informacje dotyczące Przedsięwzięcia lub służące sprawom organizacyjnym (np. harmonogram Postępowania).

Od rzetelności i kompletności dokumentów zależy nie tylko zainteresowanie Partnerów Prywatnych i Instytucji Finansujących danym Postępowaniem, ale również czas jego trwania i koszty całego Przedsięwzięcia.

Niektóre elementy dokumentacji technicznej powinny zostać opracowane przez Podmiot Publiczny już na etapie przygotowania Postępowania (na przykład badania geologiczne, badania stanu technicznego istniejącej infrastruktury; szerzej na ten temat w Wytycznych Tom I).

Od jakości Dokumentacji Postępowania zależy zarówno liczba Partnerów Prywatnych zainteresowanych udziałem w Postępowaniu, liczba pytań do SWZ/Dokumentów Koncesji, oferty składane przez Partnerów Prywatnych (w zakresie ceny, ryzyka, oraz pozostałych Kryteriów Oceny Ofert), jak również dalsza realizacja Projektu PPP.

Należy podkreślić, że im bardziej rzetelna i wiarygodna Dokumentacja Postępowania, uwzględniająca wszelkie aspekty współpracy w ramach Projektu PPP, tym ryzyka z nią związane będą dokładniej i rzetelniej wyceniane przez Partnerów Prywatnych i Instytucje Finansujące. Ma to bezpośrednie przełożenie na warunki współpracy proponowane w ofertach wykonawców, wynagrodzenie oraz zapewnienie Bankowości Projektu PPP, a w efekcie – zwiększa pewność i bezpieczeństwo jego realizacji przez Podmiot Publiczny.

Schemat 1. Wysoka jakość Dokumentacji Postępowania PPP



W tym kontekście istotne jest, żeby Dokumentacja Postępowania uwzględniała opinię Partnerów Prywatnych i Instytucji Finansujących, dlatego też rekomendowane jest przeprowadzenie Negocjacji w ramach Postępowania. Dokumentacja Postępowania powstaje wówczas we współpracy z Partnerami Prywatnymi w trakcie prowadzonych Negocjacji. Jednocześnie, podstawowe założenia Projektu PPP nie powinny ulegać zmianom, w szczególności, jeśli miałyby to prowadzić do zmiany podstaw prawnych Postępowania PPP z Postępowania Koncesyjnego na Postępowanie PZP (por. Punkt 2.2 Jak wybrać Partnera Prywatnego?) albo ograniczenia konkurencji (por. Punkt 6.3 Zarządzanie procesem Negocjacji).

Jakość Dokumentacji Postępowania jest istotna zarówno w jej pierwotnym kształcie, kiedy to Podmiot Publiczny przedstawia w większości projekty dokumentów podlegające dalszej dyskusji w ramach Negocjacji, jak również po uwzględnieniu wniosków z etapu Negocjacji.

1.5 Pozyskanie wiarygodnych Partnerów Prywatnych

Wszystkie wyżej wymienione czynniki sukcesu Postępowania PPP mają istotne znaczenie dla dokonania wyboru Partnera Prywatnego i efektywnej realizacji Projektu PPP. Należy jednak zwrócić uwagę, że tylko starannie dobrani wykonawcy, posiadający zarówno wiedzę merytoryczną i doświadczenie, jak też rzeczywistą zdolność do sfinansowania Infrastruktury Publicznej, będą w stanie przedstawić najlepsze rozwiązania, adekwatne do potrzeb i możliwości Podmiotu Publicznego.

Z powyższych względów Podmioty Publiczne powinny dołożyć najwyższej staranności na wszystkich etapach przygotowania Projektu PPP i prowadzenia Postępowania, w tym w szczególności:

- rozeznaczyć rynek Partnerów Prywatnych m.in. poprzez analizę realizowanych Projektów PPP, udział w konferencjach i szkoleniach poświęconych PPP czy korzystanie z informacji zawartych na stronie www.ppp.gov.pl;
- rozpoznać rynek Doradców, w celu doboru optymalnego do zakresu i przedmiotu planowanego Przedsięwzięcia oraz kompetencji Podmiotu Publicznego składu Zespołu Doradców;
- zadbać, aby w trakcie testów rynkowych informacja o planowanym Projekcie PPP i jego założeniach dotarła do jak największej liczby potencjalnych Partnerów Prywatnych;
- wyciągać wnioski z przeprowadzonych testów rynkowych i w toku przygotowania Postępowania brać pod uwagę wyrażane tam stanowisko Partnerów Prywatnych i Instytucji Finansujących;
- sformułować Kryteria Oceny Podmiotowej w sposób uwzględniający możliwości udziału w Postępowaniu doświadczonych Partnerów Prywatnych;
- udzielać odpowiedzi na pytania do ogłoszenia (pomimo braku takiego formalnego obowiązku) i sprawnie reagować na wnioski o wyjaśnienie lub zmianę Opisu Potrzeb i Wymagań;
- prowadzić Postępowanie w sposób zorganizowany, rzetelny i przejrzysty, dbając o zapewnienie równego traktowania uczestniczących w nim Partnerów Prywatnych we wszelkich możliwych aspektach;
- prowadzić dialog z Partnerami Prywatnymi, uwzględniać ich propozycje i uwagi – w granicach przyjętej strategii przetargowej (negocjacyjnej), o ile została przyjęta;
- na bieżąco odpowiadać na pytania, wnioski i postulaty Partnerów Prywatnych uczestniczących w Postępowaniu PPP.

Należy także pamiętać, że Partnerzy Prywatni, uczestnicząc w Postępowaniu, ponoszą znaczne koszty z tym związane. Zazwyczaj wspierani są – tak samo jak Podmioty Publiczne – zewnętrznymi doradcami prawnymi, finansowymi i technicznymi, a nierzadko również tłumaczami i innego rodzaju ekspertami. Sam udział w Negocjacjach wymaga od nich również istotnego zaangażowania czasowego i finansowego.

Z tego powodu powinno się profesjonalnie układać współpracę z wykonawcami na etapie Postępowania, w tym planować z odpowiednim wyprzedzeniem działania wymagające z ich strony określonej aktywności, nie nadużywać pozycji Zamawiającego jako gospodarza Postępowania, podchodzić ze zrozumieniem do próśb i wniosków organizacyjnych formułowanych w trakcie Postępowania PPP (np. w zakresie wydłużenia terminu na przekazanie propozycji określonych rozwiązań albo złożenia oferty).

Z uwagi na będący wciąż jeszcze w fazie rozwoju polski rynek PPP nie jest rekomendowane nadmierne ograniczanie liczby Partnerów Prywatnych uczestniczących w Postępowaniach. Jednym z czynników powodzenia Projektu PPP jest bowiem zapewnienie konkurencyjności procedury wyboru Partnera Prywatnego. Z tego powodu rekomenduje się dopuszczanie do udziału w Negocjacjach 5 Partnerów Prywatnych, co zapewnia rzeczywistą konkurencję i pozwala na dokonanie wyboru oferty najlepiej odpowiadającej potrzebom Podmiotu Publicznego.

Uwzględnienie powyższych rekomendacji powinno korzystnie wpłynąć na udział w Postępowaniu wykonawców zaangażowanych w Negocjacje, gotowych do przedstawiania optymalnych rozwiązań, prezentujących wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny. W efekcie, po przeprowadzonym Postępowaniu PPP Podmiot Publiczny powinien pozyskać Partnera Prywatnego gwarantującego wytworzenie Infrastruktury Publicznej odpowiedniej jakości oraz zapewnienie pożądanego standardu utrzymania, zarządzania lub eksploatacji obiektu, a tym samym osiągnąć korzystniejsze Value for Money dla Projektu PPP.

2. Podstawy prawne oraz tryby wyboru Partnera Prywatnego

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część I Punkt 1.1 – Podstawowe cechy modelu PPP

Tom I: Część I Punkt 1.3 – Systematyka Projektów PPP i Koncesji

Tom I: Część I Punkt 2 – Otoczenie instytucjonalno-prawne Projektów PPP

Tom I: Część I Punkt 7 – Inne formy współpracy Podmiotu Publicznego z sektorem prywatnym

Tom I: Część II Punkt 3.4.2 – Analiza sposobu oraz trybu wyboru Partnera Prywatnego

2.1 Podstawy prawne współpracy w ramach PPP

Partnerstwo Publiczno-Prywatne wpisuje się w szeroko rozumiany system zamówień publicznych wraz z tradycyjnymi zamówieniami publicznymi, koncesjami i innymi formami powierzania zadań publicznych podmiotom prywatnym.

Tym samym, realizując Projekt PPP i dokonując wyboru Partnera Prywatnego, Podmiot Publiczny musi pozostawać w zgodzie z ustawodawstwem krajowym oraz z Dyrektywami Zamówieniowymi. Oznacza to w szczególności, że Postępowanie PPP musi być oparte o zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania Partnerów Prywatnych, proporcjonalności i przejrzystości.

Określenie właściwej podstawy prawnej współpracy z Partnerem Prywatnym w ramach PPP stanowi kluczowe zadanie Podmiotu Publicznego, który zamierza realizować Projekt PPP. W przeciwieństwie do tradycyjnych zamówień publicznych, procedury wyboru Partnera Prywatnego mogą odbywać się w oparciu o różne podstawy prawne.

O wyborze odpowiednich przepisów proceduralnych decydują przede wszystkim:

- Mechanizm Wynagradzania Partnera Prywatnego;
- przypisanie jednej ze stron ryzyka ekonomicznego w ramach Projektu PPP, określonego w Ustawie o Umowie Koncesji;
- wyłączenia zastosowania przepisów Ustawy PZP lub Ustawy o Umowie Koncesji w przypadkach określonych przepisami prawa.

Ocena i rekomendacja wyboru prawidłowej podstawy prawnej dokonywana jest w ramach analiz prawnych zawartych w Ocenie Efektywności (zakres i cel analiz prawnych został szczegółowo omówiony w Wytycznych Tom I).

PRZYKŁAD

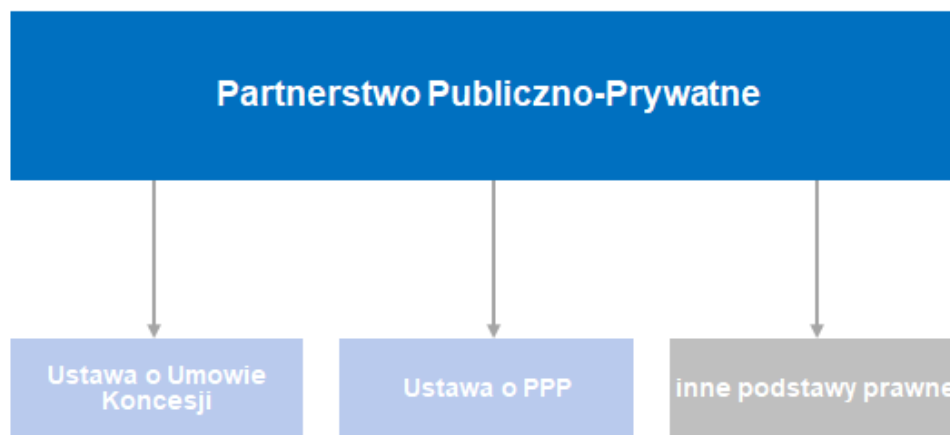


W praktyce, w Postępowaniach PPP w Polsce zdarzało się, że Podmioty Publiczne prowadziły procedurę wyboru Partnera Prywatnego w oparciu o niewłaściwe przepisy. W szczególności dotyczyło to sytuacji, w których Podmiot Publiczny stosował do wyboru Partnera Prywatnego przepisy Ustawy o Umowie Koncesji, pomimo że podział ryzyka lub Mechanizm Wynagradzania przemawiały za stosowaniem Ustawy PZP. Sytuacja taka skutkowałą unieważnianiem Postępowań.

W sytuacji, gdy na etapie ogłoszenia o Postępowaniu nie jest przesądzone, że wybór Postępowania Koncesyjnego pozostanie właściwy do końca Postępowania (np. analiza rynku oraz analiza ekonomiczno-finansowa w ramach Oceny Efektywności wykazały, iż w toku Negocjacji może okazać się konieczne dokonanie zmiany alokacji ryzyka ekonomicznego (operacyjnego) z Partnera Prywatnego na Podmiot Publiczny dla powodzenia realizacji Przedsięwzięcia) praktycznym rozwiązaniem może być prowadzenie Postępowania w oparciu o Ustawę PZP. Umożliwia to przepis art. 4 ust. 2 Ustawy o PPP (por. Punkt 2.2 Jak wybrać Partnera Prywatnego?).

W tym miejscu podkreślenia wymaga konieczność rzetelnego przygotowania Projektów PPP w zakresie założeń finansowych, ekonomicznych i technicznych, a także zrozumienie oraz umiejętność oceny przesłanek stosowania poszczególnych modeli proceduralnych.

Schemat 2. Podstawy prawne współpracy w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego



Powyższa grafika przedstawia podstawy prawne, na których można oprzeć współpracę pomiędzy Podmiotami Publicznymi a Partnerami Prywatnymi. Szczegółowe omówienie zasad i przesłanek wyboru każdej z nich zawarte zostało w kolejnych punktach Wytycznych Tom II.

ŹRÓDŁA INFORMACJI



Partnerstwo Publiczno-Prywatne, jako forma współpracy pomiędzy sektorem publicznym a prywatnym, może opierać się o różne podstawy prawne. W Polsce będzie to w szczególności Ustawa o PPP.

"Analiza prawna w zakresie konieczności stosowania ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn. zm.) do postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.)", czerwiec 2014, <https://www.ppp.gov.pl/sites/default/files/2025-08/ANALIZA-PRAWNA-01-2014.pdf>

2.1.1 Ustawa o PPP

W przeciwieństwie do innych regulacji prawnych, przepisy Ustawy o PPP obejmują wszelkie istotne zasady współpracy pomiędzy Partnerem Prywatnym a Podmiotem Publicznym. Celem Ustawy o PPP jest umożliwienie Podmiotowi Publicznemu i Partnerowi Prywatnemu podjęcia i prowadzenia wieloletniej współpracy w sposób zorganizowany i zapewniający narzędzia ułatwiające realizację Projektu PPP. Regulacja ta wprowadza również definicję PPP.

Definicja Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (art. 1 ust. 2 Ustawy o PPP)

Partnerstwo publiczno-prywatne polega na wspólnej realizacji przedsięwzięcia opartej na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym.

Kluczowym elementem współpracy opartej o Ustawę o PPP jest podział zadań i ryzyk pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym. Ryzyka powinny być tak podzielone, aby zapewnić wykonalność (w tym Bankowalność) Projektu PPP i umożliwić optymalizację ofert składanych w Postępowaniu. Innymi słowy, określone ryzyko powinna przejmować ta strona Umowy o PPP, która potrafi nim lepiej zarządzać lub ma na nie większy wpływ. Ryzyka związane z wykonaniem obowiązków przez jedną ze stron powinny zostać do niej wyraźnie przypisane. Przykładowo, jeżeli Podmiot Publiczny zobowiązany jest w ramach Projektu PPP przekazać dokumentację projektową lub nieruchomości, to ryzyka związane z wadami takiej dokumentacji lub możliwością realizacji Przedsięwzięcia na takiej nieruchomości powinny obciążać Podmiot Publiczny.

Tabela 1. Podstawowe przepisy Ustawy o PPP regulujące współpracę publiczno-prywatną

Podmiot Publiczny

Podmiotem Publicznym może być:

(art. 2 pkt 1)

- jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu Ustawy o Finansach Publicznych;
- inna niż określona w lit. a powyżej osoba prawna, utworzona w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, niedziałająca w zwykłych warunkach rynkowych, której celem nie jest wypracowanie zysku oraz nieponosząca strat wynikających z prowadzenia działalności, jeżeli podmioty, o których

mowa w tym przepisie oraz w lit. a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:

- finansują ją w ponad 50%; lub
 - posiadają ponad połowę udziałów albo akcji; lub
 - sprawują nadzór nad organem zarządzającym; lub
 - mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;
- związki podmiotów, o których mowa w lit. a i b.

Aktualnie podmiotami najczęściej angażującymi się w Projekty PPP są takie Podmioty Publiczne, jak: JST, spółki komunalne, państwowe jednostki budżetowe, spółki Skarbu Państwa, uczelnie publiczne.

Partner Prywatny
(art. 2 pkt 2)

Partnerem Prywatnym może być przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny. Z reguły Partnerzy Prywatni przystępować będą do Postępowania w formie Spółki Projektowej. Partnerem Prywatnym może być także organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie), o ile prowadzi działalność gospodarczą i figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców.

Składnik majątkowy
(art. 2 pkt 3)

Nieruchomość, część składowa nieruchomości, przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego, rzecz ruchoma oraz prawo majątkowe.

Z reguły składnikiem majątkowym, który Podmioty Publiczne angażują do Projektu PPP jest nieruchomość.

Przedsięwzięcie
(art. 2 pkt 4)

- budowa lub remont obiektu budowlanego;
- świadczenie usług, wykonanie dzieła, w szczególności wyposażenie składnika majątkowego w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność; lub
- inne świadczenie
 - połączone z utrzymaniem lub zarządzaniem składnikiem majątkowym, który jest wykorzystywany do realizacji przedsięwzięcia publiczno-prywatnego lub jest z nim związany.

Brak usług utrzymania lub zarządzania składnikiem majątkowym powoduje, że nie mamy do czynienia z Projektem PPP.

Wkład własny
(art. 2 pkt 5)

Świadczenie Podmiotu Publicznego lub Partnera Prywatnego polegające w szczególności na:

- poniesieniu części wydatków na realizację Przedsięwzięcia, w tym sfinansowaniu dopłat do usług świadczonych przez Partnera Prywatnego w ramach Przedsięwzięcia;

- wniesieniu składnika majątkowego.

Zgodnie z art. 9 Ustawy o PPP wniesienie wkładu własnego w postaci składnika majątkowego może nastąpić w szczególności w drodze sprzedaży, użyczenia, użytkowania, najmu albo dzierżawy. Katalog form prawnych udostępnienia składnika majątkowego jest otwarty. Tym samym w celu udostępnienia Partnerowi Prywatnemu składnika majątkowego dla celów należytego wykonania Umowy o PPP nie jest konieczne zawieranie odrębnej umowy od Umowy o PPP, chyba że przemawiają za tym inne względy (np. konieczność zawarcia odrębnej umowy sprzedaży nieruchomości z uwagi na formę szczególną).

Ocena Efektywności
(art. 3a)

Przed wszczęciem Postępowania w sprawie wyboru Partnera Prywatnego Podmiot Publiczny sporządza Ocenę Efektywności realizacji Przedsięwzięcia w ramach PPP w porównaniu do efektywności jego realizacji w inny sposób, w szczególności przy wykorzystaniu wyłącznie środków publicznych. Dokonując oceny, Podmiot Publiczny uwzględnia w szczególności zakładany podział zadań i ryzyk pomiędzy Podmiot Publiczny i Partnera Prywatnego, szacowane koszty cyklu życia Przedsięwzięcia i czas niezbędny do jego realizacji oraz wysokość Opłat od Użytkowników, jeżeli takie opłaty są planowane, oraz warunki ich zmiany.

**Opinia na temat
zasadności
Przedsięwzięcia
(Opinia PPP)**
(art. 3b)

Podmiot Publiczny może wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z wnioskiem o opinię na temat zasadności realizacji Przedsięwzięcia w ramach PPP. Do wniosku dołącza się Ocenę Efektywności realizacji Przedsięwzięcia. Opinia przedłożonej dokumentacji dotyczy poprawności i kompletności przeprowadzonych analiz poprzedzających realizację Przedsięwzięcia, przyjętego modelu prawno-organizacyjnego, Mechanizmów Wynagradzania Partnera Prywatnego, w tym wysokości Opłat od Użytkowników, jeżeli takie opłaty są planowane, oraz warunków ich zmiany, oraz proponowanego podziału ryzyk w Projekcie PPP.

Umowa o PPP
(art. 7 ust. 1 i 2)

Przez Umowę o PPP Partner Prywatny zobowiązuje się do realizacji Przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a Podmiot Publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu Przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego. Wynagrodzenie Partnera Prywatnego zależy przede wszystkim od rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej dostępności przedmiotu Przedsięwzięcia.

Spółka PPP
(art. 14)

Umowa o PPP może przewidywać, że w celu jej wykonania Podmiot Publiczny i Partner Prywatny zawiążą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną. Umowa o PPP może przewidywać, że w celu jej wykonania Partner Prywatny nabędzie udziały albo akcje spółki z udziałem Podmiotu Publicznego. Nabycie może

nastąpić w drodze objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo akcji. Cel i przedmiot działalności Spółki PPP nie może wykraczać poza zakres określony Umową o PPP. Projekty PPP z wykorzystaniem Spółki PPP nazywane są PPP Instytucjonalnym.

**Kontrola realizacji
Przedsięwzięcia
(art. 8)**

Podmiot Publiczny ma prawo do bieżącej kontroli realizacji Przedsięwzięcia przez Partnera Prywatnego oraz do kontroli składnika majątkowego wykorzystywanego do realizacji Przedsięwzięcia. Zasady i szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli określa Umowa o PPP. W przypadku gdy prowadzona kontrola wykaże, iż składnik majątkowy wykorzystywany przez Partnera Prywatnego do realizacji Przedsięwzięcia znajduje się w stanie technicznym wskazującym na jego nieprawidłowe wykorzystywanie, Podmiot Publiczny wzywa Partnera Prywatnego do podjęcia odpowiednich działań, w szczególności do poczynienia nakładów mających na celu doprowadzenie składnika majątkowego do właściwego stanu technicznego. Umowa o PPP określa skutki niepodjęcia działań mających na celu doprowadzenie składnika majątkowego do właściwego stanu technicznego.

Ustawa o PPP stanowi o bieżącej kontroli, co nie oznacza, że Podmiot Publiczny powinien przeprowadzać ją w sposób ciągły lub bardzo często. Określając zakres uprawnień kontrolnych oraz tryb prowadzenia kontroli, należy mieć na względzie, aby działania Podmiotu Publicznego były, w możliwy sposób, jak najmniej uciążliwe dla prowadzonej przez Partnera Prywatnego działalności w ramach Umowy o PPP.

**Organ właściwy
(art. 16a)**

Organem właściwym w sprawach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w zakresie uregulowanym w Ustawie o PPP jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.

Należy także zwrócić uwagę na obowiązek wydania przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego niewiążącej opinii w przedmiocie sposobu realizacji inwestycji, jeżeli planowana kwota finansowania z budżetu państwa tych inwestycji przekracza 500 mln PLN (por. art. 133b Ustawy o Finansach Publicznych). Czynności poprzedzające wydanie tej opinii nazywamy Testem PPP. Obowiązek ten nie dotyczy inwestycji planowanych do realizacji w ramach PPP, współfinansowanych ze środków unijnych oraz dotyczących obronności lub bezpieczeństwa.

UWAGA



Ustawę o PPP jako podstawę prawną współpracy publiczno-prywatnej, można zastosować niemal w każdej strukturze współpracy pomiędzy Podmiotem Publicznym a Partnerem Prywatnym, o ile współpraca taka przewiduje utrzymanie lub zarządzanie składnikiem majątkowym wykorzystywanym do realizacji Przedsięwzięcia.

2.1.2 Ustawa o Umowie Koncesji

Ustawę o Umowie Koncesji stosować można:

- jako samoistną podstawę współpracy z Koncesjonariuszem; albo

- jako ustawę "proceduralną" do wyboru Partnera Prywatnego i Umowy z Partnerem Prywatnym, jeżeli Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Ustawy o PPP, ale Umowa o PPP spełnia warunki właściwe dla umowy koncesji;
- dla wszystkich Projektów, które spełniają warunki określone w przepisie art. 3 Ustawy o Umowie Koncesji.

Projekt Koncesyjny (art. 3 ust. 1 i 2 Ustawy o Umowie Koncesji)

Na podstawie umowy koncesji Zamawiający powierza Koncesjonariuszowi wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami za wynagrodzeniem.

W przypadku powierzenia koncesjonariuszowi:

- 1) *wykonania robót budowlanych – wynagrodzenie stanowi wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płatnością (umowa koncesji na roboty budowlane);*
- 2) *świadczenia usług i zarządzania tymi usługami – wynagrodzenie stanowi wyłącznie prawo do wykonywania usług będących przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płatnością (umowa koncesji na usługi).*

Ryzyko Koncesjonariusza (art. 3 ust. 3 i 4 Ustawy o Umowie Koncesji)

Koncesjonariusz ponosi ryzyko ekonomiczne związane z eksploatacją obiektu budowlanego lub wykonywaniem usług i obejmujące ryzyko związane z popytem lub podażą.

Przez ponoszenie ryzyka ekonomicznego należy rozumieć sytuację, w której w zwykłych warunkach funkcjonowania koncesjonariusz nie ma gwarancji odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych lub kosztów związanych z eksploatacją obiektu budowlanego lub świadczeniem usług będących przedmiotem umowy koncesji oraz jest narażony na wahania rynku, a w szczególności jego szacowane potencjalne straty związane z wykonywaniem umowy koncesji nie mogą być jedynie nominalne lub nieistotne.

Zastosowanie Ustawy o Umowie Koncesji jako ustawy "proceduralnej" jest opcją dla Podmiotu Publicznego, który w przypadku, gdy Projekt PPP spełnia warunki Projektu Koncesyjnego, może zrealizować Przedsięwzięcie nie na podstawie Ustawy o Umowie Koncesji, a w oparciu o przepis art. 4 ust. 2 Ustawy o PPP (tzw. PPP w trybie Ustawy o Umowie Koncesji).

Jest to wynik zmian legislacyjnych mających na celu wyeliminowanie ryzyka doboru nieprawidłowej procedury wyboru Partnera Prywatnego, która historycznie dość często miała miejsce.

Z uzasadnienia projektu do nowelizacji Ustawy o PPP wynika, że wprowadzenie nowego brzmienia art. 4 ust 2 Ustawy o PPP było konieczne w celu wyeliminowania ryzyka nieprawidłowej procedury wyboru Partnera Prywatnego. Jeżeli bowiem Podmiot Publiczny prowadził Postępowanie na podstawie przepisów Ustawy o Umowie Koncesji, to był zobowiązany zawrzeć umowę koncesji. Jeżeli natomiast prowadził Postępowanie zgodnie z PZP, to uprawniony był do zawarcia Umowy o PPP (a nie umowy koncesji).

W kontekście PPP takie ścisłe rozdzielenie zakresów zastosowania ustaw proceduralnych rodziło istotne trudności praktyczne. W chwili wszczęcia postępowania w sprawie wyboru Partnera Prywatnego często nie jest bowiem pewne, czy Umowa będzie umową typu koncesyjnego, czy też zbliżoną do tradycyjnej umowy zamówienia publicznego. Konkretny kształt Umowy zależy bowiem od wyniku Negocjacji. Tymczasem zawarcie umowy, która nie przenosi ryzyka

ekonomicznego na Partnera Prywatnego, a więc nie jest umową koncesji, na podstawie Ustawy o Umowie Koncesji naruszało przepisy tej ustawy i mogło być zakwalifikowane jako nieuprawnione pominięcie bardziej rygorystycznych przepisów Ustawy PZP.

Aktualnie Podmiot Publiczny, na podstawie przepisu art. 4 ust 2 Ustawy PPP, może w każdym przypadku dokonać wyboru Partnera Prywatnego na podstawie przepisów Ustawy PZP, także wówczas, gdy Umowa będzie umową koncesji. Stosowanie Ustawy o Umowie Koncesji do wyboru Partnera Prywatnego jest zatem fakultatywne. Dzięki temu Podmiot Publiczny, który dopuszcza różne modele współpracy w ramach PPP, wszczynając Postępowanie na podstawie przepisów Ustawy PZP nie będzie miał powodów do obaw, że zastosował nieprawidłową procedurę wyboru Partnera Prywatnego, jeżeli Negocjacje zakończą się zawarciem umowy koncesji (por. uzasadnienie projektu ustawy o zmianie Ustawy o PPP, druk sejmowy nr 2333, <https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2333>).

UWAGA



W przypadku, gdy Podmiot Publiczny nie ma pewności co do utrzymania się założenia, że Partner Prywatny będzie skłonny do ponoszenia ryzyka ekonomicznego Projektu PPP, tj. że jest gotów zaakceptować brak gwarancji odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych lub kosztów związanych z eksploatacją obiektu budowlanego lub świadczenia usług będących przedmiotem umowy koncesji oraz jest narażony na wahania rynku, a w szczególności jego szacowane potencjalne straty związane z wykonywaniem umowy koncesji nie mogą być jedynie nominalne lub nieistotne – wówczas powinien zastosować do wyboru Partnera Prywatnego oraz do Umowy o PPP Ustawę o PPP oraz Ustawę PZP.

PRZYKŁAD



Hipotetycznie - Partner Prywatny realizuje Przedsięwzięcie polegające na budowie i eksploatacji pływalni. Podstawowym źródłem jego wynagrodzenia są Opłaty od Użytkowników, ale Podmiot Publiczny stosuje system dopłat do nauki pływania dzieci oraz zabezpiecza kredyt Partnera Prywatnego w formie hipoteki na nieruchomości wykorzystywanej do realizacji Przedsięwzięcia. Zapewnia także pewną część popytu w formie rekompensaty, jeżeli przychody Partnera Prywatnego spadną poniżej określonej w kontrakcie wartości.

Pomimo że wynagrodzenie Partnera Prywatnego pochodzi w przeważającej części ze świadczenia usług, otrzymuje on dodatkowo płatności od strony publicznej, a ponadto – ryzyko ekonomiczne Projektu PPP jest podzielone wskutek zabezpieczenia spłaty kredytu Partnera Prywatnego przez Podmiot Publiczny oraz zapewnienia rekompensaty w przypadku spadku popytu na usługi Partnera Prywatnego. W takiej sytuacji zastosowanie Ustawy o Umowie Koncesji jako samoistnej podstawy prawnej wyboru Partnera Prywatnego byłoby niemożliwe, albowiem Partner Prywatny nie ponosi ryzyka ekonomicznego w rozumieniu tej ustawy, w związku z tym, właściwą podstawą prawną współpracy powinna być Ustawa o PPP.

Projekty PPP realizowane na podstawie Ustawy o Umowie Koncesji mogą mieć formę koncesji na roboty budowlane lub koncesji na usługi. Przy koncesji na roboty budowlane Partner Prywatny musi zapewnić wykonanie określonych robót budowlanych, aby uzyskać prawo do eksploatacji

Infrastruktury Publicznej. Natomiast w przypadku koncesji na usługi, świadczenie usług przez Partnera Prywatnego odbywać się może z wykorzystaniem już istniejącej Infrastruktury Publicznej (np. zarządzanie kompleksem basenowym zrealizowanym z wykorzystaniem funduszy unijnych) albo niezależnie od jakiegokolwiek Infrastruktury Publicznej (np. koncesja na obsługę systemu e-płatności w zakresie opłat sądowych).

Może się także zdarzyć, że w ramach umowy koncesji na usługi wykonywane z użyciem istniejącej Infrastruktury Publicznej Koncesjonariusz zobowiązany jest do wykonywania w trakcie umowy koncesji określonych robót budowlanych (np. remontów), jednakże nie oznacza to przekwalifikowania tej umowy na umowę koncesji na roboty budowlane. Istotą koncesji na roboty budowlane jest to, że Partner Prywatny świadczy usługi z wykorzystaniem Infrastruktury Publicznej przez siebie wybudowanej, przebudowanej lub wyremontowanej, bez których to robót nie byłaby możliwa eksploatacja Infrastruktury Publicznej.

PRZYKŁAD



Przykłady umów w ramach, których najczęściej są realizowane Projekty Koncesyjne:

- umowa koncesji na budowę parkingu podziemnego;
- umowa koncesji na budowę wielofunkcyjnej hali sportowej;
- umowa koncesji na budowę centrum kongresowego;
- umowa koncesji na budowę centrum logistycznego.

W przypadku koncesji na usługi, z uwagi na brak zaangażowania istotnych nakładów inwestycyjnych po stronie Koncesjonariusza zakres zadań, które mogą być realizowane w ramach Projektów Koncesyjnych może być znacznie szerszy i obejmować również, np.: transport publiczny, cmentarze, przejścia podziemne w centrach miast, zarządzanie kompleksem basenów.

Ponadto, takie Projekty Koncesyjne mogą obejmować również usługi niezwiązane z Infrastrukturą Publiczną (np. usługi poboru opłat, najem rowerów miejskich).

2.1.3 Inne podstawy prawne

PPP w szerokim ujęciu, rozumiane jako efektywna forma współpracy pomiędzy Partnerami Prywatnymi a Podmiotami Publicznymi, oparta o podział zadań i ryzyka, może być również wdrażane w oparciu o inne niż Ustawa o PPP i Ustawa o Umowie Koncesji podstawy prawne, wskazane w poniższej tabeli:

Tabela 2. Inne podstawy prawne współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Ustawa o Autostradach Płatnych i KFD

Ustawa ta określa zasady finansowania budowy autostrad płatnych, zasady zawierania umów o budowę i eksploatację albo wyłącznie eksploatację autostrad oraz pobierania opłat za przejazd autostradami. Na zasadach określonych w ustawie mogą być budowane i eksploatowane albo wyłącznie eksploatowane, jako płatne, również drogi ekspresowe.

Można powiedzieć, że ustawa ta stanowi szczególną, branżową regulację realizacji Projektów PPP.

**Ustawa
o Gospodarcie
Komunalnej**

Ustawa ta umożliwia zawiązywanie spółek pomiędzy Partnerami Prywatnymi a Podmiotami Publicznymi, a także przystępowanie do spółek handlowych przez JST. Pomimo że samo zawiązanie spółki nie stanowi czynności objętej przepisami o zamówieniach publicznych lub koncesji, to sam fakt wykonywania działalności publiczno-prywatnej w tej formie przypomina w pewnym stopniu PPP Instytucjonalne, w ramach którego współpraca pomiędzy partnerami odbywa się w ramach Spółki PPP.

**Ustawa
o Gospodarcie
Nieruchomościami**

Ustawa ta określa m.in. zasady rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, przewidując możliwość ich sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę, najem, użytkowanie.

**Ustawa
o Efektywności
Energetycznej**

Ustawa ta określa m.in. zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, w tym zasady realizacji umów o poprawę efektywności energetycznej.

Należy jednak podkreślić, że poza Ustawą o Autostradach Płatnych i KFD oraz Ustawą o Efektywności Energetycznej, pozostałe ww. ustawy nie regulują w kompleksowy sposób zasad współpracy w ramach PPP, w związku z czym wykorzystywanie tych podstaw prawnych do realizacji Projektów PPP nie jest rekomendowanym rozwiązaniem. Z tego powodu, w dalszych częściach Wytycznych Tom II pod uwagę wzięte zostaną Ustawa o PPP i Ustawa o Umowie Koncesji oraz przewidziane przez te akty prawne tryby wyboru Partnerów Prywatnych.

DOBRE PRAKTYKI



Analiza podstaw prawnych realizacji Projektu PPP

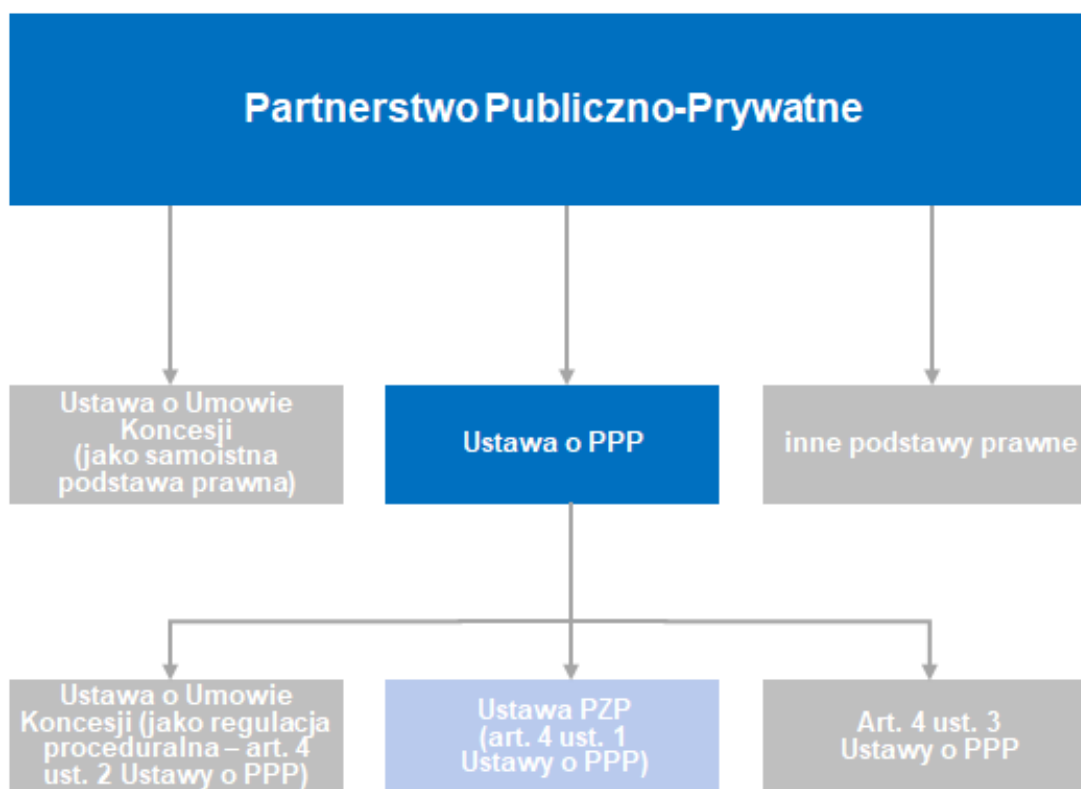
Za dobrą praktykę należy uznać dokonanie analizy prawnej różnych wariantów współpracy w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, uwzględniającej specyfikę planowanego Przedsięwzięcia. Co do zasady, właściwą podstawą prawną współpracy będzie Ustawa o PPP. W pewnych przypadkach może się jednak okazać, że określone zadanie nie wymaga stosowania przepisów Ustawy PZP ani Ustawy o Umowie Koncesji albo nie istnieje potrzeba jego realizacji w sposób kompleksowy. Ocena Efektywności Przedsięwzięcia musi uwzględniać analizę podstaw prawnych współpracy publiczno-prywatnej.

2.2 Jak wybrać Partnera Prywatnego?

2.2.1 Warianty proceduralne

Wybór podstawy prawnej współpracy w ramach PPP to nie wszystko. O ile Ustawa o Umowie Koncesji zawiera przepisy proceduralne związane z wyłonieniem Koncesjonariusza, to Ustawa o PPP jedynie odsyła do właściwych regulacji, przewidując w tym zakresie aż trzy możliwości.

Schemat 3. Procedury wyboru Partnera Prywatnego w ramach PPP



Wybór Partnera Prywatnego może być dokonany w oparciu o Ustawę PZP, Ustawę o Umowie Koncesji oraz w konkurencyjnym trybie w przypadkach, gdy przepisy prawa wyłączają zastosowanie ww. ustaw.

2.2.2 PPP na podstawie Ustawy PZP

Podstawą prawną wyboru Partnera Prywatnego, która może znaleźć zastosowanie w niemal każdej sytuacji, bez względu na podział ryzyka projektowego i zasady wynagradzania strony prywatnej, są przepisy Ustawy PZP. Jest to regulacja najbardziej "rygorystyczna" i z tego względu, z wyjątkiem przypadków wyłączenia jej stosowania w określonych sytuacjach, Podmiot Publiczny zawsze może dokonać wyboru Partnera Prywatnego na podstawie Ustawy PZP. Nie ma przy tym znaczenia, jaki w praktyce model PPP ma być wdrożony. Ponadto, o ile nie mamy do czynienia z koncesją lub koncesyjnym modelem wynagradzania Partnera Prywatnego - zastosowanie Ustawy PZP do wyboru Partnera Prywatnego jest obligatoryjne.

Wybór Partnera Prywatnego w oparciu o Ustawę PZP (art. 4 ust. 1 Ustawy o PPP)

Do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w zakresie nieuregulowanym w Ustawie o PPP.

Wybór Ustawy PZP jako podstawy wyłonienia Partnera Prywatnego ma i tę zaletę, że Podmioty Publiczne na co dzień stosują tę regulację i w znacznej mierze przygotowane są do uruchomienia procedury wyboru Partnera Prywatnego. W szczególności dotyczy to posiadania przez Podmioty Publiczne szeregu dokumentów gotowych do wykorzystania w ramach Dokumentacji Postępowania, takich jak np. regulaminy udzielania zamówień publicznych, wnioski o wszczęcie

Postępowania, zarządzenia ws. powołania Komisji Przetargowych, wzory protokołów z Postępowania itp.

Należy mieć jednak na uwadze, że ze względu na specyfikę PPP, dokumenty te będą zazwyczaj niewystarczające lub wymagały będą modyfikacji na potrzeby realizacji Projektów PPP.

W przypadku podjęcia decyzji przez Podmiot Publiczny o wykorzystaniu Ustawy PZP, będzie ona stosowana zarówno do procedury wyboru Partnera Prywatnego, jak też Umowy o PPP – w zakresie nieuregulowanym Ustawą o PPP. O ile zatem Ustawa o PPP nie zawiera odmiennych postanowień, Podmiot Publiczny będzie zobowiązany do stosowania wszelkich innych przepisów Ustawy PZP.

2.2.3 PPP na podstawie Ustawy o Umowie Koncesji

W przypadku Projektów PPP, dla których spełnione zostały warunki dla koncesji, określone w Ustawie o Umowie Koncesji możliwe jest dokonanie wyboru Partnera Prywatnego na podstawie Ustawy o PPP w oparciu o Ustawę o Umowie Koncesji (przepis art. 4 ust. 2 Ustawy o PPP).

Rozwiązanie takie jest zalecane dla Projektów PPP, w których przyjęcie przez Partnera Prywatnego ryzyka ekonomicznego jest pewne i takie przypisanie tego ryzyka nie ulegnie zmianie podczas Negocjacji, a jednocześnie Podmiot Publiczny chce skorzystać z niektórych rozwiązań z Ustawy o PPP nieprzewidzianych przepisami Ustawy o Umowie Koncesji (np. utworzenie Spółki PPP).

Wybór Partnera Prywatnego w oparciu o Ustawę o Umowie Koncesji (art. 4 ust. 2 Ustawy o PPP)

Jeżeli umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym ma spełniać warunki określone w art. 3 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy tej ustawy albo ustawy, o której mowa w ust. 1, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie. W przypadku zastosowania do wyboru partnera prywatnego ustawy, o której mowa w ust. 1 [Ustawa PZP], zastosowanie mają przepisy art. 6 oraz art. 45 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi.

2.2.4 PPP na podstawie art. 4 ust. 3 Ustawy o PPP

W przypadkach, w których stosowanie Ustawy PZP lub Ustawy o Umowie Koncesji jest wyłączone, a Przedsięwzięcie wpisuje się w definicję PPP określoną przepisami Ustawy o PPP, wyboru Partnera Prywatnego dokonuje się w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji oraz przestrzeganie zasad równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności, przy odpowiednim uwzględnieniu przepisów Ustawy o PPP, a w przypadku wniesienia przez Podmiot Publiczny wkładu własnego będącego nieruchomością, także przepisów Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami.

Przykładem zastosowania art. 4 ust. 3 Ustawy o PPP jest sektor telekomunikacyjny. Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy PZP (i analogicznie – art. 5 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Umowie Koncesji), ustawy tej nie stosuje się do zamówień i konkursów, udzielanych przez Zamawiających publicznych oraz Zamawiających subsydiowanych, w celu prowadzenia działalności w zakresie:

- udostępniania publicznej sieci telekomunikacyjnej; lub

- obsługi publicznej sieci telekomunikacyjnej; lub
- świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych za pomocą publicznej sieci telekomunikacyjnej.

Wyłączenie to skutkuje koniecznością opracowania przez Podmiot Publiczny indywidualnej procedury wyboru Partnera Prywatnego spełniającej przesłanki konkurencji, równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności, a ponadto – stosowania przepisów Ustawy o Gospodarcie Nieruchomościami, jeżeli Podmiot Publiczny wnosi w Przedsięwzięcie wkład w postaci nieruchomości. W praktyce rozwiązywanie to stosowane jest rzadko.

UWAGA



Przepis art. 4 ust 3 Ustawy o PPP nie znajdzie zastosowania do innych form współpracy Podmiotów Publicznych z sektorem prywatnym, realizowanych w oparciu o przepisy Ustawy o Gospodarcie Nieruchomościami, Ustawy o Gospodarcie Komunalnej i Kodeksu Cywilnego (zobacz też Część I Punkt 7 Wytycznych Tom I).

2.2.5 Ustawa o Umowie Koncesji

Ustawa o Umowie Koncesji w pewnych przypadkach może być stosowana jako samoistna podstawa prawna i proceduralna wyboru Koncesjonariusza. Należy jednak zwrócić uwagę, że konstrukcja ryzyka w Projektach Koncesyjnych opiera się o ponoszenie przez Koncesjonariusza pełni ryzyka ekonomicznego, podczas gdy Ustawa o PPP może przewidywać podział tego ryzyka pomiędzy Podmiot Publiczny a Partnera Prywatnego. Z tego powodu, regulacja Ustawy o PPP jest znacznie bardziej elastyczna i pozwala na lepsze dopasowanie Projektu PPP do potrzeb rynkowych.

DOBRE PRAKTYKI



Wybór Koncesjonariusza

O ile wynagrodzenie Koncesjonariusza pochodzić ma przede wszystkim z eksploatacji obiektu lub świadczenia usług, dokładnego rozważenia wymaga, czy będzie on w stanie przejąć na siebie całe ryzyko ekonomiczne związane z wykonywaniem umowy koncesji. Jeżeli po przeprowadzeniu Oceny Efektywności, ze szczególnym wskazaniem na wynik analiz rynkowych, odpowiedź na to pytanie będzie twierdząca, Podmiot Publiczny może rozważyć zastosowanie Ustawy o Umowie Koncesji jako samoistnej podstawy prawnej i proceduralnej wyłaniania Koncesjonariusza.

Jak wskazuje praktyka rynkowa, procedury wyboru Koncesjonariusza określone przepisami Ustawy o Umowie Koncesji mogą lepiej sprawdzić się w przypadku koncesji na usługi, która nie wymaga poniesienia przez Partnera Prywatnego istotnych nakładów inwestycyjnych na realizację obiektu budowlanego.

Zarówno w odniesieniu do koncesji na roboty budowlane, jak też koncesji na usługi, można zastosować tzw. PPP na podstawie Ustawy o Umowie Koncesji (szerzej na ten temat w Punkcie 2.2.3 PPP na podstawie Ustawy o Umowie Koncesji).

2.3 Tryby wyboru Partnera Prywatnego

2.3.1 Jaki tryb wybrać?

Po ustaleniu podstaw prawnych i proceduralnych, które Podmiot Publiczny zastosuje do Postępowania PPP, należy zastanowić się nad trybem wyboru Partnera Prywatnego. Ani Ustawa o PPP, ani Ustawa o Umowie Koncesji nie narzucają Podmiotowi Publicznemu konkretnego trybu, w jakim ma być prowadzone Postępowanie.

DOBRE PRAKTYKI



Tryb Wyboru Partnera Prywatnego

Za dobrą praktykę należy uznać przeprowadzenie Postępowania w trybach negocjacyjnych:

- w przypadku Ustawy PZP i Postępowania o wartości równej lub powyżej Progów Unijnych rekomendowanym trybem jest Dialog Konkurencyjny;
- w przypadku Ustawy PZP i Postępowania o wartości poniżej Progów Unijnych rekomendowanym trybem jest Tryb Negocjacyjny Podprogowy (art. 275 pkt 3 Ustawy PZP);
- w przypadku Ustawy o Umowie Koncesji rekomendowanym trybem są Negocjacje.

Tryby te zapewniają elastyczne podejście do Projektu PPP i wypracowanie wspólnie z Partnerami Prywatnymi wysokiej jakości Dokumentacji Postępowania. Jednocześnie umożliwiają one ograniczenie liczby Partnerów Prywatnych uczestniczących w Postępowaniu do poziomu zapewniającego rzeczywistą konkurencję.

Jedynie w przypadku Projektów PPP o ustalonych na rynku standardach technicznych, finansowych i prawnych, Podmiot Publiczny mógłby rozważyć zastosowanie innych trybów, takich jak np. przetarg ograniczony. Praktyka rynkowa dowodzi jednak, że zastosowanie trybów podstawowych nie przynosi zadowalających efektów, a to z uwagi na trudność w samodzielnym opracowaniu przez Podmiot Publiczny kompletnej Dokumentacji Postępowania, uwzględniającej realia rynkowe, oczekiwania Partnerów Prywatnych i Instytucji Finansujących bez szerokich konsultacji w ramach Negocjacji.

Komisja Europejska traktuje Dialog Konkurencyjny jako instrument skonstruowany z myślą o udzielaniu złożonych zamówień, w tym zawierania Umów o PPP. W ramach Zielonej Księgi "Partnerstwo publiczno-prywatne, prawo wspólnotowe, zamówienia publiczne i koncesje" z dnia 30 kwietnia 2004 r., Komisja Europejska uznała, że procedura Dialogu Konkurencyjnego może mieć zastosowanie również w przypadku Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Potwierdza to Komunikat Wyjaśniający Komisji w sprawie stosowania prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych i koncesji w odniesieniu do zinstytucjonalizowanych partnerstw publiczno-prywatnych (ZPPP) (2008/C91/02): "Jeśli utworzenie ZPPP pociąga za sobą przyznanie podmiotowi z kapitałem mieszanym zamówienia publicznego podlegającego w całości dyrektywie 2004/18/WE [aktualnie obowiązują Dyrektywy Zamówieniowe – przyp. autora], może się okazać, w związku ze złożonością finansowych i prawnych aspektów takich konstrukcji, że otwarte i ograniczone procedury zdefiniowane w powyższej dyrektywie nie są dostatecznie elastyczne. Z myślą o takich właśnie sytuacjach w dyrektywie 2004/18/WE wprowadzono innowacyjną procedurę, tzw. "Dialog Konkurencyjny", która ma za zadanie

chronić konkurencję między wykonawcami i jednocześnie umożliwiać podmiotom Zamawiającym omówienie wszystkich aspektów danego zamówienia z każdym kandydatem”.

Tryb Dialogu Konkurencyjnego został wdrożony w zdecydowanej większości państw członkowskich UE i jest w nich wykorzystywany w dużej mierze w ramach Projektów PPP oraz selekcji Partnerów Prywatnych. Również Polityka PPP wskazuje, że "choć do zawarcia umowy PPP mogą być stosowane różne tryby ustawy PZP, to z punktu widzenia specyfiki i kompleksowości trybem najbardziej odpowiednim do wyboru partnera prywatnego jest dialog konkurencyjny”.

ŹRÓDŁA INFORMACJI

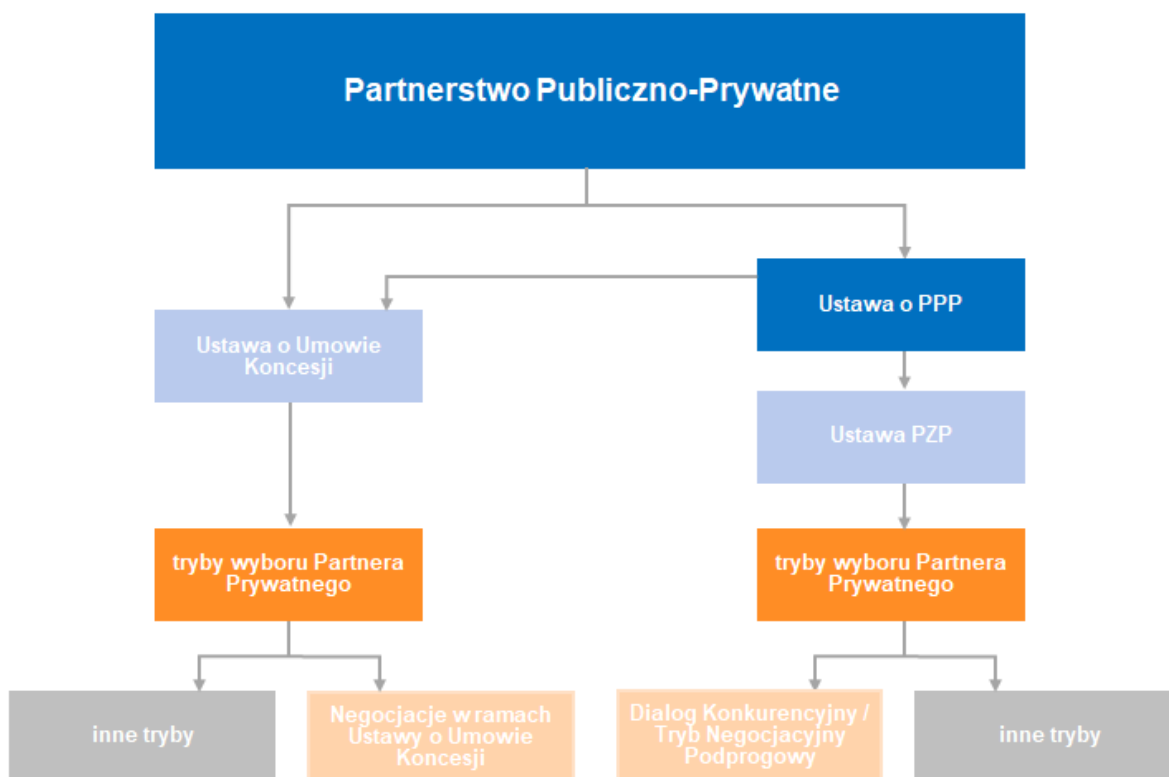


EPEC "Procurement of PPP and the use of Competitive Dialogue in Europe, a review of public sector practices across the EU", 11/2010.

Komunikat Wyjaśniający Komisji w sprawie stosowania prawa wspólnotowego dotyczącego zamówień publicznych i koncesji w odniesieniu do zinstytucjonalizowanych partnerstw publiczno-prywatnych (ZPPP) (2008/C91/02).

Na poniższym schemacie przedstawiono ścieżkę dojścia do trybu wyboru Partnera Prywatnego, uwzględniającą prezentowane wcześniej rekomendacje.

Schemat 4. Tryb wyboru Partnera Prywatnego



W dalszych punktach Wytycznych Tom II omówiono przesłanki zastosowania i kluczowe elementy rekomendowanych trybów wyboru Partnera Prywatnego.

2.3.2 Ustawa PZP

Tytułem wstępu należy wskazać, iż z punktu widzenia Projektów PPP istotne jest, że Ustawę PZP, zgodnie z jej art. 2, stosuje się do udzielania:

- 1) zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 PLN, przez Zamawiających publicznych;
- 2) zamówień sektorowych, których wartość jest równa lub przekracza Progi Unijne, przez Zamawiających sektorowych (Zamawiający publiczni oraz inne podmioty wykonujące działalność sektorową, na zasadach określonych w art. 5 Ustawy PZP);
- 3) zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest równa lub przekracza Progi Unijne, przez Zamawiających publicznych oraz Zamawiających sektorowych;
- 4) zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza Progi Unijne, przez Zamawiających subsydiowanych w okolicznościach, o których mowa w art. 6 Ustawy PZP (niektóre zamówienia finansowane w ponad 50% ze środków publicznych udzielane przez inne podmioty niż Zamawiający publiczni i sektorowi).

Dodatkowo należy wskazać, iż szczególne zasady znajdują zastosowanie do zamówień klasycznych o wartości poniżej Progów Unijnych (art. 266 i nast. Ustawy PZP).

Z perspektywy Projektów PPP oznacza to, iż w zależności od przedmiotu Projektu PPP i jego wartości konieczne będzie stosowanie odpowiedniego reżimu prawnego wynikającego z Ustawy PZP tj.:

- 1) jeżeli przedmiotem Projektu PPP jest działalność sektorowa wskazana w art. 5 ust. 4 Ustawy PZP, do wyboru Partnera Prywatnego zastosowanie znajdą regulacje właściwe dla zamówień sektorowych, tj. art. 362 i nast. Ustawy PZP. Jeżeli jednak wartość zamówienia będzie niższa niż Progi Unijne, Ustawa PZP w ogóle nie znajdzie zastosowania;
- 2) jeżeli przedmiotem Projektu PPP będzie zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa, zgodnie z jego definicją zawartą w art. 7 pkt 36 Ustawy PZP (np. roboty budowlane, dostawy i usługi związane z zabezpieczeniem obiektów będących w dyspozycji podmiotów realizujących zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa) do wyboru Partnera Prywatnego zastosowanie znajdą regulacje właściwe dla zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa tj. art. 395 i nast. Ustawy PZP. Jeżeli jednak wartość zamówienia będzie niższa niż Progi Unijne Ustawa PZP w ogóle nie znajdzie zastosowania;
- 3) w pozostałych przypadkach będziemy mieć do czynienia z zamówieniami klasycznymi, a zatem, w zależności od wartości Projektu PPP, do wyboru Partnera Prywatnego zastosowanie znajdą zasady ogólne Ustawy PZP (wartość powyżej Progów Unijnych) albo zasady szczególne uregulowane w art. 266 i nast. (wartość poniżej Progów Unijnych).

Z uwagi na fakt, iż zdecydowana większość Projektów PPP stanowić będzie zamówienie klasyczne, Wytyczne Tom II nie obejmują analizy zasad szczególnych właściwych dla zamówień sektorowych i zamówień w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa.

Z kolei, jak wskazano powyżej, w ramach zamówień klasycznych dla projektów PPP rekomendowane są tryby dwustopniowe negocjacyjne, tj. Dialog Konkurencyjny dla zamówień powyżej Progów Unijnych i Tryb Negocjacyjny Podprogowy dla zamówień poniżej Progów Unijnych, dlatego też dalsza część Wytycznych Tom II ograniczona będzie do tych dwóch trybów.

Dialog Konkurencyjny

Dialog Konkurencyjny jest dwuetapowym, otwartym i konkurencyjnym trybem rekomendowanym do wyboru Partnera Prywatnego. Dialog Konkurencyjny jest trybem mającym pewne cechy wspólne z przetargiem ograniczonym, ale został uzupełniony o możliwość pozyskania przez Podmiot Publiczny od Partnerów Prywatnych wiedzy co do koncepcji, założeń i organizacji przedmiotu przyszłej Umowy o PPP. Jednocześnie posiada on cechy zbliżone do trybu Negocjacji z ogłoszeniem, od którego odróżnia go jednak możliwość szerszej modyfikacji wszystkich aspektów prowadzonego Postępowania.

Tryb Dialogu Konkurencyjnego został wdrożony w zdecydowanej większości państw członkowskich UE i jest w nich wykorzystywany w dużej mierze w ramach projektów PPP oraz selekcji Partnerów Prywatnych (znajduje zastosowanie do ponad 70% Projektów PPP).

ŹRÓDŁA INFORMACJI



EPEC "Procurement of PPP and the use of Competitive Dialogue in Europe, a review of public sector practices across the EU", 11/2010.

Dialog Konkurencyjny (art. 169 Ustawy PZP)

Dialog konkurencyjny to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy. Zamawiający prowadzi dialog z zaproszonymi do udziału w dialogu wykonawcami w zakresie zaproponowanych przez nich rozwiązań, po zakończeniu którego zaprasza ich do składania ofert.

Zastosowanie Dialogu Konkurencyjnego warunkowane jest spełnieniem co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w art. 153 Ustawy PZP, tj.:

- rozwiązania dostępne na rynku nie mogą zaspokoić, bez ich dostosowania, potrzeb Zamawiającego;
- roboty budowlane, dostawy lub usługi obejmują rozwiązania projektowe lub innowacyjne;
- zamówienie nie może zostać udzielone bez wcześniejszych Negocjacji z uwagi na szczególne okoliczności dotyczące jego charakteru, stopnia złożoności lub uwarunkowań prawnych lub finansowych, lub z uwagi na ryzyko związane z robotami budowlanymi, dostawami lub usługami;
- jeżeli Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny sposób przez odniesienie do określonej normy, europejskiej oceny technicznej, o której mowa w art. 101 ust.1 pkt 2 lit. c, wspólnej specyfikacji technicznej, o której mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 lit. d, lub referencji technicznej;
- w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1, lub Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3.

W aktualnym stanie prawnym to Zamawiający samodzielnie decyduje o tym, czy spełnione zostały warunki do przeprowadzenia Postępowania w trybie Dialogu Konkurencyjnego. Weryfikacja poprawności takiej decyzji może nastąpić w trakcie kontroli Postępowania przez uprawnione do tego organy. Stosowne uzasadnienie wyboru Dialogu Konkurencyjnego powinno zostać zawarte w Ocenie Efektywności, o ile tryb ten rekomendowany jest w konkretnej sytuacji.

DOBRE PRAKTYKI



Podmioty Publiczne często zniechęcają się do Dialogu Konkurencyjnego z uwagi na relatywnie długi czas Postępowania, wynoszący średnio od 12 do 24 miesięcy. Dialog Konkurencyjny można usprawnić i przyspieszyć dzięki odpowiedniemu przygotowaniu Postępowania. Jednak z reguły etap ten jest czasochłonny nie tylko w Polsce, ale również w innych jurysdykcjach, z uwagi na konieczność omówienia z Partnerami Prywatnymi obszernego zakresu zagadnień (prawnych, finansowych oraz technicznych).

W praktyce w ramach Postępowania PPP udziela się kompleksowego zamówienia publicznego, obejmującego zazwyczaj: projektowanie, budowę, finansowanie, utrzymanie i/lub zarządzanie. Tymczasem, porównanie czasu trwania tradycyjnych postępowań do Postępowania PPP dowodzi, że okresy te są bardzo zbliżone, a niejednokrotnie Postępowanie PPP może okazać się szybsze z uwagi na brak konieczności organizowania kilku odrębnych procedur przetargowych (odrębnie na zaprojektowanie, budowę, finansowanie, usługi utrzymania itp.).

Pomimo że Dialog Konkurencyjny stanowi tryb udzielenia zamówienia publicznego, w tradycyjnych zamówieniach publicznych stosowany jest dosyć rzadko. Poniżej wskazano główne cechy i korzyści z zastosowania Dialogu Konkurencyjnego w PPP.

Cechy charakterystyczne Dialogu Konkurencyjnego

W odróżnieniu od trybów przetargowych, Dialog Konkurencyjny:

- nie wymaga przedstawiania na etapie ogłoszenia o zamówieniu kompletnej SWZ, gdyż Dokumentacja Postępowania wypracowywana jest w toku Postępowania;
- umożliwia zapoznanie się ze stanowiskiem strony prywatnej i przeprowadzenie na ten temat dyskusji, co pozwala stronie publicznej na wypracowanie optymalnego stanowiska, a w efekcie optymalizację przyjętych rozwiązań;
- zawiera w ogłoszeniu o zamówieniu Opis Potrzeb i Wymagań Podmiotu Publicznego, określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się przez Partnerów Prywatnych do dialogu, jak również wstępny harmonogram Postępowania;
- nie wymaga – na etapie ogłoszenia o zamówieniu - nadania Kryteriom Oceny Ofert wag, a jedynie podania kryteriów w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego;
- umożliwia dokonanie selekcji (po złożeniu wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu) Partnerów Prywatnych, którzy wezmą udział w dialogu, w liczbie zapewniającej konkurencję;
- odbywa się w ramach kilku tur dialogu, poświęconych zagadnieniom technicznym, finansowym, prawnym i innym, dotyczącym Przedsięwzięcia;

- może dotyczyć wszelkich aspektów Przedsięwzięcia, dzięki czemu stanowi procedurę bardzo elastyczną;
- ma charakter poufny, chroniona jest tajemnica handlowa Partnerów Prywatnych;
- prowadzony jest do momentu, w którym Podmiot Publiczny jest w stanie określić rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby.

Warto podkreślić, że tryb Dialogu Konkurencyjnego jest w pełni transparentny i jako tryb "zamówieniowy" podlega w całości reżimowi Ustawy PZP. W zakresie nieuregulowanym Ustawą PZP stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

W przepisach Ustawy PZP, w przypadku Postępowań o wartości poniżej Progów Unijnych, nie został przewidziany Dialog Konkurencyjny. Niemniej, zgodnie z art. 275 pkt 3 Ustawy PZP możliwe jest wykorzystanie Trybu Negocyjnego Podprogowego. Negocjacje w tym trybie są obowiązkowe. Ich przeprowadzenie następuje po etapie, w którym wykonawcy w odpowiedzi na zamieszczone w BZP ogłoszenie składają oferty, które można określić jako oferty wstępne. Zamawiający może żądać załączenia do oferty wstępnej dowodów potwierdzających kwalifikacje podmiotowe wykonawców.

W tym trybie możliwe jest również ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do Negocjacji poprzez zastosowanie Kryteriów Oceny Ofert. Jednakże liczba dopuszczonych wykonawców powinna być wystarczająca, aby zapewnić konkurencję i nie może być mniejsza niż 3. Negocjacje ofert prowadzone są w celu ich ulepszenia. W tym przypadku nie sporządza się SWZ, lecz Opis Potrzeb i Wymagań, a SWZ jest przygotowywana po zakończeniu Negocjacji.

ŹRÓDŁA INFORMACJI



- Competitive Dialogue. How to undertake a Competitive Dialogue Procurement Process, The World Bank, October 2017

2.3.3 Ustawa o Umowie Koncesji – Negocjacje

Ustawa o Umowie Koncesji przewiduje zarówno jedno-, jak też dwustopniowe tryby wyboru Partnera Prywatnego. Pomimo że formalnie nie nazywają się one tak jak w Ustawie PZP "trybami", to w praktyce pełnią dokładnie taką samą funkcję, stąd na potrzeby Wytycznych Tom II posłużono się terminem "tryb" również w odniesieniu do Ustawy o Umowie Koncesji. Zgodnie z przedstawianymi rekomendacjami optymalnym trybem dla PPP będą Negocjacje, albowiem podobnie jak Dialog Konkurencyjny dają możliwość obszernego przedyskutowania przyjętych przez Podmiot Publiczny założeń Projektu PPP.

Tryby (art. 29 ust. 1 Ustawy o Umowie Koncesji)

"Zamawiający może przeprowadzić postępowanie o zawarcie umowy koncesji, w którym:

- 1) w odpowiedzi na ogłoszenie o koncesji wszyscy zainteresowani wykonawcy składają oferty wraz z informacjami na potrzeby oceny spełniania kryteriów kwalifikacji albo*
- 2) w odpowiedzi na ogłoszenie o koncesji wszyscy zainteresowani wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji wraz z informacjami na potrzeby oceny spełniania kryteriów kwalifikacji, a następnie zaprasza do składania ofert albo do negocjacji i składania ofert wykonawców, którzy spełniają kryteria kwalifikacji; przepis ust. 5 stosuje się, albo*
- 3) przeprowadza negocjacje z wykonawcami dopuszczonymi do udziału w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji, a następnie zaprasza ich do składania ofert".*

W odróżnieniu od Ustawy PZP, Ustawa o Umowie Koncesji nie przewiduje żadnych przesłanek ani warunków, od których uzależnia zastosowanie procedury Negocjacji.

W ramce poniżej wskazano główne cechy i korzyści z zastosowania Negocjacji. Pomimo że nie wynikają one wprost z przepisów Ustawy o Umowie Koncesji, w praktyce są one bardzo zbliżone do tych prezentowanych w ramach Dialogu Konkurencyjnego.

Warto podkreślić, że procedura Negocjacji jest w pełni transparentna i podlega w całości reżimowi Ustawy o Umowie Koncesji. W zakresie nieuregulowanym Ustawą o Umowie Koncesji stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Powszechnie uważa się, że Ustawa o Umowie Koncesji przewiduje bardziej elastyczną procedurę wyboru Partnera Prywatnego niż Ustawa PZP. Wynika to z faktu, że Ustawa o Umowie Koncesji nie zawiera tak szczegółowych przepisów proceduralnych, pozostawiając stronie publicznej znaczną swobodę wyboru Partnera Prywatnego. Z drugiej jednak strony, z punktu widzenia Podmiotu Publicznego zastosowanie Ustawy o Umowie Koncesji wymaga większego wysiłku organizacyjnego, polegającego na doprecyzowaniu i uszczegółowieniu ogólnych zasad dotyczących przeprowadzenia Postępowania. Podmioty Publiczne mogą przy tym korzystać z niektórych rozwiązań przewidzianych przepisami Ustawy PZP. Nieracjonalne natomiast wydaje się oparcie całego Postępowania Koncesyjnego na zasadach wprost zaczerpniętych z regulacji Ustawy PZP, albowiem niweczyłoby to możliwość uelastycznienia Postępowania jaką dają przepisy Ustawy o Umowie Koncesji. W takiej sytuacji bardziej właściwe wydaje się zastosowanie do wyboru Partnera Prywatnego przepisów Ustawy PZP, co wprost przewidziane jest w art. 4 ust. 2 Ustawy o PPP.

Cechy charakterystyczne Negocjacji

W odróżnieniu od innych trybów koncesyjnych, procedura Negocjacji:

- nie wymaga przedstawiania na etapie ogłoszenia o koncesji kompletnych dokumentów koncesji, gdyż Dokumentacja Postępowania wypracowywana jest w toku Postępowania;
- umożliwia zapoznanie się ze stanowiskiem strony prywatnej wraz z uzasadnieniem i przeprowadzenie na ten temat dyskusji, co pozwala stronie publicznej na wypracowanie optymalnego stanowiska;

- wymaga od Podmiotu Publicznego przekazania Partnerom Prywatnym wraz z ogłoszeniem o koncesji tzw. opisu Postępowania o zawarcie umowy koncesji, który określa w szczególności: kryteria kwalifikacji, sposób komunikowania się z wykonawcami, warunki jakim mają odpowiadać wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu i oferta, planowany termin zakończenia Postępowania;
- nie wymaga - na etapie ogłoszenia o koncesji – nadania kryteriom oceny ofert wag, a jedynie podania kryteriów w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego;
- umożliwia dokonanie selekcji Partnerów Prywatnych, którzy wezmą udział w Negocjacjach, w liczbie zapewniającej konkurencję;
- odbywa się w ramach kilku tur negocjacji, poświęconych zagadnieniom technicznemu, finansowemu, prawnym i innym, dotyczącym Przedsięwzięcia;
- może dotyczyć wszelkich aspektów Przedsięwzięcia, dzięki czemu stanowi procedurę bardzo elastyczną;
- zapewnia ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa Partnerów Prywatnych;
- prowadzona jest do momentu, w którym Podmiot Publiczny jest w stanie określić rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby.

2.3.4 Inne tryby

Z formalnego punktu widzenia, wybór Partnera Prywatnego w innych trybach niż omówione wyżej jest możliwy. Nie zaleca się jednak stosowania trybów jednostopniowych, tj. przetargu nieograniczonego, o którym mowa w art. 132 Ustawy PZP, trybu podstawowego, o którym mowa w art. 275 pkt 1 Ustawy PZP lub zbliżonej procedury określonej w art. 29 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Umowie Koncesji. Procedury dwustopniowe, ale nie zawierające elementów Negocjacji (np. przetarg ograniczony), również nie zapewniają korzyści z nich płynących ani Podmiotowi Publicznemu ani Partnerom Prywatnym. Wysoki poziom złożoności Projektów PPP wymaga bowiem przeprowadzenia szeregu niezbędnych dyskusji i dokonania uzgodnień, które możliwe są jedynie w przypadku zastosowania trybów negocjacyjnych.

Jedyny inny tryb, który warto ewentualnie rozważyć w zakresie Projektów PPP, to tryb negocjacji z ogłoszeniem, regulowany w art. 152 Ustawy PZP. Zgodnie z tym przepisem, negocjacje z ogłoszeniem to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, Zamawiający zaprasza wykonawców dopuszczonych do udziału w Postępowaniu do składania ofert wstępnych, prowadzi z nimi negocjacje w celu ulepszenia treści ofert wstępnych, ofert składanych na etapie negocjacji, po zakończeniu których zaprasza wykonawców do składania ofert ostatecznych.

Ustawa wyraźnie wskazuje, że Zamawiający negocjują z wykonawcami złożone przez nich oferty, (z wyjątkiem ofert ostatecznych), w celu ulepszenia ich treści. Oznacza to, że negocjacje z ogłoszeniem można wykorzystać jedynie w sytuacji, gdy Projekt PPP i Dokumentacja Postępowania znajdują się na bardzo zaawansowanym etapie przygotowania np. Podmiot Publiczny dysponuje projektem budowlanym i Decyzjami Administracyjnymi, posiada również szczegółowo opracowany projekt Umowy o PPP z załącznikami, a celem procedury jest wyłącznie dopracowanie pewnych detali współpracy w ramach PPP. W praktyce przypadki takie zdarzają się jednak bardzo rzadko.

W poniższej ramce zaprezentowano rekomendowany model proceduralny w przypadku wątpliwości Podmiotu Publicznego co do trafności wyboru podstawy prawnej i trybu wyłaniania Partnera Prywatnego.

DOBRE PRAKTYKI



Wybór podstawy prawnej współpracy w ramach PPP

W razie wątpliwości, czy do realizacji konkretnego Projektu PPP należy zastosować Ustawę o PPP czy Ustawę o Umowie Koncesji, należy zawsze wybierać Ustawę o PPP jako regulację kompleksowo odnoszącą się do współpracy w ramach PPP, opierającą tę współpracę o uzgodniony w toku Postępowania podział zadań i ryzyk.

W razie wątpliwości, czy do wyboru Partnera Prywatnego na podstawie Ustawy o PPP stosować przepisy Ustawy PZP, czy Ustawy o Umowie Koncesji, należy wybierać Ustawę PZP, ponieważ można ją zastosować w każdych warunkach, bez względu na docelowy model Projektu PPP.

W razie wątpliwości co do trybu wyboru Partnera Prywatnego na podstawie Ustawy PZP i w przypadku spełnienia przesłanek zastosowania tego trybu, należy stosować Dialog Konkurencyjny (lub Tryb Negocyjny Podprogowy) z uwagi na możliwość elastycznego kształtowania zasad współpracy z Partnerem Prywatnym w toku Postępowania, co przekłada się na lepszą jakość Dokumentacji Postępowania.

2.4 Ustawa o PPP a Ustawa PZP i Ustawa o Umowie Koncesji

Jeżeli Podmiot Publiczny zdecyduje się na zastosowanie do Projektu PPP Ustawy o PPP, to bez względu na przepisy proceduralne (Ustawa PZP albo Ustawa o Umowie Koncesji), do Postępowania będą miały zastosowanie rozwiązania przewidziane w Ustawie o PPP. Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 Ustawy o PPP, do wyboru Partnera Prywatnego i Umowy o PPP stosuje się regulacje Ustawy PZP albo Ustawy o Umowie Koncesji – w zakresie nieuregulowanym przepisami Ustawy o PPP. O ile zatem Ustawa o PPP nie zawiera odmiennych postanowień, Podmiot Publiczny będzie zobowiązany do stosowania wszelkich innych przepisów Ustawy PZP (albo Ustawy o Umowie Koncesji).

W poniższej tabeli przedstawiono najważniejsze regulacje Ustawy o PPP, które stosowane są w toku wyboru Partnera Prywatnego na podstawie Ustawy PZP albo Ustawy o Umowie Koncesji. W przypadku, gdy Ustawa o Umowie Koncesji stosowana jest samoistnie, tj. Podmiot Publiczny nie stosuje Ustawy o PPP, a opiera współpracę z wykonawcą wyłącznie na regulacji Ustawy o Umowie Koncesji, Podmiot Publiczny nie będzie mógł skorzystać z uprawnień i rozwiązań przewidzianych w Ustawie o PPP.

Tabela 3. Wybrane przepisy szczególne zawarte w Ustawie o PPP dotyczące wyboru Partnera Prywatnego i Umowy o PPP na podstawie Ustawy PZP albo Ustawy o Umowie Koncesji

Przepis Ustawy o PPP	Ustawa o PPP	Ustawa PZP	Ustawa o Umowie Koncesji	Uwagi
Informacja o planowanym PPP (art. 5 ust. 1)	Po zamieszczeniu ogłoszenia w BZP albo opublikowaniu ogłoszenia w DUUE Podmiot Publiczny ma obowiązek zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o planowanym PPP.	Zamawiający – po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu w DUUE, zamieszcza ogłoszenie na stronie internetowej prowadzonego Postępowania oraz może dodatkowo udostępnić ogłoszenie w inny sposób (art. 88 ust.1 i 2 Ustawy PZP). Zgodnie z art. 89 Ustawy PZP Zamawiający może także zamieścić w DUUE i na stronie internetowej wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanych zamówieniach w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Ponadto, Ustawa PZP przewiduje w stosunku do Zamawiających publicznych o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2, oraz ich związków obowiązek publikacji w BZP oraz na stronie internetowej planów Postępowań	Brak takiego wymogu. Zamawiający może, po publikacji ogłoszenia o koncesji w sposób, o którym mowa w art. 18 ust. 1, albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania tego ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej, zamieścić dodatkowo ogłoszenie o koncesji w inny sposób, w szczególności w prasie o zasięgu ogólnopolskim.	Zamieszczenie informacji o planowanym PPP ma dodatkowe znaczenie informacyjne. Ustawa o PPP nie przewiduje sankcji za niedopełnienie przez Podmiot Publiczny tego obowiązku.

		o udzielenie zamówień w danym roku finansowym (art. 23 ust. 1).		
Informacja, że Postępowanie ma na celu zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (art. 5 ust. 2)	W ogłoszeniu wszczynającym Postępowanie w sprawie wyboru Partnera Prywatnego zamieszcza się informację, że Postępowanie ma na celu zawarcie Umowy o PPP.	---	---	---
Definicja najkorzystniejszej oferty (art. 6 ust. 1)	Najkorzystniejsza jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans wynagrodzenia Partnera Prywatnego albo Spółki PPP lub kosztu Przedsięwzięcia ponoszonego przez Podmiot Publiczny i innych kryteriów odnoszących się do Przedsięwzięcia.	Najkorzystniejsza jest oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem (gdy jedynym kryterium oceny jest cena lub koszt).	Brak definicji oferty najkorzystniejszej, pomimo obowiązku uzasadnienia wyboru oferty uznanej za najkorzystniejszą.	W praktyce nie ma różnicy pomiędzy "ceną" a "wynagrodzeniem". Ustawa o PPP przewiduje natomiast kryterium w postaci wynagrodzenia Spółki PPP.
Fakultatywne kryteria wyboru ofert (art. 6 ust. 2)	Kryteriami Oceny Ofert mogą być w szczególności: podział dochodów pochodzących	Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i kryteria jakościowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia, w szczególności: jakości, w tym do parametrów	Kryteriami oceny ofert mogą być w szczególności aspekty środowiskowe, społeczne lub innowacyjne przedmiotu umowy koncesji. W wyjątkowych przypadkach, gdy oferta zawiera rozwiązanie	Ustawa o PPP, nie narzuca obligatoryjnych kryteriów oceny ofert; zawiera natomiast otwarty katalog kryteriów fakultatywnych. Ustawa o Umowie

z Przedsięwzięcia pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym, w tym dochodów w postaci udziału w zysku Spółki PPP;	technicznych, właściwości estetycznych i funkcjonalnych takich jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb Użytkowników;	innowacyjne, stanowiące wdrażanie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, usługi lub procesu, w tym procesu produkcji lub budowy, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w działalności, organizacji pracy lub relacjach zewnętrznych, w szczególności mające na celu rozwiązanie problemów społecznych lub wspieranie strategii społecznych, którego Zamawiający nie mógł przewidzieć mimo zachowania należytej staranności, Zamawiający może zmienić kolejność kryteriów oceny ofert w celu uwzględnienia tego rozwiązania.	Koncesji ogranicza się do propozycji aspektów, które mogą być uwzględnione przy określaniu kryteriów oceny ofert. Przewiduje też możliwość zmiany kolejności kryteriów w sytuacji, gdy oferta zawiera rozwiązanie innowacyjne.
• stosunek wkładu własnego Podmiotu Publicznego do wkładu Partnera Prywatnego;	• aspektów społecznych, w tym integracji zawodowej i społecznej osób, o których mowa w art. 94 ust. 1;		
• efektywność realizacji Przedsięwzięcia, w tym efektywność wykorzystania składników majątkowych;	• aspektów środowiskowych, w tym efektywności energetycznej przedmiotu zamówienia;		
• kryteria odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu Przedsięwzięcia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, poziom oferowanych technologii, koszt utrzymania, serwis;	• aspektów innowacyjnych;		
• podział zadań i ryzyk związanych z Przedsięwzięciem	• organizacji, kwalifikacji zawodowych i doświadczenia osób		

	między Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym;	wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli mogą one mieć znaczący wpływ na jakość wykonania zamówienia;		
	terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń Podmiotu Publicznego, jeżeli są one planowane.	serwisu posprzedażnego, pomocy technicznej, warunków dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.		
Definicja Podmiotu Publicznego (art. 2 pkt 1)	Podmiotem Publicznym jest: - jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu Ustawy o Finansach Publicznych; - inna osoba prawna, utworzona w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, nie działająca w zwykłych warunkach rynkowych, której celem nie jest wypracowanie zysku	Zamawiającym publicznym jest: - jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu Ustawy o Finansach Publicznych; - inna niż określone w punkcie powyżej, państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;	Zamawiającym jest: - podmiot, o którym mowa w art. 4 Ustawy PZP; - przedsiębiorstwo publiczne, przez które należy rozumieć przedsiębiorstwo, na które podmiot, o którym mowa w art. 4 Ustawy PZP, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio może wywierać dominujący wpływ przez: - posiadanie ponad połowy udziałów	Zakres pojęć "Podmiot Publiczny", "Zamawiający publiczny" i Zamawiający nie jest tożsamy. Nie każdy Zamawiający będzie Podmiotem Publicznym. Należy przy tym pamiętać, że kwalifikacja Zamawiającego wyłącznie jako Zamawiającego sektorowego lub subsydiowanego w rozumieniu Ustawy PZP nie powoduje zakwalifikowania go automatycznie

oraz nieponosząca strat wynikających z prowadzenia działalności, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz wymienione we wcześniejszym punkcie, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: - finansują ją w ponad 50%; lub - posiadają ponad połowę udziałów albo akcji; lub - sprawują nadzór nad organem zarządzającym; lub - mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;	albo akcji w tym przedsiębiorstwie; - kontrolowanie ponad połowy głosów przypadających na akcje wyemitowane przez to przedsiębiorstwo; - prawo do powoływania ponad połowy członków organu zarządzającego lub nadzorczego przedsiębiorstwa; jeżeli umowa koncesji jest zawierana w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności sektorowej;	do kręgu Podmiotów Publicznych w rozumieniu Ustawy o PPP.
• związki podmiotów, o których mowa we wcześniejszych punktach	• inna osoba prawna, utworzona w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli	• podmiot inny niż określony w lit. a i b, jeżeli umowa koncesji jest zawierana w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności sektorowej, a działalność ta jest

	podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz wymienione we wcześniejszych punktach, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: - finansują je w ponad 50%; lub - posiadają ponad połowę udziałów albo akcji; lub - sprawują nadzór nad organem zarządzającym; lub - mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego;	wykonywana na podstawie praw szczególnych lub praw wyłącznych, o których mowa w art. 5 ust. 2 Ustawy PZP.
	• związki podmiotów/jednostek, o których mowa we wcześniejszych punktach.	
	Ustawa PZP wyróżnia także Zamawiających sektorowych	

oraz Zamawiających subsydiowanych.				
Definicja Partnera Prywatnego (art. 2 pkt 2)	Partnerem Prywatnym jest przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny.	Wykonawcą zamówienia publicznego jest osoba fizyczną, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.	Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub grupa takich podmiotów, które ubiegają się o zawarcie Umowy Koncesji lub złożyły ofertę. Koncesjonariuszem jest wykonawca, z którym zawarto umowę koncesji.	W odróżnieniu od definicji wykonawcy na gruncie Ustawy PZP, Partnerem Prywatnym może być wyłącznie przedsiębiorca. W praktyce ma to jednak marginalne znaczenie.
Finansowanie Projektu PPP (art. 7 ust. 1)	Partner Prywatny zobowiązuje się do poniesienia w całości albo w części wydatków na realizację Przedsięwzięcia lub poniesienia ich przez osobę trzecią.	Ustawa PZP nie zawiera żadnych postanowień dotyczących finansowania zamówienia publicznego przez wykonawcę.	Ustawa o Umowie Koncesji nie zawiera szczegółowych postanowień dotyczących finansowania przedmiotu umowy koncesji. Z treści tej regulacji wynika jednak obowiązek Koncesjonariusza do wykonania robót budowlanych lub świadczenia usług na jego ryzyko.	Partner Prywatny musi zapewnić finansowanie inwestycji choćby w części. W innych przypadkach nie będziemy mieli do czynienia z Projektem PPP.

Wynagrodzenie Partnera Prywatnego (art. 7 ust. 2)	Wynagrodzenie Partnera Prywatnego zależy przede wszystkim od rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej dostępności przedmiotu Przedsięwzięcia.	Brak określenia podobnych przesłanek wypłaty wynagrodzenia.	Wynagrodzenie Koncesjonariusza stanowi wyłącznie prawo do eksploatacji obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płatnością (umowa koncesji na roboty budowlane) albo wyłącznie prawo do wykonywania usług będących przedmiotem umowy albo takie prawo wraz z płatnością (umowa koncesji na usługi).	Wynagrodzenie Partnera Prywatnego zależy zatem od efektywności wykorzystania Infrastruktury Publicznej.
Postanowienia dot. Umów o PPP (art. 7 ust. 3a Ustawy o PPP)	Do umów o partnerstwie publiczno-prywatnym art. 95, art. 436 pkt 3 i 4, art. 437, art. 438, art. 439, art. 440, art. 443, art. 447, art. 463, art. 464, art. 465 Ustawy PZP nie stosuje się.	Art. 95 – dot. wymagań w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego. Art. 436 pkt 3 – określający obowiązek wprowadzenia w umowie limitu kar umownych oraz pkt 4 – wprowadzenia w umowach powyżej 12 miesięcy zasad dot. zmian wysokości wynagrodzenia. Art. 437, 438, 447, 463, 464 i 465 – określające wymagania dot. treści umowy o roboty budowlane i zasad realizacji		Specyfika PPP powoduje, że nie wszystkie przepisy odnoszące się do umów w sprawie zamówienia publicznego są adekwatne w przypadku Umów o PPP.

zamówienia w zakresie korzystania z podwykonawców.

Art. 439 i 440 – dotyczący zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Art. 443 – dotyczący obowiązku płatności wynagrodzenia w częściach, po wykonaniu części umowy lub udziela zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Odpowiedzialność członków konsorcjum za wykonanie Umowy o PPP i zabezpieczenie należytego wykonania Umowy o PPP (art. 7 ust. 4)	Do odpowiedzialności za wykonanie Umowy o PPP i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przepisów art. 445 ust. 1, art. 452 i art. 453 Ustawy PZP nie stosuje się.	Art. 445 ust. 1. Wykonawcy, o których mowa w art. 58 ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Art. 452 ust. 1. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej	Ustawa o Umowie Koncesji nie zawiera szczegółowych rozwiązań w zakresie odpowiedzialności członków konsorcjum. Zgodnie z przepisem art. 15 Ustawy o Umowie Koncesji wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zawarcie umowy koncesji, na zasadach określonych w Prawie zamówień publicznych. Tym samym	Zdarza się w praktyce, że Podmioty Publiczne narzucają Partnerom Prywatnym umowną solidarną odpowiedzialność z tytułu wykonania Umowy o PPP. Jeżeli Podmiot Publiczny przewiduje takie podejście, wówczas powinien już w ogłoszeniu o zamówieniu zastrzec,
---	--	---	---	---

wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe.

2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy.

3. Zabezpieczenie można ustalić w wysokości większej niż określona w ust. 2, nie większej jednak niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia, co Zamawiający opisał w SWZ lub innych dokumentach zamówienia.

na podstawie art. 15 w zw. z art. 141 Ustawy PZP wykonawcy wspólnie ubiegający się o zawarcie umowy koncesji ponoszą solidarną odpowiedzialność za jej wykonanie.

Ustawa o Umowie Koncesji nie zawiera postanowień dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pozostawiając w tym zakresie swobodę Zamawiającemu.

że będzie wymagał ponoszenia solidarnej odpowiedzialności z tytułu wykonania Umowy o PPP przez członków konsorcjum.

Brak podobnego zastrzeżenia (przy jednoczesnym założeniu solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum np. na etapie Negocjacji), może skutkować rzeczywistym zmniejszeniem liczby wykonawców aktywnie uczestniczących w Postępowaniu i w efekcie - mniejszą liczbą złożonych ofert.

W odniesieniu do zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o PPP, wobec wyłączenia stosowania art. 452 i 453 Ustawy PZP, Podmiot Publiczny samodzielnie decyduje o wysokości i zasadach

4. Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok, zabezpieczenie, za zgodą Zamawiającego, może być tworzone przez potrącenia z należności za częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.

6. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

8. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie

zwalniania takiego zabezpieczenia. Liberalizacja zasad dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy w Ustawie o PPP uzasadniona jest tym, że konstrukcja Umowy o PPP, przewidująca finansowanie po stronie Partnera Prywatnego przy jednoczesnym systemie kar z tytułu nienależytej jakości standardów utrzymania lub zarządzania oraz zasad dostępności objętych Przedsięwzięciem, w sposób wystarczający zabezpiecza interesy Podmiotu Publicznego.

W tym kontekście utrzymywanie zabezpieczenia zgodnie z warunkami Ustawy PZP niepotrzebnie mogłoby zwiększyć koszty Przedsięwzięcia (koszty

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

zabezpieczenia zostaną uwzględnione przez Partnerów Prywatnych w ofertach).

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

10. Wypłata, o której mowa w ust. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

Art. 453. 1. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane.

2. Zamawiający może pozostawić na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji kwotę nie przekraczającą 30% zabezpieczenia.
3. Kwota, o której mowa w ust. 2, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
4. Zamawiający może dokonać częściowego zwrotu zabezpieczenia po wykonaniu części zamówienia, jeżeli przewidział taką możliwość w dokumentach zamówienia.

PPP Instytucjonalne (Spółka PPP)	Umowa o PPP może przewidywać, że w celu jej wykonania Podmiot Publiczny i Partner Prywatny zawiążą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółkę akcyjną. Umowa o PPP może przewidywać, że w celu jej wykonania Partner Prywatny nabędzie udziały albo akcje spółki z udziałem Podmiotu Publicznego. Nabycie może	Ustawa PZP nie przewiduje utworzenia spółki Zamawiającego z wykonawcą.	Ustawa o Umowie Koncesji nie przewiduje utworzenia spółki z Koncesjonariuszem.	Wśród wszystkich analizowanych przepisów dotyczących szeroko pojętego PPP, jedynie Ustawa o PPP wprost przewiduje możliwość utworzenia Spółki PPP i reguluje niektóre aspekty jej funkcjonowania.
---	---	---	---	--

nastąpić w drodze objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo akcji.

Cel i przedmiot działalności spółki nie może wykraczać poza zakres określony Umową o PPP.

Zmiany podmiotowe (art. 7a)	Podmiot Publiczny może wyrazić zgodę na zawarcie i wykonanie Umowy o PPP z zawiązaną po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu realizacji Przedsięwzięcia jednoosobową spółką Partnera Prywatnego albo spółką kapitałową, której jedynymi wspólnikami są Partnerzy Prywatni. Warunki zgody Podmiot Publiczny określa w pierwszym dokumencie, który udostępnia w Postępowaniu, w szczególności w dokumentach zamówienia, Dokumentach Koncesji albo innej dokumentacji Postępowania. Jeżeli Podmiot Publiczny nie wyraża zgody, zamieszcza stosowną informację	Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, może zastąpić inny wykonawca: • na podstawie postanowień umownych (o ile zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia w postaci jasnych i precyzyjnych postanowień umownych); • w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego	Na podstawie postanowień umownych Koncesjonariusza, może zastąpić inny Koncesjonariusz: • na podstawie postanowień umownych (o ile zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o koncesji lub innym Dokumencie Koncesji w postaci jednoznacznych postanowień umownych); • w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Koncesjonariusza lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Koncesjonariusz spełnia kryteria kwalifikacji, pod warunkiem,	W przypadku dokonania zmiany podmiotowej na podstawie przepisu art. 7a Ustawy o PPP, Partner Prywatny odpowiada solidarnie ze Spółką Projektową za szkodę wyrządzoną Podmiotowi Publicznemu wskutek nieudostępnienia Spółce Projektowej zasobów, które wskazał w ofercie, chyba że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy. Taką samą odpowiedzialność ponoszą podmioty, które na etapie Postępowania przekazały potencjał Partnerowi Prywatnemu.
------------------------------------	---	---	---	--

	w ogłoszeniu wszczynającym Postępowanie. Partner Prywatny odpowiada za szkodę wyrządzoną Podmiotowi Publicznemu solidarnie ze Spółką Projektową, chyba że nie ponosi winy.	przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w Postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy, lub w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1.	że nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy koncesji i nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy; • w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Koncesjonariusza względem jego podwykonawców.	
		W przypadkach innych niż wyżej wymienione, zmianę podmiotową po stronie wykonawcy uznaje się za istotną zmianę umowy.	W przypadkach innych niż wyżej wymienione, zmianę podmiotową po stronie Koncesjonariusza uznaje się za istotną zmianę umowy.	
Odpowiedzialność Podmiotu Publicznego wobec podwykonawców (art. 7b)	Przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczących odpowiedzialności inwestora za wynagrodzenie należne podwykonawcy nie stosuje się do Podmiotu Publicznego, jeżeli Umowa o PPP tak stanowi.	Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę	Ustawa o Umowie Koncesji nie zawiera odrębnych rozwiązań w tym zakresie, w związku z czym zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.	Jest to istotna różnica wobec tradycyjnego systemu zamówień publicznych. W ramach Umowy o PPP Podmiot Publiczny może wyłączyć swoją odpowiedzialność

W przypadku, gdy Podmiot Publiczny jest inwestorem, a nie stosuje się do niego tych przepisów, Partner Prywatny informuje o tym podwykonawcę przed zawarciem z nim umowy.

Jeżeli Umowa o PPP wyłącza odpowiedzialność Podmiotu Publicznego za wynagrodzenie należne podwykonawcy, za wynagrodzenie należne podwykonawcy, jak inwestor, odpowiada:

1) Spółka PPP

Partner Prywatny, jeżeli Przedsięwzięcie jest realizowane przez Partnera Prywatnego albo Spółkę Projektową. Ponadto zgodnie z art. 7 ust. 3a Ustawy o PPP wyłączony został m.in. art. 465 Ustawy PZP, który wprowadza odpowiedzialność Zamawiającego za wynagrodzenie podwykonawców w przypadku zamówień na roboty budowlane.

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylecia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

Do solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy PZP nie stanowią inaczej.

Art. 647¹ Kodeksu Cywilnego:

§ 1. Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego

względem podwykonawców Partnera Prywatnego, nawet jeżeli to Podmiot Publiczny jest inwestorem.

Takie podejście jest uzasadnione, albowiem podmiotem, który faktycznie posiada środki finansowe na płatności względem wykonawców robót jest Partner Prywatny. Podmiot Publiczny na etapie robót nie będzie posiadać zabezpieczonych środków na ewentualną płatność wobec wykonawców robót budowlanych. Inne podejście przeczyłoby istocie PPP, w którym Podmiot Publiczny realizuje płatności po zakończeniu robót budowlanych, przez okres wskazany w Umowie o PPP.

robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

§ 2. Zgłoszenie, o którym mowa w § 1, nie jest wymagane, jeżeli inwestor i wykonawca określili w umowie, zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, szczegółowy przedmiot robót budowlanych wykonywanych przez oznaczonego podwykonawcę.

§ 3. Inwestor ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w umowie między podwykonawcą a wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty

budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w § 1 albo 2. W takim przypadku odpowiedzialność inwestora za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy za roboty budowlane, których szczegółowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgłoszenia albo z umowy, o których mowa w § 1 albo 2. § 4. Zgłoszenie oraz sprzeciw, o których mowa w § 1, wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. § 5. Przepisy § 1–4 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności inwestora, wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

Prawo interwencji (Step-in rights) (art. 10a)	Podmiot Publiczny może zawrzeć umowę z osobą trzecią finansującą Przedsięwzięcie	---	---	Ustawa o PPP wprowadza możliwość przeniesienia praw
--	--	-----	-----	---

w całości lub w części, na mocy której, w przypadku poważnego zagrożenia realizacji Przedsięwzięcia, będzie mógł przenieść na tę osobę trzecią całość lub część obowiązków Partnera Prywatnego, wraz ze związanymi z nimi prawami.

Osoba trzecia, o której mowa powyżej, może powierzyć realizację Przedsięwzięcia innemu podmiotowi lub podmiotom tylko za zgodą Podmiotu Publicznego.

Ogłoszenie o zamówieniu, dokumenty zamówienia, Dokumenty Koncesji lub inna Dokumentacja Postępowania w sprawie wyboru Partnera Prywatnego zawiera warunki stosowania ww. zasad.

i obowiązków Partnera Prywatnego na Instytucję Finansującą (a w praktyce – na wskazanego przez nią nowego Partnera Prywatnego) w przypadku poważnego zagrożenia realizacji Przedsięwzięcia. Warunki dokonania *step-in rights* muszą zostać określone w Dokumentacji Postępowania.

3. Przygotowanie Postępowania PPP

3.1 Czynności przygotowawcze

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część I Punkt 2 – Otoczenie instytucjonalno-prawne Projektów PPP
Tom I: Część II Punkt 1.1.2 – Analiza opcji realizacji inwestycji
Tom I: Część II Punkt 1.2 – Przygotowanie informacji o Projekcie PPP
Tom I: Część II Punkt 2 – Przygotowanie organizacyjne
Tom I: Część II Punkt 4 – Działania do podjęcia przed wszczęciem Postępowania PPP

3.1.1 Opinia PPP

Przed zorganizowaniem i wszczęciem Postępowania można rozważyć skorzystanie z Opinii PPP. Zgodnie z art. 3b Ustawy o PPP, Podmiot Publiczny może wystąpić do ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego z wnioskiem o opinię na temat zasadności realizacji Przedsięwzięcia w ramach PPP. Do wniosku należy dołączyć Ocenę Efektywności realizacji Przedsięwzięcia.

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego opiniuje przedłożoną dokumentację w zakresie poprawności i kompletności przeprowadzonych analiz poprzedzających realizację Przedsięwzięcia, przyjętego modelu prawno-organizacyjnego, Mechanizmów Wynagradzania Partnera Prywatnego, w tym wysokości Opłat od Użytkowników oraz warunków ich zmiany (jeżeli takie opłaty są planowane), a także proponowanego podziału ryzyk w Projekcie PPP.

Opinia wydawana jest w terminie 60 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku, przy czym minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może zwrócić się do Podmiotu Publicznego o poprawienie, wyjaśnienie lub uzupełnienie wniosku. Opinia ma charakter poufny – nie ujawnia się jej osobom trzecim do chwili zawarcia Umowy o PPP, umowy koncesji lub umowy w sprawie zamówienia publicznego albo zakończenia Postępowania w inny sposób. W przypadku, gdy mimo wydania Opinii PPP nie wszczęto Postępowania, Opinia PPP może zostać ujawniona nie wcześniej niż w terminie 2 lat od jej wydania. Ponadto, nie ujawnia się informacji pozyskanych w związku z wydaniem Opinii PPP, jeżeli groziłoby to ujawnieniem tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również innych tajemnic ustawowo chronionych.

UWAGA



Pomimo że wystąpienie przez Podmiot Publiczny z wnioskiem o wydanie Opinii PPP nie jest obowiązkowe, zaleca się skorzystanie z tej możliwości, w szczególności w przypadku, gdy Podmioty Publiczne samodzielnie opracowują Ocenę Efektywności i nie korzystają z zewnętrznych Doradców lub korzystają z ich wsparcia w ograniczonym zakresie.

3.1.2 Organizacja Postępowania

3.1.2.1 Postępowanie PZP

Za przygotowanie i przeprowadzenie Postępowania odpowiada kierownik Zamawiającego, a także inne osoby w zakresie, w jakim powierzono im czynności z tym związane. Kierownik Zamawiającego może powierzyć pisemnie wykonywanie zastrzeżonych dla niego czynności pracownikom Zamawiającego (por. art. 52 Ustawy PZP).

Przepisy Ustawy PZP formułują prawa i obowiązki kierownika Zamawiającego w sposób ogólny, z wyróżnieniem pewnych decyzji lub czynności, które kierownik jest zobowiązany i uprawniony podejmować w Postępowaniu.

Do zadań kierownika Zamawiającego należy w szczególności przygotowanie i przeprowadzenie Postępowania, w tym:

- prawidłowy wybór trybu udzielenia zamówienia publicznego;
- należyte oszacowanie wartości zamówienia;
- właściwe opracowanie OPIW oraz opisu przedmiotu zamówienia;
- właściwe opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu;
- należyte dokumentowanie Postępowania;
- terminowe dokonywanie czynności w toku Postępowania;
- dbanie o prawidłowość i zgodność z prawem decyzji Zamawiającego.

Do wyłącznej kompetencji kierownika Zamawiającego należy podejmowanie decyzji kluczowych dla Postępowania, w tym:

- powołanie Komisji Przetargowej;
- powołanie i odwołanie członków Komisji Przetargowej;
- określenie organizacji, składu i trybu pracy Komisji Przetargowej;
- ustalenie zakres obowiązków poszczególnych członków Komisji Przetargowej;
- wykluczenie wykonawcy;
- odrzucenie i wybór oferty;
- wybór oferty najkorzystniejszej;
- unieważnienie Postępowania;
- powołanie biegłych;
- zawarcie umowy z wykonawcą (Umowy o PPP).

3.1.2.2 Postępowanie Koncesyjne

Ustawa o Umowie Koncesji reguluje kwestię organizacji Postępowania Koncesyjnego w przepisie art. 28, stanowiąc, że "Zamawiający organizuje postępowanie o zawarcie umowy koncesji w sposób odpowiadający jego potrzebom".

W Ustawie o Umowie Koncesji brak jest analogicznej do Ustawy PZP podstawy prawnej określającej zakres odpowiedzialności kierownika Zamawiającego w Postępowaniu. Jednakże

z brzmienia przepisu art. 30 ust. 2 Ustawy o Umowie Koncesji, który mówi o odebraniu oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu osób wykonujących czynności w Postępowaniu przez "kierownika Zamawiającego lub osobę, której powierzył czynności w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji" można wywieść odpowiedzialność kierownika Zamawiającego za przygotowanie i przeprowadzenie Postępowania oraz uprawnienie do powierzenia wykonywania zastrzeżonych dla niego czynności pracownikom Zamawiającego. Należy rekomendować udzielenie takiego upoważnienia na piśmie.

3.1.3 Komisja Przetargowa

3.1.3.1 Zagadnienia wspólne

Na Etapie Przygotowawczym Projekt PPP prowadzony jest zazwyczaj przez Zespół Projektowy PPP oraz Komitet Sterujący, jeśli został utworzony. Członkowie Zespołu Projektowego najczęściej powoływani są w skład Komisji Przetargowej.

Po określeniu składu osobowego Komisji Przetargowej oraz formalnego jej powołania, należy przypisać jej członkom odpowiednie zadania wynikające ze specyfiki danego Projektu PPP oraz wewnętrznych aktów obowiązujących w danej jednostce, regulujących sposób przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub/i postępowania o zawarcie umowy koncesji.

Skład Komisji Przetargowej oraz zadania poszczególnych jej członków powinny być dostosowane do potrzeb Projektu PPP i Postępowania.

Poniższa tabela prezentuje przykładowy zakres zadań członków Komisji Przetargowej.

Tabela 4. Przykładowy zakres zadań członków Komisji Przetargowej

Członek Komisji ds. technicznych	Członek Komisji ds. finansowych	Członek Komisji ds. prawnych	Członek Komisji ds. administracyjnych
• odpowiada za techniczne aspekty Projektu PPP w trakcie Postępowania; • odpowiada za przygotowanie dokumentacji technicznej na potrzeby Negocjacji; • weryfikuje założenia do modeli finansowych pod kątem kosztów; • analizuje koszty Projektu PPP w ujęciu wieloletnim i przekazuje dane ekspertowi ds. finansów; • aktywnie uczestniczy w turach Negocjacji, wypowiadając się w kwestiach technicznych i rekomenduje określone rozwiązania; • aktywnie uczestniczy w opracowaniu, opiniowaniu i współpracuje z Doradcami w zakresie przygotowania standardów utrzymania oraz zasad dostępności;	• odpowiada za aspekty finansowe Projektu PPP w trakcie Postępowania; • aktywnie uczestniczy w turach Negocjacji, wypowiadając się w aspektach finansowych; • opracowuje lub weryfikuje założenia do modeli finansowych; • dba o Bankowość Projektu PPP; • weryfikuje Dokumentację Postępowania w zakresie finansowym; • współpracuje z pozostałymi członkami Komisji Przetargowej i Doradcami, w tym zapewnia dostępność niezbędnych informacji i dokumentów w zakresie aspektów finansowych;	• odpowiada za prawne i proceduralne aspekty Projektu PPP w trakcie Postępowania; • odpowiada za przygotowanie dokumentów niezbędnych do wszczęcia Postępowania; • odpowiada za przygotowanie dokumentacji prawnej na potrzeby Negocjacji, w tym przede wszystkim przygotowanie lub weryfikację projektu Umowy o PPP; • aktywnie uczestniczy w rundach Negocjacji, we wszystkich aspektach prawnych i proceduralnych, rekomendując określone rozwiązania; • odpowiada za Dokumentację Postępowania; • współpracuje z pozostałymi członkami Komisji Przetargowej i Doradcami, w tym zapewnia dostępność niezbędnych	• odpowiada za obsługę administracyjną Postępowania; • odpowiada za sprawny obieg informacji pomiędzy uczestnikami Postępowania; • organizuje i protokołuje cykliczne narady koordynacyjne dotyczące zadań związanych z prowadzonym Postępowaniem; • organizuje kolejne tury Negocjacji; • sporządza protokół z prowadzonych Negocjacji; • sporządza protokół z Postępowania PPP; • archiwizuje dokumentację Postępowania.

Członek Komisji ds. technicznych

- weryfikuje Dokumentację Postępowania w zakresie technicznym;
- współpracuje z pozostałymi członkami Komisji Przetargowej i Doradcami, w tym zapewnia dostępność niezbędnej dokumentacji technicznej;
- uczestniczy w ocenie ofert i weryfikuje je w zakresie aspektów technicznych.

Członek Komisji ds. finansowych

- uczestniczy w ocenie złożonych ofert i weryfikuje je w zakresie aspektów finansowych.

Członek Komisji ds. prawnych

- informacji i dokumentów w zakresie aspektów prawnych;
- uczestniczy w ocenie złożonych ofert i weryfikuje je w zakresie aspektów prawnych.

Członek Komisji ds. administracyjnych

Warto wskazać, że spośród członków Komisji Przetargowej wybierany jest przewodniczący, który powinien przede wszystkim dbać o spójność przyjętych rozwiązań, za które odpowiadają poszczególni członkowie Komisji Przetargowej oraz rozwiązywać problemy i ewentualne sytuacje sporne.

W pracach Komisji Przetargowej mogą brać udział również inne osoby z jednostki Podmiotu Publicznego, w zależności od zakresu Projektu PPP i jego cech. Na przykład w przypadku Projektu Hybrydowego skład Komisji Przetargowej powinien zostać poszerzony o osobę odpowiadającą za sprawy związane z pozyskaniem środków unijnych.

Poza składem Komisji Przetargowej kierownik Zamawiającego ma prawo do powołania biegłych – zarówno z grona pracowników jednostki, jak i z instytucji/firm zewnętrznych. Może to nastąpić w sytuacji, gdy dokonanie określonych czynności związanych z Postępowaniem wymaga specjalistycznej wiedzy. Z fachowej wiedzy tych osób można korzystać na każdym etapie Postępowania, również w trakcie jego przygotowywania. Rolę biegłych mogą pełnić Doradcy.

W zależności od obiektywnych potrzeb, można rozważyć przygotowanie i przyjęcie regulaminu prowadzenia Postępowania na wybór Partnera Prywatnego, jeśli obowiązujące w danej jednostce regulacje wewnętrzne (np. regulamin udzielania zamówień publicznych) zostaną uznane za niewystarczająco precyzyjne lub niedostosowane do specyfiki PPP i przez to uniemożliwiające sprawne i prawidłowe przeprowadzenie Postępowania.

Regulamin Postępowania powinien zawierać:

- cel oraz podstawę prawną wszczynanego Postępowania – w szczególności określenia wymaga tryb wyboru Partnera Prywatnego;
- podstawowe zasady prowadzenia Postępowania, które będą obowiązywać w jego trakcie;
- zakres poufności informacji przekazywanych Zamawiającemu przez uczestników Postępowania – w szczególności sposób postępowania z informacjami mogącymi stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa, a w przypadku Dialogu Konkurencyjnego lub Trybu Negocyjacyjnego Podprogowego – poufności przekazywanych informacji technicznych i handlowych;
- sposobu komunikacji uczestników w trakcie Postępowania;
- opis przebiegu Negocjacji – w szczególności wskazanie planowanego harmonogramu Negocjacji, sposobu organizacji spotkań/tur negocjacyjnych, a także zasad przekazywania informacji pomiędzy spotkaniami;
- zasady dokumentowania przebiegu Postępowania – sposobu prowadzenia protokołu i utrwalania przebiegu Negocjacji oraz wskazania osoby odpowiedzialnej za wykonywanie ww. czynności;
- organizację i tryb pracy Komisji Przetargowej – w szczególności poprzez określenie zasad procedowania i podejmowania decyzji w ramach Komisji Przetargowej;
- skład Komisji Przetargowej – z określeniem funkcji pełnionych przez poszczególne osoby oraz przyporządkowaniem zadań organizacyjnych i merytorycznych.

DOBRE PRAKTYKI



Regulamin udzielania zamówień w ramach PPP

W praktyce regulaminy udzielania zamówień publicznych obowiązujące w jednostkach sektora finansów publicznych nie uwzględniają specyfiki PPP. Jednak nie w każdym przypadku konieczne jest przyjmowanie odrębnego Regulaminu Postępowania. Najczęściej dokonuje się niezbędnych zmian w istniejących regulacjach, polegających w szczególności na:

- odstąpieniu od wymogu zabezpieczania środków na realizację zamówienia w roku budżetowym, w którym wszczynane jest Postępowanie, o ile ewentualne, zakładane płatności w ramach Projektu PPP rozpoczynają się w późniejszych latach niż rok, w którym wszczynane jest Postępowanie;
- w przypadku prowadzenia Postępowania na podstawie Ustawy o Umowie Koncesji – włączeniu do regulaminu udzielania zamówień postanowień obejmujących kwestie specyficzne dla koncesji;
- wprowadzeniu jako podstawy szacowania wartości Projektu PPP, wyników Oceny Efektywności;
- rozszerzeniu składu Komisji Przetargowej.

3.1.3.2 Postępowanie PZP

W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu Postępowania na wybór Partnera Prywatnego na podstawie przepisów Ustawy PZP Komisja Przetargowa powoływana jest przez kierownika Zamawiającego, który odpowiedzialny jest za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 52 Ustawy PZP).

Komisja Przetargowa stanowi zespół pomocniczy kierownika Zamawiającego, której głównym zadaniem jest dokonanie oceny spełniania przez Partnerów Prywatnych warunków udziału w Postępowaniu PPP oraz badanie i ocena ofert. Kierownik Zamawiającego może jednak powierzyć Komisji Przetargowej dokonanie innych czynności, zarówno z zakresu przygotowania (np. przygotowanie SWZ), jak i prowadzenia Postępowania.

Komisja Przetargowa ma obowiązek przedkładać kierownikowi Zamawiającego propozycje dokonania czynności takich jak:

- wykluczenie wykonawcy;
- odrzucenie oferty;
- wybór oferty najkorzystniejszej;
- unieważnienie Postępowania;

przy czym kierownik Zamawiającego nie jest związany takimi propozycjami – w sytuacji, gdy nie zgadza się z uzasadnieniem faktycznym i prawnym dokonania proponowanej czynności, może podjąć decyzję odmienną (art. 54-55 Ustawy PZP).

Skład Komisji Przetargowej ustalany jest przez kierownika Zamawiającego – on powołuje i odwołuje jej członków. Ustawa PZP przewiduje, iż komisja musi się składać z minimum 3 osób (art. 55 ust. 2). W przypadku zamówień bardziej skomplikowanych, a do takich niewątpliwie należą

Postępowania PPP, pożądane jest powołanie Komisji Przetargowej w szerszym składzie. W jej skład mogą wchodzić także osoby, które nie są pracownikami Zamawiającego.

Powołując Komisję Przetargową, biegłych lub korzystając z usług Zespołu Doradców, kierownik Zamawiającego powinien mieć na uwadze zasadę bezstronności i obiektywizmu osób wykonujących czynności w postępowaniu (art. 17 ust. 3 Ustawy PZP). Regulacja art. 56 Ustawy PZP zawiera nakaz wyłączenia osób wykonujących czynności w Postępowaniu po stronie Zamawiającego lub mogące wpłynąć na wynik tego Postępowania lub udzielające zamówienia, jeżeli po ich stronie występuje konflikt interesów. Konflikt interesów występuje wówczas, gdy ww. osoby:

- 1) ubiegają się o udzielenie tego zamówienia;
- 2) pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- 3) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, otrzymywały od wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia;
- 4) pozostają z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego postępowania;
- 5) zostały prawomocnie skazane za przestępstwa określone w Ustawie PZP.

Osoby wykonujące czynności w Postępowaniu zobowiązane są do złożenia oświadczenia o istnieniu/nieistnieniu ww. okoliczności kierownikowi Zamawiającego, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (art. 56 ust. 4 Ustawy PZP).

Oświadczenie o istnieniu okoliczności, o których mowa w Punktach 1) - 4) powyżej składa się niezwłocznie po powzięciu wiadomości o ich istnieniu, a oświadczenie o braku istnienia tych okoliczności nie później niż przed zakończeniem postępowania o udzielenie zamówienia (art. 56 ust. 5 Ustawy PZP).

Z kolei oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w Punkcie 5) składa się przed rozpoczęciem wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia (art. 56 ust. 6 Ustawy PZP).

Ewentualne wystąpienie konfliktu interesów ma ten skutek, że zgodnie z art. 56 ust. 7 Ustawy PZP, czynności w Postępowaniu podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych czynności faktycznych niewpływających na wynik Postępowania.

Warto pamiętać, że w przypadku Projektów Hybrydowych brak wyłączenia ww. osób może skutkować nawet 100% korektą finansową.

3.1.3.3 Postępowanie Koncesyjne

W przypadku, gdy Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Ustawę o Umowie Koncesji, należy zauważyć, że poza ogólną zasadą, zgodnie z którą Zamawiający organizuje postępowanie o zawarcie Umowy Koncesji w sposób odpowiadający jego potrzebom (art. 28 Ustawy o Umowie Koncesji), nie reguluje ona sposobu powołania członków i organizacji prac Komisji Przetargowej oraz nie identyfikuje osób odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie Postępowania w strukturze organizacyjnej Zamawiającego. Powyższe oznacza, że Zamawiający przy przygotowaniu Postępowania może zastosować odpowiednio rozwiązania przewidziane w Ustawie PZP, dopasowując je do zakresu danego Projektu PPP.

Zamawiający powinien zatem przenieść do treści Dokumentów Koncesji lub wewnętrznych regulacji te rozwiązania, które w praktyce pozwolą mu sprawnie przygotować i przeprowadzić Postępowanie.

Z pewnością do takich rozwiązań należy zaliczyć powołanie Komisji Przetargowej, w skład której wejdą osoby posiadające kompetencje niezbędne do przygotowania Postępowania i prowadzenia Negocjacji z Partnerami Prywatnymi oraz wyboru najkorzystniejszej oferty.

Jedynym wymogiem wskazanym przez ustawodawcę odnośnie do udziału osób wykonujących czynności w Postępowaniu o zawarcie Umowy Koncesji po stronie Zamawiającego jest regulacja art. 30 Ustawy o Umowie Koncesji, zbliżona do rozwiązań przewidzianych w art. 56 Ustawy PZP dotyczących wyłączenia członka Komisji Przetargowej, o których była mowa powyżej.

Zgodnie z art. 30 Ustawy o Umowie Koncesji – osoby wykonujące czynności w Postępowaniu podlegają wyłączeniu, jeżeli ich bezstronność lub niezależność w związku z tym Postępowaniem jest lub może być zagrożona, z uwagi na posiadanie bezpośredniego lub pośredniego interesu finansowego, ekonomicznego lub osobistego w określonym rozstrzygnięciu tego Postępowania, w szczególności, jeżeli:

- ubiegają się o zawarcie tej umowy koncesji;
- pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o zawarcie umowy koncesji;
- pozostają lub w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o zawarcie umowy koncesji pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą, otrzymywały od wykonawcy wynagrodzenie z innego tytułu lub były członkami organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawców ubiegających się o zawarcie umowy koncesji;
- zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Z przepisów Ustawy o Umowie Koncesji wynika konieczność zbadania powyższych przesłanek i złożenia przez osoby wykonujące czynności w Postępowaniu stosownych oświadczeń nie później niż przed zawarciem umowy koncesji lub niezwłocznie po powzięciu wiadomości o tych okolicznościach (art. 30 ust. 2).

Jednocześnie brak jest innych uregulowań, które należałoby stosować wprost do osób biorących udział w Postępowaniu po stronie Zamawiającego, co może stanowić znaczne ułatwienie przy

organizacji Postępowania, o ile zostanie to wyczerpująco opisane w Dokumentach Koncesji i przyjętych regulaminach.

MAŁE PROJEKTY



Komisja Przetargowa w Małych Projektach z reguły jest mniej rozbudowana, co nie powinno oznaczać, iż jej członkowie nie powinni posiadać kompetencji potrzebnych do właściwego prowadzenia Negocjacji i przeprowadzenia Postępowania. Jako złą praktykę należy ocenić ograniczanie zadań i kompetencji członków Komisji Przetargowej z uwagi na mniejszą wartość Projektu PPP.

3.1.4 Szacowanie wartości zamówienia oraz koncesji

Jedną z podstawowych czynności, do których Zamawiający zobowiązany jest przed wszczęciem Postępowania PPP, stanowi – w zależności od Projektu PPP – oszacowanie wartości zamówienia lub koncesji.

Zarówno w przypadku Projektów PPP, jak i Projektów Koncesyjnych szacowanie odbywa się na etapie Oceny Efektywności, w ramach analizy technicznej i finansowej przy wykorzystaniu modelu finansowego, zawierającego elementy i założenia wskazane odpowiednio w Wytycznych Tom I.

Szacowanie wartości dokonywane przed ogłoszeniem o zamówieniu w przypadku Projektów PPP ma na celu potwierdzenie lub zmianę wartości przyjętych w Ocenie Efektywności.

Szacowanie wartości zamówienia spełnia dwie podstawowe funkcje:

- stanowi dla Zamawiającego podstawę do określenia Kryteriów Oceny Podmiotowej (m.in. w zakresie zdolności technicznej i finansowej oraz kryteriów selekcji);
- decyduje o miejscu publikacji ogłoszenia o zamówieniu (DUUE albo BZP), a w konsekwencji – o stosowaniu przepisów Ustawy PZP albo Ustawy o Umowie Koncesji dotyczących zamówień powyżej Progów Unijnych.

Należy zauważyć, że sposób szacowania wartości różni się, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z zamówieniem publicznym czy koncesją.

W przypadku zamówień publicznych sposób szacowania opisują odpowiednie przepisy Ustawy PZP m.in. art. 28-36. Zgodnie z przepisem art. 28 Ustawy PZP podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należyłą starannością. Wartość zamówienia odnosi się więc wprost do szacunkowego wynagrodzenia wykonawcy. W przypadku Projektów PPP opartych o Opłatę za Dostępność będzie to zatem szacunkowa suma Opłat za Dostępność obliczona z należyłą starannością. Opłata za Dostępność pokrywa koszty usług różnego rodzaju: prac projektowych, robót budowlanych, usługi finansowej, usług utrzymania (w tym remontów) lub zarządzania.

Poziom kosztów (inwestycyjnych i operacyjnych) powinien zostać oszacowany przez Podmiot Publiczny zgodnie z jego najlepszą wiedzą na podstawie danych, którymi dysponuje na danym etapie (np. przeprowadzone wcześniej wstępne analizy lub studia wykonalności, rozeznania rynku itp.). Przyjmowane na każdym etapie założenia do szacowania kosztów powinny być oparte o aktualne informacje dotyczące realizacji planowanego Projektu PPP bądź podobnych projektów w analizowanych sektorach oraz o aktualne założenia makroekonomiczne. Przykładowo, przyjęcie

zbyt optymistycznego założenia co do częstotliwości koniecznych remontów skutkować może niedoszacowaniem wartości Projektu PPP, a tym samym całości prognozowanej Opłaty za Dostępność.

W przypadku szacowania kosztów na podstawie danych z Projektów PPP realizowanych w formule tradycyjnej, należy zweryfikować, czy zakładana dla rozważanego Projektu PPP jakość i poziom świadczenia usług oraz rozwiązania technologiczne i stan utrzymania Infrastruktury Publicznej odpowiadają projektowi realizowanemu w formule tradycyjnej, jeśli nie – należy rozważyć ich proporcjonalne zwiększenie. Oszacowanie kosztów może zostać wykonane metodą porównawczą w odniesieniu do już realizowanych inwestycji w danym rejonie charakteryzujących się podobnymi parametrami np. oszacowanie kosztu wybudowania jednego kilometra drogi o podobnych parametrach dla tej samej kategorii drogi czy jednego kilometra wodociągu o tej samej średnicy i z podobnych materiałów, czy jednego metra kwadratowego powierzchni obiektu kubaturowego. Metoda porównawcza polegająca na szacowaniu kosztów w odniesieniu do podobnych inwestycji powinna być stosowana na etapie przygotowania Projektu PPP, z uwagi na jej ogólny charakter i mniejszą dokładność niż szacowanie kosztów realizacji danej inwestycji w oparciu o wybraną Koncepcję Projektową.

Na podstawie zaprognozowanych w ten sposób kosztów Projektu PPP należy oszacować oczekiwane wynagrodzenie Partnera Prywatnego, z uwzględnieniem oczekiwanego zwrotu z inwestycji (szerzej na ten temat w Wytycznych Tom I Punkt 3.8) i w oparciu o to oszacować całkowitą wartość zamówienia. Szczegółowość oszacowania kosztów w głównej mierze uzależniona będzie od zakresu informacji, jakimi dysponuje Podmiot Publiczny (np. szacunkami kosztów opracowanymi w oparciu o PFU/STF).

Przy wstępnych wycenach kosztów można również opierać się na różnego rodzaju opracowaniach naukowych, na doradztwie specjalistycznych jednostek projektowych czy też zastosować wskaźniki jednostkowe lub porównanie z nakładami inwestycyjnymi dla Projektów PPP o podobnym zakresie i skali prac rzeczowych oraz o zbliżonych rozwiązaniach technicznych. Możliwe jest również wstępne oszacowanie wartości zamówienia w oparciu o rozeznanie rynku.

W sytuacji, w której na etapie Oceny Efektywności dla Projektu PPP Podmiot Publiczny dysponuje wykonanym wcześniej projektem budowlanym, może na jego podstawie pozyskać dokładniejsze dane o nakładach inwestycyjnych. Sporządzanie tego typu Dokumentacji Projektowej, jakkolwiek korzystne z perspektywy dokładności szacowania kosztów inwestycji, nie jest rekomendowane i nie powinno być jednak regułą dla Projektów PPP, gdyż ogranicza to możliwość korzystania z innowacyjnych rozwiązań Partnerów Prywatnych i w pewnym stopniu wpływa na podział ryzyk w Projekcie PPP. Należy również pamiętać o aktualizacjach wykonanego wcześniej oszacowania wartości zamówienia w przypadku opóźnień w realizacji danego Projektu PPP.

W praktyce zatem szacowaną wartością zamówienia w przypadku Projektów PPP, w których Partner Prywatny wybierany jest na podstawie przepisów Ustawy PZP będzie całkowita Opłata za Dostępność, obejmująca przewidywane nakłady na roboty budowlane i usługi świadczone przez Partnera Prywatnego, powiększone o prognozowane koszty finansowania robót budowlanych.

Zupełnie inne zasady szacowania dotyczą Projektów Koncesyjnych. Zgodnie z przepisem art. 6 Ustawy o Umowie Koncesji, szacunkową wartość zamówienia stanowi całkowity przychód Koncesjonariusza uzyskany w okresie obowiązywania Umowy, bez podatku od towarów i usług, oszacowany przez Zamawiającego z zachowaniem należytej staranności, z tytułu wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami, będących

przedmiotem koncesji, powiększony o wartość dostaw i usług towarzyszących takim robotom lub usługom.

W przypadku koncesji chodzi zatem w praktyce o analizę i oszacowanie wartości Opłat od Użytkowników oraz innych przychodów Koncesjonariusza, o ile są planowane.

Ustawa o Umowie Koncesji nie narzuca przy tym konkretnej metody szacowania wartości Umowy, nakazując jedynie Zamawiającemu użycie w tym celu "obiektywnej metody", uwzględniającej w szczególności (przepis art. 6 ust. 4 Ustawy o Umowie Koncesji):

- wartość opcji i przedłużenie okresu obowiązywania Umowy;
- przychody z opłat i kar uiszczanych przez korzystających z obiektów budowlanych lub usług (z wyjątkiem opłat i kar pobieranych w imieniu Zamawiającego);
- płatności lub inne korzyści finansowe, niezależnie od ich formy, przekazywane Koncesjonariuszowi przez Zamawiającego albo inny organ publiczny, w tym rekompensatę z tytułu spełnienia obowiązku świadczenia usługi publicznej i dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
- wartość dotacji lub innych korzyści finansowych, niezależnie od ich formy, od osób trzecich z tytułu wykonania Umowy;
- przychody ze sprzedaży aktywów wchodzących w skład przedmiotu Umowy;
- wartość dostaw i usług udostępnianych Koncesjonariuszowi przez Zamawiającego, jeżeli są one niezbędne do wykonania robót budowlanych lub świadczenia usług;
- nagrody lub płatności na rzecz wykonawcy lub Koncesjonariusza.

Należy zwrócić uwagę, że okres, jaki mija od wykonania Oceny Efektywności, w tym szacowania wartości zamówienia, od ogłoszenia o zamówieniu/koncesji, nie powinien być zbyt długi.

W przeciwnym razie może bowiem dojść do dezaktualizacji przyjętych szacunków.

Stosownie do art. 36 Ustawy PZP, jeżeli w zakres Projektu PPP wchodzić będą roboty budowlane, ustalenie wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia Postępowania. Natomiast, jeżeli po ustaleniu wartości zamówienia nastąpi zmiana okoliczności mających wpływ na dokonane szacunki, Podmiot Publiczny zobowiązany jest do dokonania zamiany (czyli ponownego obliczenia) wartości Projektu PPP jeszcze przed wszczęciem Postępowania. Za okoliczności mające wpływ na dokonane ustalenie wartości zamówienia należy uznać wszelkie zmiany stanu faktycznego, np. zmiana cen materiałów budowlanych, jak i zmiany stanu prawnego, np. konieczność uwzględnienia nowych rozwiązań w Projekcie PPP.

Ustawa o Umowie Koncesji nie zawiera co prawda podobnego nakazu, ale wprowadza innego rodzaju rozwiązanie. Mianowicie, w przypadku, gdy wartość umowy koncesji (bez podatku od towarów i usług) w dniu jej zawarcia jest wyższa o więcej niż 20% od wartości szacowanej na dzień ogłoszenia o koncesji, przyjmuje się, że wartością szacunkową umowy koncesji jest wartość z dnia jej zawarcia. Zasada ta umożliwia w sposób elastyczny dopasowanie rzeczywistej wartości Umowy o PPP do wartości szacowanej.

Biorąc pod uwagę, że czas od ogłoszenia o zamówieniu do zakończenia Negocjacji i zaproszenia do składania ofert trwa prawie zawsze dłużej niż 6 miesięcy, należy dokonać aktualizacji szacowanej wartości zamówienia/koncesji po zakończeniu Negocjacji, a przed przekazaniem Partnerom Prywatnym ostatecznej wersji SWZ/Dokumentów Koncesji.

3.1.5 Zgoda ministra właściwego ds. finansów publicznych

Należy zwrócić uwagę, że niektóre Przedsięwzięcia – realizowane głównie przez administrację rządową – wymagały będą uzyskania przez Podmiot Publiczny dodatkowej zgody ministra właściwego ds. finansów publicznych. Mowa o Projektach PPP, w ramach których planowane jest finansowanie z budżetu państwa w kwocie przekraczającej 100 000 000 PLN. Minister właściwy ds. finansów publicznych, udzielając zgody na sfinansowanie takiego Przedsięwzięcia, musi uwzględnić wpływ planowanych wydatków z budżetu państwa na bezpieczeństwo finansów publicznych.

Pomimo że nie wynika to wprost z Ustawy o PPP, do wniosku o wyrażenie zgody na realizację Przedsięwzięcia Podmiot Publiczny powinien dołączyć posiadane analizy w ramach przeprowadzonej Oceny Efektywności oraz wszelkie inne dokumenty i informacje (np. o etapie, na jakim znajduje się Projekt PPP), które umożliwią ministrowi właściwemu ds. finansów publicznych pełną identyfikację Przedsięwzięcia, w tym ocenę zasadności jego realizacji, o ile zwrócił się o taką ocenę do ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego.

Ponadto, zaleca się uzyskanie zgody ministra właściwego ds. finansów publicznych przed wszczęciem Postępowania. W innym przypadku, unieważnienie Postępowania w związku z odmową udzielenia zgody będzie skutkowało poniesieniem przez Podmiot Publiczny i Partnerów Prywatnych nieuzasadnionych kosztów związanych z przygotowaniem i prowadzeniem Postępowania.

Zgoda ministra właściwego ds. finansów publicznych nie jest wymagana w przypadku, gdy finansowanie obejmuje środki europejskie, tj. środki przeznaczone na finansowanie projektów z funduszy i programów, uregulowanych w odpowiednich przepisach (Projekty Hybrydowe).

Stosownie do art. 18 ust. 2 Ustawy o PPP, zgoda udzielana jest na wniosek Podmiotu Publicznego, który zawiera:

- określenie Podmiotu Publicznego;
- określenie planowanego Przedsięwzięcia PPP;
- przewidywaną wysokość środków z budżetu państwa przeznaczonych w poszczególnych okresach budżetowych na realizację Przedsięwzięcia.

Minister właściwy ds. finansów publicznych wydaje zgodę albo odmawia wydania zgody w terminie 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku. Zgoda i odmowa zgody nie są Decyzją Administracyjną. Zgoda ministra właściwego ds. finansów publicznych nie stanowi zabezpieczenia finansowania Przedsięwzięcia z budżetu państwa.

Ponadto, jak wynika z art. 18 ust. 6 Ustawy o PPP, jeżeli Postępowanie zostało wszczęte przed uzyskaniem zgody, a minister właściwy ds. finansów publicznych odmówił jej udzielenia, odmowa taka może stanowić przesłankę unieważnienia Postępowania, o ile zostało to przewidziane w Dokumentacji Postępowania.

W przypadku innych Projektów PPP zgoda ministra właściwego ds. finansów publicznych nie jest wymagana. Warto zauważyć, że na etapie przygotowania Postępowania zazwyczaj nie jest wymagane zabezpieczenie środków na realizację Przedsięwzięcia, a to z uwagi na stosunkowo odległy termin rozpoczęcia pierwszych płatności na rzecz Partnera Prywatnego. Praktyka pokazuje, że Partnerzy Prywatni będą oczekiwali od Podmiotu Publicznego wiążących decyzji o zabezpieczeniu środków na realizację Przedsięwzięcia jeszcze przed złożeniem ofert.

3.2 Harmonogram Postępowania

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część I Punkt 3 – Etapy realizacji Projektu PPP

Tom I: Część II Punkt 2 – Przygotowanie organizacyjne

Przy tworzeniu harmonogramu Postępowania należy wziąć pod uwagę zarówno terminy wynikające z przepisów prawa, jak i praktyki prowadzenia Postępowań PPP.

Harmonogram Postępowania powinien uwzględniać, w szczególności:

- wszelkie działania do wykonania w trakcie Postępowania;
- odpowiedni czas na określone działanie (w tym wynikające z przepisów prawa i specyfiki danego Projektu PPP);
- proces decyzyjny po stronie Podmiotu Publicznego (np. konieczność uzyskania zgód organów nadzorczych, uchwał rady miasta, dostępność zarządu JST, itd.);
- proces decyzyjny po stronie Partnerów Prywatnych (np. konieczność uzyskania zgód korporacyjnych);
- kamienie milowe tj. zdarzenia, od których zależy podjęcie kolejnych czynności;
- potencjalne ograniczenia dostępności Podmiotu Publicznego oraz Partnerów Prywatnych, np. biorąc pod uwagę święta państwowe czy okresy wakacyjne;
- przypisanie odpowiedzialności konkretnym podmiotom lub osobom za konkretne działania wynikające z harmonogramu Postępowania.

W przypadku, gdy realizacja Projektu PPP zakłada zastosowanie rozwiązań nietypowych lub skomplikowanych, wymagających od Partnerów Prywatnych zastosowania niestandardowych rozwiązań, należy zapewnić odpowiedni czas na przygotowanie ofert uwzględniających te oczekiwania, np. w przypadku konieczności przedstawienia szczegółowej koncepcji architektonicznej należy dodać dodatkowy, niezbędny czas na jej przygotowanie.

3.2.1 Postępowanie PZP

Przygotowanie harmonogramu Postępowania jest niezbędne z punktu widzenia sprawnego i efektywnego prowadzenia Postępowania.

W harmonogramie Postępowania należy szczegółowo rozpisać wszystkie działania po stronie Podmiotu Publicznego związane z każdym z etapów przygotowania i prowadzenia Postępowania na wybór Partnera Prywatnego, ze wskazaniem kamieni milowych oraz osób odpowiedzialnych za realizację danego zadania.

Harmonogram Postępowania powinien uwzględniać wszystkie czynności niezbędne do jego prawidłowego przeprowadzenia pod kątem formalnym, lecz również realne terminy wykonania działań nie mających charakteru proceduralnego, lecz niezbędnych do efektywnego przeprowadzenia Postępowania (np. terminy dla Partnerów Prywatnych potrzebne do przetłumaczenia Dokumentacji Postępowania, uzyskania zgód korporacyjnych na poszczególne

działania, wykonania koniecznych badań istniejącej Infrastruktury Publicznej – np. odwiertów w celu zweryfikowania ryzyka geologicznego).

Harmonogram jest narzędziem do zarządzania, mobilizującym Podmiot Publiczny do sprawnego przeprowadzenia Projektu PPP, dlatego powinien wskazywać na potencjalne konflikty czasowe i wpływ ewentualnych zmian na osiągnięcie terminów docelowych/końcowych. Odpowiedzialność za dotrzymanie terminów leży po stronie zarówno Kierownika Projektu, jak i Komitetu Sterującego (jeśli utworzono) oraz osób wskazanych bezpośrednio w harmonogramie.

Pierwotnie przygotowany harmonogram powinien podlegać bieżącej weryfikacji i może ulegać zmianom, w szczególności, jeżeli w trakcie Negocjacji Partnerzy Prywatni wskażą na nierealność osiągnięcia określonych kamieni milowych w proponowanych terminach. Należy jednak pamiętać, że osiągnięcie terminów w dużym stopniu zależy od woli i determinacji Podmiotu Publicznego do realizacji Projektu PPP, a w szczególności od sprawnego podejmowania decyzji w momentach kryzysowych lub strategicznych.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie PPP, dotyczącym wymiany oświetlenia ulicznego na energooszczędne, Podmiot Publiczny podjął decyzję o istotnym skróceniu pierwotnie przyjętego harmonogramu Postępowania. Podstawową motywacją Podmiotu Publicznego była w tym przypadku chęć jak najszybszego uzyskania oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, dzięki realizacji inwestycji.

Skrócenie harmonogramu było możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy Zespołu Projektowego z Zespołem Doradców, przejawiającej się m.in. w równoległym prowadzeniu prac nad wyłonieniem krótkiej listy Partnerów Prywatnych oraz nad wypracowaniem Projektowanych Postanowień Umowy. Ponadto, Podmiot Publiczny zobowiązał się do niezwłocznego zajmowania stanowiska wobec propozycji Zespołu Doradców oraz sprawnego dokonywania odbiorów prac doradczych.

Przewidziano przy tym krótsze (choć realne) terminy na odbycie tur Negocjacji, ograniczając jednocześnie ich liczbę do trzech (z pierwotnie planowanych pięciu). Umożliwiło to skrócenie harmonogramu Postępowania o ponad połowę, co spotkało się również z pozytywnym przyjęciem przez Partnerów Prywatnych.

Harmonogram Postępowania obejmuje harmonogram Negocjacji (szerzej na ten temat w Punkcie 6.3.2 Harmonogram i agendy tur Negocjacji).

Poniższa tabela prezentuje poszczególne etapy Postępowania na wybór Partnera Prywatnego w Postępowaniu PPP o wartości zamówienia równej lub przekraczającej Progi Unijne w trybie Dialogu Konkurencyjnego oraz w Trybie Negocjacyjnym Podprogowym wraz z orientacyjnym czasem ich trwania. W przypadku Projektów PPP o wartości poniżej Progów Unijnych, realizowanych w Trybie Negocjacyjnym Podprogowym, harmonogram Postępowania będzie zazwyczaj krótszy. Wynika to zarówno ze skali takich Przedsięwzięć, mniejszego stopnia ich złożoności, a często też z prostszych zasad finansowania. Ponadto, ustawowe terminy na dokonywanie określonych czynności w Postępowaniu są znacznie krótsze niż w ramach Dialogu Konkurencyjnego (przykładowo – minimalny termin na składanie ofert ostatecznych wynosi 10 dni w przypadku robót budowlanych, zaś 5 dni w przypadku dostaw i usług).

Należy zastrzec, że rzeczywisty harmonogram Postępowania uzależniony będzie przede wszystkim od liczby wykonawców biorących udział w Postępowaniu, tempa prac nad Projektem ze strony Podmiotu Publicznego oraz podejmowania istotnych decyzji dotyczących procedury wyboru Partnera Prywatnego.

Etap/czynność	Czas trwania – Dialog Konkurencyjny	Czas trwania – Tryb Negocjacyjny Podprogowy
Etap I. Ogłoszenie Postępowania na wybór Partnera Prywatnego		
1. Opracowanie oraz przekazanie ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej/zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP	Brak terminu ustawowego. W praktyce przygotowanie ogłoszenia powinno zająć nie dłużej niż 30 dni.	Brak terminu ustawowego. W praktyce przygotowanie ogłoszenia powinno zająć nie dłużej niż 30 dni.
2. Zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o planowanym PPP.	Brak terminu ustawowego. Informację zamieszcza się po opublikowaniu ogłoszenia w DUUE. Jako czynność techniczna, nie powinna ona zająć dłużej niż 1 dzień.	Brak terminu ustawowego. Informację zamieszcza się po opublikowaniu ogłoszenia w BZP. Jako czynność techniczna, nie powinna ona zająć dłużej niż 1 dzień.
Etap II. Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu / ofert wstępnych		
1. Składanie wniosków dopuszczenie do udziału w Postępowaniu/ofert wstępnych	Termin ustawowy. Minimalny termin na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu – 30 dni od przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Termin ten winien być dostosowany do specyfiki danego Projektu PPP. Często może zająć potrzeba wydłużenia go np. do 2-3 miesięcy (Partnerzy Prywatni muszą np. podjąć decyzję co do utworzenia konsorcjum lub założenia Spółki Projektowej. W tym wypadku może być także	Termin ustawowy. Minimalny termin na składanie ofert wstępnych w Postępowaniu – 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP (w przypadku robót budowlanych) albo 7 dni (w przypadku dostaw lub usług) od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Termin ten winien być dostosowany do specyfiki danego Projektu PPP. Często może zająć potrzeba wydłużenia go np. do 1-2 miesięcy, jeśli wynika to z potrzeb organizacyjnych Partnerów Prywatnych.

	niezbędne uzyskanie określonych zgód korporacyjnych).	
2.	Ocena wniosków/ofert wstępnych (także ewentualne wezwania do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień).	Brak terminu ustawowego. W praktyce termin zależy od liczby złożonych wniosków i ich jakości. Minimalny czas potrzebny na przeprowadzenie weryfikacji wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu i przesłanie zaproszenia do udziału w Negocjacjach - łącznie z uzupełnianiem lub wyjaśnianiem wniosków, wynosi ok. 14 dni. W przypadku dużej liczby wniosków procedura ich oceny może trwać znacznie dłużej, choć nie powinna przekraczać 90 dni.
	Brak terminu ustawowego.	
	W praktyce termin zależy od liczby złożonych ofert wstępnych i ich jakości. Minimalny czas potrzebny na przeprowadzenie weryfikacji ofert wstępnych i przesłanie zaproszenia do udziału w Negocjacjach - łącznie z uzupełnianiem lub wyjaśnianiem ofert, wynosi ok. 14 dni. W przypadku dużej liczby ofert wstępnych procedura ich oceny może trwać znacznie dłużej, choć nie powinna przekraczać 60 dni.	
3.	Przekazanie informacji Partnerom Prywatnym, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu/oferty wstępne - o wynikach oceny i ustalenie liczby podmiotów, z którymi prowadzone będą Negocjacje.	Czynność techniczna, której wykonanie nie powinno zająć dłużej niż 1 dzień.
	Czynność techniczna, której wykonanie nie powinno zająć dłużej niż 1 dzień.	

Etap III. Negocjacje

1. Negocjacje z Partnerami Prywatnymi	Brak terminu ustawowego.	Brak terminu ustawowego.
Podczas tego etapu zostaną ustalone wszelkie kluczowe kwestie realizacji Projektu PPP i opracowana zostanie istotna część Dokumentacji Postępowania (w tym PFU).	Przepisy prawa nie określają minimalnych ani maksymalnych terminów trwania Negocjacji – prowadzi się je do momentu określenia rozwiązań odpowiadających potrzebom Podmiotu Publicznego. W praktyce Dialog Konkurencyjny trwa średnio od 6 do 12 miesięcy.	Przepisy prawa nie określają minimalnych ani maksymalnych terminów trwania Negocjacji – prowadzi się go do momentu określenia rozwiązań odpowiadających potrzebom Podmiotu Publicznego. W praktyce Negocjacje trwają średnio od 3 do 9 miesięcy.

Etap IV. Składanie ofert / ofert ostatecznych

1. Sporządzenie ostatecznej treści SWZ/Dokumentacji Postępowania oraz zaproszenie do składania ofert.	Brak terminu ustawowego. Minimalny okres potrzebny na przygotowanie niezbędnych dokumentów wynosi w praktyce ok. 14 dni, może się jednak znacznie wydłużyć wskutek prac nad ostatecznym kształtem Dokumentacji Postępowania.	Brak terminu ustawowego. Minimalny okres potrzebny na przygotowanie niezbędnych dokumentów wynosi w praktyce ok. 14 dni, może się jednak znacznie wydłużyć wskutek prac nad ostatecznym kształtem Dokumentacji Postępowania.
2. Składanie ofert.	Termin ustawowy. Nie krótszy niż 30 dni - a pod warunkami wskazanymi w Ustawie PZP - nie krótszy niż 10 dni od przekazania zaproszenia do składania ofert. W praktyce PPP termin ten ustala się na ok. 3-6 miesięcy (dłuższy termin może być konieczny, jeśli Podmiot Publiczny oczekuje złożenia ofert	Termin ustawowy. Minimalny termin na składanie ofert ostatecznych w Postępowaniu – 10 dni (w przypadku robót budowlanych) albo 5 dni (w przypadku dostaw lub usług) od przekazania zaproszenia do składania ofert. W praktyce PPP termin ten ustala się na ok. 2-4 miesiące.

wraz z dodatkowymi przedmiotowymi środkami dowodowymi, jak np. koncepcja architektoniczna).

W praktyce termin składania ofert dość często ulega przedłużeniu wskutek pytań zadawanych do SWZ i zmian wprowadzanych w SWZ.

W praktyce termin składania ofert ostatecznych może ulegać przedłużeniu wskutek pytań zadawanych do SWZ i zmian wprowadzanych w SWZ.

Etap V. Otwarcie, ocena ofert i rozstrzygnięcie Postępowania

1. Otwarcie, ocena ofert i zawiadomienie wszystkich oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Brak terminu ustawowego.

Minimalny czas potrzebny na dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty to od 7 do 14 dni, w zależności od przyjętych Kryteriów Oceny Ofert.

W praktyce Podmioty Publiczne dokonują oceny ofert w dłuższych terminach (np. 1-2 miesiące).

Brak terminu ustawowego.

Minimalny czas potrzebny na dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty to od 3 do 10 dni, w zależności od przyjętych Kryteriów Oceny Ofert.

W praktyce Podmioty Publiczne dokonują oceny ofert w dłuższych terminach (np. 1 miesiąc).

2. Zawarcie Umowy o PPP.

Termin ustawowy.

Zawarcie umowy będzie możliwe dopiero po bezskutecznym upływie okresu przeznaczonego na wniesienie ewentualnego odwołania od wyniku Postępowania (tzw. klauzula "standstill"), czyli po upływie 10 dni od dnia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni, jeżeli w/w informację przekazano w inny sposób. W przypadku gdy wpłynęła tylko jedna oferta, termin ten nie musi zostać zachowany.

Termin ustawowy.

Zawarcie umowy będzie możliwe dopiero po bezskutecznym upływie okresu przeznaczonego na wniesienie ewentualnego odwołania od wyniku Postępowania (tzw. klauzula "standstill"), czyli po upływie 5 dni od dnia przekazania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli w/w informację przekazano w inny sposób. W przypadku gdy wpłynęła tylko jedna oferta ostateczna, termin ten nie musi zostać zachowany.

W zależności od liczby Partnerów Prywatnych oraz stopnia złożoności procesu Negocjacji, całe Postępowanie może trwać od kilku do nawet kilkudziesięciu miesięcy. Należy też pamiętać, że na wszystkich etapach Postępowania zainteresowanym wykonawcom przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, a następnie skarga do sądu powszechnego (szerzej na ten temat patrz Punkt 8 Środki ochrony prawnej).

3.2.2 Postępowanie Koncesyjne

Harmonogram Postępowania organizowanego na podstawie Ustawy o Umowie Koncesji zasadniczo nie różni się od prezentowanego wyżej harmonogramu w oparciu o Ustawę PZP. Jedyna różnica polega na nieokreśleniu przez ustawodawcę minimalnego terminu na złożenie ofert, co w praktyce ma i tak niewielkie znaczenie, gdyż terminy te są znacznie dłuższe niż "ustawowe" 10 dni.

MAŁE PROJEKTY



Warto zwrócić uwagę, że w sferze proceduralnej Małe Projekty niewiele różnią się od dużych Przedsięwzięć, ponieważ przebieg Postępowania jest taki sam. Skala i poziom skomplikowania Projektu PPP może wpływać na harmonogram Postępowania (np. w Dużym Projekcie może zaistnieć konieczność dwóch rund technicznych, podczas gdy w Małym Projekcie wystarczy jedna), niemniej jednak zakres zadań koniecznych do wykonania jest taki sam. Powyższe odpowiednio dotyczy pakietowych Projektów PPP.

3.3 Strategia negocjacyjna

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom III: Część I Punkt 2.3 – Strategia negocjacyjna

Tom IV: Część II Punkt 1.3 – Umowa o PPP – proces negocjacyjny i postanowienia istotne z punktu widzenia Zarządzania Umową o PPP

Pomimo że nie istnieje legalna definicja strategii negocjacyjnej, ani też jej opracowanie nie wynika z przepisów prawa, jest ona istotnym i pożądanym narzędziem, stosowanym w ramach Postępowania PPP, szczególnie w przypadku skomplikowanych lub bardzo Dużych Projektów.

Przez strategię negocjacyjną należy rozumieć, przyjęcie przez Podmiot Publiczny określonych założeń, wytycznych, instrukcji, warunków brzegowych na potrzeby przyszłych Negocjacji. Podmiot Publiczny powinien zdefiniować przed przystąpieniem do Negocjacji swoje podejście co do zakresu Projektu PPP oraz Dokumentacji Postępowania, który nie może ulec zmianie, jak również granice w jakich może się poruszać w celu dokonania ewentualnych zmian.

Przyjęcie strategii negocjacyjnej umożliwia ustalenie najlepszych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów Projektu PPP, w oparciu o zidentyfikowane potrzeby Podmiotu Publicznego.

Strategia negocjacyjna stanowi efekt wszystkich działań przygotowawczych, poprzedzających rozpoczęcie Postępowania PPP. Przed opublikowaniem ogłoszenia Podmiot Publiczny posiada już sprecyzowane założenia Projektu PPP, będące wynikiem Oceny Efektywności oraz przeprowadzonych testów rynkowych, dysponuje Zespołem Projektowym PPP i Doradcami,

pozyskał konieczne na tym etapie zgody lub opinie (o ile są wymagane lub pożądane, por. Punkt 3.1.1 Opinia PPP i 3.1.5 Zgoda ministra właściwego ds. finansów publicznych).

Zasadność opracowania strategii wynika również z faktu, iż każda decyzja podjęta w ramach złożonej procedury wyboru Partnera Prywatnego ma określone konsekwencje na dalszych jej etapach i ostatecznie może stanowić o powodzeniu całego Postępowania i Projektu PPP.

Strategia negocjacyjna powinna koncentrować się na priorytetowych kwestiach, które należy omówić i przeanalizować z Partnerami Prywatnymi uczestniczącymi w Negocjacjach. Dzięki takiemu podejściu już na samym początku Negocjacji mogą zostać ustalone podstawowe elementy i warunki współpracy, decydujące często o wykonalności Projektu PPP. W ramach strategii należy zatem określić warunki brzegowe dla Projektu PPP, wskazać zagadnienia szczególnie istotne dla Podmiotu Publicznego oraz zdefiniować zasadnicze kwestie wymagające uzgodnienia z Partnerami Prywatnymi. Należy także zidentyfikować te elementy Przedsięwzięcia, które nie przedstawiają większej wartości z punktu widzenia interesu Podmiotu Publicznego, a zarazem nie są atrakcyjne dla wykonawców i które można zatem wykluczyć z Projektu PPP na etapie Negocjacji.

Oprócz zagadnień merytorycznych, strategia negocjacyjna może zawierać również kwestie organizacyjne. Obejmują one m.in. sposób prowadzenia Negocjacji, szczegółowy podział ról w ramach Komisji Przetargowej przy okazji omawiania konkretnych aspektów Projektu PPP, ewentualnie także taktykę lub techniki negocjacyjne. Strategia musi być także skorelowana z harmonogramem Postępowania (szerzej na ten temat w Punkcie 3.2 Harmonogram Postępowania). Prawidłowo opracowana strategia negocjacji powinna również zakładać przeprowadzenie ich w taki sposób, aby w jak największym stopniu Partnerzy Prywatni byli zmotywowani do wykazywania aktywności i kreatywności w zakresie proponowanych rozwiązań związanych z realizacją przyszłej Umowy o PPP (np. przeprowadzenia własnej oceny technicznej określonych elementów Projektu PPP, przygotowania ocen lub analiz, zaproponowania rozwiązań technologicznych, standardów utrzymania lub zarządzania, zaprezentowania i uzasadnienia konkretnego stanowiska w stosunku do wskazanych problemów itp.).

Strategia negocjacyjna może zyskać status formalnego dokumentu (np. zarządzenie kierownika jednostki Podmiotu Publicznego) lub też przybrać inną formę akceptowalną dla Podmiotu Publicznego (np. opracowanie w formie prezentacji, dodatkowy dokument roboczy na potrzeby prac Komisji Przetargowej, uzgodnienia dokonane w ramach prac Zespołu Projektowego PPP itp.).

Celem strategii jest przede wszystkim, aby Zamawiający, przygotowując się do rozmów z wykonawcami, zidentyfikował czynniki ryzyka związane z realizacją planowanego Przedsięwzięcia, a następnie określił warunki brzegowe ich Negocjacji odpowiadające zakresowi Projektu PPP oraz jego uwarunkowaniom organizacyjno-prawnym i finansowym. Z oczywistych względów strategia będzie w związku z tym w dużej mierze bazowała na opracowanej uprzednio Ocenie Efektywności.

MAŁE PROJEKTY



W przypadku niektórych Małych Projektów PPP oraz projektów pakietowych opracowanie strategii negocjacyjnej jest również ważne. Określenie założeń i warunków wdrożenia Przedsięwzięcia przed rozpoczęciem Postępowania PPP powinno nastąpić bez względu na wartość planowanego Projektu PPP. Nieprawidłowe jest podejście, zgodnie z którym Podmiot Publiczny bazuje jedynie na bardzo ogólnych założeniach Projektu PPP i nie ustala

akceptowalnych granic jego realizacji. Taki sposób prowadzenia Negocjacji utrudnia istotnie rozmowy z Partnerami Prywatnymi i rzutuje negatywnie na jakość Dokumentacji Postępowania, wydłużając jednocześnie czas jej przygotowania. Brak sprecyzowanych problemów i zagadnień do omówienia oraz bierne oczekiwanie na aktywność Partnerów Prywatnych, skutkują także trudnościami w zrozumieniu podejścia Podmiotu Publicznego do Projektu PPP i powodować mogą liczne nieporozumienia związane ze sposobem i warunkami jego realizacji.

Dodatkowo, w przypadku projektów pakietowych należy pogodzić interesy, oczekiwania i potrzeby wszystkich uczestników pakietu biorących udział w Postępowaniu i tym bardziej wypracowanie wspólnej strategii jest istotne z punktu widzenia efektywności Negocjacji.

Należy zastrzec, że z uwagi na swój charakter i zakres, strategia negocjacyjna wykorzystywana jest na wewnętrzne potrzeby Podmiotu Publicznego w toku Postępowania (w szczególności na etapie Negocjacji) i nie powinna być udostępniana Partnerom Prywatnym ani osobom trzecim.

Z wyjątkiem podstawowych założeń Projektu PPP i ustalonych warunków brzegowych jego realizacji, planując strategię negocjacyjną należy uwzględnić możliwość jej zmiany. Modyfikacje strategii zależeć mogą przede wszystkim od przebiegu Negocjacji, uwzględniania niektórych propozycji Partnerów Prywatnych, pojawiania się nowych koncepcji lub rozwiązań określonych problemów lub zmiany podejścia Podmiotu Publicznego do zagadnień analizowanych w ramach Oceny Efektywności Projektu. Na zmianę strategii mogą mieć również wpływ określone zdarzenia zewnętrzne (np. zmiana przepisów prawa, nagle zmiana sytuacji społecznej lub gospodarczej, pojawienie się w otoczeniu Projektu PPP konkurencyjnych usług, zmiana składu Komisji Przetargowej, inna niż zakładana liczba Partnerów Prywatnych uczestniczących w Negocjacjach itp.).

PRZYKŁAD



Podmiot Publiczny w ramach przyjętej strategii negocjacyjnej zakładał, że wybrany Partner Prywatny realizował będzie usługi utrzymania wyłącznie w zakresie niezbędnym do zapewnienia technicznej sprawności Infrastruktury Publicznej. W toku Negocjacji wszyscy wykonawcy zadeklarowali chęć przejęcia usług związanych z bieżącą eksploatacją obiektu (w zakresie konserwacji sprzętu i urządzeń, sprzątnięcia, monitoringu i ochrony, pielęgnacji zieleni), proponując jednocześnie przejęcie od Podmiotu Publicznego pracowników zajmujących się tymi czynnościami. Zdaniem wykonawców, umożliwiłoby to stronie publicznej uzyskanie wyższej jakości usług, przy jednoczesnym zmniejszeniu ponoszonych dotychczas kosztów. Podmiot Publiczny dokonał zmiany w ramach strategii negocjacyjnej, dopuszczając takie rozwiązanie i rozszerzając tym samym zakres Przedsięwzięcia. Jednocześnie wymagało to od Podmiotu Publicznego dokonania dodatkowej analizy kosztów w celu potwierdzenia zdolności do ponoszenia wyższej Opłaty za Dostępność, a także dodatkowych ustaleń z Partnerami Prywatnymi, dotyczących zakresu obowiązków związanych z bieżącą eksploatacją obiektu oraz zasad przejęcia personelu.

Strategię negocjacyjną powinien opracować Podmiot Publiczny we współpracy z Doradcami (jeśli są zatrudnieni). Praca nad strategią może przybrać formę warsztatu, w trakcie którego omówione i ustalone zostaną poszczególne elementy merytoryczne strategii, jak również kwestie organizacyjne dotyczące prowadzenia Negocjacji.

3.4 Projekty pakietowe – grupowanie Projektów PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część II Punkt 1.3 – Wstępna ocena PPP jako modelu realizacji projektu

Tom I: Część II Punkt 3.4.1 – Analiza prawna możliwości realizacji zakładanego Projektu PPP

Tom IV: Część I Punkt 7 – Pakietowe Projekty PPP

W wielu przypadkach okazuje się, że planowany Projekt PPP jest zbyt mały, aby realizować go efektywnie w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Dotyczy to przede wszystkim inwestycji w obiekty kubaturowe (np. przedszkola, szkoły) opartych o Opłatę za Dostępność, o wartości nie przekraczającej w odniesieniu do pojedynczego projektu kilku milionów złotych. Koszty transakcyjne takich Przedsięwzięć oraz przewidywane koszty zaangażowania wykonawców na etapie eksploatacji obiektów są zwykle zbyt duże, aby formuła PPP mogła przynieść wymierne korzyści dla sektora publicznego. Z tego powodu znaczna część takich Projektów PPP nie znajduje zainteresowania rynku PPP.

Sposobem na realizację bardzo małych inwestycji w ramach PPP jest łączenie ich w jeden większy Projekt PPP. Uzyskany dzięki temu efekt skali może przełożyć się na efektywne wdrożenie Przedsięwzięcia. Takie Projekty PPP określa się mianem pakietowych.

PRZYKŁAD



Hipotetycznie - Gmina planuje budowę lokali komunalnych. Szacowana wartość inwestycji wynosi 5 mln PLN. Po przeprowadzonym rozpoznaniu rynku okazuje się, że żaden wykonawca nie jest zainteresowany zaprojektowaniem, budową, sfinansowaniem, utrzymaniem i zarządzaniem tak małym obiektem. Podmiot Publiczny w porozumieniu z gminami sąsiednimi postanowił przeprowadzić analizy dotyczące połączonych potrzeb w zakresie mieszkań komunalnych. Gmina inicjująca w imieniu pozostałych JST przeprowadziła analizy, które wykazały potencjał i pozytywne VfM takiego wspólnego Projektu PPP. Gminy postanowiły przeprowadzić wspólne Postępowanie, w wyniku którego Partner Prywatny zawarłby z każdą z gmin odrębną Umowę o PPP, dotyczącą lokali mieszkalnych w danej gminie. Powyższe podejście pozwoliło na zwiększenie potencjału rynkowego Projektu PPP, przy jednoczesnym zachowaniu niezależności każdej z gmin.

Pakietowanie Projektów PPP może m.in. polegać na tym, że jeden Podmiot Publiczny w celu zwiększenia skali Projektu PPP uwzględnia w nim kilka inwestycji (np. budowa i utrzymanie kilku szkół lub kompleksowa modernizacja energetyczna kilkunastu obiektów użyteczności publicznej). Realizacja takiego Projektu PPP nie powoduje istotnego utrudnienia z punktu widzenia formalnego czy organizacyjnego w zakresie przeprowadzenia Postępowania na wybór Partnera Prywatnego.

Bardziej skomplikowane są pakietowane Projekty PPP, w których po stronie publicznej zaangażowanych jest więcej niż jeden Podmiot Publiczny. W takich przypadkach możliwe są różne konfiguracje współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami po stronie publicznej, w tym prowadzące do zawarcia odrębnych Umów o PPP albo przyjmujących formę bardziej zorganizowaną, skutkującą podpisaniem jednej Umowy o PPP.

Analiza możliwych form organizacyjnych pakietowego Projektu PPP została przedstawiona w dokumencie "Analiza i rekomendacja struktury organizacyjno-prawnej pakietowego projektu PPP w sektorze dróg gminnych i powiatowych", dostępnym na stronie internetowej pod adresem: <https://www.ppp.gov.pl/analiza-struktury-organizacyjno-prawnej-pakietowego-ppp>. Dokument został przygotowany na potrzeby ww. sektora, jednakże zawiera rekomendacje, które mogą być wykorzystane w innych sektorach. Warto jednak pamiętać, że wybór odpowiedniej struktury organizacyjno-prawnej takiego Projektu PPP musi zostać dokonany po przeprowadzeniu szczegółowych analiz, jeszcze na etapie przygotowania Projektu PPP.

Nie w każdym przypadku pakietowanie Projektów PPP będzie jednak możliwe lub zasadne. Pakietowanie jest uzasadnione wówczas, gdy poza potrzebą zwiększenia skali Projektu PPP, istnieje pomiędzy nimi jakikolwiek wspólny mianownik, np. projekty powiązane wertykalnie (oczyszczalnia ścieków i sieć wodno-kanalizacyjna), projekty powiązane horyzontalnie (np. kilkanaście szkół) bliskość terytorialna (zarządzanie energią w różnych obiektach), wspólna polityka (tworzenie produktów turystycznych).

PRZYKŁAD



Jeżeli jednostki publiczne planowałyby realizację inwestycji w różnych sektorach (np. budowa drogi, szpitala, muzeum oraz zarządzanie oczyszczalnią ścieków) ich wspólna realizacja mogłaby okazać się wyjątkowo trudna, a Partnerzy Prywatni niekoniecznie wyraziliby chęć udziału w takim Postępowaniu.

Realizacja Małych Projektów drogowych wspólnie przez JST niesąsiadujące ze sobą, przez co te Projekty PPP nie tworzyłyby jednej sieci dróg może nie spotkać się z zainteresowaniem rynku. Z tego względu należy dążyć do możliwie spójnej wizji grupowych Projektów PPP i obejmować nią – w miarę możliwości – tożsame lub powiązane ze sobą zadania publiczne.

W poniższej tabeli wskazano podstawowe zalety i wady pakietowania Projektów PPP.

Tabela 5. Zalety i wady pakietowania Projektów PPP

Zalety pakietowania Projektów PPP	Wady pakietowania Projektów PPP
Uzyskanie efektu skali, dzięki któremu możliwe jest zainteresowanie Projektem PPP rynku Partnerów Prywatnych oraz Instytucji Finansujących.	Wydłużenie czasu koniecznego na przygotowanie Przedsięwzięcia i przeprowadzenie Postępowania (w tym m.in. powstanie struktury organizacyjno-prawnej po stronie publicznej, opracowanie Oceny Efektywności, dokonywanie bieżących uzgodnień w trakcie Negocjacji z uczestnikami po stronie publicznej itp.).

Zalety pakietowania Projektów PPP	Wady pakietowania Projektów PPP
Mniejsze koszty realizacji Przedsięwzięcia niż w przypadku pojedynczych inwestycji, w szczególności w zakresie kosztów finansowania i kosztów eksploatacyjnych.	Brak porozumienia pomiędzy jednostkami publicznymi uczestniczącymi w Postępowaniu co do niektórych warunków realizacji Projektu PPP, skutkujący odstąpieniem od Postępowania niektórych uczestników pakietu.
Ustandaryzowanie zakresu i warunków realizacji poszczególnych inwestycji wchodzących w skład Projektu PPP.	Trudności w uwzględnieniu specyficznych zagadnień lub problemów właściwych dla poszczególnych podmiotów po stronie publicznej, z uwagi na konieczność standaryzacji Umowy o PPP.
Tworzenie dobrych praktyk dla innych Projektów PPP pakietowych.	Bardziej złożony proces zarządzania Umową o PPP.

Pakietowanie Projektów PPP wymaga bardzo dobrej koordynacji działań i współpracy wszystkich jednostek publicznych oraz Doradcy. Z jednej strony mamy tu bowiem do czynienia z małymi inwestycjami, z drugiej jednak – może być ich kilka lub kilkanaście, a każdy taki "podprojekt" wymaga indywidualnego podejścia.

Procedura wyboru Partnera Prywatnego dla Projektów PPP pakietowych niewiele różni się od procedur standardowych, obejmujących tylko jeden Projekt PPP. Z uwagi na większą liczbę podmiotów po stronie publicznej wymaga jednak odpowiednio więcej działań organizacyjnych po tej stronie, gdyż w czynności związane z Postępowaniem zaangażowane będą najczęściej wszystkie podmioty uczestniczące w projekcie pakietowym.

To co natomiast jest istotne, to wybór odpowiedniej struktury organizacyjnej, dostosowanej do charakterystyki danego Projektu PPP. Wybór właściwej formy prawnej i odpowiedniej formuły rozliczeń pomiędzy jednostkami publicznymi uczestniczącymi w Projekcie PPP może decydować o jego powodzeniu. Umowna współpraca między jednostkami publicznymi (np. porozumienie administracyjne lub międzygminne) może mieć zastosowanie szczególnie w tych Projektach PPP, w których zakłada się zawarcie wielu Umów o PPP (pakietowanie wówczas występuje w zakresie procedury wyboru Partnera Prywatnego i ewentualnie koordynacji realizacji Umowy o PPP) lub też nie jest celowe zastosowanie formy zinstytucjonalizowanej (np. pakietowy Projekt PPP obejmujący kilka państwowych jednostek budżetowych). W takich przypadkach jeden z Podmiotów Publicznych powinien zostać wybrany jako pełnomocnik pozostałych Zamawiających i prowadzić Postępowanie PPP w imieniu i na rzecz wszystkich Podmiotów Publicznych tworzących projekt pakietowy. W przypadku Postępowania PZP podstawę prawną stanowi tu będzie przepis art. 38 Ustawy PZP, zgodnie z którym Zamawiający mogą wspólnie przygotować lub przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia, zawierając w tym celu stosowne porozumienie. Należy pamiętać, że za zgodność takiego Postępowania z przepisami Ustawy PZP wszyscy Zamawiający odpowiadają wspólnie. W przypadku Postępowania Koncesyjnych mogą zostać zastosowane podobne rozwiązania, pomimo że Ustawa o Umowie Koncesji nie przewiduje wprost możliwości wspólnego prowadzenia Postępowania przez wielu Zamawiających.

Natomiast w przypadku bardzo dużych Projektów PPP lub projektów o charakterze sieciowym (np. gospodarka odpadami), rekomenduje się rozważenie przyjęcia struktury organizacyjno-prawnej opartej na formach instytucjonalnych. Na szczególną uwagę zasługuje rozważenie

wykorzystania w tym celu formuły spółki komunalnej lub związku komunalnego, znanych Instytucjom Finansującym i wykorzystywanych przez JST przy realizacji projektów infrastrukturalnych realizowanych w formule tradycyjnej.

4. Ogłoszenie o zamówieniu oraz koncesji

4.1 Zakres ogłoszenia w Postępowaniu PPP

4.1.1 Postępowanie PZP

Celem ogłoszenia o zamówieniu jest umożliwienie dostępu do treści ogłoszenia wszystkim potencjalnym Partnerom Prywatnym oraz innym osobom zainteresowanym Postępowaniem (np. Instytucjom Finansującym, organom kontroli, podmiotom analizującym rynek PPP itp.).

W trybie Dialogu Konkurencyjnego Zamawiający przygotowuje ogłoszenia zgodnie z wzorami standardowych formularzy, określonymi w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającym rozporządzenie wykonawcze nr 842/2011. Po publikacji ogłoszenia w DUUE Zamawiający zamieszcza je także na swojej stronie internetowej oraz może je dodatkowo udostępnić w inny sposób. W przypadku Dialogu Konkurencyjnego Zamawiający sporządza także i udostępnia na stronie internetowej OPIW celem umożliwienia wykonawcom ustalenia potrzeb Zamawiającego dotyczących charakteru i zakresu zamówienia oraz wymagań formalnych i proceduralnych prowadzonego Postępowania.

Zamawiający może ograniczyć liczbę wykonawców zapraszanych do Dialogu Konkurencyjnego których wnioski nie podlegały odrzuceniu, o ile liczba ta jest wystarczająca, aby zapewnić konkurencję i nie jest mniejsza niż 3. W takiej sytuacji Zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w OPIW kryteria selekcji, które zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do dialogu, oraz podaje minimalną liczbę wykonawców, których zaprosi do tego dialogu. Zamawiający może także wskazać maksymalną liczbę wykonawców, których zaprosi do dialogu (art. 177 Ustawy PZP).

W Trybie Negocjacyjnym Podprogowym ogłoszenie o zamówieniu jest zamieszczane w BZP. Zamawiający wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem złożoności zamówienia oraz czasu potrzebnego na ich przygotowanie, z tym, że termin ten w przypadku dostaw i usług nie może być krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP, a w przypadku robót budowlanych nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP (art. 283 Ustawy PZP). Również i w tym przypadku Zamawiający może ograniczyć liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do Negocjacji oraz złożenia ofert ostatecznych, w liczbie nie mniejszej niż 3 (art. 288 Ustawy PZP).

W ogłoszeniu o zamówieniu należy zawrzeć informację, że Postępowanie ma na celu zawarcie Umowy o PPP (art. 5 ust. 2 Ustawy o PPP).

Po zamieszczeniu ogłoszenia w BZP albo opublikowaniu ogłoszenia w DUUE, obowiązkiem Podmiotu Publicznego jest również zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o planowanym PPP (art. 5 ust. 1 Ustawy o PPP). Stosownie do art. 16b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy o PPP, Podmiot Publiczny zobowiązany jest do przekazania ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego informacji o wszczęciu Postępowania, w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w DUUE albo zamieszczenia w BZP.

4.1.2 Postępowanie Koncesyjne

Celem ogłoszenia o koncesji – analogicznie jak w przypadku ogłoszenia o zamówieniu w ramach Ustawy PZP – jest umożliwienie zapoznania się z treścią tego ogłoszenia przez podmioty zainteresowane Postępowaniem.

Szczegółowy zakres treści ogłoszenia o koncesji został wskazany w art. 21 Ustawy o Umowie Koncesji, zgodnie z którym w ogłoszeniu tym Zamawiający zamieszcza: Opis Przedmiotu Umowy Koncesji, Kryteria Oceny Podmiotowej, opis Kryteriów Oceny Ofert oraz minimalne wymagania (o ile zostały określone).

Opis Przedmiotu Umowy Koncesji pozwala na wskazanie celu koncesji. Zamawiający może określić w nim wymagania związane z realizacją Umowy. Jednocześnie należy pamiętać, iż opis ten powinien stanowić podstawę, w oparciu o którą zostanie wypracowany (w toku Negocjacji) ostateczny zakres realizacyjny przedmiotu Projektu PPP.

Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu również tzw. minimalne wymagania (o ile zostały określone), które obejmują warunki i cechy charakterystyczne (w szczególności techniczne, fizyczne, funkcjonalne i prawne), które każdy z wykonawców powinien spełnić lub zapewnić. Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 29 ust. 2 Ustawy o Umowie Koncesji, Zamawiający nie może w trakcie Negocjacji zmieniać Kryteriów Oceny Ofert ani minimalnych wymagań.

Wzór ogłoszenia o koncesji określa – w zależności od miejsca publikacji ogłoszenia (DUUE albo BZP) - rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiające standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 oraz rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji.

Zamawiający przedstawia wykonawcom również opis Postępowania o zawarcie Umowy, w którym określa w szczególności: kryteria kwalifikacji; sposób komunikowania się z wykonawcami; warunki, którym mają odpowiadać wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu o zawarcie Umowy i oferta, pod rygorem ich odrzucenia; planowany termin zakończenia Postępowania.

Opis ten stanowi Dokument Koncesji i jako taki wraz z pozostałymi Dokumentami Koncesji udostępniany jest na stronie internetowej odpowiednio, od daty opublikowania ogłoszenia o koncesji. Ustawodawca nie wskazał celu, dla którego należy powielić w opisie Postępowania wskazane w ogłoszeniu kryteria kwalifikacji. Natomiast pozostałe informacje wskazane w otwartym katalogu określonym w art. 29 ust. 3 Ustawy o Umowie Koncesji mają za zadanie przybliżyć wykonawcom podstawowe kwestie w przedmiocie zasad wymiany informacji oraz dokumentów pomiędzy Zamawiającym i wykonawcami, wskazania formalno-prawnych wymogów odnośnie do wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu i oferty oraz zakładanego terminu zakończenia Postępowania.

Ponadto, jeżeli Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy o PPP, czyli na podstawie przepisów Ustawy o Umowie Koncesji, w ogłoszeniu należy zawrzeć informację, że Postępowanie ma na celu zawarcie Umowy o PPP (art. 5 ust. 2 Ustawy o PPP).

Po zamieszczeniu ogłoszenia w BZP albo opublikowaniu ogłoszenia w DUUE, obowiązkiem Podmiotu Publicznego jest również zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej informacji o planowanym PPP. Analogicznie jak w przypadku Postępowania PZP, jeśli Postępowanie Koncesyjne wszczynane jest w oparciu o art. 4 ust. 2 Ustawy o PPP, Podmiot Publiczny

zobowiązany jest do przekazania ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego informacji o wszczęciu Postępowania, w terminie 30 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w DUUE albo zamieszczenia w BZP (art. 16b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Ustawy o PPP).

4.1.3 Obowiązki związane z RODO

Należy zwrócić uwagę, że w Postępowaniu PPP dochodzi do przetwarzania danych osobowych, które podlegają ochronie w oparciu o przepisy RODO z uwzględnieniem regulacji krajowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Dane te dotyczyć mogą zarówno Partnerów Prywatnych będących osobami fizycznymi (prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą albo działalność w formie spółki cywilnej), ich pełnomocników (osób fizycznych), jak również informacji o osobach zawartych we wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, które Partner Prywatny przedstawia w celu wykazania spełniania warunków, braku podstaw do wykluczenia lub spełnienia innych wymogów Zamawiającego.

Sam Zamawiający przetwarza także dane osobowe członków Zespołu Projektowego, Komisji Przetargowej, biegłych i Zespołu Doradców oraz innych osób wykonujących czynności w Postępowaniu.

Co istotne, regulację RODO stosuje się, bez względu na tryb udzielania zamówienia, jego wartość i rodzaj.

Przepisy RODO mają zastosowanie również do Umów o PPP zawartych w wyniku przeprowadzenia Postępowania oraz całej dokumentacji zgromadzonej w związku z Postępowaniami PPP.

ŹRÓDŁA INFORMACJI



Podstawowe wskazówki oraz wzory klauzul i oświadczeń Zamawiających i wykonawców, które można zastosować również w Postępowaniach PPP, zawarte zostały w publikacji Urzędu Zamówień Publicznych pt. "Wskazówki dotyczące prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z uwzględnieniem regulacji RODO", dostępnej pod adresem: www.uzp.gov.pl

4.2 Opis Projektu PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część II Punkt 1.2 – Przygotowanie informacji o Projekcie PPP

4.2.1 Postępowanie PZP – Opis Potrzeb i Wymagań

Opis Potrzeb i Wymagań jest niezbędnym dokumentem, stanowiącym swoiste wprowadzenie do Postępowania PPP. Wobec braku precyzyjnego określenia przedmiotu zamówienia, OPIW spełnia rolę podstawowego dokumentu, za pomocą którego Zamawiający opisuje planowane Przedsięwzięcie.

Informacje o Projekcie PPP określone są już na etapie identyfikacji projektów, w ramach przygotowania Projektu PPP, stanowiąc punkt wyjścia do oceny czy dany projekt spełnia podstawowe kryteria Projektu PPP. Następnie informacje te są uszczegółowiane i, jeśli zajdzie taka potrzeba, zmieniane w toku Oceny Efektywności, aby w ostatecznym kształcie zostać uwzględnione w OPIW.

Zakres tego dokumentu (w odniesieniu do Dialogu Konkurencyjnego określony w art. 174 Ustawy PZP) powinien obejmować podstawowe informacje o Projekcie PPP, takie jak w szczególności:

- cel oraz opis wstępnego zakresu Projektu PPP;
- podstawę prawną oraz tryb wyboru Partnera Prywatnego;
- szacunkową wartość Umowy o PPP;
- wstępny podział ryzyk w ramach planowanego Przedsięwzięcia;
- planowany Mechanizm Wynagradzania Partnera Prywatnego;
- wymogi w zakresie wytworzenia i utrzymania lub zarządzania Infrastrukturą Publiczną;
- informację o posiadanych przez Zamawiającego Decyzjach Administracyjnych i innych dokumentach lub materiałach istotnych z punktu widzenia Postępowania.

Ponadto OPIW w przypadku Dialogu Konkurencyjnego powinien zawierać część informacji, które Ustawa PZP wymaga dla OPIW sporządzanego w trybie Negocjacji z ogłoszeniem (art. 156 ust. 1 Ustawy PZP). W przypadku Dialogu Konkurencyjnego są one ograniczone do elementów zawartych w art. 156 ust. 1 pkt 1-4, 9-16 i 19 Ustawy PZP. Co istotne zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt 10 Ustawy PZP Zamawiający ma obowiązek podać w OPIW informacje o podmiotowych środkach dowodowych oraz wskazać etapy Postępowania, na których będzie ich wymagać.

Zamawiający może załączyć Opis Potrzeb i Wymagań do ogłoszenia o zamówieniu, ale może również ograniczyć się do podania informacji o sposobie uzyskania opisu. W tym drugim przypadku Opis Potrzeb i Wymagań zostanie udostępniony wykonawcom w innej formie, np. na platformie elektronicznej lub w wersji papierowej, w szczególności, gdy opis zawiera dużą liczbę dokumentów o znacznej objętości.

Informacje zawarte w Opisie Potrzeb i Wymagań służą Partnerom Prywatnym do wstępnej analizy Przedsięwzięcia, weryfikacji jego założeń i potwierdzania dalszego zainteresowania Projektem PPP. W trakcie Dialogu Konkurencyjnego Opis Potrzeb i Wymagań stanowi punkt wyjścia do dyskusji nad proponowanymi rozwiązaniami.

W Trybie Negocjacyjnym Podprogowym zakres Opisu Potrzeb i Wymagań uregulowany został w przepisach art. 281 i 282 Ustawy PZP.

4.2.2 Postępowanie Koncesyjne – Opis Przedmiotu Umowy Koncesji

Informacje o Projekcie PPP określone są już na etapie identyfikacji Projektów PPP, w ramach przygotowania Projektu PPP, a następnie informacje te są uszczegółowiane i, jeśli zajdzie taka potrzeba, zmieniane w toku Oceny Efektywności, aby w ostatecznym kształcie zostać uwzględnione w OPUK.

Opis Przedmiotu Umowy Koncesji stanowi obligatoryjny element ogłoszenia o koncesji. Rolą powyższego dokumentu jest wskazanie wszystkich niezbędnych elementów planowanego Projektu PPP, w celu umożliwienia zapoznania się z Projektem PPP przez potencjalnych Partnerów Prywatnych i podjęcia decyzji o przystąpieniu do Postępowania. Ustawa o Umowie Koncesji

nie zawiera szczegółowych wytycznych w zakresie tworzenia opisu, przestając wyłącznie na sformułowaniu ogólnego zakazu opisywania przedmiotu koncesji poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, lub mogłyby prowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów (z zastrzeżeniem dopuszczenia odstępstw od zakazu poprzez określenie równoważności – art. 26 ust. 3 i 4 Ustawy o Umowie Koncesji).

Z uwagi na powyższe, w celu wskazania niezbędnych elementów OPUK, należy odwołać się do praktyki realizacji Projektów PPP w modelu koncesji. Biorąc pod uwagę charakter oraz rolę tego Dokumentu Koncesji, powinien on wskazywać w szczególności:

- cel oraz opis wstępnego zakresu Projektu PPP;
- podstawę prawną oraz tryb wyboru Partnera Prywatnego;
- szacunkową wartość Umowy;
- wstępny katalog obowiązków stron w zakresie realizacji przedmiotu koncesji;
- planowany Mechanizm Wynagradzania Partnera Prywatnego;
- wstępny podział ryzyk – przy założeniu, że ryzyko ekonomiczne związane z eksploatacją obiektu budowlanego lub wykonywaniem usług i obejmujące ryzyko związane z popytem lub podażą znajduje się po stronie Partnera Prywatnego;
- wymogi w zakresie wytworzenia lub eksploatacji i zarządzania Infrastrukturą Publiczną;
- informację o posiadanych przez Zamawiającego Decyzjach Administracyjnych i innych dokumentach lub materiałach istotnych z punktu widzenia Postępowania.

Dobłą praktyką może być łączenie OPUK z opisem Postępowania o zawarcie Umowy. Dzięki powyższemu zabiegowi potencjalni Partnerzy Prywatni dysponują jednolitym dokumentem, który obejmuje najważniejsze aspekty przedmiotu koncesji i stanowi materiał, który będzie podlegał uzupełnieniom w toku Negocjacji, aż do wypracowania ostatecznej treści Dokumentów Koncesji.

W tym miejscu należy wskazać na pewne ograniczenie w zakresie modyfikacji powyższych dokumentów – nie mogą one doprowadzić do zasadniczej zmiany przedmiotu koncesji. Granicę dopuszczalnych zmian w toku Negocjacji stanowią minimalne wymagania Zamawiającego (jeśli zostały określone) związane z przedmiotem koncesji, które to nie mogą ulec zmianie.

4.3 Kryteria Oceny Podmiotowej

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część II Punkt 3.1 – Analiza interesariuszy

Tom I: Część II Punkt 3.4 – Analizy prawne

Tom I: Część II Punkt 3.6 – Analizy rynkowe

Tom I: Część II Punkt 3.4.2 – Analiza sposobu oraz trybu wyboru Partnera Prywatnego

Tom II: Część II Punkt 1.12 – Podwykonawcy

4.3.1 Zagadnienia wspólne

Kryteria Oceny Podmiotowej, zarówno w Postępowaniu PZP, jak też Postępowaniu Koncesyjnym, służą dokonaniu wyboru Partnerów Prywatnych, z którymi prowadzone będą Negocjacje. Kryteria te dzielą się na trzy zasadnicze grupy:

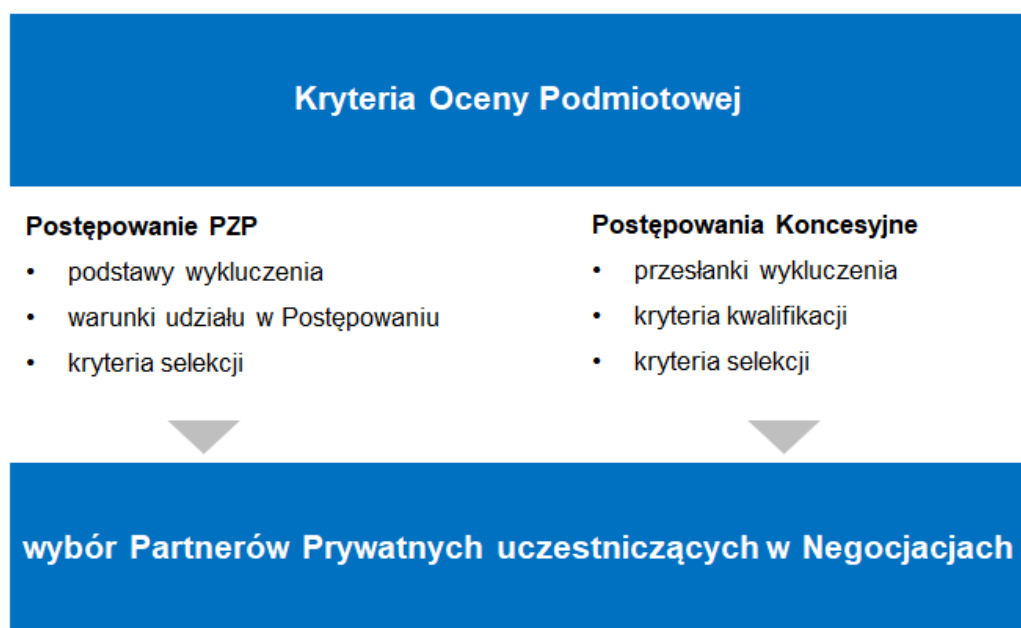
- podstawy/przesłanki wykluczenia, których zadaniem jest eliminacja z Postępowania takich wykonawców, którzy nie spełniają ustawowych przesłanek do uczestniczenia w Postępowaniu (np. jeżeli wobec wykonawcy orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne);
- warunki udziału w Postępowaniu/kryteria kwalifikacji, dotyczące m.in. zdolności technicznej i finansowej wykonawców, które Zamawiający określa biorąc pod uwagę zakres i przedmiot zamówienia;
- kryteria selekcji, służące ograniczeniu liczby wykonawców uczestniczących w Negocjacjach, jeżeli Zamawiający zdecydował się na ich wprowadzenie (co stanowi rekomendowaną praktykę w przypadku Postępowania PPP).

Kryteria Oceny Podmiotowej należy opracowywać łącznie z Kryteriami Oceny Ofert (szerzej na ten temat w Punkcie 4.5 Kryteria Oceny Ofert). Wspólnie stanowią one bowiem warunki oceny wykonawców na wszystkich etapach Postępowania PPP, dzięki którym Zamawiający powinien dążyć do rozpoczęcia Negocjacji z najlepszymi merytorycznie Partnerami Prywatnymi, a następnie dokonać wyboru oferty najlepiej zaspokajającej jego potrzeby.

Właściwe dobranie Kryteriów Oceny Podmiotowej zmierza do dokonania wyboru doświadczonych Partnerów Prywatnych, co ma bezpośredni wpływ na wykonalność i Bankowość Projektów PPP. W szczególności premiowane powinny być doświadczenia w zakresie utrzymania Infrastruktury Publicznej, ponieważ przychody w okresie utrzymania są źródłem spłaty finansowania.

Poniżej przedstawiono schemat Kryteriów Oceny Podmiotowej.

Schemat 5. Kryteria Oceny Podmiotowej



W celu uniknięcia trudności interpretacyjnych związanych z nieco odmienną terminologią dotyczącą ww. Kryteriów Oceny Podmiotowej w Ustawie PZP i Ustawie o Umowie Koncesji oraz uwypuklenia różnic w posługiwaniu się tymi kryteriami w stosowaniu obu aktów prawnych, w poniższych punktach przedstawiono zasady ustalania i ewaluacji Kryteriów Oceny Podmiotowej odrębnie dla Ustawy PZP i Ustawy o Umowie Koncesji.

UWAGA



Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 22 października 2024 roku w sprawie C-652/22 wskazał, że wykonawcy z państw trzecich (rozumianych jako państwa, które: (i) nie są państwami członkowskimi UE; (ii) nie są stroną Porozumienia w sprawie zamówień publicznych (GPA) oraz (iii) nie zawarły z Unią innej umowy międzynarodowej gwarantującej prawo do „nie mniej korzystnego traktowania” przysługujące wykonawcom z tych państw), nie mogą powoływać się na przepisy Dyrektywy Zamówieniowej (w tym przypadku dyrektywy 2014/25, tzw. dyrektywy sektorowej) i w ten sposób domagać się równego traktowania swoich ofert z ofertami złożonymi przez oferentów z państw członkowskich i oferentów z państw trzecich będących stroną GPA lub odpowiedniej umowy międzynarodowej z Unią. Trybunał w swoim wyroku stwierdził, iż: „dyrektywę 2014/25 należy rozumieć w ten sposób, że dostęp wykonawców ze wspomnianych państw trzecich do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w Unii nie jest zagwarantowany, a wykonawcy ci mogą zostać z nich wykluczeni”.

W wyroku tym Trybunał wskazuje, że sam fakt dopuszczenia przez podmiot zamawiający wykonawcy z państwa trzeciego do udziału w postępowaniu nie przyznaje takiemu wykonawcy prawa do powoływania się na przepisy dyrektywy w celu kwestionowania decyzji zamawiającego o udzieleniu zamówienia.

W konsekwencji powyższego wyroku Zamawiający powinien pamiętać, że choć może dopuścić do udziału w postępowaniu wykonawców z państw trzecich, nie są oni uprawnieni do korzystania z ochrony gwarantowanej przez przepisy Dyrektyw Zamówieniowych, a Zamawiający nie jest zobowiązany do równego traktowania takich wykonawców względem wykonawców z państw członkowskich UE lub państw będących stroną GPA albo stroną odpowiedniej umowy międzynarodowej z Unią, gwarantującej prawo do „nie mniej korzystnego traktowania” wykonawców. Wnosząc z ww. wyroku, Zamawiający uprawniony jest do wykluczenia wykonawców z takich państw trzecich z Postępowania, a wykonawcy tacy nie mają uprawnienia do kwestionowania tej decyzji na podstawie odpowiednich przepisów Dyrektyw Zamówieniowych.

ŹRÓDŁA INFORMACJI



Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 22 października 2024 r. w sprawie C-652/22 mającej za przedmiot wnioski o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Visoki upravni sud (apelacyjny sąd administracyjny, Chorwacja) postanowieniem z dnia 10 października 2022 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 18 października 2022 r., w postępowaniu Kolin Inšaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ przeciwko Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, przy udziale HŽ Infrastruktura d.o.o.,

Strabag AG, Strabag d.o.o., Strabag Rail a.s. (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62022CJ0652>)

4.3.2 Postępowanie PZP

4.3.2.1 Podstawy wykluczenia wykonawcy

W ramach weryfikacji wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający w pierwszej kolejności bada brak podstaw do wykluczenia z Postępowania.

Katalog podstaw wykluczenia został wskazany w art. 108 i 109 Ustawy PZP i ma charakter zamknięty. Ustawa PZP przewiduje dwie kategorie podstaw wykluczenia: obligatoryjne (określone w art. 108 – dotyczące m.in. popełnienia określonych czynów zabronionych przez wykonawcę lub osoby działające w jego imieniu) oraz fakultatywne (określone w art. 109 i obejmujące m.in. upadłość lub likwidację, poważne naruszenie obowiązków zawodowych itd.).

W razie wystąpienia którejkolwiek z przesłanek obligatoryjnych, Zamawiający ma – co do zasady – obowiązek wykluczenia danego wykonawcy z Postępowania (niezależnie od tego, czy przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu albo w SWZ).

Do decyzji Zamawiającego należy czy i które z przesłanek fakultatywnych zastosuje w danym Postępowaniu. Aby Zamawiający był uprawniony do wykluczenia wykonawcy na podstawie przesłanki fakultatywnej, jest zobowiązany do określenia katalogu tych przesłanek w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ. W takim przypadku, w razie wystąpienia którejś z przesłanek fakultatywnych w trakcie Postępowania, Zamawiający będzie zobowiązany do wykluczenia wykonawcy.

W ślad za Dyrektywami Zamówieniowymi, przepisy Ustawy PZP przewidują instytucję samooczyszczenia wykonawcy (tzw. *self-cleaning*), która umożliwia wykonawcom wykazanie, że pomimo wystąpienia przesłanki wykluczenia, podjęte zostały środki niezbędne do wykazania jego rzetelności i tym samym, brak jest podstawy wykluczenia.

Ustawa podaje w art. 110 ust. 2 przykładowe środki organizacyjne i kadrowe służące samooczyszczeniu, takie jak zerwanie wszelkich powiązań z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy, zreorganizowanie personelu, wdrożenie systemu sprawozdawczości i kontroli, utworzenie struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów, a także wprowadzenie wewnętrznych regulacji dotyczących odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów. *Self-cleaning* obejmuje następujące przesłanki wykluczenia określone w art. 108 i 109 Ustawy PZP:

- wykluczenie z powodu skazania za przestępstwo (art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy PZP);
- zawarcie porozumienia ograniczającego konkurencję (art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP);
- fakultatywne przesłanki wykluczenia określone w art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 Ustawy PZP.

Katalog dokumentów umożliwiających Zamawiającemu weryfikację przesłanek wykluczenia został określony w Rozporządzeniu w sprawie Dokumentów (§ 2).

Na kolejnych stronach przedstawiono katalog obligatoryjnych podstaw wykluczenia oraz omówiono dokumenty umożliwiające weryfikację braku podstaw wykluczenia.

W praktyce, z uwagi na to, iż Postępowania PPP mają na celu wyłonienie Partnera Prywatnego zapewniającego należyłą realizację zamówienia, z którym dojdzie do wieloletniej współpracy, Zamawiający powinni rozważyć uwzględnienie fakultatywnych podstaw wykluczenia.

Tabela 6. Obligatoryjne podstawy wykluczenia wykonawcy

Przesłanki obligatoryjne - z postępowania wyklucza się wykonawcę (art. 108 Ustawy PZP):	Self- cleaning	Dokument zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie Dokumentów
Ust. 1 pkt 1 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za: • sfinansowanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym; • handel ludźmi; • sprzedajność; • przekupstwo; • płatną protekcję; • nakłanianie do głosowania; • udział w zorganizowanej grupie przestępczej lub związku przestępczym; • faworyzowanie wierzycieli, łapownictwo; • przyjęcie lub udzielenie korzyści majątkowej lub osobistej; • przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; • przestępstwo skarbowe; • przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu; • przestępstwo oszustwa w celu uzyskania korzyści majątkowej; • przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;	tak	<i>informacja z Krajowego Rejestru Karnego (§ 2 ust. 1 pkt 1)</i>

- przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

Ust. 1 pkt 2

jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

tak

*informacja z Krajowego Rejestru Karnego
(§ 2 ust. 1 pkt 1)*

Ust. 1 pkt. 3

wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

nie

*oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego
(§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. a)*

Ust. 1 pkt 4

wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

nie

*informacja z Krajowego Rejestru Karnego
(§ 2 ust. 1 pkt 1)*

*oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne
(§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. b)*

Ust. 1 pkt 5

jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

tak

oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
(§ 2 ust. 1 pkt 2)

oświadczenie wykonawcy odnośnie (nie) zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji
(§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. c)

Ust. 1 pkt 6

jeżeli doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

nie

oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego
(§ 2 pkt 7 d)

Ust. 2

w przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty dla robót budowlanych – 20000000 euro, a dla dostaw lub usług – 10000000 euro, wyklucza się wykonawcę, który udaremnia lub utrudnia stwierdzenie przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywa ich pochodzenie, w związku z brakiem możliwości ustalenia beneficjenta rzeczywistego, w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115, 1520, 1655 i 1798).

nie

informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru (§ 2 ust. 1 pkt 3)

Poniżej przedstawiono katalog fakultatywnych przesłanek wykluczenia oraz omówiono dokumenty umożliwiające weryfikację braku podstaw wykluczenia.

Tabela 7. Fakultatywne podstawy wykluczenia

Przesłanki fakultatywne --

z postępowania Zamawiający może wykluczyć wykonawcę (art. 109 ust. 1 Ustawy PZP):

Self-cleaning

Dokument zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie Dokumentów

Pkt 1

który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

nie

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat (§ 2 ust. 1 pkt 4)

zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (§ 2 ust. 1 pkt 5)

Przesłanki fakultatywne --

z postępowania Zamawiający może wykluczyć wykonawcę (art. 109 ust. 1 Ustawy PZP):

	Self-cleaning	Dokument zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie Dokumentów
		<i>oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) (§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. e)</i>
Pkt 2 lit. a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;	tak	<i>informacja z Krajowego Rejestru Karnego (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. c)</i>
Pkt 2 lit. b) będącego osobą fizyczną prawomocnie skazanego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny;	tak	<i>informacja z Krajowego Rejestru Karnego (§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. d)</i> <i>oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu odnośnie do skazania za wykroczenie, za które wymierzone karę ograniczenia wolności lub karę grzywny (§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. f)</i>
Pkt. 2 lit. c)	tak	<i>oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału</i>

Przesłanki fakultatywne --

z postępowania Zamawiający może wykluczyć wykonawcę (art. 109 ust. 1 Ustawy PZP):

**Self-
cleaning**

**Dokument zgodnie z Rozporządzeniem
w sprawie Dokumentów**

wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;

*w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego
(§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. g)*

Pkt. 3

jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub wykroczenie, o którym mowa w pkt. 2 lit. a lub b;

tak

*informacja z Krajowego Rejestru Karnego
(§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. e)
oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu odnośnie do skazania
za wykroczenie, za które wymierzone karę
ograniczenia wolności lub karę grzywny
(§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. h)*

Pkt. 4

w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

tak

*odpis lub informacja z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
(§ 2 ust. 1 pkt 6)*

Przesłanki fakultatywne --

z postępowania Zamawiający może wykluczyć wykonawcę (art. 109 ust. 1 Ustawy PZP):

	Self-cleaning	Dokument zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie Dokumentów
Pkt. 5 który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;	tak	oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego (§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. i)
Pkt. 6 jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;	nie	oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego (§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. i)
Pkt. 7 który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;	tak	oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego (§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. i)

Przesłanki fakultatywne --

z postępowania Zamawiający może wykluczyć wykonawcę (art. 109 ust. 1 Ustawy PZP):

	Self-cleaning	Dokument zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie Dokumentów
Pkt. 8 który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;	tak	oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego (§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. i)
Pkt. 9 który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;	tak	oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego (§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. i)
Pkt. 10 który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.	tak	oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego (§ 2 ust. 1 pkt 7 lit. i)

W przypadku postępowań o wartości niższej niż Progi Unijne, Zamawiający nie ma obowiązku żądania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia (art. 273 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP). W związku z tym § 3 Rozporządzenia w sprawie Dokumentów przewiduje regulację, która umożliwia Zamawiającemu żądanie ogólnego oświadczenia o braku podstaw wykluczenia, które zastępuje podmiotowe środki dowodowe ujęte w katalogu zawartym w § 2 Rozporządzenia w sprawie Dokumentów.

DOBRE PRAKTYKI



Podmiotowe środki dowodowe

Za dobrą praktykę należy uznać żądanie przez Zamawiającego od Partnerów Prywatnych podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w §2 Rozporządzenia w sprawie Dokumentów. Z uwagi na kompleksowy charakter Projektów PPP i długotrwałą relację stron Umowy o PPP pożądane jest bowiem, aby Partner Prywatny legitymował się kompletem dowodów świadczącym o braku podstaw wykluczenia z Postępowania, a nie poprzestawał jedynie na złożeniu oświadczenia w tym zakresie.

Należy podkreślić, że w związku z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 r., do systemu zamówień publicznych dodana została nowa podstawa wykluczenia wykonawców. Stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

- 1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593, z późn. zm.7) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120 i 295) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.

Ponadto na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), od dnia 9 kwietnia 2022 r. obowiązuje zakaz udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych,

a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- 1) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
- 2) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
- 3) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

4.3.2.2 Warunki udziału w Postępowaniu

Określenie warunków udziału w Postępowaniu to jedna z kluczowych czynności podejmowanych przez Zamawiającego, która ma bezpośredni wpływ na krąg wykonawców, mogących ubiegać się o udzielenie zamówienia, zawężając go w mniejszym albo większym stopniu. Odmienne od podstaw wykluczenia, warunki udziału w Postępowaniu Zamawiający może kształtować samodzielnie w granicach określonych w art. 112 ust. 1 Ustawy PZP. Niezwykle ważne jest zatem sformułowanie warunków w sposób nienaruszający zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a przede wszystkim w sposób zgodny z przepisami art. 112-117 Ustawy PZP i jednocześnie umożliwiający wyłonienie Partnera Prywatnego dającego rękojmię należytego wykonania Przedsięwzięcia. Trzeba pamiętać, że celem Postępowania nie jest przeprowadzenie procedury i wybór wykonawcy sam w sobie, ale dokonanie wyboru takiego wykonawcy, który w sposób optymalny będzie w stanie zrealizować potrzeby Podmiotu Publicznego. Pomimo że generalną zasadą jest, iż stawiane wykonawcom wymogi muszą być proporcjonalne (a tym samym nie mogą one być nadmierne), przyjmuje się, że w niektórych, szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być one postawione na wysokim poziomie - zbliżonym, czy niekiedy nawet tożsamym z zakresem ujętym w opisie przedmiotu zamówienia (por. szerzej np. wyrok KIO z 8 kwietnia 2015 r. (KIO 579/15)). Takie podejście wskazane jest szczególnie przy większych lub bardziej skomplikowanych Projektach PPP.

Podmiot Publiczny, formułując warunki udziału w Postępowaniu, zmuszony jest zatem do poszukania "złotego środka", który z jednej strony zapewni konkurencyjność procedury, z drugiej jednak ograniczy możliwość udziału w Postępowaniu podmiotom niedoświadczonym i niedającym gwarancji powodzenia Przedsięwzięcia. Z tego powodu zalecić można w szczególności przeprowadzenie pogłębionego badania doświadczenia wykonawców na etapie testów rynkowych. Dlatego też najczęściej w ramach analiz prowadzonych na potrzeby Oceny Efektywności proponuje się wstępne Kryteria Oceny Podmiotowej, albowiem ustalenie adekwatnych i proporcjonalnych Kryteriów Ewaluacji często wymaga wiedzy o rynku Partnerów Prywatnych. W celu zapewnienia proporcjonalności oraz adekwatności Kryteriów Oceny Podmiotowej należy rekomendować, ażeby były one wypracowywane przez Doradcę prawnego we współpracy z Doradcą technicznym oraz Doradcą finansowym. Podmiot Publiczny, nawet już po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu, może rozważyć zmianę warunków udziału w Postępowaniu (por. Punkt 4.7.1 Postępowanie PZP).

Warunki udziału w Postępowaniu, stosownie do art. 112 ust. 2 Ustawy PZP, mogą dotyczyć:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
- zdolności technicznej lub zawodowej.

Należy zauważyć, że jeśli Zamawiający nie ma potrzeby badania zdolności wykonawców do należytego wykonania zamówienia pod kątem któregośkolwiek z ww. aspektów, nie jest on zobowiązany do określenia żadnych warunków w tym zakresie, poprzestając jedynie na weryfikacji przesłanek wykluczenia.

W praktyce, Zamawiający najczęściej formułują jednak warunki udziału w Postępowaniu w odniesieniu do niektórych z elementów potencjału wykonawców. Istotne jest również, żeby warunki takie zostały określone w sposób niebudzący wątpliwości. Uznaje się, że, jeśli możliwe są różne metody ich odczytania lub rozumienia, czy też jednoznacznie nie wskazano jak odbywać się będzie ocena poziomu ich spełniania, to należy wybrać ten sposób interpretacji, który jest korzystniejszy dla wykonawcy (szerzej zob. np. wyrok KIO z 14 marca 2014 r. (KIO 395/14), wyrok KIO z dnia 18 maja 2017 r. (KIO 938/17), wyrok SN z dnia 4 lipca 2019 r. (IV CSK 363/18)).

Warunki udziału w Postępowaniu muszą zostać ustalone w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiające ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia (art. 112 ust. 1 Ustawy PZP).

Podkreślenia wymaga, że warunki udziału w Postępowaniu wykonawca może spełnić samodzielnie, wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) lub wykonawca posługujący się potencjałem innego podmiotu.

W przypadku Postępowań PPP, których celem jest wieloletnia współpraca pomiędzy stronami, prawidłowe określenie warunków udziału w Postępowaniu jest niezwykle ważne, aby zapewnić wybór Partnera Prywatnego, który będzie w stanie wspólnie z Podmiotem Publicznym realizować Przedsięwzięcie przy uwzględnieniu wszelkich ustalonych przez strony ryzyk.

Specyfika Postępowań PPP wymaga, aby nie ograniczać się jedynie do wymagania doświadczenia wykonawców w projektowaniu czy budowie określonej Infrastruktury Publicznej. Podmioty Publiczne powinny wymagać bowiem doświadczenia adekwatnego do rodzaju planowanego Przedsięwzięcia, obejmującego zwykle nie tylko projektowanie, budowę, lecz również finansowanie, utrzymanie lub zarządzanie planowaną Infrastrukturą Publiczną. Niezwykle ważne jest zatem, aby oprócz typowych warunków dotyczących budowy, Zamawiający oczekiwał doświadczenia niezbędnego na etapie eksploatacyjnym. W przeciwnym razie do Postępowania mogą zgłosić się podmioty o niewystarczających kompetencjach w tym zakresie.

DOBRE PRAKTYKI



Warunki udziału w Postępowaniu

W ramach Postępowań PPP na podstawie Ustawy PZP, dobrą praktyką będzie ustanowienie warunku udziału w Postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej, wykazania się realizacją w przeszłości podobnych robót budowlanych oraz usług, jak też dysponowania odpowiednim potencjałem osobowym, gwarantującym należytą realizację zamówienia.

Jeśli zatem przedmiotem Przedsięwzięcia będzie np. zaprojektowanie i budowa obiektu kubaturowego oraz utrzymanie nowopowstałej Infrastruktury Publicznej, warunki udziału w Postępowaniu powinny zostać ustalone na poziomie umożliwiającym wyłonienie Partnera Prywatnego zdolnego nie tylko do wybudowania wymaganego przez Zamawiającego budynku, ale także do utrzymania Infrastruktury Publicznej.

W przypadku Projektów, w których zadaniem Partnera Prywatnego jest zarządzanie i eksploatacja Infrastruktury Publicznej (np. oczyszczalni ścieków, parkingu podziemnego, krytej pływalni), jednym z warunków udziału w Postępowaniu musi być również doświadczenie wykonawcy w realizacji tego typu usług.

Zamawiający formułując w ogłoszeniu warunki udziału w Postępowaniu (a także kryteria selekcji lub fakultatywne podstawy wykluczenia), powinien również określić wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie tych warunków (lub kryteriów selekcji, jeżeli są one ustalone oraz braku podstaw wykluczenia). Dokumenty, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, okres ich ważności oraz formy, w jakich te dokumenty mogą być składane określa Rozporządzenie w sprawie Dokumentów.

Poniżej omówiono poszczególne warunki udziału w Postępowaniu oraz określono dokumenty, jakich może żądać od wykonawcy Zamawiający na potwierdzenie ich spełniania.

1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej

Warunek ten może zostać ustanowiony jedynie w sytuacji, gdy odrębne przepisy nakładają obowiązek uzyskania określonych uprawnień (art. 114 Ustawy PZP). Pod pojęciem uprawnień należy rozumieć w szczególności koncesje, zezwolenia, licencje czy działalność regulowaną.

W niektórych Projektach PPP konieczne może okazać się wymaganie od wykonawców potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności. W praktyce chodzi o to, aby – w przypadku, gdy dana działalność stanowi jeden z podstawowych obowiązków Partnera Prywatnego w ramach planowanego Projektu PPP – wykonawca potwierdził nie tylko doświadczenie, ale też posiadanie wymaganych uprawnień. Należy jednak zastrzec, że nie w każdym przypadku, gdy w ramach Projektu PPP prowadzona będzie jakakolwiek działalność wymagająca takich uprawnień, Podmiot Publiczny zobowiązany jest do żądania ich wykazania na etapie ogłoszenia o zamówieniu.

Nie należy również wymagać uprawnień, które nie dają podstaw do prowadzenia działalności w ramach Przedsięwzięcia, a które będą wymagane dopiero na etapie realizacji.

PRZYKŁAD



W Postępowaniu PPP, którego przedmiotem jest budowa i eksploatacja oczyszczalni ścieków oraz systemu wodno-kanalizacyjnego, główna działalność Partnera Prywatnego polegała będzie na zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków na terenie całej gminy.

Zamawiający nie powinien wymagać od Partnera Prywatnego zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, albowiem zezwolenie takie będzie dopiero pozyskiwane na późniejszym etapie.

Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, Zamawiający może żądać od wykonawcy następujących dokumentów:

Warunek	Dokumenty, jakich może żądać Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie Dokumentów*
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów	Koncesje, zezwolenia, licencje lub dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest wpisany do rejestru działalności regulowanej. W przypadku zamówienia na usługi: 1) odpowiednie zezwolenia, licencje, koncesje lub potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; 2) dokument potwierdzający status członka danej organizacji, jeżeli członkostwo w tej organizacji jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

* Zamawiający może żądać złożenia tych dokumentów na potwierdzenie spełniania odpowiednich kryteriów selekcji, o ile są ustalone.

Wymaganie określonych zezwoleń czy uprawnień jest zasadne w przypadku, gdy mają one charakter uniwersalny i dają podstawy do wykonywania określonej działalności na potrzeby różnych Projektów PPP.

PRZYKŁAD



W postępowaniu PPP, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, budowa, finansowanie i późniejsze utrzymanie obiektu muzeum, jednym z istotnych zadań Partnera Prywatnego będzie zapewnienie całodobowej ochrony obiektu i znajdujących się w nim, cennych zbiorów muzealnych.

O ile zatem Zamawiający wymagał będzie doświadczenia Partnera Prywatnego w tym zakresie, może przykładowo sformułować następujący warunek udziału w Postępowaniu:

"W Postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu określone przez Zamawiającego, tj.: dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada koncesję na ochronę osób i mienia, wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przed dniem opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej".

2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Zasady dotyczące ustalania warunków udziału w Postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej określa art. 115 Ustawy PZP. Celem weryfikowania tych warunków jest potwierdzenie zdolności wykonawców do wykonania przedmiotu zamówienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i sfinansowania go do czasu dokonania płatności przez Zamawiającego (chyba, że Mechanizm Wynagradzania przewiduje Opłaty od Użytkowników lub inne formy wynagrodzenia Partnera Prywatnego). Może to mieć istotne znaczenie w szczególności w odniesieniu do Postępowań PPP, gdzie wartość Przedsięwzięcia jest wysoka, a Partner Prywatny zobowiązuje się do zapewnienia finansowania robót budowlanych (bez względu na Mechanizm Wynagradzania Partnera Prywatnego, zacznie on uzyskiwać wynagrodzenie zazwyczaj dopiero po oddaniu obiektu do użytkowania).

Sytuacja ekonomiczna odnosi się do zespołu wskaźników odzwierciedlających kondycję ekonomiczną wykonawcy (por. np. wyrok KIO z 22.05.2015 r. (KIO 952/15)). Ma służyć zabezpieczeniu realizacji zamówienia w aspekcie finansowym oraz potwierdzać, że kondycja ekonomiczna wykonawcy we wcześniejszych okresach uprawdopodobnia realizację tego postulatu. Z kolei sytuacja finansowa odnosi się do wykazania, że wykonawca jest w stanie dysponować środkami finansowymi (własnymi lub pochodzącymi z innych źródeł) lub zdolnością kredytową w wysokości wymaganej do realizacji zamówienia, tj. związanej z wartością szacowanych nakładów inwestycyjnych planowanego Przedsięwzięcia, choć poziom ten może być również niższy. To do oceny Zamawiającego należy ustalenie, czy ustanawiając warunek zdolności finansowej na niższym poziomie, wykonawcy zaproszeni do udziału w Negocjacjach będą w stanie rzeczywiście zrealizować Przedsięwzięcie. Konstruując ten warunek udziału w Postępowaniach PPP, Podmiot Publiczny powinien zatem uwzględnić w szczególności okoliczności konkretnego Postępowania i jego przedmiotu - charakteru zadania, czasu jego trwania, konieczności finansowania poszczególnych kosztów i nakładów związanych z jego wykonaniem, a także ryzyk towarzyszących realizacji Projektu PPP.

W odniesieniu do warunków udziału w Postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej Zamawiający może wymagać w szczególności:

- 1) aby wykonawcy posiadali określone minimalne roczne przychody, w tym określone minimalne roczne przychody w zakresie działalności objętej zamówieniem;
- 2) aby wykonawcy przedstawili informacje na temat ich rocznych sprawozdań finansowych wykazujących w szczególności stosunek aktywów do zobowiązań;
- 3) posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;
- 4) posiadania przez wykonawcę określonej zdolności kredytowej lub środków finansowych.

Zamawiający nie może wymagać, aby minimalne roczne przychody, o których mowa w pkt 1, przekraczały dwukrotność wartości zamówienia, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków

odnoszących się do przedmiotu zamówienia lub sposobu jego realizacji. Zamawiający wskazuje w dokumentach zamówienia powody zastosowania takiego wymagania.

Stosunek aktywów do zobowiązań, o którym mowa w pkt 2, może być uwzględniony, jeżeli Zamawiający określi w dokumentach zamówienia przejrzyste i obiektywne metody i kryteria takiego uwzględnienia.

W Projektach PPP Partner Prywatny tworzy z reguły Spółkę Projektową, a spłata finansowania oparta jest o przepływy pieniężne z Projektu PPP i na nich, co do zasady, jest zabezpieczona. Tym samym w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i finansowej Spółka Projektowa zwykle będzie korzystała z potencjału spółek z grupy kapitałowej lub innych podmiotów trzecich. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 7a ust. 4 Ustawy o PPP w takim przypadku Partner Prywatny odpowiada solidarnie ze Spółką Projektową, za szkodę wyrządzoną Podmiotowi Publicznemu wskutek nieudostępnienia Spółce Projektowej zasobów, które wskazał w ofercie, chyba że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy. Ponadto, należy zauważyć, że Ustawa o PPP nie przewiduje solidarnej odpowiedzialności Partnera Prywatnego i Spółki Projektowej za należyte wykonanie Umowy o PPP. Zagadnienie to może stanowić przedmiot Dialogu Konkurencyjnego i zostać uregulowane w Umowie o PPP. W praktyce w projektach typu *project finance* trudno jednak wymagać dodatkowych gwarancji lub zabezpieczeń od Partnera Prywatnego, które zostałyby ustanowione na rzecz Podmiotu Publicznego.

Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający może żądać od wykonawcy następujących dokumentów:

Dokumenty jakich może żądać Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie Dokumentów (§ 8 Rozporządzenia w sprawie Dokumentów)* **

Warunek

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez firmę audytorską zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające w szczególności przychody oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Oświadczenie wykonawcy o rocznym przychodzie wykonawcy lub o przychodzie wykonawcy w obszarze objętym zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

Dokumenty jakich może żądać Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie Dokumentów (§ 8 Rozporządzenia w sprawie Dokumentów)* **

Warunek

Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

** Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej (por. § 8 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie Dokumentów)*

*** Zamawiający może żądać złożenia tych dokumentów na potwierdzenie spełniania odpowiednich kryteriów selekcji, o ile są ustalone*

PRZYKŁAD



W Postępowaniu PPP przedmiotem jest zaprojektowanie, budowa i późniejsze utrzymanie obiektu kubaturowego o szacowanej wartości przedmiotu zamówienia ok. 100 mln zł. Na kwotę 100 mln zł składają się: wartość nakładów inwestycyjnych (50 mln zł), koszty finansowania (25 mln zł) i koszty utrzymania (25 mln zł), Zamawiający nie musi żądać od wykonawców legitymowania się zdolnością finansową na pełne 100 mln zł; wystarczy, że odniesie się do oszacowanej wartości nakładów inwestycyjnych.

W podanym przykładzie można sformułować następujący warunek udziału w Postępowaniu dotyczący zdolności finansowej lub ekonomicznej: "W Postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, tj.: dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe i/lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 000 000 zł lub w wysokości równoważnej dla walut obcych. W przypadku wskazania przez wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału lub kryteriów selekcji, waluty innej niż polska (PLN), aby dokonać jej przeliczenia stosowany będzie: średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota".

Należy pamiętać, że na szacowaną wartość Przedsięwzięcia w ramach PPP składają się nie tylko nakłady na inwestycję (roboty budowlane), ale również koszty finansowania i nakłady na utrzymanie/eksploatację Infrastruktury Publicznej.

UWAGA



W praktyce Postępowania PPP potwierdzenie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Partnerów Prywatnych może okazać się problematyczne. Mianowicie, wykazanie tego warunku na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu – z uwagi na czas trwania Postępowania – nie musi oznaczać, że wykonawca będzie zdolny do sfinansowania robót budowlanych już po zawarciu Umowy o PPP. Dlatego na etapie składania ofert Podmioty Publiczne żądają czasem złożenia przez Partnerów Prywatnych niewiążących lub wiążących warunków finansowania. Niemniej, realnemu udowodnieniu zdolności do zapewnienia finansowania Przedsięwzięcia służy Zamknięcie Finansowe. W pewnych przypadkach Zamknięcie Komercyjne i Zamknięcie Finansowe dokonywane są w tym samym momencie.

3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową wykonawcy, Zamawiający może postawić minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia (którego posiadanie będzie gwarantowało prawidłową realizację zamówienia), potencjału technicznego wykonawcy (np. wymagany sprzęt lub różnego rodzaju urządzenia, niezbędne zaplecze techniczne) lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (art. 116 Ustawy PZP). Zamawiający powinien tak je sformułować, aby ich spełnienie gwarantowało, że wykonawca jest zdolny zrealizować zamówienie na odpowiednim poziomie jakości.

Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej mogą więc być formułowane w stosunku do wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w zależności od potrzeb Zamawiającego oraz rodzaju i charakteru zamówienia. Jak była już o tym mowa, specyfika Projektów PPP nakazuje wymagać od wykonawców zdolności zarówno do zaprojektowania i wybudowania obiektu, jak też zapewnienia jego prawidłowej eksploatacji. Dotyczy to zarówno wykonawców, jak też osób, które zamierza skierować do realizacji Projektu PPP.

Na potwierdzenie spełniania tego warunku udziału w Postępowaniu, Zamawiający może żądać od wykonawcy następujących dokumentów:

Dokumenty jakich może żądać Zamawiający zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie Dokumentów (§ 9 Rozporządzenia w sprawie Dokumentów)*

Warunek

Zdolność techniczna lub zawodowa

- 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty**.

- 2) Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy
** ***.
-
- 3) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
-
- 4) Opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych stosowanych przez wykonawcę w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy.
-
- 5) Wykaz systemów zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego.
-
- 6) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych wykonawcy, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości, z których wykonawca będzie korzystać - w przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje produkty lub usługi o złożonym charakterze lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu.
-
- 7) Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.
-

-
- 8) Wykaz środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego.
-
- 9) Oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
-
- 10) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
-
- 11) W przypadku dostarczania produktów:
- próbki, opisy lub fotografie dostarczanych produktów, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 - zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
-
- 12) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez wykonawcę określonych norm zarządzania jakością, w tym dostępności dla osób niepełnosprawnych, jeżeli zamawiający odwołuje się do systemów zarządzania jakością opartych na odpowiednich seriach norm europejskich oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki.
-
- 13) Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełnienia przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego, jeżeli zamawiający odwołuje się do systemu ek zarządzania i audytu, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ek zarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającym rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), lub do innych norm zarządzania środowiskowego opartych na odpowiednich normach europejskich lub międzynarodowych oraz certyfikowanych przez akredytowane jednostki.
-

* Zamawiający może żądać złożenia tych dokumentów na potwierdzenie spełniania odpowiednich kryteriów selekcji, o ile są ustalone.

** Zgodnie z § 9 ust. 4 Rozporządzenia w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający może dopuścić, aby wykaz:

1. robót, dotyczył robót budowlanych wykonanych w okresie dłuższym niż ostatnie 5 lat;

2. dostaw lub usług, dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata.

*** Wykaz dostaw lub usług jest dokumentem wskazanym w Rozporządzeniu w sprawie Dokumentów, jednak w praktyce w Postępowaniach PPP wykaz dostaw nie jest zazwyczaj wymagany przez Podmiot Publiczny, ponieważ ich przedmiotem są zazwyczaj roboty budowlane lub usługi, a ewentualne dostawy stanowią mały procent zakresu zamówienia.

Wskazane w tabeli okresy ostatnich lat lub miesięcy co do zasady liczone będą wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu. Jedynie w szczególnych wypadkach wskazanych w § 9 ust. 2 pkt 2-3 Rozporządzenia w sprawie Dokumentów punkt odniesienia będzie stanowił inny moment (dotyczy to np. zmiany Partnera Prywatnego w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości itp.).

Poniżej przedstawiono przykłady warunków udziału w Postępowaniu uwzględniających specyfikę Projektów PPP: pierwszy dotyczy budynku użyteczności publicznej, a drugi samorządowego projektu drogowego.

Przykłady obejmują konieczność dysponowania przez wykonawcę osobą pełniącą funkcję kierownika projektu, posiadającą doświadczenie przy przygotowaniu lub zarządzaniu Projektami PPP. Osoba taka jest niezbędna w zespole Partnera Prywatnego, albowiem Projekty PPP wymagają wiedzy i doświadczenia w zarządzaniu takimi projektami.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Postępowaniu PPP, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, budowa i utrzymanie obiektu ratusza miejskiego (ok. 45 000 m³) o szacowanej wartości zamówienia ok. 150 mln zł, w tym 50 mln zł nakładów inwestycyjnych, można sformułować następujące warunki udziału w Postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

"Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

/dot. doświadczenia wykonawcy/

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku o całkowitej wartości inwestycji co najmniej (rekomenduje się ustalić kwotę podobną lub nieznacznie mniejszą od wartości nakładów w planowanym projekcie np. 30-50 mln zł brutto) oraz o kubaturze co najmniej 15 000 m³. Poprzez wykonanie w sposób należyty roboty budowlanej Zamawiający rozumie konieczność zakończenia wszystkich prac budowlanych, zakończonych odbiorem robót budowlanych oraz uzyskaniem dla budynku pozwolenia na użytkowanie. Przez "budynek" - należy rozumieć (zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;*
- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną usługę, która polegała na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku użyteczności publicznej, o kubaturze budynku nie mniejszej niż 15 000 m³, na podstawie, której wydane zostało pozwolenie na budowę. Przez "budynek użyteczności publicznej" - należy rozumieć budynek użyteczności publicznej*

zdefiniowany w § 3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, przez okres co najmniej 12 miesięcy następujących po sobie, co najmniej jedną usługę polegającą na zapewnieniu utrzymania obiektu o kubaturze co najmniej 30 000 m³ (budynku użyteczności publicznej).

Przez utrzymanie Zamawiający rozumie wypełnianie standardów utrzymania Infrastruktury Publicznej oraz zapewnianiu dostępności w zakresie co najmniej:

- utrzymania technicznego (jak np. malowanie ścian, konserwacja klimatyzacji i wentylacji, wykonywanie planowanych remontów, konserwacja dźwigów osobowych);
- utrzymania czystości wewnątrz obiektu (mycia okien, podłóg, usuwania odpadów z pomieszczeń, uzupełniania środków czystości i higienicznych w toaletach itp.) i na zewnątrz obiektu (usuwanie odpadów z ciągów komunikacyjnych czy terenów zieleni);
- utrzymania zieleni (koszenie trawy, pielęgnacja zieleni ozdobnej);
- utrzymania elementów wyposażenia (jak np. mebli, białego montażu w toaletach wraz z ich planową wymianą);
- administrowania Infrastrukturą Publiczną, prowadzenia kontroli okresowych w celu raportowania ewentualnych uchybień w zakresie standardów utrzymania, zarządzania i zasad dostępności czy przeprowadzania kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego wynikających z przepisów prawa.

/dot. dysponowania odpowiednim potencjałem osobowym/

Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) co najmniej:

- osobą pełniącą rolę głównego projektanta posiadającą:
 - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
 - co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień, o których mowa w punkcie a.; oraz
 - doświadczenie w zakresie wykonywania w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania wniosków co najmniej 2 dokumentacji projektowych przy zamówieniach obejmujących zaprojektowanie budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 30 mln zł brutto każda.
- osobą pełniącą rolę kierownika budowy, posiadającą:
 - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
 - co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową; oraz
 - doświadczenie w kierowaniu budową przy realizacji w ostatnich pięciu latach przed upływem składania wniosków co najmniej jednego zamówienia obejmującego

wykonanie budynku użyteczności publicznej o wartości zamówienia nie mniejszej niż 30 mln zł brutto.

- *kierownikiem projektu posiadającym doświadczenie po stronie prywatnej zdobytym na stanowisku kierowniczym w ciągu ostatnich 10 lat, w przygotowaniu lub zarządzaniu Projektem PPP o wartości całkowitej wynagrodzenia Partnera Prywatnego lub o wartości całkowitych kosztów co najmniej 30 mln zł brutto, w ramach którego została zawarta Umowa o PPP, obejmująca zrealizowanie robót budowlanych oraz utrzymywanie i zarządzanie składnikiem majątku przez okres co najmniej 10 lat oraz zostało pozyskane finansowanie".*

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Postępowaniu PPP, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, budowa i utrzymanie 200 km dróg krajowych o szacowanej wartości zamówienia ok. 1 mld zł, w tym 400 mln zł nakładów inwestycyjnych, można sformułować następujące warunki udziału w Postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

"Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

/dot. potencjału finansowego wykonawcy/

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 200 mln zł.

/dot. doświadczenia wykonawcy/

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

- co najmniej 2 inwestycje obejmujące wykonanie przebudów lub budów drogi klasy min. G (w rozumieniu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych), przy czym każda z nich o długości co najmniej 40 km i o wartości co najmniej 80 mln zł brutto (równowartość w walutach obcych wg średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia);
- co najmniej 5 inwestycji obejmujących budowę obiektów mostowych o długości co najmniej 20 m każdy;
- co najmniej 1 inwestycję obejmującą budowę mostu drogowego o długości co najmniej 150 m;
- co najmniej 1 usługę polegającą na utrzymaniu lub utrzymywaniu dróg klasy min. G przez okres nie krótszy niż 2 lata, o wartości wynagrodzenia za usługę nie mniejszej niż 1 mln zł brutto; oraz
- co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej składającej się z projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy lub budowy drogi klasy min. G o długości co najmniej 10 km.

/dot. dysponowania odpowiednim potencjałem osobowym/

Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) co najmniej:

- osobą pełniącą rolę głównego projektanta drogowego posiadającą:
 - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
 - co najmniej siedmioletnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień, o których mowa w tirecie powyżej; oraz
 - doświadczenie w zakresie wykonywania w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania wniosków co najmniej 2 dokumentacji projektowych przy zamówieniach obejmujących zaprojektowanie i wykonanie (system "Projektuj i Buduj") drogi klasy min. G o wartości nie mniejszej niż 100 mln zł brutto każda.
- osobą pełniącą rolę głównego projektanta mostowego posiadającą:
 - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania mostów lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
 - co najmniej siedmioletnie doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień, o których mowa w punkcie a.; oraz
 - doświadczenie w zakresie wykonywania w ostatnich pięciu latach przed upływem składania wniosków co najmniej 2 dokumentacji projektowych przy zamówieniach obejmujących zaprojektowanie i wykonanie (tzw. system "Projektuj i Buduj") dwóch obiektów mostowych o obciążeniu dla klasy a i o rozpiętości teoretycznej przęsła co najmniej 50 m każdy, na stanowisku projektanta.
- osobą pełniącą rolę kierownika budowy, posiadającą:
 - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi; w specjalności drogowej lub inne odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
 - co najmniej siedmioletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową; oraz
 - doświadczenie w kierowaniu budową przy realizacji w ostatnich pięciu latach przed upływem składania wniosków co najmniej jednego zamówienia obejmującego zaprojektowanie i wykonanie (tzw. system "Projektuj i Buduj") drogi klasy min. G o wartości zamówienia nie mniejszej niż 100 mln zł brutto.
- kierownikiem projektu posiadającym doświadczenie po stronie prywatnej zdobyte na stanowisku kierowniczym w ciągu ostatnich 10 lat, w przygotowaniu lub zarządzaniu Projektem PPP o wartości całkowitej wynagrodzenia lub o wartości całkowitych kosztów co najmniej 100 mln zł brutto, w ramach którego została zawarta Umowa o PPP, obejmująca zrealizowanie robót budowlanych oraz utrzymywanie i zarządzanie składnikiem majątku przez okres co najmniej 10 lat oraz zostało pozyskane finansowanie".

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku Postępowania o wartości poniżej Progów Unijnych, Zamawiający nie ma w ogóle obowiązku wprowadzania warunków udziału w Postępowaniu.

W przypadku Projektów PPP, z uwagi na ich kompleksowy i długotrwały charakter, trudno jednak wyobrazić sobie sytuację, w której Podmiot Publiczny odstępuje od sformułowania takich warunków.

4.3.2.3 Kryteria selekcji

Postępowania PPP na podstawie Ustawy PZP odbywają się najczęściej w trybie Dialogu Konkurencyjnego (ewentualnie – w Trybie Negocyjnym Podprogowym), który jest postępowaniem dwustopniowym. Pomimo że teoretycznie można sobie wyobrazić sytuację, w której Podmiot Publiczny dopuszcza do udziału w Postępowaniu wszystkich wykonawców, którzy spełnią warunki udziału, to jednak w praktyce działanie takie prowadziłoby do paraliżu Postępowania. Trudno bowiem przyjąć za racjonalne prowadzenie Negocjacji np. z 10 podmiotami. Organizacja Postępowania powinna przewidywać zatem jego racjonalną konkurencyjność.

W ramach postępowań negocyjnych dwustopniowych możliwe jest ograniczenie liczby potencjalnych wykonawców, którzy zostaną dopuszczeni do udziału w Postępowaniu, a w efekcie - do składania ofert.

W przypadku stosowania przez Zamawiającego w ramach danego Postępowania kryteriów selekcji, jest on zobowiązany do wskazania w ogłoszeniu o zamówieniu jaką liczbę wykonawców dopuści do udziału w kolejnym etapie Postępowania oraz określenia kryteriów, na podstawie których dojdzie do selekcji tych kandydatów i stworzenia tzw. krótkiej listy. W wyniku selekcji dochodzi więc do wyłonienia stosunkowo wąskiego grona podmiotów, które (np. ze względu na posiadane doświadczenie lub ekspercką wiedzę) są najlepiej przygotowane do realizacji zamówienia. Minimalna liczba podmiotów dopuszczonych do udziału w Postępowaniu powinna obejmować 3 wykonawców (art. 177 ust. 1 i art. 288 ust. 1 Ustawy PZP).

Warto dodać, że jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu jest mniejsza niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprasza do Dialogu Konkurencyjnego wszystkich wykonawców spełniających te warunki, ale może również w takim przypadku unieważnić Postępowanie z uwagi na brak zakładanej konkurencji (por. art. 178 ust. 3 i art. 289 ust. 4 Ustawy PZP).

DOBRE PRAKTYKI



Liczba Partnerów Prywatnych zapraszanych do Negocjacji

W przypadku Dużych Projektów za dobrą praktykę należy uznać zapraszanie do Negocjacji pięciu Partnerów Prywatnych. Taka liczba pozwala na efektywne planowanie harmonogramu i zarządzanie Postępowaniem, a jednocześnie nie ogranicza w zbyt dużym stopniu konkurencji.

Praktyka pokazuje, że Podmioty Publiczne chętnie korzystają z proponowanego przez PZP rozwiązania zapraszania 3 podmiotów. Rodzi to jednak ryzyko ograniczenia konkurencji. Zdarza się, że w toku Negocjacji z różnych przyczyn, w tym niewynikających z samego Projektu PPP, Partnerzy Prywatni mogą stracić zainteresowanie Projektem PPP albo propozycje wypracowane w toku Negocjacji nie dla wszystkich są jednakowo atrakcyjne. Stąd ograniczenie liczby Partnerów Prywatnych uczestniczących w Negocjacjach do trzech wydaje się nieść ze sobą zbyt duże ryzyko ograniczonej liczby lub braku ofert.

Większa liczba wykonawców dopuszczonych do Negocjacji (np. 10) mogłaby z kolei spowodować zmniejszenie zainteresowania Projektem PPP, z uwagi na niechęć

do "inwestowania" środków w pokrycie kosztów udziału w Negocjacjach, w którym uczestniczy tak wiele podmiotów. Co więcej, zarządzanie takim procesem z punktu widzenia efektywności Postępowania jest zadaniem niezwykle trudnym, dlatego też rekomenduje się zapraszanie do udziału w Negocjacjach pięciu wykonawców, co powinno zapewnić właściwy poziom konkurencyjności i nie oddziaływać negatywnie na efektywność prowadzonego Postępowania.

Istotną wskazówką odnośnie do liczby wykonawców zapraszanych do udziału w Postępowaniu powinny być również wnioski ze wstępnych konsultacji rynkowych, które również stanowią narzędzie do określenia popytu na Projekt PPP.

PRZYKŁAD



Hipotetycznie - Podmiot Publiczny w ogłoszeniu o zamówieniu przewidział, że do udziału w Negocjacjach dopuszczeni zostaną trzej Partnerzy Prywatni, którzy spełnią warunki udziału w Postępowaniu (i określone kryteria selekcji, jeżeli liczba wykonawców będzie większa). W Postępowaniu złożony został jeden wniosek spełniający warunki. Podmiot Publiczny, na podstawie np. 258 Ustawy PZP może unieważnić Postępowanie. Czynność taka powinna być jednak poprzedzona rzetelną analizą rynku potencjalnych Partnerów Prywatnych. Może się bowiem okazać, że z określonych przyczyn (nawet pomimo pozytywnych wyników testów rynkowych) zainteresowanie Projektem PPP jest niewielkie, w związku z czym unieważnienie Postępowania skutkować będzie brakiem realizacji Projektu PPP. Z drugiej strony, przeprowadzona analiza rynku może doprowadzić do odmiennych konkluzji, np. takich, że przyjęte Kryteria Oceny Podmiotowej były zdecydowanie zbyt wygórowane i niemożliwe do spełnienia przez większość zainteresowanych wykonawców. W takiej sytuacji Zamawiający powinien dokonać zmiany Kryteriów Oceny Podmiotowej.

W ramach kryteriów selekcji Zamawiający może ustalić dodatkowe kryteria, które umożliwią kwalifikację wykonawców wówczas, gdy uzyskana przez kilku wykonawców punktacja jest identyczna. Takimi kryteriami mogą być np. dodatkowa zdolność techniczna lub zawodowa. Z uwagi na specyfikę Projektów PPP należy rozważyć premiowanie doświadczenia Partnerów Prywatnych w zakresie usług utrzymania lub zarządzania (w zależności od zakresu konkretnego Projektu PPP).

W ogłoszeniu Zamawiający powinien określić metodę, zgodnie z którą będzie przyznawać punkty za każde dodatkowo wykazane (ponad podstawowe wymogi kwalifikujące do udziału w Postępowaniu), premiując, np.:

- doświadczenie w wykonaniu określonej roboty budowlanej o danej wartości;
- doświadczenie w wykonaniu usługi polegającą na zapewnieniu utrzymania lub dostępności o danej wartości;
- wykazanie doświadczenia wykraczającego poza minimalne wymogi określone w treści ogłoszenia, a ponadto za każdy zrealizowany lub realizowany Projekt PPP (adekwatny), w ramach którego: (i) została zawarta Umowa o PPP obejmująca zrealizowanie robót budowlanych oraz utrzymywanie lub zarządzanie składnikiem majątku przez okres co najmniej 12 miesięcy oraz (ii) zostało pozyskane finansowanie.

Doświadczenie w zakresie utrzymania lub realizowania Projektów PPP powinno być premiowane, albowiem trudność Projektu PPP polega na pozyskaniu finansowania i zarządzaniu Projektem PPP, a nie na samym wykonaniu robót, co jest względnie powszechne.

DOBRE PRAKTYKI



Kryteria selekcji

Zaleca się zastosowanie co najmniej dwóch kryteriów selekcji. Dzięki temu można wyeliminować sytuację, gdy w wyniku zastosowania jedynego kryterium selekcji dwa podmioty albo większa liczba podmiotów uzyska tę samą liczbę punktów. Przyjmuje się bowiem, że liczba wykonawców, jaką Zamawiający zaprosi do Negocjacji, odnosi się do liczby pozycji przewidzianych do zaproszenia niezależnie od tego, ilu wykonawców (którzy uzyskali taką samą liczbę punktów) ją zajmuje (zob. np. wyrok KIO 1724/11, wyrok KIO z dnia 16 sierpnia 2017 r. (KIO 1518/17)).

PRZYKŁAD



W Postępowaniu PPP, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, budowa i późniejsze utrzymanie obiektu kubaturowego o kubaturze ok. 45 000 m³ i o szacowanej wartości zamówienia ok. 100 mln zł (w tym szacowanej wartości nakładów inwestycyjnych ok. 50 mln zł), można sformułować następujące kryteria selekcji:

- 1) *"Zamawiający zaprosi do udziału w Postępowaniu 5 wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu będzie mniejsza niż 5, Zamawiający zaprosi do udziału w Postępowaniu wszystkich wykonawców spełniających te warunki bez przeprowadzania kwalifikacji punktowej wniosków, z zastrzeżeniem możliwości unieważnienia Postępowania na podstawie art. 258 Ustawy PZP.*
- 2) *Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu będzie większa niż 5, wówczas Zamawiający zaprosi do dialogu 5 wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów, obliczonych w sposób określony poniżej:*

2.1) Zamawiający przyzna po 1 punkcie za wykonanie przez wykonawcę w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej każdej dodatkowej roboty budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegającej na budowie budynku użyteczności publicznej o całkowitej wartości inwestycji co najmniej 50 000 000,00 PLN brutto oraz o kubaturze co najmniej 30 000 m³. Poprzez wykonanie w sposób należyty roboty budowlanej Zamawiający rozumie konieczność zakończenia wszystkich prac budowlanych, zakończonych odbiorem robót budowlanych oraz uzyskaniem dla budynku pozwolenia na użytkowanie.

Zamawiający, dokonując powyższej punktacji, nie będzie brał pod uwagę robót, które służyły wykonawcy do wykazania warunku udziału w Postępowaniu. Przez "budynek użyteczności publicznej" – należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby

administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

2.2) W przypadku, gdy w wyniku zastosowania wskazanego powyżej kryterium dwa bądź większa liczba podmiotów uzyska tę samą punktację, o kolejności wniosków decydować będzie liczba usług utrzymania obiektu. Zamawiający przyzna po 1 punkcie za wykonanie przez wykonawcę w sposób należyty każdej dodatkowej usługi utrzymania technicznego budynku użyteczności publicznej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Przez utrzymanie Zamawiający rozumie wypełnianie standardów utrzymania Infrastruktury Publicznej oraz zapewnianiu dostępności w zakresie co najmniej:

- utrzymania technicznego (jak np. malowanie ścian, konserwacja klimatyzacji i wentylacji, wykonywanie planowanych remontów, konserwacja dźwigów osobowych);
- utrzymania czystości wewnątrz obiektu (mycia okien, podłóg, usuwania odpadów z pomieszczeń, uzupełniania środków czystości i higienicznych w toaletach itp.) i na zewnątrz obiektu (usuwanie odpadów z ciągów komunikacyjnych czy terenów zieleni);
- utrzymania zieleni (koszenie trawy, pielęgnacja zieleni ozdobnej);
- utrzymania elementów wyposażenia (jak np. mebli, białego montażu w toaletach wraz z ich planową wymianą);
- administrowania Infrastrukturą Publiczną, prowadzenia kontroli okresowych w celu raportowania ewentualnych uchybień w zakresie standardów utrzymania, zarządzania i zasad dostępności oraz przeprowadzania kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego wynikających z przepisów prawa".

W przypadku, gdy po dokonanej selekcji, na ostatnim miejscu kwalifikującym wykonawców do dalszego udziału w Postępowaniu znajdzie się więcej niż 1 (jeden) wykonawca, Zamawiający zakwalifikuje do udziału w Postępowaniu wszystkich wykonawców, którzy znajdą się na tym miejscu.

UWAGA



Stosowanie kryterium selekcji w postaci dodatkowej zdolności technicznej lub finansowej, może w niektórych przypadkach prowadzić do dyskryminacji Partnerów Prywatnych. Dotyczy to sytuacji, gdy wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu składa Spółka Projektowa, co stanowi częstą praktykę w Postępowaniach PPP. Aby zapewnić konkurencyjność Postępowania, Podmiot Publiczny powinien przewidzieć, aby na potrzeby oceny kryteriów

selekcji dopuszczalne było poleganie przez Spółki Projektowe na dodatkowej zdolności podmiotów trzecich.

W tym celu w treści ogłoszenia należy zamieścić wyjaśnienie, że dopuszczone jest poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków (wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13 września 2013 r., sygn.: XIX Ga 461/12, wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2015 r., sygn.: XII Ga 108/15, wyrok KIO z dnia 7 maja 2018 r., sygn. akt: KIO 736/18 oraz KIO 699/18, pismo UZP z dnia 14 lutego 2018 r., wyrok KIO z dnia 27 lutego 2020 r., sygn. akt: KIO 299/20).

Ponadto możliwe jest również skorzystanie przez Partnera Prywatnego z art. 7a Ustawy o PPP, który dopuszcza, aby Umowę o PPP zawarł nie Partner Prywatny, który uczestniczył w Postępowaniu, a powołana przez niego Spółka Projektowa. W takim przypadku ważne jest, aby Podmiot Publiczny pamiętał o zamieszczeniu w Dokumentacji Postępowania wyraźnej zgody na zawarcie i wykonanie Umowy o PPP przez Spółkę Projektową oraz o określeniu warunków takiej zgody w ogłoszeniu o zamówieniu lub Opisie Potrzeb i Wymagań.

4.3.3 Postępowanie Koncesyjne

4.3.3.1 Przesłanki wykluczenia wykonawcy

Ustawa o Umowie Koncesji, podobnie jak Ustawa PZP, dzieli przesłanki wykluczenia na obligatoryjne (art. 32 ust. 1) i fakultatywne (art. 32 ust. 2), z zastrzeżeniem, że przesłanki obligatoryjne dotyczą wyłącznie Zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a Ustawy PZP (pozostali Zamawiający mogą, lecz nie muszą ich przewidzieć w ogłoszeniu o koncesji). Nie jest to jedyne podobieństwo – w zakresie katalogu przesłanek wykluczenia wykonawcy z Postępowania Ustawa o Umowie Koncesji w zasadzie powtarza uregulowania Ustawy PZP. Wprowadzono również możliwość udowodnienia przez wykonawcę, że dokonał tzw. "*self-cleaningu*", a więc usunął skutki ewentualnych naruszeń, które teoretycznie obligowałyby Zamawiającego do podjęcia decyzji o jego wykluczeniu. Biorąc pod uwagę, że przesłanki wykluczenia określone w art. 32 ust. 1 i 2 są niemalże tożsame z przesłankami określonymi przepisami Ustawy PZP, aktualne pozostają wskazówki zawarte w Punkcie 4.3.2.1 Podstawy wykluczenia wykonawcy.

Zasadniczą różnicą jest natomiast brak wymogu stosowania wprost przepisów Rozporządzenia w sprawie Dokumentów – tak jak ma to miejsce w przypadku Ustawy PZP – w zakresie określenia katalogu dokumentów umożliwiających Zamawiającemu weryfikację przesłanek wykluczenia określonych w Rozporządzeniu w sprawie Dokumentów. Powyższe nie oznacza jednak, że Zamawiający nie może żądać złożenia przez wykonawcę dokumentów na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu, określonych odpowiednio z wykorzystaniem ww. przepisów.

Zgodnie z Ustawą o Umowie Koncesji Zamawiający powinien przewidzieć podstawy wykluczenia w ogłoszeniu o koncesji. Istotnym dopełnieniem powyższego obowiązku jest sformułowany w art. 35 Ustawy o Umowie Koncesji obowiązek określenia przez Zamawiającego w treści ogłoszenia o koncesji zasad, zgodnie z którymi wykonawca będzie miał obowiązek złożyć oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, jak również zasad, zgodnie z którymi Zamawiający może żądać od wykonawców przedłożenia dokumentów potwierdzających brak przesłanek wykluczenia. Formułując w ogłoszeniu o koncesji katalog przesłanek wykluczenia, Zamawiający

powinien mieć na względzie, że sprecyzowany przez niego zakres dokumentów oraz sposób ich przedłożenia nie mogą mieć charakteru dyskryminacyjnego i muszą pozostawać proporcjonalne do przedmiotu Umowy, służąc wyłącznie wykazaniu braku przesłanek wykluczenia po stronie wykonawcy. Nieprecyzyjne wskazanie katalogu dokumentów potwierdzających brak przesłanek wykluczenia oraz nieokreślenie zasad ich składania, może uniemożliwić zweryfikowanie przez Zamawiającego czy sformułowane przez niego przesłanki wykluczenia znajdują zastosowanie do wykonawców ubiegających się o zawarcie Umowy.

Należy pamiętać, iż zgodnie z dyspozycją art. 32 ust. 7 Ustawy o Umowie Koncesji – analogicznie do regulacji Ustawy PZP - Zamawiający jest uprawniony do wykluczenia wykonawcy na każdym etapie Postępowania, jeżeli okaże się, że zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia.

4.3.3.2 Kryteria kwalifikacji

Kryteria kwalifikacji oznaczają warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, które musi spełnić wykonawca, żeby uzyskać możliwość udziału w Postępowaniu o zawarcie Umowy. Ich odpowiednikiem w przepisach Ustawy PZP są warunki udziału w Postępowaniu.

Należy wskazać, iż wymagające kryteria kwalifikacji umożliwią zaproszenie do Negocjacji tych podmiotów, które wykazą się najwyższą zdolnością do wykonania przedmiotu koncesji.

Podobnie jak w przypadku Postępowania PZP, wykonawcy, w celu wykazania spełnienia kryteriów kwalifikacji, mogą opierać się na zasobach osób trzecich. W takim wypadku rekomendowane jest, aby takie zasoby podlegały ocenie na równi z zasobami własnymi wykonawców.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 Ustawy o Umowie Koncesji, Zamawiający może określić kryteria kwalifikacji dotyczące:

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
- zdolności technicznej lub zawodowej.

Powyższe kryteria zostały określone w sposób ogólny, pozwalając Zamawiającemu na ich konkretyzację w danym Postępowaniu tak, aby umożliwić przyjęcie zindywidualizowanych kryteriów niezbędnych do wyłonienia najlepszych wykonawców, zdolnych do wykonania określonego przedmiotu Umowy.

Zastosowane kryteria kwalifikacji powinny być:

- związane z przedmiotem Umowy;
- proporcjonalne do tego przedmiotu;
- zapewniać rzeczywistą konkurencję;
- umożliwiać Zamawiającemu zweryfikowanie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy, niezbędnej do wykonania Umowy.

Praktyka realizacji Projektów PPP w modelu koncesyjnym wskazuje na odpowiednie stosowanie przepisów Ustawy PZP przy konstrukcji kryteriów kwalifikacji oraz postanowień Rozporządzenia w sprawie Dokumentów – przy wskazywaniu dokumentów składanych na potwierdzenie spełniania tychże kryteriów.

Wśród kryteriów dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej można wskazać na dysponowanie środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w określonej wysokości.

Z kolei wśród kryteriów dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej wyróżnia się wymagania dotyczące wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez niego do realizacji Umowy. Zakres wymaganych dokumentów, składanych przez wykonawcę na potwierdzenie spełniania kryteriów kwalifikacji, może zostać określony przez Zamawiającego w dowolny sposób, jednakże rekomenduje się wskazanie w Dokumentach Koncesji - odpowiednich dokumentów zaczerpniętych wprost z katalogu określonego w Rozporządzeniu o Dokumentach.

PRZYKŁAD



W Postępowaniu na wybór operatora obiektu kubaturowego, o powierzchni 5000 m², którego zadaniem będzie świadczenie usług w zakresie zarządzania (bieżącej eksploatacji) i utrzymania technicznej sprawności obiektu (naprawy, konserwacje, remonty), którego koszty związane z zarządzaniem i utrzymaniem wynoszą ok. 2 mln zł rocznie, można sformułować następujące kryteria kwalifikacji:

"Kryteria dotyczące sytuacji finansowej lub ekonomicznej

Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1.000.000,00 zł lub w wysokości równoważnej dla walut obcych, liczonej według średniego kursu w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień, w którym ukazało się ogłoszenie.

Kryteria dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zarządzał lub zarządza, w ciągu 12 następujących po sobie miesięcy działalności, co najmniej 1 obiektem o łącznej powierzchni min. 3000 m², przy czym minimum połowę powierzchni obiektu stanowiła powierzchnia biurowa i konferencyjna. Przez zarządzanie Zamawiający rozumie świadczenie usług w zakresie bieżącej eksploatacji i utrzymania technicznej sprawności obiektu (naprawy, konserwacje, remonty), a tym samym podejmowanie wszelkich działań zmierzających do utrzymania obiektu w stanie niepogorszonym oraz gwarantujące jego przydatność do osiągnięcia określonych celów.

Na potwierdzenie spełnienia ww. kryteriów kwalifikacji można wskazać na obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu następujących dokumentów (wskazanych w ogłoszeniu o koncesji):

- na potwierdzenie kryterium dotyczącego sytuacji finansowej lub ekonomicznej - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu;*
- na potwierdzenie kryterium dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - wykazu usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, powierzchni obiektu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem*

dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu".

Należy zwrócić uwagę, że szczególnie w Postępowaniach Koncesyjnych, w których Mechanizm Wynagradzania przewiduje Opłaty od Użytkowników, kryteria kwalifikacji w zakresie zdolności technicznej, a zatem doświadczenia wykonawcy, mogą być szczególnie istotne dla dokonania wyboru Partnerów Prywatnych zapewniających merytoryczny wkład w Negocjacje i gwarantujących wysoki poziom realizacji usług publicznych. Przykładowo, należą do nich:

- w przypadku koncesji na usługi zarządzania dużą halą widowiskowo-sportową – obowiązek wykazania, że wykonawca posiada doświadczenie w organizacji imprez sportowych o zasięgu międzynarodowym lub imprez masowych;
- w przypadku koncesji na świadczenie usług transportu zbiorowego – odpowiednio długi (np. minimum 3-letni) okres świadczenia takich usług przez wykonawcę;
- w przypadku koncesji na zarządzanie basenem – doświadczenie w kompleksowym zarządzaniu takim obiektem, obejmujące nie tylko zdolność do bieżącego utrzymania technicznego obiektu, ale również praktykę w zakresie obsługi Użytkowników, zapewniania ratowników, sprzątnia itp.

Wymogi Zamawiającego w zakresie kryteriów kwalifikacji nie powinny być jednak przesadnie wysokie. Ustaleniu Partnerów Prywatnych uczestniczących w Negocjacjach służą przede wszystkim kryteria selekcji, omówione w kolejnym punkcie.

4.3.3.3 Kryteria selekcji

Uprawnienie Zamawiającego do ograniczenia liczby wykonawców, z którymi prowadzić będzie Negocjacje, zostało sformułowane w art. 29 ust. 5 Ustawy o Umowie Koncesji. Zgodnie z tym przepisem Zamawiający może wprowadzić element selekcji wykonawców, określając kryteria dodatkowe lub dodatkowo punktowane. Ograniczenie liczby wykonawców może nastąpić wyłącznie w oparciu o obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, co należy rozumieć w ten sposób, że Zamawiający nie może stosować kryteriów odnoszących się do wyłącznej właściwości niektórych wykonawców lub specyfiki oferowanych wyłącznie przez nich produktów lub usług.

W praktyce do dokonania selekcji wykorzystuje się wskazane już w danym ogłoszeniu kryteria kwalifikacji. Jednocześnie, w zakresie wskazania maksymalnej liczby wykonawców, których Zamawiający powinien zaprosić do udziału w Postępowaniu, wydaje się, że rzeczywistą konkurencję umożliwi ograniczenie liczby Partnerów Prywatnych uczestniczących w Negocjacjach do 5.

PRZYKŁAD



W Postępowaniu na wybór Partnera Prywatnego, mającego pełnić również rolę operatora obiektu kubaturowego, którego zadaniem będzie m.in. świadczenie usług w zakresie bieżącej eksploatacji i utrzymania technicznej sprawności obiektu (naprawy, konserwacje, remonty) można sformułować następujące kryteria selekcji:

"Zamawiający zaprosi do udziału w postępowaniu 5 wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu.

Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu będzie mniejsza niż 5, Zamawiający zaprosi do udziału w Postępowaniu wszystkich wykonawców spełniających te warunki bez przeprowadzania kwalifikacji punktowej wniosków. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 5, wówczas Zamawiający zaprosi do udziału w Postępowaniu 5 wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów, obliczonych w sposób określony poniżej:

Zamawiający przyzna 1 punkt za każdą dodatkową wykazaną usługę, o której mowa w pkt [...] ogłoszenia, a w przypadku, gdy były one realizowane w ramach Przedsięwzięcia PPP Zamawiający przyzna 2 punkty, w przypadku, gdy w wyniku zastosowania wskazanego powyżej kryterium dodatkowego dwa bądź większa liczba podmiotów uzyska tę samą punktację, o kolejności tych wniosków decydować będzie wyższa zdolność finansowa lub kredytowa zgodnie z pkt [...] ogłoszenia".

Selekcja powinna odbywać się na podstawie dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu o koncesji.

W odniesieniu do kryteriów selekcji w Postępowaniu Koncesyjnym aktualne pozostają uwagi dotyczące kryteriów selekcji w Postępowaniu PZP, poczynione w Punkcie 4.3.2.3 Kryteria selekcji. Jako szczególnie istotną należy przypomnieć rekomendację, zgodnie z którą Zamawiający powinien dopuszczać możliwość polegania przez Spółki Projektowe na zasobach innych podmiotów również w zakresie kryteriów selekcji.

4.4 Dokumenty i oświadczenia Partnerów Prywatnych

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom II: Część II Punkt 1.12 – Podwykonawcy

4.4.1 Postępowanie PZP

Zgodnie z art. 124 Ustawy PZP Zamawiający ma obowiązek żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia (jednak obligatoryjnie tylko w przypadku Postępowań, których wartość przekracza Progi Unijne – por. art. 273 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP) oraz może żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu lub kryteriów selekcji.

Zamawiający ma obowiązek wskazania w OPIW informacji o oświadczeniach i dokumentach (podmiotowych środkach dowodowych), które mają dostarczyć wykonawcy w toku Postępowania oraz wskazać na jakim etapie Postępowania będzie wymagać poszczególnych dokumentów (art. 174 Ustawy PZP w zw. z art. 156 ust. 1 pkt 10 Ustawy PZP). Co istotne, Zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia Postępowania, potwierdzających:

- spełnianie warunków udziału w Postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia (dokumenty podmiotowe);
- spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego (dokumenty przedmiotowe – dokumenty te mogą być złożone na etapie składania ofert, z uwagi na okoliczność, że w przypadku Dialogu Konkurencyjnego, w chwili publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie jest dokładnie znany przedmiot zamówienia, w związku z czym Zamawiający nie określa w ogłoszeniu katalogu tych dokumentów).

Katalog dokumentów, których może żądać Zamawiający od wykonawców na potwierdzenie ww. okoliczności, określa Rozporządzenie w sprawie Dokumentów.

Wykonawcy dowiadują się zatem już z OPIW kiedy i jakich dokumentów Zamawiający będzie wymagać, z tym że w przypadku postępowań dwuetapowych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu obligatoryjnie wymagać powinien JEDZ wykonawcy (art. 125 ust 1 i 2 Ustawy PZP) oraz podmiotów przekazujących potencjał (art. 125 ust. 5 Ustawy PZP), jak również oświadczeń o przekazaniu potencjału (art. 118 ust 3 Ustawy PZP). Pozostałych dokumentów Zamawiający może żądać na każdym etapie Postępowania zgodnie z informacją zawartą w OPIW (art. 126 ust. 2 i 3 Ustawy PZP) albo dopiero po dokonaniu oceny ofert jedynie od podmiotu, który złożył ofertę najkorzystniejszą (art. 126 ust. 1 Ustawy PZP). Ta ostatnia opcja nie jest rekomendowana w długotrwałych Postępowaniach dwuetapowych, ponieważ może prowadzić do sytuacji, w której Zamawiający prowadzi przez wiele miesięcy dialog z wykonawcami, których ostatecznie będzie musiał wykluczyć z Postępowania.

Jak wynika z powyższego w odniesieniu do składania dokumentów i oświadczeń, Ustawa PZP dzieli postępowanie na dwie fazy – pierwsza faza obejmuje dokumenty, które wykonawca powinien złożyć wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu (w tym w szczególności wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu, kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia), a w ramach drugiej – wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa na wezwanie Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty określone w OPIW i SWZ.

Co do wspomnianego już JEDZ do wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu wykonawca dołącza aktualne na dzień składania wniosków oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu (w Postępowaniach o wartości zamówienia równej lub przekraczającej Progi Unijne – w formie JEDZ, a w Postępowaniach o wartości zamówienia poniżej Progów Unijnych – w formie zwykłego oświadczenia). Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią dowód tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe (art. 125 ust. 3 Ustawy PZP).

Pierwsza faza badania wniosku obejmuje więc wstępną weryfikację, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w Postępowaniu oraz czy spełnia warunki udziału lub kryteria selekcji. Weryfikacja okoliczności potwierdzanych wstępnie oświadczeniem następuje na podstawie oświadczeń lub dokumentów (podmiotowych środków dowodowych) przedkładanych na żądanie

Zamawiającego, i to jedynie w stosunku do wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej (na podstawie art. 126 ust. 1 Ustawy PZP).

Jeżeli natomiast zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

W odniesieniu do długotrwałych Postępowań PPP przepisy te (podobnie jak poprzednio obowiązujący art. 26 ust. 2f ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) w praktyce znajdują zastosowanie.

Jeśli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, jest zobowiązany do złożenia wraz z wnioskiem, JEDZ podmiotu trzeciego/informacji w oświadczeniu zwykłym, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w Postępowaniu, a także oryginału zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów. Zamawiający może przewidzieć w ogłoszeniu obowiązek przedstawienia przez podwykonawców JEDZ/informacji w oświadczeniu zwykłym wykonawcy w celu wykazania braku istnienia podstaw wykluczenia wobec podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia (art. 125 ust. 5 Ustawy PZP).

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ lub oświadczenie zwykle składa każdy z członków konsorcjum. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w Postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w Postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia (art. 125 ust. Ustawy PZP).

Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:

- może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków (rejestrem takim jest np. Krajowy Rejestr Sądowy, dostępny pod adresem ems.ms.gov.pl/krs);
- podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (art. 127 ust. 1 Ustawy PZP).

Ponadto zgodnie z art. 127 ust. 2 Ustawy PZP wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

4.4.2 Postępowanie Koncesyjne

Zamawiający ma obowiązek wskazania w ogłoszeniu o koncesji informacji o oświadczeniach i dokumentach, które mają dostarczyć wykonawcy w celu umożliwienia dokonania weryfikacji:

- spełniania kryteriów kwalifikacji;
- braku przesłanek do wykluczenia.

Dobłą praktyką jest wskazanie przez Zamawiającego obowiązku złożenia przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu. Powyższe umożliwia dokonanie kwalifikacji do Postępowania wykonawców w oparciu o dokumenty podmiotowe określone z odpowiednim zastosowaniem przepisów Rozporządzenia w sprawie

Dokumentów. Tym samym Zamawiający zyskuje pewność, że w Negocjacjach będą uczestniczyć wyłącznie podmioty posiadające odpowiednie zdolności techniczne i zawodowe, znajdujące się w określonej sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz niepodlegające wykluczeniu.

Jednocześnie warto rozważyć posłużenie się w ogłoszeniu o koncesji instytucją zbliżoną do określonej w art. 126 ust. 2 i 3 Ustawy PZP.

4.5 Kryteria Oceny Ofert

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część II Punkt 3.4 – Analizy prawne

Tom I: Część II Punkt 3.6 – Analizy rynkowe

Tom I: Część II Punkt 3.4.2 – Analiza sposobu oraz trybu wyboru Partnera Prywatnego

4.5.1 Zagadnienia wspólne

Kryteria Oceny Ofert to mierniki służące za podstawę oceny ofert złożonych w Postępowaniu przez Partnerów Prywatnych, umożliwiające sprawiedliwe porównanie ofert oraz gwarantujące wybór oferty rzeczywiście najkorzystniejszej. Jednocześnie, Kryteria Oceny Ofert to ostatnie narzędzie selekcji Partnerów Prywatnych uczestniczących w Postępowaniu. O ile Kryteria Oceny Podmiotowej (zob. Punkt 4.3 Kryteria Oceny Podmiotowej) służą zakwalifikowaniu do Negocjacji kilku najlepszych wykonawców, o tyle Kryteria Oceny Ofert pomagają Zamawiającemu w osiągnięciu celu Postępowania, którym jest dokonanie wyboru jednej oferty, najlepiej spełniającej jego oczekiwania.

Warto zwrócić uwagę, że Kryteria Oceny Podmiotowej odnoszą się do właściwości Partnerów Prywatnych, a nie do świadczeń, które wykonawcy oferują Podmiotowi Publicznemu. Dlatego też Zamawiający na etapie Negocjacji nie ma jeszcze gwarancji, że otrzyma oferty o rzeczywiście najkorzystniejszym Value for Money. W praktyce, to od Kryteriów Oceny Ofert zależał będzie wybór najlepszego Partnera Prywatnego. Aby tak się stało, Kryteria Oceny Ofert muszą być nie tylko prawidłowo skonstruowane od strony formalnej, ale przede wszystkim powinny odpowiadać na rzeczywiste potrzeby Zamawiającego i uwzględniać jego możliwości finansowe.

Podmioty Publiczne stosują dosyć często w Postępowaniach PPP Kryteria Oceny Ofert znane im z tradycyjnych zamówień publicznych (np. cena i termin wykonania robót budowlanych). Niestety, w większości przypadków nie jest to podejście właściwe. Należy podkreślić, że Postępowanie PPP umożliwia Zamawiającemu nie tylko skorzystanie z szerokiego wachlarza kryteriów pozacenowych, ale także doprecyzowanie Kryteriów Oceny Ofert po etapie Negocjacji i nadanie im konkretnego znaczenia (patrz Punkt 4 Ogłoszenie o zamówieniu oraz koncesji i Punkt 6 Negocjacje).

PRZYKŁAD



Podmiot Publiczny planuje budowę nowego budynku urzędu miasta w ramach PPP. Z uwagi na brak doświadczenia w realizacji podobnych Przedsięwzięć, w ogłoszeniu o zamówieniu przyjmuje następujące Kryteria Oceny Ofert, nadając im od razu konkretne znaczenie (wagę):

- 1) Cena: 60%;
- 2) Okres gwarancji ponad wymagane 3 lata: 25%;
- 3) Termin wykonania robót budowlanych: 15%.

W trakcie Negocjacji okazuje się, że wypracowane standardy utrzymania obiektu przewyższają uprawnienia wynikające z gwarancji jakości, w związku z czym kryterium to staje się nieprzydatne. Ponadto, z uwagi na długi termin na wybudowanie obiektu, zakładany od początku przez Zamawiającego, kryterium terminu wykonania robót budowlanych również traci na znaczeniu. W efekcie, Postępowanie rozstrzygnięte zostanie wyłącznie w oparciu o kryterium ceny (wszyscy wykonawcy deklarują w ofertach zarówno wydłużoną gwarancję, jak też skrócenie terminu wykonania budowy).

UWAGA



Błędem jest stosowanie Kryteriów Oceny Ofert właściwych wyłącznie dla tradycyjnych zamówień publicznych albo określanie pozornych kryteriów pozacenowych, które w praktyce i tak są w stanie spełnić wszyscy wykonawcy. W przypadku, gdy dla Zamawiającego jedynym wyznacznikiem wartości składanych ofert jest cena, powinien przyjąć to kryterium jako dominujące. Ustawa o PPP ani Ustawa o Umowie Koncesji nie ograniczają Podmiotów Publicznych w stosowaniu maksymalnej wagi 60% dla kryterium ceny. Nie oznacza to jednak, że Zamawiający uzyska w ten sposób pożądaný rezultat Postępowania i otrzyma oferty w pełni spełniające jego oczekiwania.

Należy zwrócić uwagę, że Kryteria Oceny Ofert powinny być starannie dopasowane do charakteru Projektu PPP, dobrze przemyślane i skorelowane z rzeczywistymi możliwościami Partnerów Prywatnych.

PRZYKŁAD



Podmiot Publiczny prowadzi Postępowanie PPP obejmujące zaprojektowanie, budowę, sfinansowanie, utrzymanie i zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy. W trakcie testów rynkowych okazało się, że potencjalni Partnerzy Prywatni nie są zainteresowani przejęciem ryzyka popytu ani też ryzyka płatności czynszów przez lokatorów mieszkań komunalnych. Pomimo tego, Zamawiający na pierwszych miejscach w hierarchii Kryteriów Oceny Ofert, umieścił właśnie te dwa ryzyka. Podczas Negocjacji Partnerzy Prywatni zdecydowanie potwierdzili swoje negatywne stanowisko wobec przejęcia tego rodzaju ryzyk. W efekcie, zaproponowana przez Zamawiającego alokacja ryzyk okazałaby się zupełnie nieadekwatna do przedmiotu zamówienia i "zajęła miejsce" innym kryteriom, które w tym przypadku mogłyby lepiej odpowiedzieć na potrzeby Zamawiającego.

Jak zatem konstruować Kryteria Oceny Ofert, aby Postępowanie było efektywne? Przede wszystkim należy zidentyfikować rzeczywiste potrzeby Podmiotu Publicznego, które mogą zostać lepiej zaspokojone dzięki przyjęciu określonych Kryteriów Oceny Ofert. Pomimo że przeważająca część zasad współpracy znajduje odzwierciedlenie w Dokumentacji Postępowania (patrz Punkt 6.4

Zasady dokumentowania Negocjacji), to jednak umiejętnie przyjęte kryteria pozwalają udoskonalić oferty i odpowiedzieć na szczegółowe potrzeby Zamawiającego.

PRZYKŁAD



Z uwagi na planowany termin otwarcia hali widowiskowo-sportowej oraz konieczność wydatkowania dotacji pozyskanej na ten cel, Podmiotowi Publicznemu bardzo zależy na szybkim terminie wykonania robót budowlanych. Kryterium to określa jako pierwsze w hierarchii przyjętej w ogłoszeniu o zamówieniu; w drugiej kolejności przyjmuje kryterium ceny (wysokości płatności na rzecz Partnera Prywatnego). Ponadto, zamierza premiować rozwiązania efektywne energetycznie, dzięki którym uzyskane zostaną wymierne efekty ekonomiczne i ekologiczne, posiłkując się w tym celu kryterium "efektywności energetycznej".

MAŁE PROJEKTY



Wyznaczanie Kryteriów Oceny Ofert w przypadku Małych Projektów PPP w zasadzie nie różni się od kryteriów określanych dla Dużych Projektów. W każdym przypadku mogą wystąpić bowiem specyficzne potrzeby Zamawiającego, których ujęcie w ramach Kryteriów Oceny Ofert umożliwi podniesienie jakości Projektu PPP.

W przypadku pakietowych Projektów PPP warto zwrócić uwagę na konieczność wspólnego przyjęcia i uzgodnienia Kryteriów Oceny Ofert przez wszystkie Podmioty Publiczne. Z uwagi na charakter Projektów pakietowych, trudniej będzie uwzględnić indywidualne preferencje wszystkich uczestników Postępowania po stronie Zamawiającego, ale przyjęte kryteria powinny być akceptowalne dla każdego z Podmiotów Publicznych.

PRZYKŁAD



Podmiot Publiczny ustalając Kryteria Oceny Ofert oraz ich wagi powinien uwzględnić swoje konkretne oczekiwania co do Infrastruktury Publicznej. W większości Projektów PPP możliwość uzyskiwania przychodów przez Partnera Prywatnego po zakończeniu robót budowlanych stanowi wystarczającą motywację do zakończenia ich w oczekiwanym terminie, w związku z czym przypisywanie istotnej wagi kryterium terminu wykonania prac nie jest pożądane. Natomiast w Projektach PPP wymagających od Podmiotu Publicznego przygotowania Infrastruktury Publicznej na określony i nieprzekraczalny termin (np. budynek szkoły, obiekt sportowy na imprezę międzynarodową, Projekt Hybrydowy), może uzasadniać przypisanie temu kryterium większej wagi.

Kryteria Oceny Ofert mogą być swobodnie określane przez Podmiot Publiczny. Jedynym warunkiem, który musi być spełniony, jest ich związanie z przedmiotem zamówienia/koncesji.

W przypadku stosowania kryteriów pozacenowych należy zauważyć, że kryteria te mogą być zarówno wymierne (np. skrócenie czasu na usunięcie awarii), jak też niewymierne (np. jakość koncepcji architektonicznej, właściwości estetyczne obiektu). Zasady równego traktowania

Partnerów Prywatnych, przejrzystości i uczciwej konkurencji nakazują jednak, aby stosowane kryteria miały charakter obiektywny. Pomimo że Ustawa o PPP, Ustawa PZP ani tym bardziej Ustawa o Umowie Koncesji nie zakazują stosowania kryteriów subiektywnych, Zamawiający powinien dążyć do ich minimalizacji i starać się je zobiektywizować (por. np. wyrok KIO z 6 stycznia 2010 r., sygn. akt: KIO 1804/10, wyrok KIO 28 czerwca 2018 r., sygn. akt: KIO 1168/10 oraz wyrok KIO z dnia 13 stycznia 2020 r., sygn. akt: KIO 2615/19).

Tak samo jak w przypadku tradycyjnych zamówień publicznych, Zamawiający musi wskazać dla każdego z Kryteriów Oceny Ofert wagę, aby określić jego znaczenie przy dokonywaniu oceny i porównania ofert. Zwyczajowo waga kryteriów wyrażana jest wartością procentową. Na sumę Kryteriów Oceny Ofert (100%) składać się będą zatem poszczególne kryteria wyznaczone przez Zamawiającego wraz z przypisanymi im wagami. Te z kolei przeliczane będą na punkty.

W praktyce Postępowania PPP zaleca się przy tym stosowanie kryteriów mierzalnych, których wartość można wyrazić w punktach, przyznając ich określoną liczbę za spełnienie lub poziom spełnienia danego kryterium (np. przejście ryzyka protestów społecznych, skrócenie czasu reakcji na awarię).

Z kolei korzystanie z niewymiernych Kryteriów Oceny Ofert obarczone jest zawsze pewnym ryzykiem błędu, który może skutkować wyborem oferty niespełniającej w praktyce wymogów Zamawiającego. Ponadto, w przypadku kryteriów niemierzalnych, ich kwantyfikacja polega zwykle na stopniowaniu spełnienia oczekiwań Zamawiającego w określonej skali punktowej (np. walory estetyczne obiektu, skala od 1 do 5). W wielu sytuacjach do rzetelnej oceny takich kryteriów konieczne będzie zatrudnienie dodatkowych ekspertów (np. architektów), których ocena siłą rzeczy zawierała będzie pewne elementy subiektywne.

Stosowanie kryteriów pozacenowych, w tym w szczególności jakościowych, może wpłynąć na wysokość Opłaty za Dostępność, Opłaty od Użytkowników lub Myto Ukryte. Dlatego też w każdym przypadku Podmiot Publiczny, we współpracy z Doradcami lub innymi ekspertami, powinien szczegółowo przeanalizować wpływ rozważanych Kryteriów Oceny Ofert (i ich znaczenia) na Projekt PPP.

DOBRE PRAKTYKI



Znaczenie Kryteriów Oceny Ofert

W Postępowaniach PPP za dobrą praktykę należy uznać ustalanie szczegółowego znaczenia Kryteriów Oceny Ofert dopiero po przeprowadzonych Negocjacjach. Zarówno w Postępowaniu PZP (art. 174 ust. 2 pkt 4 oraz art. 179 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP), jak też w Postępowaniu Koncesyjnym (art. 37 ust.1 Ustawy o Umowie Koncesji) dopuszczalne jest wskazanie w OPIW, SWZ lub ogłoszeniu o zamówieniu/koncesji Kryteriów Oceny Ofert w kolejności od najważniejszego, do najmniej ważnego – bez przypisywania im wag na tym etapie. W toku Negocjacji czasem okazuje się, że szczegółowe znaczenie poszczególnych kryteriów dla Zamawiającego musi ulec doprecyzowaniu w stosunku do założeń określonych przed wszczęciem Postępowania. Określenie wag poszczególnych Kryteriów Oceny Ofert powinno nastąpić najpóźniej wraz z zaproszeniem do składania ofert (art. 171 ust. 2 oraz art. 282 ust. 2 pkt 5 Ustawy PZP).

DOBRE PRAKTYKI



Kryteria Oceny Ofert i zasady zrównoważonego rozwoju

Za dobrą praktykę należy uznać stosowanie w ramach Kryteriów Oceny Ofert zasad zrównoważonego rozwoju (tzw. SGDs – *Sustainable Development Goals*), związanych z zasadą "Value for People" oraz takimi zagadnieniami, jak np.: poprawa dostępu społecznego do usług publicznych, w tym dostosowanie jej w niektórych aspektach do specyficznych potrzeb kobiet (jak np. dostosowanie transportu publicznego do mobilności kobiet); wspieranie transformacji gospodarczej; budowanie obiektów odpornych na zmiany klimatu; podniesienie jakości usług; poprawa wydajności operacyjnej i redukcja kosztów; zapewnienie szkoleń dla lokalnych pracowników w celu transferu umiejętności.

Praktyka wykształcona na polskim rynku PPP dowodzi, że Podmioty Publiczne często sięgają w Postępowaniach PPP po kryterium podziału zadań i ryzyk. Wynika to z faktu, że przez pierwsze lata obowiązywania Ustawy o PPP było to kryterium obligatoryjne.

Aktualnie zaleca się podejście, zgodnie z którym Zamawiający przed wszczęciem Postępowania określa pożądane Kryteria Oceny Ofert, odzwierciedlające jego potrzeby wynikające ze specyfiki Przedsięwzięcia. Nie zmienia to faktu, że Kryteria Oceny Ofert mogą zostać doprecyzowane po przeprowadzeniu Negocjacji.

PRZYKŁAD



W przypadku niektórych Projektów PPP opartych o Opłaty od Użytkowników, takich jak porty morskie, rzeczne i suche, lotniska, centra logistyczne, hale widowiskowo-konferencyjne, jednym z pozacenowych Kryteriów Oceny Ofert jest ocena biznesplanów sporządzanych przez Partnerów Prywatnych.

Sukces tego typu Projektów zależy bowiem od operacyjnej efektywności Partnera Prywatnego, jego innowacyjności, zdolności do generowania popytu na świadczone usługi (często dzięki pozycji rynkowej).

Zamawiający w Dokumentacji Postępowania określa wymagane elementy biznesplanu, takie jak np.:

- opis uzasadnienia biznesowego oraz opis strategii i planu rozwoju Przedsięwzięcia;
- informację o planowanej współpracy z kluczowymi klientami, jej skali oraz informacją o dotychczasowych doświadczeniach we współpracy z nimi lub/i o zawartych lub planowanych porozumieniach;
- opis i graficzne przedstawienie propozycji koncepcji zagospodarowania terenu Przedsięwzięcia;
- opis poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego, ze wskazaniem nakładów i harmonogramu realizacji inwestycji;
- określenie przewidywanego zapotrzebowania na poszczególne typy mediów niezbędnych do prowadzonej działalności, oczekiwanych od Podmiotu Publicznego oraz określenie przewidywanych rozwiązań projektowych i systemowych zmierzających do ograniczenia śladu środowiskowego inwestycji;
- deklarowane przez Partnera Prywatnego źródła finansowania kapitałowego i/lub dłużnego Przedsięwzięcia;
- opis struktury podmiotów realizujących przedsięwzięcie (spółka celowa, jej udziałowcy lub sponsorzy, kluczowi podwykonawcy na etapie przygotowania, budowy i eksploatacji);
- opis doświadczenia zawodowego wymaganego od kierownika projektu i zespołu zarządzającego;
- opis stosowanej polityki oraz proponowanych do wdrożenia działań w zakresie środowiskowym, społecznym oraz ładu korporacyjnego (ESG) w związku z budową i eksploatacją przedsięwzięcia;
- opis przewidywanych metod i narzędzi zarządzania cyklem życia realizowanej i eksploatowanej Infrastruktury;
- procedury związane ze zwrotem Infrastruktury po zakończeniu Umowy o PPP.

Częstym sposobem jest również przypisanie większej i zróżnicowanej liczby punktów za każdy element, w zależności od priorytetów i celów Podmiotu Publicznego.

Warto podkreślić, że stosowanie Kryteriów Oceny Ofert uwzględniających aspekty ekonomiczne, społeczne, środowiskowe, jakkolwiek należy oceniać pozytywnie w kontekście stymulowania

Projektów PPP innowacyjnych i korzystnych dla społeczeństwa, to jednak będzie miało wpływ na wysokość Opłaty za Dostępność lub Opłaty od Użytkowników.

ŹRÓDŁA INFORMACJI



Pozacenowe kryteria oceny ofert. Poradnik z katalogiem dobrych praktyk. Ver. 2.0, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2020:

<https://www.gov.pl/web/uzp/pozacenowe-kryteria-oceny-ofert>

Należy zauważyć, że jeżeli Podmiot Publiczny dąży do uzyskania konkretnego standardu usług świadczonych w ramach PPP, powinien ustalić ten standard w warunkach Umowy o PPP, a nie za pomocą Kryteriów Oceny Ofert. Kryteria służą bowiem zaspokojeniu potrzeb Podmiotu Publicznego ponad minimum określone w SWZ/Dokumentach Koncesji. Ponadto, nie ma gwarancji, że Partnerzy Prywatni zadeklarują w składanych ofertach spełnienie wszystkich kryteriów pożądaných przez Zamawiającego.

ŹRÓDŁA INFORMACJI



Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie – rekomendacje dla beneficjentów realizujących projekty indywidualne, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010 (aktualny również dla perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027).

4.5.2 Postępowanie PZP

Zamawiający już w ogłoszeniu o zamówieniu musi określić, na podstawie jakich kryteriów będą oceniane oferty oraz oznaczyć ich wagę (na tym etapie - od najważniejszego do najmniej ważnego, bez obowiązku określania wagi procentowej – art. 174 ust. 2 pkt 4 Ustawy PZP). W ogłoszeniu Zamawiający nie jest jeszcze zobowiązany do dokonania opisu, w jaki sposób zostanie przeprowadzona ocena ofert w ramach danych Kryteriów Oceny Ofert, ponieważ (z wyjątkiem kryterium ceny) "wykrystalizują" się one w trakcie Negocjacji z Partnerami Prywatnymi. Szczegółowy opis oraz konkretną wagę przyznaną poszczególnym Kryteriom Oceny Ofert należy wskazać w SWZ na etapie zaproszenia do składania ofert (zob. Punkt 7.1 Zaproszenie do składania ofert). Istotne jest, aby Kryteria Oceny Ofert zostały określone w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiające sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców.

Definicja najkorzystniejszej oferty (art. 6 ust. 1 Ustawy o PPP)

Najkorzystniejszą w Postępowaniu jest oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans wynagrodzenia Partnera Prywatnego albo Spółki PPP, lub kosztu Przedsięwzięcia ponoszonego przez Podmiot Publiczny i innych kryteriów odnoszących się do Przedsięwzięcia.

Ustawa o PPP nie wprowadza obligatoryjnych Kryteriów Oceny Ofert. Wskazuje ona jednak przykładowy, fakultatywny i otwarty katalog Kryteriów Oceny Ofert, zaliczając do nich (art. 6 ust. 3):

1) podział dochodów pochodzących z Projektu PPP pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym, w tym dochodów w postaci udziału w zysku Spółki PPP

Kryterium to zarezerwowane jest wyłącznie do Przedsięwzięć dochodowych, czyli takich, w których występują Opłaty od Użytkowników albo możliwości komercyjnego wykorzystania Infrastruktury Publicznej lub innych składników majątkowych Projektu PPP. W praktyce może być wykorzystywane m.in. w sektorach gospodarki wodno-ściekowej, transportu publicznego, rewitalizacji i komercjalizacji przestrzeni miejskiej, turystyki i rekreacji, centrów logistycznych i handlowych, parkingów miejskich. Stosowanie kryterium podziału dochodów może być szczególnie przydatne w Projektach PPP, w których Podmiot Publiczny wnosi istotny wkład finansowy lub rzeczowy na etapie budowy. Wówczas wspólne Przedsięwzięcie polega również na czerpaniu przez stronę publiczną zysków z jego realizacji.

2) stosunek wkładu własnego Podmiotu Publicznego do wkładu Partnera Prywatnego

W Projektach PPP, które zdolne są do generowania dochodów, można posłużyć się kryterium stosunku wkładu własnego Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego. Zazwyczaj chodziło będzie o wkład finansowy, w rzadszych przypadkach – wkład rzeczowy w postaci składnika majątkowego (np. stworzenie wspólnego produktu turystycznego w oparciu o zabytkowe obiekty będące w posiadaniu obu podmiotów). Kryterium to może być stosowane wspólnie z kryterium podziału dochodów z Przedsięwzięcia.

3) efektywność realizacji Projektu PPP, w tym efektywność wykorzystania składników majątkowych

Kryterium to początkowo (w ogłoszeniu o zamówieniu) może mieć charakter niewymierny. Jego kwantyfikacja powinna zostać dokonana w oparciu o obiektywną metodę, obejmującą posłużenie się przez Zamawiającego konkretnymi parametrami, które umożliwią dokonanie pomiaru efektywności wykorzystania składników majątkowych. Przykładowo, można za jego pomocą uzyskać dodatkowe inwestycje lub lepsze wykorzystanie powierzchni Infrastruktury Publicznej albo większą ilość lub jakość usług świadczonych przez Partnera Prywatnego na bazie tej infrastruktury.

4) kryteria odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu Przedsięwzięcia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, poziom oferowanych technologii, koszt utrzymania, serwis

Jest to grupa kryteriów (w większości niemierzalnych na etapie ogłoszenia o zamówieniu) ściśle związana z przedmiotem Projektu PPP. Zastosowanie tych Kryteriów Oceny Ofert będzie miało szczególne znaczenie dla rozwiązań projektowych przyjętych przez Partnera Prywatnego. Ich kwantyfikacja musi nastąpić przed zaproszeniem wykonawców do złożenia ofert.

5) podział zadań i ryzyk związanych z Projektem PPP pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym

Podział zadań i ryzyk to stosunkowo często wykorzystywane Kryterium Oceny Ofert. Użyte w powyższym brzmieniu na etapie ogłoszenia o zamówieniu/koncesji stanowi kryterium niekwantyfikowalne, które w toku Negocjacji musi zostać doprecyzowane i przybrać wymierną i skwantyfikowaną postać w SWZ/Dokumentach Koncesji. W celu dookreślenia tego kryterium Podmioty Publiczne często posilkują się Rozporządzeniem w Sprawie Ryzyka, identyfikując

i określając różne kategorie ryzyk na poszczególnych etapach przygotowania, inwestycji oraz eksploatacji Infrastruktury Publicznej.

6) terminy i wysokość przewidywanych płatności lub innych świadczeń Podmiotu Publicznego, jeżeli są one planowane

Kryterium to w praktyce dotyczy głównie wynagrodzenia Partnera Prywatnego, ewentualnie innych korzyści, jakie wykonawca może uzyskać od Podmiotu Publicznego. Warto zauważyć, że poza wysokością płatności obejmuje ono również terminy ich dokonywania. W Projektach PPP najczęściej przyjmuje się rozliczenia miesięczne, ponieważ odpowiadają one zarówno harmonogramom spłat kredytów przez stronę prywatną, jak też standardowym okresom uiszczania Opłaty za Dostępność w zakresie utrzymania i zarządzania Infrastrukturą Publiczną. Innego rodzaju świadczenia mogą natomiast dotyczyć przykładowo zobowiązań Podmiotu Publicznego do ustanowienia zabezpieczenia kredytu Partnera Prywatnego, obowiązku zakupu od niego określonych usług, czy dodatkowych obowiązków związanych bezpośrednio z Przedsięwzięciem.

PRZYKŁAD



Podmiot Publiczny planuje ogłosić Postępowanie PPP, którego przedmiotem jest zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie i utrzymanie budynku użyteczności publicznej w zabytkowej części miasta. Mechanizm Wynagradzania Partnera Prywatnego oparty będzie o Opłatę za Dostępność.

W związku z tym, w ogłoszeniu o zamówieniu, formułuje następujące Kryteria Oceny Ofert:

- 1) wysokość Opłaty za Dostępność;
- 2) Koncepcja Projektowa.

Doprecyzowanie opisu i nadanie wag ww. Kryteriom Oceny Ofert nastąpi dopiero po zakończeniu Negocjacji. Niemniej jednak, przyjęta hierarchia Kryteriów Oceny Ofert już na tym etapie obrazuje podejście Podmiotu Publicznego do Projektu PPP. Partnerzy Prywatni od początku wiedzą, że Opłata za Dostępność stanowiła będzie kryterium wiodące. Uwzględnienie koncepcji projektowej jako kryterium pozacenowego było dla Zamawiającego bardzo ważne z uwagi na umiejscowienie urzędu w zabytkowej części miasta. Konieczne było poszanowanie nie tylko przepisów prawa przy projektowaniu, ale też walory estetyczne i funkcjonalne budynku. W przypadku tego kryterium szczegółowy opis jego znaczenia oraz sposób oceny i przypisanie wagi dokonane zostały na etapie opracowywania SWZ.

Liczba Kryteriów Oceny Ofert nie powinna być zbyt duża, gdyż każde następne kryterium pomniejsza wagę pozostałych kryteriów; znaczna liczba Kryteriów Oceny Ofert może sprawiać też trudności związane z ich oceną. Z tego powodu nie rekomenduje się określania większej liczby niż 5-6 Kryteriów Oceny Ofert (łącznie z podkryteriami).

4.5.3 Postępowanie Koncesyjne

W odniesieniu do Projektów PPP realizowanych na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy o PPP, tj. w oparciu o Ustawę o Umowie Koncesji należy podkreślić, że zastosowanie mogą znaleźć zarówno Kryteria Oceny Ofert omówione wyżej w Punkcie 4.5.2 Postępowanie PZP (z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy o PPP do wyboru Partnera Prywatnego i Umowy o PPP

stosuje się przepisy Ustawy o Umowie Koncesji, w zakresie nieuregulowanym w Ustawie o PPP), jak też inne kryteria ustalone przez Zamawiającego, uwzględniające specyfikę Projektów Koncesyjnych. Natomiast w przypadku, gdy Ustawa o Umowie Koncesji stanowi samoistną podstawę prawną wyboru Koncesjonariusza, Podmiot Publiczny będzie miał pełną swobodę ich określania, w tym może kierować się propozycjami Kryteriów Oceny Ofert określonymi w Ustawie o PPP lub Ustawie PZP. Należy pamiętać, że katalog Kryteriów Oceny Ofert ma charakter przykładowy i to od Zamawiających zależy które Kryteria Oceny Ofert zastosują.

Najkorzystniejsza oferta – Ustawa o Umowie Koncesji

Ustawa o Umowie Koncesji nie definiuje pojęcia oferty najkorzystniejszej. O ile zatem Przedsięwzięcie wdrażane jest na podstawie przepisu art. 4 ust. 2 Ustawy o PPP, zastosowanie znajdzie definicja wskazana w Punkcie 4.5.2 Postępowanie PZP.

Zamawiający może określić Kryteria Oceny Ofert z wykorzystaniem przepisów art. 37 Ustawy o Umowie Koncesji. Zgodnie z ww. regulacją Zamawiający powinien wskazać Kryteria Oceny Ofert związane z przedmiotem Umowy w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. Szczegółowy opis oraz konkretne wagi przyznawane poszczególnym Kryteriom Oceny Ofert zostaną opracowane w Dokumentach Koncesji po zakończeniu Negocjacji, na etapie zaproszenia Partnerów Prywatnych do składania ofert (zob. Punkt 7.1 Zaproszenie do składania ofert).

Do przykładowych elementów, które można wziąć pod uwagę podczas formułowania Kryteriów Oceny Ofert, zalicza się w szczególności aspekty środowiskowe, społeczne lub innowacyjne przedmiotu Umowy. W przypadku koncesji należy zatem kierować się oddziaływaniem Projektu PPP na otoczenie społeczno-gospodarcze, uwzględniając kwestie związane z ochroną środowiska, wpływ na społeczeństwo oraz nowatorskie rozwiązania, które mogą być zastosowane do realizacji Projektu PPP. Jak można zauważyć, w Postępowaniach Koncesyjnych zdecydowanie rzadziej niż w przypadku Postępowań PZP występuje kryterium ceny/płatności Podmiotu Publicznego. Wynika to z samej istoty koncesji, w ramach której Partner Prywatny ponosi ryzyko ekonomiczne związane z Projektem PPP. W miejsce kryterium ceny występować będzie najczęściej kryterium Opłaty od Użytkowników.

W oparciu o praktykę prowadzenia Postępowań Koncesyjnych jako przykładowe Kryteria Oceny Ofert można wskazać:

1) czas trwania Umowy

Kryterium to stosowane jest w dużej liczbie Postępowań Koncesyjnych. Co do zasady, premiowani są wykonawcy, którzy zadeklarują w ofertach krótszy (niż bazowy, wyznaczony przez Zamawiającego) okres obowiązywania Umowy. Podejście takie wiąże się z przekonaniem, że skoro Koncesjonariusz ponosi ryzyko ekonomiczne wykonywania Umowy, to powinien w możliwie krótkim czasie odzyskać poniesione nakłady inwestycyjne, a Podmiot Publiczny powinien jak najszybciej przejąć funkcjonującą Infrastrukturę Publiczną. Należy zwrócić jednak uwagę, że zbyt krótki okres, na jaki zawarta zostanie Umowa, może skutkować podwyższeniem Opłat od Użytkowników. Ponadto, nie w każdym przypadku stronie publicznej zależy na jak najkrótszym okresie współpracy z Koncesjonariuszem.

Zakończenie Umowy oznacza, że Podmiot Publiczny musi przejąć realizację Projektu PPP (do czego np. może nie mieć odpowiednich zasobów lub kompetencji) albo dokonać wyboru kolejnego Partnera Prywatnego (co wymaga ponownie przeprowadzenia Postępowania). Z powyższych powodów należy każdorazowo zastanowić się nad zasadnością stosowania

omawianego Kryterium Oceny Ofert. Być może – w niektórych Projektach - dłuższy okres obowiązywania Umowy wiązał się będzie z pobieraniem mniejszych Opłat od Użytkowników lub zaoferowaniem przez Partnera Prywatnego dodatkowych usług świadczonych w ramach Projektu PPP.

2) wysokość Opłat od Użytkowników

Podstawowym skutkiem przejęcia przez Partnera Prywatnego ryzyka ekonomicznego w ramach Projektu Koncesyjnego jest oparcie Mechanizmu Wynagradzania na Opłatach od Użytkowników (ewentualnie z uwzględnieniem dodatkowych płatności Podmiotu Publicznego lub innych form wynagradzania – szerzej na ten temat patrz Wytyczne Tom I). W interesie Podmiotu Publicznego jest, aby opłaty te nie były zbyt wysokie. Z tego powodu, kryterium Opłat od Użytkowników stanowi często wykorzystywane Kryterium Oceny Ofert, znajdując zastosowanie wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze świadczeniem usług użyteczności publicznej na rzecz mieszkańców lub innych podmiotów (np. parkingi miejskie, obiekty sportowe, cmentarze, transport publiczny). W niektórych Projektach Użytkownikami mogą być przede wszystkim podmioty gospodarcze lub też Partner Prywatny świadczy głównie usługi komercyjne (np. w ramach centrów przesiadkowych, parków rozrywki, parków wodnych, mieszkań komercyjnych) – wówczas Podmiot Publiczny nie powinien zasadniczo ingerować w poziom pobieranych przez niego opłat. Należy dodać, że niektóre sektory użyteczności publicznej może cechować obecność centralnego regulatora, z góry narzucającego maksymalne stawki za określone usługi (np. w zadaniach z zakresu gospodarki wodno-ściekowej).

3) kryteria odnoszące się bezpośrednio do przedmiotu Przedsięwzięcia, w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, poziom oferowanych technologii, koszt utrzymania, serwis

Podobnie jak w Postępowaniach PZP, jako Kryteria Oceny Ofert zastosowanie znaleźć mogą kryteria odnoszące się do przedmiotu Projektu PPP (zob. Punkt 4.5.2 Postępowanie PZP).

4) wysokość płatności Partnera Prywatnego

Wysokość opłat uiszczanych przez Partnera Prywatnego może być stosowana jako Kryterium Oceny Ofert przede wszystkim w Projektach PPP dotyczących koncesji na usługi. W takich sytuacjach wykonawca otrzymuje bowiem prawo do eksploatacji istniejącej Infrastruktury Publicznej (nie musi jej budować). Można się również zastanowić, czy zamiast pobierać od strony prywatnej opłaty za używanie Infrastruktury Publicznej, nie należy wykorzystać innych Kryteriów Oceny Ofert, dotyczących warunków świadczenia usług przez Partnera Prywatnego (np. zniżki na niektóre usługi, większa ilość lub wyższa jakość usług).

5) wysokość płatności Podmiotu Publicznego

W praktyce to Kryterium Oceny Ofert występuje w tych Projektach PPP, które dla swej rentowności wymagają pewnego poziomu dopłat ze strony Zamawiającego. Płatności mogą przyjąć formę bezpośredniego, stałego wynagrodzenia na rzecz Partnera Prywatnego, albo też być związane ze świadczonymi przez niego usługami (np. Podmiot Publiczny dopłaca pewną kwotę do każdego mieszkańca gminy korzystającego z krytej pływalni).

PRZYKŁAD



Planowany Projekt dotyczy zarządzania krytą pływalnią w ramach koncesji na usługi. W ogłoszeniu o koncesji Podmiot Publiczny formułuje następujące Kryteria Oceny Ofert:

- 1) Opłaty od Użytkowników;
- 2) jakość obsługi.

Na tym etapie nie określa jeszcze dokładnego znaczenia Kryteriów Oceny Ofert, przyjmując jedynie powyższą ich kolejność. Wiodące Kryterium Oceny Ofert stanowiła będzie cena usługi świadczonej na rzecz osób korzystających z pływalni, ale z uwagi na przyjęcie jako drugiego (i ostatniego) kryterium jakości obsługi, nie wiadomo jeszcze jaka będzie relacja pomiędzy tymi Kryteriami Oceny Ofert. Po przeprowadzonych Negocjacjach może okazać się, że rozwiązania proponowane przez wykonawców doprowadzą do zrównoważenia obu Kryteriów Oceny Ofert albo odwrotnie – kryterium Opłat od Użytkowników zyska dużą przewagę.

Zasady doprecyzowania opisu Kryteriów Oceny Ofert i nadania im konkretnego znaczenia omówiono w Punkcie 6.5.3 Doprecyzowanie Kryteriów Oceny Ofert.

Podobnie jak w Postępowaniu PZP, liczba Kryteriów Oceny Ofert nie powinna być zbyt duża, gdyż każde następne Kryterium Oceny Ofert pomniejsza wagę pozostałych Kryteriów Oceny Ofert, czasami może sprawiać też trudności związane z ich oceną. Z tego powodu nie rekomenduje się określania większej liczby niż 5-6 Kryteriów Oceny Ofert (łącznie z podkryteriami).

Należy pamiętać, iż zgodnie z regulacją art. 37 ust. 3 Ustawy o Umowie Koncesji w wyjątkowych przypadkach wskazanych w tym przepisie (proponowane w ofercie rozwiązania innowacyjne), Zamawiający może zmienić kolejność Kryteriów Oceny Ofert przewidzianych w ogłoszeniu o koncesji. W takim przypadku Zamawiający powinien poinformować wszystkich wykonawców o zmianie kolejności Kryteriów Oceny Ofert oraz przekazać nowe zaproszenie do składania ofert, a także opublikować nowe ogłoszenie o koncesji.

4.6 Wadium

4.6.1 Postępowanie PZP

Wadium jest wnoszone w formie zapłaty określonej sumy pieniężnej lub odpowiedniego zabezpieczenia jej zapłaty, które powinno być ustanowione przed przystąpieniem do przetargu, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim (art. 70⁴ Kodeksu Cywilnego). Głównym celem wadium jest należyte zabezpieczenie interesów Zamawiającego przed skutkami działań lub zaniechań nierzetelnego wykonawcy, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na wynik Postępowania.

Zamawiający w Postępowaniu PZP może żądać od wykonawców wniesienia wadium (art. 97 ust. 1 Ustawy PZP). Co istotne, wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, a nie wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 (wcześniejsze zawarcie Umowy o PPP lub unieważnienie Postępowania) oraz ust. 2 Ustawy PZP (wycofanie przez danego wykonawcę oferty przed terminem składania ofert, odrzucenie oferty danego wykonawcy, wybór oferty innego wykonawcy). Wysokość wadium nie może być większa

niż 3% wartości zamówienia, a w przypadku Postępowań o wartości poniżej Progów Unijnych - 1,5% (art. 97 ust. 2 oraz 281 ust. 4 Ustawy PZP).

Należy przy tym pamiętać, że w przypadku Projektów PPP wartość ta obejmuje nie tylko koszty robót budowlanych, ale także finansowania, utrzymania lub zarządzania obiektem. Przewidziany Ustawą PZP procent odnoszony będzie zatem do całej wartości Umowy o PPP.

Z uwagi na specyfikę Dialogu Konkurencyjnego, Podmiot Publiczny może w ogłoszeniu o zamówieniu wskazać konkretną wysokość wymaganego wadium, bądź poprzestać na określeniu, że wysokość wadium zostanie ustalona w SWZ (czyli już po odbyciu Negocjacji), co stanowi rekomendowaną praktykę.

Wadium, zgodnie z art. 97 ust. 7 Ustawy PZP może być wnoszone w następujących formach:

- 1) pieniądzu (na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego);
- 2) gwarancjach bankowych;
- 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wybór formy wadium należy do wykonawcy – może on przy tym wybrać jedną spośród form wymienionych wyżej, a także połączyć różne z nich.

O zachowaniu terminu wniesienia wadium świadczy data wpływu wadium na konto (w przypadku wadium pieniężnego) lub jego złożenie u Podmiotu Publicznego (w przypadku pozostałych form).

Należy dodać, że żądanie wadium w maksymalnej wysokości skutkowało będzie zawsze wyższą ceną ofert. Z tego powodu, uwzględniając specyfikę Projektów PPP, warto skoncentrować się w większym stopniu na etapie Zamknięcia Finansowego (szerzej na ten temat w Punkcie 1.1 Wysoka jakość analiz w ramach Oceny Efektywności i uwzględnienie wniosków z testów rynkowych). W szczególności nie zaleca się stosowania maksymalnej wartości wadium, zwłaszcza, że odnosi się ono do całkowitej szacowanej wartości Umowy o PPP.

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności (art. 98 ust. 1 Ustawy PZP):

- upływu terminu związania ofertą;
- zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

W przypadku złożenia przez wykonawcę wniosku o zwrot wadium, Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy (art. 98 ust. 2 Ustawy PZP):

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
- którego oferta została odrzucona;
- po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;

- po unieważnieniu Postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

Zgodnie z art. 98 ust. 3 Ustawy PZP złożenie wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.

Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium (art. 98 ust. 4 i 5 Ustawy PZP).

Ustawa PZP przewiduje zamknięty katalog przesłanek zatrzymania wadium, zatem nie jest możliwe, żeby Zamawiający samodzielnie określił inne przypadki. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w następujących sytuacjach:

- 1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
- 2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
- 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia Zamawiający w celu zatrzymania wadium, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium.

Należy dodać, że w przypadku Trybu Negocyjnego Podprogowego Zamawiający może wymagać od wykonawców wniesienia wadium na etapie składania ofert ostatecznych. Wysokość wadium nie może przy tym przekroczyć 1,5% wartości zamówienia, a obowiązek jego wniesienia określany jest w SWZ (por. art. 295 ust. 3 w zw. z art. 281 ust. 2 pkt 10 Ustawy PZP). W Trybie Negocyjnym Podprogowym obowiązują analogiczne zasady wnoszenia i zwrotu wadium, jak w przypadku Dialogu Konkurencyjnego.

4.6.2 Postępowanie Koncesyjne

W przeciwieństwie do Ustawy PZP, w Ustawie o Umowie Koncesji nie ma przepisów regulujących instytucję wadium. Powyższe nie oznacza jednak, że Zamawiający nie może określić każdorazowo w Dokumentach Koncesji obowiązku wniesienia wadium przez Partnera Prywatnego w celu zabezpieczenia jego oferty na zasadach określonych odpowiednio na podstawie Kodeksu Cywilnego (art. 16 ust. 1 Ustawy o Umowie Koncesji w zw. z art. 70⁴ Kodeksu Cywilnego).

Zamawiający może przewidzieć w ogłoszeniu konieczność wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, zaś warunki dotyczące wysokości, formy i sposobu wniesienia wadium, a także zwrotu wadium, należy szczegółowo doprecyzować w Dokumentach Koncesji. Dokumenty Koncesji mogą na przykład przewidywać, że Partner Prywatny traci wadium (wraz z ewentualnymi odsetkami), jeżeli odmówi podpisania Umowy o PPP na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Partnera Prywatnego.

4.7 Zmiany ogłoszenia i OPIW

4.7.1 Postępowanie PZP

4.7.1.1 Zmiany ogłoszenia o zamówieniu

O ile w tradycyjnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ewentualne zmiany dotyczą przede wszystkim SWZ, warto pamiętać, że ogłoszenie o zamówieniu w ramach Postępowania PPP również może zostać zmienione. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy Zamawiający uwzględnia wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści ogłoszenia, zmianę warunków udziału w Postępowaniu lub kryteriów selekcji.

Przesłanką zmiany ogłoszenia może być przykładowo uwzględnienie przez Zamawiającego uzasadnionego wniosku wykonawcy o dokonanie zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, jak również zastosowanie się do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej – nakazującego Zamawiającemu dokonanie stosownych zmian w ogłoszeniu wskutek uwzględnienia odwołania wniesionego przez wykonawcę.

Jeżeli jest to konieczne, jednocześnie z dokonaniem zmiany ogłoszenia, Zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach. Jeśli zmiana jest istotna dla sporządzenia wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, Kryteriów Oceny Podmiotowej, Kryteriów Oceny Ofert, lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach (poprzez skorygowanie wcześniej przygotowanych dokumentów albo opracowanie ich od nowa) – por. art. 90 ust. 2 oraz art. 271 ust. 1 Ustawy PZP.

Jeżeli zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu istotnie zmieniają charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmieniają zakres zamówienia, Zamawiający unieważnia Postępowanie na podstawie art. 256 Ustawy PZP. Obowiązkiem Zamawiającego jest zamieszczenie informacji o zmianach na stronie internetowej po jej przekazaniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

DOBRE PRAKTYKI



Pytania do ogłoszenia

Pomimo że Ustawa PZP nie przewiduje możliwości zadawania pytań do ogłoszenia o zamówieniu (w obecnym stanie prawnym możliwe jest składanie wniosków o wyjaśnienie OPIW), w praktyce Postępowania PPP przyjęło się, że Podmioty Publiczne udzielają odpowiedzi na pytania do treści ogłoszenia zadawane przez wykonawców i zamieszczają je na swojej

stronie internetowej. Działanie takie należy uznać za dobrą praktykę PPP, dzięki której Partnerzy Prywatni mogą lepiej przygotować się do Postępowania.

4.7.2 Postępowanie Koncesyjne

Ustawa o Umowie Koncesji dopuszcza możliwość dokonania zmiany informacji zawartych w ogłoszeniu o koncesji (art. 29 ust. 4 Ustawy o Umowie Koncesji), kształtując jednocześnie obowiązek każdorazowego poinformowania wykonawców biorących udział w Postępowaniu o dokonywanych zmianach. Konieczność zmiany ogłoszenia o koncesji może nastąpić w szczególności w przypadku:

- 1) dokonania zmiany informacji zawartych zarówno w opisie postępowania o zawarcie Umowy Koncesji i ogłoszeniu o koncesji;
- 2) dokonania zmiany istotnych elementów treści ogłoszenia (np. zmiany kryteriów kwalifikacji, kryteriów selekcji lub sposobu oceny ich spełniania);
- 3) dokonania zmiany miejsca, terminu i sposobu złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu.

Przyczyną zmiany ogłoszenia może być przykładowo uwzględnienie przez Zamawiającego uzasadnionego wniosku wykonawcy o dokonanie zmiany treści ogłoszenia o koncesji, jak również zastosowanie się do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej – nakazującego Zamawiającemu dokonanie stosownych zmian w ogłoszeniu wskutek uwzględnienia odwołania wniesionego przez wykonawcę.

Zmiana treści ogłoszenia niezależnie od miejsca jej publikacji (BZP lub DUUE) powinna zostać dokonana poprzez zamieszczenie sprostowania lub zmiany ogłoszenia. W przypadku dokonania zmiany ogłoszenia rekomenduje się wydłużenie terminu na złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu o czas niezbędny na wprowadzenie przez wykonawców zmian we wnioskach.

5. Badanie i ocena wniosków

5.1 Postępowanie PZP

5.1.1 Weryfikacja informacji, oświadczeń lub dokumentów

Po upływie terminu na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu Zamawiający przystępuje do ich badania i oceny. Podstawę ich weryfikacji stanowią Kryteria Oceny Podmiotowej. W praktyce Komisja Przetargowa zbiera się w wyznaczonym terminie w celu sprawdzenia powyższych okoliczności (czynnościom tym podlegają jedynie wnioski złożone w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie).

Ustawodawca nie przewidział terminu, w jakim ma nastąpić cały proces badania i oceny wniosków, lecz przyjmuje się, że powinno to nastąpić bez zbędnej zwłoki. Członkowie Komisji Przetargowej w pierwszej kolejności sprawdzają kompletność wniosku i jego załączników, a później przystępują do badania dokumentów potwierdzających należyte umocowanie wykonawcy do złożenia wniosku (dokumenty rejestrowe, pełnomocnictwa), wstępnych oświadczeń w formie JEDZ lub oświadczenia zwykłego i innych dokumentów.

Oceny pod kątem spełniania warunków udziału w Postępowaniu lub kryteriów selekcji Zamawiający dokonuje w odniesieniu do wykonawcy (lub konsorcjum traktowanego jako wykonawca na podstawie art. 58 ust. 5 Ustawy PZP). Jeśli wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu został złożony przez konsorcjum, co do zasady wystarczające jest, aby jeden z wykonawców wykazał spełnienie warunków udziału w Postępowaniu lub kryteriów selekcji. W przypadku braku podstaw do wykluczenia z Postępowania wykonawca (każdy z członków konsorcjum) podlega ocenie, czy nie zachodzą wobec niego przesłanki wskazujące na wykluczenie. Trzeba mieć na uwadze, że ziszczenie się choćby jednej z przesłanek w odniesieniu do wykonawcy lub któregośkolwiek z członków konsorcjum skutkuje koniecznością wykluczenia z Postępowania całego konsorcjum. Podmiot trzeci, na zasoby którego powołuje się wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, jest również weryfikowany pod kątem braku podstaw wykluczenia. Jeśli dojdzie do sytuacji, że którakolwiek z podstaw wykluczenia ziści się w odniesieniu do podmiotu trzeciego, wykonawca będzie musiał wykazać się spełnieniem warunków udziału w Postępowaniu na nowo (art. 122 Ustawy PZP). Jeśli Zamawiający zastrzegł w ogłoszeniu, że będzie weryfikował brak podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawców, bada również tę kwestię.

Na tym etapie Zamawiający weryfikuje jedynie informacje zawarte w oświadczeniu wstępnym wykonawcy (JEDZ albo oświadczeniu zwykłym). Zgodnie z ogólną zasadą stosowaną zresztą w każdym z trybów Postępowania (art. 126 ust. 1 lub 2 Ustawy PZP), Zamawiający wzywa do złożenia dokumentów podmiotowych jedynie wykonawcę, którego oferta została w toku przeprowadzonego Postępowania oceniona jako najkorzystniejsza, tj. uplasowała się na najwyższej pozycji w rankingu ofert.

Z uwagi na okoliczność, iż w wyniku kwalifikacji dokonanej na podstawie oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu do dalszego etapu, tj. Negocjacji, a później do składania ofert, zostanie zaproszona liczba wykonawców określona w ogłoszeniu o zamówieniu, zasadne jest skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia określonego w art. 126 ust. 2 Ustawy PZP. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu Postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie Postępowania, w tym na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału

w Postępowaniu lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych aktualnych na dzień ich złożenia.

Aby uniknąć sytuacji, w której do Negocjacji zostanie dopuszczony wykonawca, który w rzeczywistości nie spełnia Kryteriów Oceny Podmiotowej i nie będzie w stanie potwierdzić tych okoliczności po złożeniu oferty (na wezwanie Zamawiającego), Zamawiający może skorzystać z ww. regulacji. Jest to w szczególności uzasadnione, jeżeli liczba wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, jest większa niż przewidziana w ogłoszeniu liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert (przykładowo 10 wniosków na 5 zapraszanych wykonawców), a tym samym może dojść do sytuacji, w której do kolejnego etapu nie zostanie zaproszony wykonawca spełniający warunki udziału w Postępowaniu i niepodlegający wykluczeniu, który uzyskał liczbę punktów plasującą go na 6. miejscu. W takim przypadku, wykonawca ten znalazłby się na liście podmiotów dopuszczonych do Negocjacji, jeśli wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostałby wykluczony z Postępowania w wyniku wcześniejszej weryfikacji dokumentów przez Zamawiającego.

5.1.2 Wyjaśnianie i uzupełnianie wniosków

Jeśli w trakcie weryfikacji dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu lub w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 126 ust. 2, Zamawiający dostrzeże, że zawierają one błędy, braki lub są wadliwe albo wymagają wyjaśnienia, jest zobowiązany do zastosowania art. 128 Ustawy PZP, tj. do skierowania do wykonawców wezwania do uzupełnień/wyjaśnień. Przepisy Ustawy PZP nie określają terminu, jaki Zamawiający powinien wyznaczyć wykonawcy w celu wyjaśnienia lub uzupełnienia wniosków. Przyjmuje się jednak, że powinien on być odpowiedni i dostosowany do zakresu lub stopnia skomplikowania wyjaśnień lub uzupełnień. Wszystkie z omawianych wezwań mogą być od siebie niezależne, a ustawodawca nie nakłada na Zamawiającego konieczności stosowania ich w określonej kolejności.

Jeżeli złożony przez wykonawcę JEDZ lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.

Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie JEDZ lub podmiotowych środków dowodowych nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji.

5.1.3 Wezwanie z art. 128 ust. 1 Ustawy PZP

Zgodnie z art. 128 ust. 1 Ustawy PZP, jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 (JEDZ), podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w Postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie, lub zachodzą przesłanki unieważnienia Postępowania.

Niezwykle istotne jest przygotowanie przez Zamawiającego treści wezwań w sposób jak najbardziej precyzyjny, który nie pozostawi w sferze domysłów zakresu uzupełnienia

lub wyjaśnienia. Podkreślenia wymaga, że wezwanie do uzupełnień w trybie art. 128 ust. 1 Ustawy PZP może nastąpić jednokrotnie w odniesieniu do danego dokumentu/informacji w JEDZ.

Szczególnego omówienia wymaga kwestia uzupełniania JEDZ. Zamawiający określa w ogłoszeniu oraz ewentualnie we wzorze JEDZ (zmodyfikowanym w dopuszczalnym zakresie na potrzeby danego Postępowania), jakiego rodzaju informacji oczekuje od wykonawcy. Może się zdarzyć, że wykonawca wypełni JEDZ informacjami w zakresie niewymaganim przez Zamawiającego.

W takim przypadku, Zamawiający nie ma obowiązku wezwania wykonawcy do uzupełnienia, ponieważ nie ma ku temu podstaw prawnych (zob. stanowisko UZP dostępne pod adresem

Istotne jest również to, iż zgodnie z art. 128 ust. 3 Ustawy PZP, złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy PZP, lub podmiotowych środków dowodowych nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji. Oznacza to, iż np. uzupełnienie lub poprawienie referencji możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy dana referencja miała wykazać spełnienie warunku udziału w Postępowaniu, a nie służyć uzyskaniu punktów w ramach prekwalfikacji.

5.1.4 Wezwanie z art. 128 ust. 4 Ustawy PZP

Art. 128 ust. 4 Ustawy PZP przewiduje wezwanie wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści JEDZ lub złożonych podmiotowych środków dowodowych, lub innych dokumentów, lub oświadczeń składanych w Postępowaniu (w odniesieniu do wniosku o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu – dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu, kryteriów selekcji, braku podstaw wykluczenia).

Zamawiający ma obowiązek wezwania wykonawcy do wyjaśnień, jeśli dostrzeże niejasności lub wewnętrzne sprzeczności, które wzbudzą jego wątpliwości. Podkreślenia wymaga, że wyjaśniać można jedynie treści, które zostały zawarte w oświadczeniach lub dokumentach i które nie są jednoznaczne. Odpowiedź wykonawcy na ww. wyjaśnienia nie może skutkować uzupełnieniem brakujących informacji, do których udzielenia wykonawca był zobowiązany wraz ze złożeniem wniosku. Co istotne, wezwanie do wyjaśnień może zostać wystosowane przez Zamawiającego wielokrotnie w odniesieniu do danego dokumentu/informacji w JEDZ. Jeżeli z wyjaśnień wykonawcy wynika, że złożone dokumenty są niekompletne, wówczas Zamawiający ma obowiązek wezwać do ich uzupełnienia na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy PZP.

5.1.5 Ocena wniosków i dopuszczenie do udziału w Postępowaniu

Po uzyskaniu odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, Zamawiający dokonuje oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu.

Wniosek jest odrzucany, jeśli:

- został złożony po terminie;
- został złożony przez wykonawcę:
 - podlegającego wykluczeniu z Postępowania;
 - niespełniającego warunków udziału w Postępowaniu;
 - który nie złożył w przewidzianym terminie JEDZ lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w Postępowaniu, innych dokumentów lub oświadczeń;

- jest niezgodny z przepisami ustawy;
- jest nieważny na podstawie odrębnych przepisów;
- nie został sporządzony lub przekazany w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego (art. 176 ust. 2 w zw. z art. 146 ust. 1 Ustawy PZP).

Ponadto w Trybie Negocjacyjnym Podprogowym Zamawiający odrzuca oferty wstępne, które nie spełniają minimalnych wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, określonych przez Zamawiającego (por. art. 289 ust. 4 Ustawy PZP).

W wyniku weryfikacji spełniania przez wykonawców kryteriów selekcji, Zamawiający tworzy ranking wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w Negocjacjach. Po dokonaniu ww. czynności Zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, o wynikach oceny i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków.

Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w Postępowaniu, jest większa niż określona w ogłoszeniu, Zamawiający zaprasza do Negocjacji wykonawców wyłonionych na podstawie kryteriów selekcji. Wniosek o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu wykonawcy niezaproszonego do Negocjacji uznaje się za odrzucony.

W przypadku gdy liczba wykonawców, którzy złożyli niepodlegające odrzuceniu wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu jest mniejsza od minimalnej liczby określonej w ogłoszeniu, Zamawiający może kontynuować postępowanie, zapraszając do składania ofert tych wykonawców, albo unieważnić Postępowanie na podstawie art. 258 ust. 1 albo 289 ust. 4 Ustawy PZP.

Należy pamiętać, że od dnia poinformowania o wynikach oceny spełniania warunków udziału w Postępowaniu jawne są nie tylko wnioski, lecz także dokumenty złożone w ich uzupełnieniu oraz wyjaśnienia. Potwierdzenie (lub brak potwierdzenia) spełnienia wymagań Zamawiającego lub też ocena skuteczności złożenia wniosku wynika bowiem ze wszystkich tych dokumentów łącznie (por. wyrok KIO z 8 listopada 2013 r.; sygn. akt KIO 2525/13 oraz wyrok KIO z 23 lipca 2018 r.; sygn. akt KIO 1340/18).

Należy podkreślić istotę rzetelnego uzasadnienia oceny wniosków, w szczególności w zakresie przyznanej punktacji. Brak takiego uzasadnienia, jako naruszenie podstawowych obowiązków informacyjnych, dawałby podstawę do zaskarżenia takiej decyzji przed KIO (vide: wyrok KIO z dnia 16 stycznia 2015 r. (sygn. 2708/14, 2717/14, 2720/14, 2723/14); port. także z wyrokiem KIO z dnia 31 marca 2021 r. sygn. KIO 16/21). W efekcie każdy z wykonawców powinien otrzymać informacje o przydzielonej punktacji wraz z uzasadnieniem.

5.2 Postępowanie Koncesyjne

Po upływie wyznaczonego terminu na złożenie wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu Zamawiający przystępuje do ich badania i oceny. Podstawę ich weryfikacji stanowią kryteria kwalifikacji oraz przesłanki wykluczenia wskazane w ogłoszeniu, a także kryteria selekcji (jeżeli Zamawiający je stosuje). Jednocześnie, Zamawiający - zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu o koncesji - może żądać od wykonawcy przedłożenia wraz z wnioskiem dokumentów potwierdzających spełnienie Kryteriów Oceny Podmiotowej. Na potrzeby weryfikacji dokumentów podmiotowych wykonawcy, warto jest przewidzieć w ogłoszeniu możliwość wezwania wykonawców, którzy nie złożyli oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów

kwalifikacji lub niepodleganie wykluczeniu, lub gdy złożone oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, do ich złożenia - uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielania wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Powyższe umożliwi Zamawiającemu dokładne zweryfikowanie potencjału danego wykonawcy, jak również uchroni potencjalnych Partnerów Prywatnych przed wykluczeniem z Postępowania, w szczególności z uwagi na niezłożenie danego oświadczenia lub dokumentu.

W celu zachowania zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji warto również przewidzieć w treści ogłoszenia możliwość jednokrotnego wezwania odnośnie do danego dokumentu lub oświadczenia, tak jak ma to miejsce w przypadku procedury prowadzonej na podstawie Ustawy PZP.

Po uzyskaniu odpowiedzi na ewentualne wezwania, Zamawiający dokonuje oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu. Jeśli w wyniku analizy tych dokumentów i oświadczeń okaże się, że dany wykonawca nie potwierdził spełnienia kryteriów kwalifikacji albo istnieją wobec niego podstawy do wykluczenia, Zamawiający wyklucza danego wykonawcę (pod warunkiem, że w ogłoszeniu o koncesji przewidział możliwość wykluczenia wykonawcy, który nie wykaże spełnienia kryteriów kwalifikacji – brak jest bowiem takiej przesłanki w Ustawie o Umowie Koncesji).

W przypadku, gdy wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu zostały złożone przez większą liczbę wykonawców od maksymalnej – wskazanej w ogłoszeniu o koncesji, Zamawiający stosuje, jeżeli przewidział to w ogłoszeniu, kryteria selekcji i tworzy ranking wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w Negocjacjach. Po dokonaniu ww. czynności Zamawiający niezwłocznie informuje wykonawców, którzy złożyli wnioski o wynikach oceny spełniania warunków udziału w Postępowaniu i otrzymanych ocenach.

6. Negocjacje

6.1 Zakres dokumentacji Podmiotu Publicznego na potrzeby Negocjacji

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część II Punkt 3.10 – Podsumowanie Oceny Efektywności

Tom III: Część II Punkt 1.10 – Umowa Bezpośrednia

Tom IV: Część II Punkt 2.2 – Określenie przyszłej struktury instytucjonalnej Zarządzania Umową o PPP

Tom IV: Część II Punkt 2.3 – Wstępne określenie Standardów Utrzymania

Tom IV: Część II Punkt 2.4 – Identyfikacja ryzyk projektowych i ich wstępny podział

W celu zapewnienia efektywnych Negocjacji, zakończonych sporządzeniem jak najlepszej SWZ/Dokumentów Koncesji, niezwykle istotne jest przygotowanie możliwie szczegółowej dokumentacji na potrzeby Negocjacji.

Dlatego też należy rekomendować, aby na jej pierwszą turę Podmiot Publiczny przygotował podstawowe dokumenty transakcyjne, w tym projekt Umowy o PPP. Pozwoli to na rozpoczęcie merytorycznej dyskusji i pozyskanie informacji zwrotnej od Partnerów Prywatnych od samego początku Negocjacji i tym samym na efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na ten etap Postępowania.

Podmiot Publiczny na użytek Negocjacji powinien przygotować Dokumentację Postępowania zawierającą co najmniej:

- wnioski z Oceny Efektywności;
- adekwatne i potrzebne materiały Podmiotu Publicznego (w tym techniczne);
- wstępny projekt Umowy o PPP;
- wstępną koncepcję techniczną oraz wstępne PFU;
- wstępny projekt dokumentu zawierającego standardy utrzymania/zarządzania/świadczenia usług/zwrotu Infrastruktury Publicznej;
- wstępny Mechanizm Wynagradzania.

W praktyce często okazuje się też, że w trakcie Negocjacji identyfikowana jest potrzeba pozyskania lub opracowania przez Podmiot Publiczny dodatkowych materiałów, takich jak np. umowy z dostawcami mediów, stanowiska organów nadzoru lub kontroli albo dokonania określonych czynności – związanych np. z wyjaśnieniem stanu prawnego nieruchomości lub przeprowadzeniem badań geologicznych. Zazwyczaj są to na tyle istotne materiały, że bez ich udostępnienia Partnerom Prywatnym, niemożliwe będzie dokonanie dalszych uzgodnień w ramach Negocjacji.

UWAGA



Pomimo że Projekty PPP obejmują zazwyczaj projektowanie, w praktyce zdarza się, że Podmiot Publiczny na etapie ogłaszania Postępowania PPP dysponuje już projektem budowlanym wraz z pozwoleniem na budowę. W takim przypadku możliwe są trzy podejścia:

- nakazanie wykorzystania projektu budowlanego przez Partnera Prywatnego;
- przekazanie projektu budowlanego do ewentualnych zmian przez Partnera Prywatnego;
- wprowadzenie zmian do projektu budowlanego przez Podmiot Publiczny i przekazanie zmienionej wersji Partnerom Prywatnym wraz z SWZ.

Gdyby Podmiot Publiczny nakazał Partnerowi Prywatnemu zastosowanie posiadanej dokumentacji projektowej, wówczas ryzyko kompletności i niewadliwości projektu budowlanego obciążało będzie Podmiot Publiczny.

W przypadku udostępnienia dokumentacji Podmiotu Publicznego (wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę) Partnerom Prywatnym do celów informacyjnych i dopuszczenie zarówno jej weryfikacji, negocjacji rozwiązań projektowych, jak i ewentualnej zmiany projektu budowlanego, wówczas zmiana projektu budowlanego oraz uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę przeniesie ryzyko kompletności i niewadliwości dokumentacji na Partnera Prywatnego.

W przypadku, gdy Podmiot Publiczny samodzielnie wprowadzi zmiany do projektu budowlanego wówczas ryzyko kompletności i niewadliwości projektu budowlanego obciążało będzie Podmiot Publiczny. W tym ostatnim przypadku celowość przygotowania przez Podmiot Publiczny projektu budowlanego i wykonawczego zależy od indywidualnych cech danego Projektu PPP np. w celu skrócenia czasu realizacji całego Projektu PPP oraz w przypadku powtarzalnych Projektów PPP, w których wpływ know-how Partnera Prywatnego ma mniejsze znaczenie. Z drugiej strony dla Projektów PPP typowo technologicznych oraz nowatorskich może wpłynąć na ograniczenie zastosowania specjalistycznych rozwiązań technicznych oferowanych przez Partnerów Prywatnych.

Ponadto, narzucenie Partnerowi Prywatnemu rozwiązań projektowych może negatywnie wpłynąć na etap utrzymania lub zarządzania, ponieważ Partner Prywatny mógłby zastosować bardziej efektywne rozwiązania.

DOBRE PRAKTYKI



Sposób przekazywania dokumentów

Niewątpliwie do dobrych praktyk należy zaliczyć gromadzenie i udostępnianie Partnerom Prywatnym dokumentów w określonej przestrzeni wirtualnej. Może to być własny serwer Zamawiającego, jak też serwery firm specjalizujących się w takich usługach. W ten sposób zapewniony zostaje równy dostęp wszystkich uczestników Dialogu Konkurencyjnego do materiałów informacyjnych, jak również zaoszczędzony czas na drukowanie i doręczanie Partnerom Prywatnym często obszernych dokumentów.

Dokumenty powinny być udostępniane w formie pdf oraz w wersji umożliwiającej edycję.

UWAGA



Należy przypomnieć, że Podmiot Publiczny może swobodnie udostępniać wyłącznie własne materiały. Nie może ujawniać bez zgody Partnerów Prywatnych materiałów przekazywanych przez nich w trakcie Negocjacji i nie wolno mu udostępniać ich pozostałym Partnerom Prywatnym.

Niekiedy zdarza się również, że w końcowej fazie Negocjacji Podmiot Publiczny przekazuje Partnerom Prywatnym projekt kompletnej Dokumentacji Postępowania, w tym projekt SWZ, wyznaczając im termin na wniesienie ostatecznych uwag i propozycji przed ostatecznym zaproszeniem do składania ofert. Taki zabieg pozwala na uzyskanie opinii Partnerów Prywatnych co do ostatecznej wersji SWZ, co może zmniejszyć ryzyko kwestionowania postanowień SWZ/Dokumentów Koncesji przez Partnerów Prywatnych w ramach środków odwoławczych.

UWAGA



Z uwagi na zainteresowanie Dużymi Projektami wśród Partnerów Prywatnych spoza Polski, należy rozważyć w takich Postępowaniach przetłumaczenie Dokumentacji Postępowania na język angielski. Podmioty Publiczne mogą oczekiwać opłaty za udostępnienie takiego tłumaczenia Partnerom Prywatnym uczestniczącym w Postępowaniu. Powyższa praktyka pozwoli na usprawnienie Postępowania i ograniczy ryzyko rozbieżności pomiędzy różnymi tłumaczeniami. Praktyka taka staje się coraz bardziej powszechna w innych krajach (np. Słowacja, Turcja, Egipt).

Dostarczenie tłumaczenia Dokumentacji Postępowania (szczególnie jej pierwszej i ostatecznej wersji) ułatwi i znacznie skróci proces Negocjacji. Będzie to też pozytywny sygnał dla rynku i na pewno zwiększy zainteresowanie Instytucji Finansujących we wcześniejszych fazach Projektu PPP. Nie jest jednak potrzebne tłumaczenie wszystkich dokumentów (np. typowo technicznych, takich jak projekty lub rysunki).

6.2 Zaproszenie do Negocjacji

6.2.1 Zagadnienia wspólne

Dla porządku należy przypomnieć, że pod pojęciem Negocjacji w Wytycznych Tom II rozumiany jest tryb Dialogu Konkurencyjnego (w przypadku Ustawy PZP), negocjacje w trybie podstawowym (Tryb Negocjacyjny Podprogowy) oraz negocjacyjna procedura konkurencyjna, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Umowie Koncesji.

Zaproszenie do Negocjacji przekazywane jest Partnerom Prywatnym, którzy spełnili warunki udziału w Postępowaniu/kryteria kwalifikacji, nie podlegają wykluczeniu oraz spełnili kryteria selekcji i w efekcie znaleźli się na tzw. "krótkiej liście", tj. w gronie podmiotów, które będą uczestniczyć w Postępowaniu na etapie Negocjacji.

W przypadku Trybu Negocyjnego Podprogowego Zamawiający zaprasza jednocześnie wykonawców do Negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu, a jeżeli ustalił kryteria, o których mowa w art. 288 ust. 2 Ustawy PZP (Kryteria Oceny Ofert, które Zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców), zaproszenie kieruje do tych wykonawców, których oferty spełniają w najwyższym stopniu te kryteria, w liczbie ustalonej przez Zamawiającego.

Zaproszenie do Negocjacji stanowi formalne rozpoczęcie procesu Negocjacji. Pomimo że ustawodawca nie określił Podmiotowi Publicznemu terminu, w jakim ma zaprosić do Negocjacji wykonawców, czynność ta powinna zostać wykonana w możliwie krótkim czasie.

6.2.2 Postępowanie PZP

Jak była o tym mowa wcześniej, minimalna liczba wykonawców uczestniczących w Dialogu Konkurencyjnym, zgodnie z Ustawą PZP powinna wynosić 3, choć Zamawiający może określić w ogłoszeniu o zamówieniu/Koncesji większą ich liczbę (rekomenduje się liczbę 5 Partnerów Prywatnych).

Ustawodawca wymaga (art. 179 ust. 1 Ustawy PZP), aby zaproszenie do Dialogu Konkurencyjnego zawierało co najmniej:

- 1) nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego Postępowania;
- 2) numer opublikowanego ogłoszenia o zamówieniu;
- 3) adres strony internetowej, na której dostępny jest Opis Potrzeb i Wymagań oraz jego ewentualne zmiany i wyjaśnienia, a także inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia, niezbędne do przygotowania się wykonawców do udziału w Dialogu Konkurencyjnym;
- 4) informację o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli Zamawiający przewiduje wymóg składania wszystkich lub wybranych podmiotowych środków dowodowych na etapie Dialogu Konkurencyjnego;
- 5) wagę przypisaną kryteriom oceny ofert lub, w stosownych przypadkach, kolejność tych kryteriów od najważniejszego do najmniej ważnego, jeśli nie zostało to wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Opisie Potrzeb i Wymagań;
- 6) informację o miejscu i terminie rozpoczęcia Dialogu Konkurencyjnego;
- 7) informację o języku lub językach, w jakich będzie prowadzony Dialog Konkurencyjny.

UWAGA



Na etapie zaproszenia do Dialogu Konkurencyjnego Zamawiający nie posiada jeszcze ostatecznej treści SWZ. Ponadto na podstawie przepisu art. 37 ust. 2 Ustawy PZP Zamawiający może (lecz nie musi) udostępnić SWZ na stronie internetowej. Nawet jednak w takim przypadku będzie to wstępny projekt SWZ, a nie jej docelowa treść. Ostateczna wersja SWZ jest zamieszczana na stronie internetowej Zamawiającego po zakończeniu Dialogu Konkurencyjnego.

Zaproszenie do Dialogu Konkurencyjnego zawiera informację o miejscu i terminie jego rozpoczęcia. Najczęściej Negocjacje odbywają się w siedzibie Podmiotu Publicznego lub miejscu przez niego wskazanym. Jeżeli z przyczyn logistycznych lub ekonomicznych uzasadnione jest odbycie tury Dialogu Konkurencyjnego w innym miejscu (np. w innym mieście), nie ma do tego żadnych przeszkód. Sytuacja taka może wystąpić np. wówczas, gdy wszyscy Partnerzy Prywatni oraz Zespół Doradców mają siedzibę w miejscu innym niż Zamawiający.

Językiem, w którym prowadzony będzie Dialog Konkurencyjny, jest co do zasady język polski. W praktyce, jeżeli w Negocjacjach uczestniczą podmioty zagraniczne, Partnerzy Prywatni powinni na swój koszt zapewnić udział tłumaczy.

DOBRE PRAKTYKI



Zaproszenie do Negocjacji

Katalog informacji zawartych w zaproszeniu do Dialogu Konkurencyjnego nie ma charakteru zamkniętego. W szczególności, jeżeli Podmiot Publiczny dysponuje dodatkową dokumentacją dotyczącą Projektu PPP (np. koncepcja projektowa, wstępny PFU, Decyzje Administracyjne), powinien udostępnić ją Partnerom Prywatnym wraz z zaproszeniem. Im wcześniej wykonawcy uzyskają dostęp do materiałów związanych z Projektem PPP, tym szybciej będą mogli je zweryfikować, przygotować się do Negocjacji, zaproponować określone rozwiązania i pomysły.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku Trybu Negocjacyjnego Podprogowego Zamawiający zaprasza do Negocjacji wykonawców po etapie składania ofert "wstępnych".

6.2.3 Postępowanie Koncesyjne

Ustawa o Umowie Koncesji nie formułuje wobec Zamawiającego żadnych wymogów związanych z rozpoczęciem Negocjacji. Podmiot Publiczny, jako gospodarz Postępowania, może zatem w sposób dowolny kształtować treść zaproszenia do Negocjacji.

6.3 Zarządzanie procesem Negocjacji

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom III: Część I Punkt 2.3 – Strategia negocjacyjna

Tom IV: Część II Punkt 1.3 – Umowa o PPP – proces negocjacyjny i postanowienia istotne z punktu widzenia Zarządzania Umową o PPP

Tom IV: Część II Punkt 2.1.2 – Procesy decyzyjne

Tom IV: Część II Punkt 2.1.4 – Komunikacja z Partnerem Prywatnym

Tom IV: Część II Punkt 2.5 – Negocjacje

6.3.1 Zdefiniowanie zakresu Negocjacji

Jednym z najistotniejszych elementów Postępowania PPP jest sprawne przeprowadzenie Negocjacji. Punkt wyjścia do zdefiniowania zakresu Negocjacji stanowi przygotowanie materiałów i dokumentów przekazywanych Partnerom Prywatnym wraz z zaproszeniem do Negocjacji.

W celu usprawnienia Postępowania zaleca się, ażeby Partnerzy Prywatni otrzymali jak największy zakres Dokumentacji Postępowania, w tym pierwszy projekt Umowy o PPP wraz z załącznikami przygotowanymi w sposób najpełniej odzwierciedlający oczekiwania Podmiotu Publicznego.

Zakres Negocjacji może obejmować wszelkie aspekty związane z Przedsięwzięciem, w tym zagadnienia techniczne, technologiczne, finansowe, podatkowe, prawne, administracyjne, organizacyjne i inne. Szczegółowy zakres Negocjacji zależy od konkretnego Projektu PPP.

W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że nie każdy element Przedsięwzięcia wymagał będzie Negocjacji. Podmiot Publiczny może przed rozpoczęciem Negocjacji określić minimalne wymagania lub warunki, które nie będą podlegały Negocjacjom z wykonawcami. Warunki takie formułowane są zazwyczaj w strategii negocjacyjnej (szerzej na ten temat patrz Punkt 3.3 Strategia negocjacyjna).

UWAGA



Należy zwrócić uwagę, iż zakres Negocjacji w przypadku PPP Instytucjonalnego (realizowanego przez Spółkę PPP) jest nieco szerszy i tym samym należy przewidzieć dodatkowe spotkanie z Partnerami Prywatnymi, w celu wypracowania uzgodnień w zakresie poszerzonej Dokumentacji Postępowania. Ponad standardowe dokumenty podlegające Negocjacjom, w ramach PPP Instytucjonalnego należy bowiem uzgodnić warunki utworzenia Spółki PPP oraz jej funkcjonowania, w tym treść umowy Spółki PPP oraz podstawowe warunki funkcjonowania Spółki PPP. W ramach Dokumentacji Postępowania nie ma natomiast potrzeby wypracowywania warunków wszystkich kluczowych umów, które zawrze Spółka PPP, takich jak np. umowa o zaprojektowanie i budowę Infrastruktury Publicznej oraz umowa o utrzymanie i zarządzanie Infrastrukturą Publiczną – umowy te mogą zostać wypracowane już na etapie wykonywania Umowy o PPP.

Zamawiający, bez względu na podstawę prawną prowadzonego Postępowania (Postępowanie PZP albo Postępowanie Koncesyjne), nie może w trakcie Negocjacji zmieniać Kryteriów Oceny Ofert ani minimalnych wymagań.

Przynajmniej niektóre z powyższych warunków powinny zostać przedstawione w ogłoszeniu o zamówieniu/koncesji lub OPIW/OPUK i konsekwentnie przestrzegane w całym toku Postępowania. W przeciwnym razie istotna zmiana ww. założeń może doprowadzić do wątpliwości co do konkurencyjności Postępowania i równego traktowania Partnerów Prywatnych.

PRZYKŁAD



Podmiot Publiczny, w trakcie Negocjacji, wbrew założeniom prezentowanym w Opisie Potrzeb i Wymagań, dopuścił znacznie większy poziom płatności na rzecz Partnera Prywatnego oraz przeniesienie własności Infrastruktury Publicznej na Partnera Prywatnego po zakończeniu Umowy o PPP. Ponadto, wbrew przyjętemu w OPIW podziałowi ryzyka, zobowiązał się

do wzięcia na siebie całego ryzyka popytu. Niezgodnie z pierwotnymi założeniami postanowił również współfinansować 50% budowy planowanego obiektu. W efekcie, mamy do czynienia z zupełnie innym niż zakładany (i opisany w ogłoszeniu o zamówieniu) Projektem PPP. Pomimo że Negocjacje służą właśnie uzgodnieniu sposobu i warunków realizacji Przedsięwzięcia, a Podmiot Publiczny dokonuje jego modyfikacji wskutek rozwiązań proponowanych przez wykonawców, to jednak nie powinno to doprowadzać do naruszenia kluczowych elementów i założeń przedmiotu zamówienia/koncesji. Daleko idące zmiany mogą bowiem godzić w konkurencyjność Postępowania i ograniczać do niego dostęp Partnerom Prywatnym, a także pozostawać w sprzeczności z zawartymi w ogłoszeniu Kryteriami Oceny Podmiotowej. W skrajnych przypadkach, skutkiem takich drastycznych zmian może być nawet unieważnienie Umowy o PPP przez sąd (por. art. 457 i 459 Ustawy PZP).

6.3.2 Harmonogram i agendy tur Negocjacji

Harmonogramu Negocjacji nie należy mylić z harmonogramem Postępowania, choć zawierają one element wspólny. Harmonogram Negocjacji stanowi bowiem uszczegółowienie harmonogramu Postępowania w zakresie planowanych Negocjacji. O ile harmonogram Postępowania zawiera kamienie milowe związane z całą procedurą udzielenia zamówienia, tj. od czynności przygotowawczych do Zamknięcia Finansowego, to harmonogram Negocjacji obejmuje wyłącznie etap od zaproszenia do Negocjacji do zakończenia tur negocjacyjnych i zamknięcia Negocjacji. Zdarza się również, że Podmioty Publiczne przekazują Partnerom Prywatnym pełny harmonogram Postępowania.

Harmonogram Negocjacji należy przygotować na cały planowany okres Negocjacji i rekomendowane jest ściśle jego przestrzeganie w miarę możliwości. Pozwoli to na przygotowanie się do Negocjacji przez wszystkich uczestników z wyprzedzeniem i zorganizowanie odpowiednich zasobów w sposób efektywny.

Należy dodać, że nie wszystkie tury Negocjacji muszą być prowadzone w formie bezpośrednich spotkań (choć jest to forma rekomendowana i powszechnie stosowana). W praktyce Postępowania PPP zdarzają się także Negocjacje odbywane zdalnie – w formie tele- lub wideokonferencji. Przy wykorzystaniu takich środków należy dołożyć wszelkich starań (wcześniejsze testy sprzętu, wykorzystanie profesjonalnych usług firmy zewnętrznej itp.), aby nie wystąpiły problemy techniczne mogące utrudnić prowadzenie Negocjacji.

W okresie pandemii Covid-19 prowadzenie Negocjacji w formie wideokonferencji stało się standardem. Okazało się, że jest to bardzo dogodny, a przy tym efektywny ekonomicznie sposób prowadzenia rozmów z Partnerami Prywatnymi. Zdalne Negocjacje umożliwiają bowiem organizację Postępowania w sposób bardziej elastyczny i dostosowany do możliwości Partnerów Prywatnych działających w różnych lokalizacjach, a nierzadko też za granicą. Po zakończeniu pandemii częstą praktyką jest odbywanie Negocjacji w formie hybrydowej, z udziałem zdalnym niektórych uczestników Negocjacji.

Przykładowe harmonogramy i agendy Negocjacji oraz zagadnienia do dyskusji zaproponowane przez Podmiot Publiczny zawarte zostały w załącznikach Nr 1 – 8 do Wytycznych Tom II.

6.3.3 Regulamin i sposób prowadzenia Negocjacji

Organizacja procesu Negocjacji wymaga zwykle przyjęcia regulaminu Negocjacji.

DOBRE PRAKTYKI



Regulamin Negocjacji

Regulamin Negocjacji nie jest dokumentem wymaganym przepisami prawa, jednakże stanowi dobrą praktykę w Postępowaniach PPP, wskazując ramy współpracy i zasady komunikacji na etapie Negocjacji pomiędzy Podmiotem Publicznym, a pozostałymi uczestnikami Postępowania. Jego zadaniem jest zapewnienie dobrej organizacji sesji dialogowych i równego traktowania Partnerów Prywatnych.

Regulamin Negocjacji powinien zawierać następujące elementy:

- 1) określenie celu, przedmiotu i podstawy prawnej realizacji Przedsięwzięcia;
- 2) słowniczek pojęć, który ułatwi korzystanie z regulaminu;
- 3) podstawowe zasady prowadzenia Negocjacji, takie jak: zapewnienie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Partnerów Prywatnych, pisemna forma i język Postępowania, zasady ponoszenia kosztów w trakcie Negocjacji;
- 4) poufność Negocjacji, w tym sposób zastrzegania tajemnicy przedsiębiorstwa, zasady ujawniania przez Podmiot Publiczny informacji uzyskanych w toku Negocjacji, wykaz informacji niepodlegających tajemnicy przedsiębiorstwa;
- 5) komunikacja stron, w tym forma, terminy, adresy, a także sposób przekazywania materiałów i informacji;
- 6) przebieg Negocjacji, określający harmonogram i agendy tur Negocjacji, a także miejsce i terminy ich odbywania oraz sposób poinformowania Partnerów Prywatnych o zakończeniu Negocjacji;
- 7) zasady dotyczące Postępowania po zaproszeniu do składania ofert;
- 8) organizację, tryb pracy i skład Komisji Przetargowej;
- 9) informacje dodatkowe i porządkowe, w tym zasady zmiany regulaminu i data wejścia w życie.

Przykładowy regulamin Negocjacji znajduje się w załączniku nr 3 do Wytycznych Tom II.

Negocjacje z reguły odbywają się w kilku turach. Przepisy prawa nie limitują ich liczby. W Postępowaniu PZP Dialog Konkurencyjny powinien być prowadzony do momentu, w którym Zamawiający jest w stanie określić, w wyniku porównania rozwiązań proponowanych przez wykonawców, jeżeli jest to konieczne, rozwiązanie lub rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby (Dialog Konkurencyjny - art. 184 Ustawy PZP) albo doprecyzować lub uzupełnić wszystkie warunki zamówienia, które podlegają Negocjacom (Tryb Negocjacyjny Podprogowy – art. 291 ust. 4 Ustawy PZP).

Zazwyczaj w ramach Negocjacji odbywa się 3-5 spotkań negocjacyjnych (sesji dialogowych). Jednakże, w przypadku, gdy istnieje potrzeba odbycia dodatkowych rund Dialogu Konkurencyjnego i jest to obiektywnie uzasadnione (np. pojawią się nowe okoliczności istotne dla Projektu PPP lub określone zagadnienie wymaga pogłębionych dyskusji), Podmiot Publiczny powinien dopuścić taką możliwość i zainicjować lub wyrazić zgodę na kolejne spotkania. Możliwe jest także ograniczenie liczby tur Negocjacji w przypadku powtarzalnych lub ustandaryzowanych Projektów PPP.

Poszczególne tury Negocjacji powinny odbywać się w możliwie krótkim czasie. Przykładowo, jeżeli w Dialogu Konkurencyjnym uczestniczy 5 wykonawców, a na Negocjacje z jednym wykonawcą ma być poświęcony jeden dzień, optymalne jest przeprowadzenie pełnej rundy negocjacyjnej w ciągu jednego tygodnia.

Taki sposób procedowania, oprócz zapewnienia zasady równości w dostępie do zamówienia, ma i tę zaletę, że zespół Zamawiającego może na bieżąco porównywać rozwiązania proponowane przez poszczególnych Partnerów Prywatnych.

Harmonogram Negocjacji należy zaplanować w sposób uwzględniający:

- 1) wszystkie zaplanowane działania, jakie mają zostać podjęte w ramach etapu Negocjacji;
- 2) odpowiedni czas na określone działanie, uwzględniający możliwości po stronie Podmiotu Publicznego oraz Partnerów Prywatnych (np. potencjał kadrowy Podmiotu Publicznego);
- 3) proces decyzyjny po stronie Podmiotu Publicznego;
- 4) kamienie milowe, tj. zdarzenia, od których zależy podjęcie kolejnych czynności;
- 5) potencjalne ograniczenia dostępności Podmiotu Publicznego oraz Partnerów Prywatnych np. biorąc pod uwagę święta państwowe czy okresy wakacyjne;
- 6) przypisanie odpowiedzialności konkretnym podmiotom lub osobom za konkretne działania.

Przejawem równego traktowania wykonawców jest przeznaczanie dokładnie takiej samej liczby tur negocjacyjnych i czasu ich trwania dla każdego wykonawcy.

Czasami Partner Prywatny zwraca się z wnioskiem do Podmiotu Publicznego o wyznaczenie dodatkowego spotkania w celu omówienia określonych zagadnień. W przypadku, gdy Zamawiający uzna wniosek za zasadny, powinien przeznaczyć również dodatkowy czas na spotkania z pozostałymi Partnerami Prywatnymi, jeżeli wyrażą oni wolę w tym zakresie.

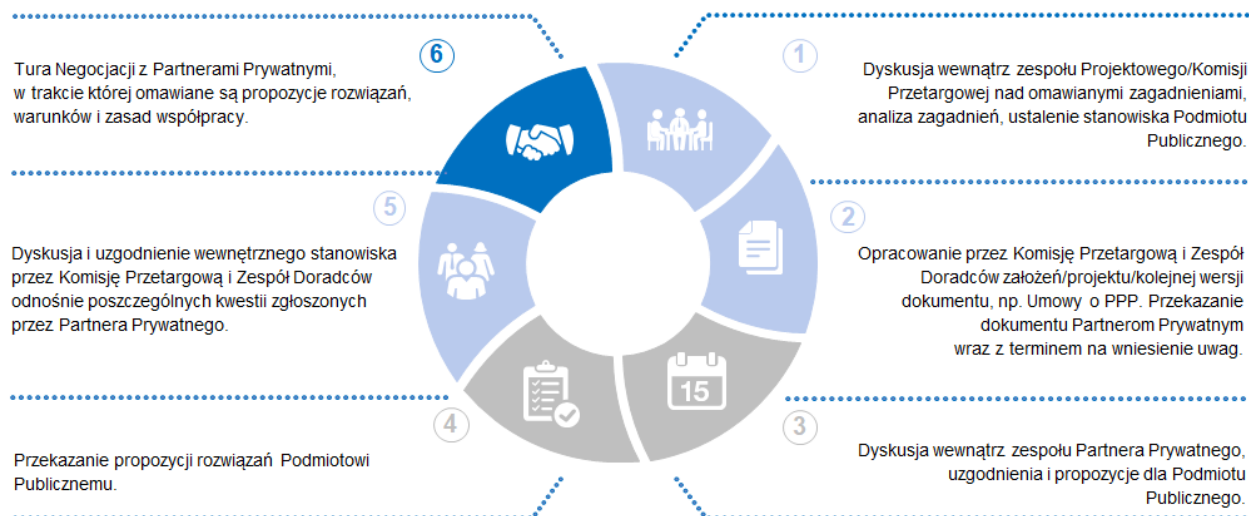
Zdarza się również rezygnacja Partnera Prywatnego z udziału w sesji dialogowej, co oznacza, że z tym wykonawcą Zamawiający przeprowadzi krótsze Negocjacje. Nie oznacza to jednak nierównego traktowania Partnerów Prywatnych. Rezygnacja z udziału w sesjach dialogowych nie oznacza, że Partner Prywatny nie złoży oferty.

Należy mieć na względzie, że praca nad Dokumentacją Postępowania nie sprowadza się wyłącznie do rund negocjacyjnych. Niemniej ważne jest to, co dzieje się przed Negocjacjami i po zakończeniu każdej tury. Okres pomiędzy kolejnymi rundami Negocjacji można określić mianem cyklu negocjacyjnego. W jego trakcie zarówno Podmiot Publiczny jak i Partnerzy Prywatni pracują nad poszczególnymi elementami Dokumentacji Postępowania, aby móc przedyskutować je wspólnie podczas najbliższej tury Negocjacji.

Stanowi to element zarządzania po stronie Zamawiającego procesem modyfikacji dokumentacji technicznej oraz pierwotnej wersji Umowy o PPP w trakcie Negocjacji.

Przykładowy przebieg jednego cyklu negocjacyjnego może kształtować się następująco:

Schemat 6. Przykładowy przebieg jednego cyklu negocjacyjnego



Przepisy prawa nie wymagają, aby w każdej turze Negocjacji uczestniczyła Komisja Przetargowa i Zespół Doradców w pełnym składzie. W takich jednak przypadkach konieczne byłoby zapewnienie właściwej koordynacji prac i sprawnego przepływu informacji pomiędzy tymi osobami, co wymaga zwykle odbywania dodatkowych spotkań oraz ustaleń. Rekomenduje się zatem, aby Zespół Projektowy brał udział we wszystkich spotkaniach negocjacyjnych, zwłaszcza że zagadnienia techniczne, finansowe i prawne – poruszane na poszczególnych turach Dialogu Konkurencyjnego – zazwyczaj "przenikają się". Obecność na wszystkich spotkaniach pozwala też lepiej zrozumieć zagadnienia i problemy adresowane w toku Negocjacji, jak również porównywać rozwiązania prezentowane przez poszczególnych wykonawców.

Nie ma natomiast potrzeby, aby cały skład Zespołu Projektowego spotykał się za każdym razem w celu dokonywania analizy rozwiązań, dyskusji i wypracowania stanowisk. Wystarczająca będzie praca nad Dokumentacją Postępowania realizowana przez członków zespołu o określonych kompetencjach (techniczne/finansowe/prawne).

W ramach współpracy pomiędzy Podmiotem Publicznym (Komisją Przetargową) a Zespołem Doradców następuje bieżąca wymiana informacji oraz kolejnych wersji Dokumentów Postępowania. Poniżej przedstawiono przykładowy schemat takiej współpracy. Schemat ten stanowi część 1 oraz 2 cyklu negocjacyjnego przedstawionego na Schemacie 7.

Schemat 7. Przykładowy schemat współpracy Komisji przetargowej i Zespołu Doradców



Należy dodać, że w niektórych turach Negocjacji uczestniczyć mogą biegli powoływani planowo lub *ad-hoc* (np. broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, specjalista ds. prawa pracy, audytor energetyczny i inni eksperci branżowi). Ponadto, w Negocjacjach mogą uczestniczyć Instytucje Finansujące, jednakże praktyka wskazuje, że banki komercyjne nie są skłonne do formalnego zaangażowania się w ocenę przedstawianej przez Zamawiającego Dokumentacji Postępowania na etapie Negocjacji oraz zaoferowania swoich usług i związania się z konkretnym Partnerem Prywatnym.

W przypadku Dialogu Konkurencyjnego, zgodnie z art. 183 Ustawy PZP Zamawiający może podzielić Dialog Konkurencyjny na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań, stosując kryteria oceny ofert określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Opisie Potrzeb i Wymagań, o ile skorzystanie z tej możliwości przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Opisie Potrzeb i Wymagań. Liczba rozwiązań uzyskana na ostatnim etapie musi zapewniać konkurencję, o ile istnieje wystarczająca liczba wykonawców.

Zamawiający informuje jednocześnie wszystkich wykonawców, których propozycje zostały zakwalifikowane do kolejnych etapów dialogu o wszelkich zmianach mających wpływ na treść kolejnych propozycji, w szczególności o zmianach związanych z opisem potrzeb Zamawiającego i cechami charakterystycznymi dostaw, robót budowlanych lub usług, stanowiących przedmiot zamówienia, warunkami umowy w sprawie zamówienia publicznego, tak aby poszczególni wykonawcy mieli jednakowo wystarczająco dużo czasu na zmodyfikowanie i ponowne złożenie kolejnych poprawionych propozycji.

Ponadto zgodnie z art. 184 ust. 2 Ustawy PZP o zakończeniu Dialogu Konkurencyjnego Zamawiający jednocześnie informuje wszystkich pozostałych uczestniczących w Dialogu Konkurencyjnym wykonawców, a do składania ofert zaprasza wykonawców, z którymi prowadził Dialog Konkurencyjny i którzy nie zostali wyeliminowani z Postępowania na poszczególnych etapach (art. 186 ust. 1 Ustawy PZP). Analogiczna regulacja dotyczy Trybu Negocyjacyjnego Podprogowego, w ramach którego zamawiający zaprasza wykonawców do złożenia ofert ostatecznych (art. 293 ust. 2 Ustawy PZP).

Poza formalnymi aspektami procedury negocjacyjnej, należy zwrócić uwagę na najważniejsze kwestie dotyczące sposobu prowadzenia Negocjacji. Przedstawiono je w poniższej tabeli.

Tabela 8. Dobre praktyki związane z prowadzeniem Negocjacji

Zagadnienie/kwestia	Dobre praktyki
Dialog, a nie monolog	Negocjacje powinny być konstruktywnym procesem wzajemnych uzgodnień. Za niedopuszczalne należy uznać zachowanie Podmiotu Publicznego polegające na ignorowaniu lub uporczywym nieuwzględnianiu wszelkich propozycji i uwag Partnerów Prywatnych. Należy słuchać Partnerów Prywatnych i w racjonalnym zakresie uwzględniać ich oczekiwania.
Rozwiązywanie problemów	Kwestii problematycznych lub spornych nie należy zostawiać na koniec. Od ich rozwiązania zależy może powodzenie całego Postępowania, a na pewno jakość Dokumentacji Postępowania.
Równe traktowanie Partnerów Prywatnych	Do wszystkich wykonawców należy podchodzić w taki sam sposób. Nie chodzi przy tym wyłącznie o równość formalną. Wykonawcy powinni uzyskiwać od Zamawiającego takie same informacje.
Agenda Negocjacji	Należy określać przedmiot poszczególnych spotkań, a Podmiot Publiczny musi być do nich dobrze przygotowany. Jednocześnie warto zachować pewną elastyczność – w trakcie tury poświęconej np. kwestiom technicznym, niejednokrotnie pojawi się konieczność omówienia zagadnień finansowych lub prawnych.
Informacja zwrotna	Istotne jest, aby Podmiot Publiczny przedstawiał wykonawcom jasne, rzetelne i uczciwe stanowisko w poszczególnych sprawach, również w formie pisemnej. W ten sposób można uniknąć nieporozumień, a Partnerzy Prywatni będą w stanie lepiej odpowiedzieć na potrzeby Podmiotu Publicznego.
Jasne komunikowanie potrzeb	Należy w sposób jasny i precyzyjny przekazywać Partnerom Prywatnym potrzeby Zamawiającego. Umożliwi to uniknięcie sytuacji, w których wykonawcy tracą czas i pieniądze na pracę nad rozwiązaniami, które są niepotrzebne lub nieakceptowalne.
Komunikacja i koordynacja	Ważne jest zapewnienie skutecznych kanałów komunikacji na linii Podmiot Publiczny – Partnerzy Prywatni, jak też w ramach Komisji Przetargowej i Komitetu Sterującego. Koordynacja prac Zespołu Projektowego pozwoli także na wyeliminowanie powielania pracy przez różne osoby.
Prawa własności intelektualnej	Podmiot Publiczny nie powinien wykorzystywać praw własności intelektualnej Partnerów Prywatnych w sposób wybiórczy, w szczególności po to, aby wzmacniać (lub osłabiać) rozwiązania innego wykonawcy. Szczególnie w zakresie praw własności intelektualnej należy pamiętać o tajemnicy przedsiębiorstwa i poufności Negocjacji.

Zagadnienie/kwestia Dobre praktyki

**Tempo prowadzenia
Negocjacji**

Odstępy między turami Negocjacji należy planować w taki sposób, ażeby uwzględnić konieczność przygotowania się stron do kolejnej tury, w tym wprowadzenie zmian do Dokumentacji Postępowania przez Podmiot Publiczny oraz zapoznanie się z Dokumentacją Postępowania w nowym brzmieniu przez Partnerów Prywatnych.

W zależności od składu Partnerów Prywatnych należy uwzględnić ewentualną konieczność tłumaczenia przez Partnerów Prywatnych Dokumentacji Postępowania na obcy język.

Odstępy pomiędzy poszczególnymi turami nie mogą być jednak zbyt długie, ażeby utrzymać presję konkurencyjną oraz zainteresowanie Postępowaniem.

Na uzasadnioną prośbę poszczególnych Partnerów Prywatnych Podmiot Publiczny w miarę możliwości powinien dostosować terminy poszczególnych tur Negocjacji do ich terminarza.

**Zakończenie
Negocjacji**

Zakończenie Negocjacji powinno nastąpić w momencie, gdy wszystkie zagadnienia zostały już przedyskutowane i przeanalizowane do tego stopnia, że Podmiot Publiczny może zakończyć pracę nad Dokumentacją Postępowania. Negocjacje powinny zakończyć się dla wszystkich Partnerów Prywatnych w tym samym czasie.

źródło: opracowanie na podstawie: Competitive Dialogue. How to undertake a Competitive Dialogue Procurement Process, The World Bank, October 2017.

DOBRE PRAKTYKI



Do dobrych praktyk PPP należy zaliczyć szczegółowe omawianie z Partnerami Prywatnymi wszelkich kluczowych kwestii dotyczących Projektu PPP. Dogłębna analiza istotnych zagadnień pozwoli uniknąć szeregu wątpliwości i zmniejszyć liczbę pytań do SWZ/Dokumentów Koncesji na etapie składania ofert przez wykonawców (por. też Punkt 7.2 Pytania do SWZ oraz Dokumentów Koncesji).

6.3.4 Aktualizacja Oceny Efektywności

Podmiot Publiczny powinien zaktualizować Ocenę Efektywności w przypadku, gdy podczas Negocjacji wystąpią okoliczności powodujące zmianę parametrów Projektu PPP. Mogą to być zmiany zaproponowane przez Partnerów Prywatnych lub zmiany na rynku mające wpływ na koszty Projektu PPP, w tym zarówno koszty związane z projektowaniem i budową, jak i koszty finansowe. Aktualizacja Oceny Efektywności, w szczególności analizy finansowo ekonomicznej i VfM, może być niezbędna także z powodu długości okresu, w trakcie którego prowadzono Negocjacje, jeśli był on dłuższy niż 6 miesięcy.

Metodyka przeprowadzenia Oceny Efektywności wskazana została w Wytocznych Tom I. W przypadku aktualizacji oceny jakościowej Podmiot Publiczny na nowo przypisuje punkty w tabeli jakościowej i ocenia zmianę w całkowitej punktacji. W przypadku oceny ilościowej aktualizacja

polega na wprowadzeniu nowych założeń do modelu finansowego i otrzymaniu nowych wyników. Celem aktualizacji jest sprawdzenie czy Podmiot Publiczny w wyniku zmian w dalszym ciągu osiąga wartość z realizacji Projektu PPP.

Podmiot Publiczny powinien przeprowadzić aktualizację oceny jakościowej i ew. oceny ilościowej w następujących okolicznościach:

- 1) w trakcie Negocjacji – rekomendowane w przypadku, gdy podział ryzyk oraz zakres Projektu PPP zaproponowane przez Podmiot Publiczny są nie do przyjęcia dla Partnerów Prywatnych i został przez nich zaproponowany inny podział ryzyk oraz zakres Projektu PPP, który powoduje wzrost nakładów inwestycyjnych lub zwiększenie kosztów operacyjnych. Do przesłanek aktualizacji Oceny Efektywności należy także wzrost wskaźników stóp procentowych powodujący wzrost kosztów finansowania Przedsięwzięcia;
- 2) po zakończeniu Negocjacji przed przekazaniem SWZ Partnerom Prywatnym – w przypadku, gdy wynegocjowany zakres Projektu PPP uległ zmianie. Aktualizacja będzie miała dwojakie zastosowanie: (a) pomoże w określeniu szacunkowej wartości zamówienia oraz (b) potwierdzi, czy Projekt PPP w dalszym ciągu generuje VfM;
- 3) po otrzymaniu ofert – w celu potwierdzenia, że Projekt PPP w dalszym ciągu generuje wartość dla Podmiotu Publicznego, szczególnie jeśli czas na składanie ofert wynosił 6 miesięcy lub więcej i w tym czasie sytuacja na rynku uległa znaczącym zmianom, powodując wzrost cen materiałów budowlanych, wzrost kosztów finansowania lub zmiany prawa skutkujące dodatkowymi kosztami dla Partnerów Prywatnych.

Aktualizacja Oceny Efektywności nie będzie ograniczała się wyłącznie do Value for Money. Skutkiem aktualizacji Oceny Efektywności może być także konieczność zmiany założeń lub rozwiązań przyjętych w analizie prawnej, podatkowej, technicznej, ryzyka.

6.4 Zasady dokumentowania Negocjacji

Przepisy prawa nie nakładają na Podmiot Publiczny obowiązku dokumentowania prowadzonych Negocjacji w określony sposób. Niemniej jednak, w praktyce Postępowania PPP przyjęte zostały następujące rozwiązania:

- 1) rejestrowanie przebiegu Negocjacji za pomocą systemów audio (rzadziej – video, przy czym w przypadku Negocjacji odbywanych on-line rejestracja video stanowi dobrą praktykę) - zaleca się, aby możliwość ta została przewidziana wprost w regulaminie Negocjacji; Partnerzy Prywatni powinni wyrazić zgodę na rejestrowanie Negocjacji, zaś z uwagi na poufny charakter dialogu, nośniki muszą być przechowywane w bezpiecznym miejscu; nagrywanie Negocjacji umożliwia prześledzenie ich przebiegu w przypadku wątpliwości co do ustnych stanowisk prezentowanych podczas sesji dialogowych, ułatwia także sporządzenie rzetelnego protokołu z odbywanych spotkań negocjacyjnych;
- 2) sporządzanie notatek z każdej tury Negocjacji – notatki służą w praktyce sporządzeniu protokołu z tury Negocjacji; powinny być na tyle szczegółowe, aby osoba zajmująca się protokolowaniem przebiegu spotkania mogła z łatwością sporządzić protokół;
- 3) sporządzanie protokołu z każdej tury Negocjacji – protokół powinien zawierać kluczowe kwestie i ustalenia; w żadnym razie nie stanowi on pełnego zapisu Negocjacji; w razie wątpliwości istnieje możliwość odtworzenia ich przebiegu w oparciu o sporządzone notatki lub nagrania.

UWAGA



Ustalenia dokonywane z Partnerami Prywatnymi w trakcie Negocjacji nie mają wiążącego charakteru. Zarówno Zamawiający, jak i Partnerzy Prywatni mogą zmieniać zajmowane wcześniej stanowiska. Pomimo tego, Negocjacje prowadzone rzetelnie i w dobrej wierze wymagają przedstawiania przemyślanych propozycji, rozwiązań i stanowisk. Tylko w ten sposób możliwe jest doprowadzenie do stworzenia Dokumentacji Postępowania o dobrej jakości.

W przypadku, gdy Podmiot Publiczny zamierza zmienić stanowisko w istotnej dla wykonawców lub Projektu PPP kwestii, powinien przedstawić taką zmianę Partnerom Prywatnym (wraz z uzasadnieniem) do ewentualnej dalszej dyskusji w ramach Negocjacji.

6.5 Opracowanie ostatecznej Dokumentacji Postępowania

6.5.1 Postępowanie PZP – SWZ

Specyfikacja Warunków Zamówienia jest dokumentem (a raczej zbiorem dokumentów), który powstaje w toku Postępowania PPP.

Ostateczna treść SWZ w Dialogu Konkurencyjnym musi zawierać wszelkie informacje, o których mowa w art. 134 ust. 1 i 2 Ustawy PZP, z wyjątkiem art. 134 ust. 2 pkt 11. To ostatnie wyłączenie wynika z faktu, że w Dialogu Konkurencyjnym nie stosuje się tzw. odwróconej oceny ofert właściwej dla przetargu nieograniczonego, w ramach której Zamawiający może najpierw ocenić ofertę, a potem wezwać do złożenia JEDZ. W Trybie Negocjacyjnym Podprogowym SWZ zawiera natomiast informacje, o których mowa w art. 281 ust. 1 pkt 1–3 i 5–19 i ust. 2 (art. 295 ust. 3 Ustawy PZP).

Poza informacjami określonymi wcześniej w ogłoszeniu o zamówieniu i OPIW, obejmują one m.in. termin związania ofertą; opis sposobu przygotowywania ofert; miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; opis Kryteriów Oceny Ofert; istotne postanowienia Umowy o PPP; wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; informacje o formalnościach, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia Umowy o PPP.

Termin związania ofertą

Oferta Partnera Prywatnego stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy o PPP (por. art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego). Termin związania ofertą wyznacza zatem ramy czasowe tego oświadczenia.

Termin związania ofertą, zgodnie z art. 220 Ustawy PZP, wynosi maksymalnie 90 dni, a 120 dni – jeżeli wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro, a dla dostaw lub usług – 10 000 000 euro od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Przykładowo, jeżeli termin składania ofert wyznaczony jest na 27 maja, pierwszym dniem terminu związania ofertą będzie 27 maja.

Zamawiający określa w dokumentach zamówienia termin związania ofertą przez wskazanie daty. W Postępowaniach PPP, z uwagi na stosowanie pozacenowych, a czasem dosyć złożonych Kryteriów Oceny Ofert, zaleca się stosowanie maksymalnych terminów związania ofertą. Rekomendacja ta dotyczy w szczególności Postępowań, w ramach których stosowane są kryteria

niewymierne, wymagające od Zamawiającego pogłębionej analizy złożonych ofert (np. kryterium właściwości estetycznych lub organizacji Przedsięwzięcia).

Uchylenie się przez Partnera Prywatnego od zawarcia Umowy w terminie związania ofertą, jeżeli wynika z przyczyn leżących po jego stronie, skutkowało będzie utratą wadium.

W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody. W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Po upływie terminu związania ofertą (w przypadku braku jego przedłużenia) wykonawca może odmówić podpisania umowy bez negatywnych konsekwencji.

W Trybie Negocjacyjnym Podprogowym wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego datą w dokumentach zamówienia, jednak nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni (por. art. 307 Ustawy PZP).

Poza aspektami formalnymi oraz Kryteriami Oceny Ofert, najistotniejszą część SWZ stanowią załączniki obejmujące m.in. istotne postanowienia Umowy o PPP, dokumentację techniczną oraz inne, takie jak np. zakres informacji do opracowania modelu finansowego (por. Punkt 6.5.5 Dokumentacja techniczna i Punkt 6.5.6 Dokumentacja finansowa). W praktyce – co stanowi cechę charakterystyczną Postępowań PPP – SWZ tworzona jest w oparciu o prowadzone Negocjacje.

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby SWZ wraz z załącznikami stanowiła dokument nie tylko poprawny pod względem formalnym, ale też jak najbardziej szczegółowy i wewnętrznie spójny. Od jakości Dokumentacji Postępowania zależy bowiem powodzenie całego Postępowania PPP, w tym uzyskanie przez Podmiot Publiczny ofert odpowiadających jego potrzebom i możliwościom.

6.5.2 Postępowanie Koncesyjne – Dokumenty Koncesji

W przypadku koncesji ustawodawca nie przewidział instytucji SWZ. Ustawa o Umowie Koncesji odnosi się w ogólny sposób do Dokumentów Koncesji, którymi są w zasadzie wszystkie dokumenty opracowywane przez Zamawiającego związane z Postępowaniem. Zamawiający może określić w Opisie Przedmiotu Umowy Koncesji wymagania związane z realizacją Umowy, które mogą obejmować aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem (art. 27 Ustawy o Umowie Koncesji). Natomiast stosownie do art. 26 tej ustawy, Zamawiający zobowiązany jest do dookreślania w Dokumentach Koncesji m.in. wymogów technicznych lub funkcjonalnych robót budowlanych, lub usług, będących przedmiotem Umowy. Wymogi te nie mogą być opisywane w sposób utrudniający uczciwą konkurencję tj. przez wskazanie znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (ewentualnie dopuszczalne jest posługiwaniem się terminem "lub równoważne").

Inaczej niż w przypadku stosowania Ustawy PZP, w Umowie o PPP zawieranej w trybie Postępowania Koncesyjnego Zamawiający powinien określić wymagania zatrudnienia przez Koncesjonariusza (lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji Umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W takim przypadku w opisie przedmiotu Umowy należy określić sposób dokumentowania zatrudnienia takich osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania tych wymagań (a także sankcje w przypadku ich niespełniania) oraz rodzaje czynności niezbędnych do realizacji Umowy, których dotyczą wymagania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.

Dokumenty Koncesji przekazywane wraz z zaproszeniem do składania ofert powinny być spójne, precyzyjne i szczegółowe. Od Dokumentacji Postępowania zależy bowiem uzyskanie przez Podmiot Publiczny ofert odpowiadających jego potrzebom i możliwościom.

6.5.3 Doprecyzowanie Kryteriów Oceny Ofert

Na etapie opracowywania SWZ/Dokumentów Koncesji jednym z istotnych zadań Podmiotu Publicznego jest doprecyzowanie opisu Kryteriów Oceny Ofert. Jak wskazano w Punkcie 4.5.1 Zagadnienia wspólne, dobrą praktykę Projektów PPP stanowi ustalanie szczegółowego znaczenia Kryteriów Oceny Ofert dopiero po przeprowadzonych Negocjacjach. Dzięki temu, Podmiot Publiczny jest w stanie lepiej dopasować Kryteria Oceny Ofert do swoich potrzeb.

W pierwszej kolejności Podmiot Publiczny powinien dookreślić Kryteria Oceny Ofert, jeżeli kryteria przyjęte w ogłoszeniu o zamówieniu/koncesji nie były jeszcze określone w sposób szczegółowy (np. kryterium wartości technicznej nowego środka trwałego, funkcjonalności budynku w zakresie dostępności dla określonych grup Użytkowników itp.). W uszczegółowieniu takich kryteriów pomocne może być Rozporządzenie w sprawie Ryzyka, które określa kilkadziesiąt przykładowych jego rodzajów.

PRZYKŁAD



Podmiot Publiczny prowadzi Postępowanie, którego przedmiotem jest budowa i eksploatacja parkingu podziemnego na 500 miejsc postojowych w ramach PPP. Zgodnie z założeniami Projektu PPP, Podmiot Publiczny ma wynająć od Partnera Prywatnego do 50 miejsc parkingowych w okresie obowiązywania Umowy. Zamawiający jako jedno z kryteriów przyjął organizację myjni samochodowej. Rozwiązania proponowane przez Partnerów Prywatnych w toku Negocjacji doprowadziły do następującego sprecyzowania tego kryterium:

Kryterium: Organizacja myjni samochodowej.

Podkryterium 1: Liczba stanowisk przeznaczonych do mycia pojazdów.

Podkryterium 2: Zastosowanie ekologicznych środków czystości.

Podkryterium 3: Organizacja stanowiska bezobsługowego.

PRZYKŁAD



Hipotetyczny Zamawiający, na etapie ogłoszenia o koncesji, wskazał jako jedno z Kryteriów Oceny Ofert: jakość obsługi Użytkowników świadczonej usługi użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego. Po przeprowadzeniu Negocjacji i omówieniu z Partnerami Prywatnymi zakresu, sposobu i warunków świadczenia usługi, Zamawiający może doprecyzować to kryterium w następujący sposób:

Kryterium: jakość obsługi Użytkowników.

Podkryterium 1: Zapewnienie kursowania pojazdów niskopodłogowych.

Podkryterium 2: Dostęp Użytkowników do elektronicznego systemu obsługi klienta.

Podkryterium 3: Godziny otwarcia punktu obsługi klientów.

Jak wynika z powyższego przykładu, nawet posłużenie się kryteriami bardziej szczegółowymi nie oznacza jeszcze, że będą one w pełni precyzyjnie określone. Z tego powodu niezwykle ważne jest, aby Podmiot Publiczny dokładnie opisał każde z Kryteriów Oceny Ofert w taki sposób, aby jego ocena nie budziła wątpliwości.

PRZYKŁAD



Ryzyko związane z warunkami meteorologicznymi na etapie budowy można opisać w następujący sposób:

Partner Prywatny ponosi ryzyko prowadzenia robót budowlanych bez względu na warunki atmosferyczne. Oznacza to, że z wyłączeniem przypadków siły wyższej, określonych w Umowie o PPP, dla zachowania zakresu i terminu wykonania robót budowlanych nie mają znaczenia warunki pogodowe, w tym intensywne opady deszczu, śniegu, silne wiatry, burze, susze i inne zjawiska atmosferyczne.

W PPU można określić, że w przypadku uciążliwych warunków atmosferycznych, utrzymujących się przez określony czas, Partner Prywatny ma prawo przerwać prowadzone roboty budowlane bez stosowania wobec niego sankcji za nienależyte wykonywanie Umowy).

Zamawiający musi wskazać dla każdego z Kryteriów Oceny Ofert wagę, aby określić jego znaczenie przy dokonywaniu oceny i porównywaniu ofert. Waga kryteriów wyrażana jest wartością procentową. Na sumę Kryteriów Oceny Ofert (100%) składają się zatem poszczególne kryteria określone przez Zamawiającego, wraz z przypisanymi im wagami. Należy przypomnieć, że im wyższą wagę kryteriów pozacenowych zastosuje Zamawiający, tym większe będzie ich znaczenie w trakcie oceny ofert. Przyjmuje się bowiem, że jeżeli kryterium ceny wynosi ponad 60%, to w praktyce zazwyczaj rozstrzyga ono o wyborze oferty najkorzystniejszej i Zamawiający nie uzyskuje realnych korzyści z zastosowania kryteriów pozacenowych.

PRZYKŁAD



Planowane Przedsięwzięcie dotyczy rewitalizacji obiektów miejskich i nadania im nowych funkcji publicznych i komercyjnych.

W ogłoszeniu o zamówieniu Podmiot Publiczny formułuje następujące Kryteria Oceny Ofert:

- 1) ryzyko popytu;
- 2) efektywność wykorzystania składników majątkowych;
- 3) terminy i wysokość płatności.

Na tym etapie nie określa jeszcze dokładnego znaczenia Kryteriów Oceny Ofert, przyjmując jedynie powyższą ich kolejność.

Po przeprowadzonych Negocjacjach jest w stanie dookreślić Kryteria Oceny Ofert i nadać im wagi, przykładowo:

- 1) Ryzyko popytu: 45%.
Podkryterium 1: Ryzyko popytu związane z funkcjami komercyjnymi: 40%.
Podkryterium 2: Ryzyko popytu związane z usługami społecznymi: 5%.
- 2) Efektywność wykorzystania składników majątkowych: 40%.
Podkryterium 1: Liczba dodatkowych usług publicznych: 20%.
Podkryterium 2: Funkcjonalność rozwiązań (funkcje budynków, rozwiązania komunikacyjne): 20%.
- 3) Terminy i wysokość płatności: 15%.
Podkryterium 1: Wysokość miesięcznej dopłaty na rzecz Partnera Prywatnego: 10%.
Podkryterium 2: Termin płatności na rzecz Partnera Prywatnego co 1, 2 lub 3 miesiące: 5%.

PRZYKŁAD



Planowany Projekt dotyczy zarządzania krytą pływalnią w ramach koncesji na usługi.

W ogłoszeniu o koncesji Podmiot Publiczny formułuje następujące Kryteria Oceny Ofert:

- 1) Opłaty od Użytkowników;
- 2) jakość obsługi.

Na tym etapie nie określa jeszcze dokładnego znaczenia Kryteriów Oceny Ofert, przyjmując jedynie powyższą ich kolejność.

Po przeprowadzonych Negocjacjach Zamawiający określił w Dokumentach Koncesji m.in. maksymalne stawki za jedną godzinę pływania oraz minimalne wymogi dotyczące zakresu obsługi osób korzystających z pływalni. Założeniem Podmiotu Publicznego jest

m.in. uatrakcyjnienie oferty pływalni, w związku z czym przed zaproszeniem do składania ofert sformułował następujące podkryteria i ich wagi:

1) Opłaty od Użytkowników: opłata za jedną godzinę pływania: 55%.

2) Jakość obsługi: 45%.

Podkryterium 1: Organizacja zajęć nauki pływania dla dorosłych: 25%.

Podkryterium 2: Organizacja zajęć na pływalni dla rodziców z małymi dziećmi: 20%.

Podmiot Publiczny zobowiązany jest do szczegółowego i precyzyjnego opisu sposobu oceny ofert. Wszystkim Kryteriom Oceny Ofert musi zostać przyporządkowana odpowiednia punktacja.

W przypadku Kryteriów Oceny Ofert mierzalnych możliwe będzie ustalenie punktacji z wykorzystaniem wzorów matematycznych. Najczęściej stosuje się dwa rodzaje wzorów służących do obliczenia punktów przyznawanych ofertom:

- 1) Kryterium malejące – wzór "mniej – lepiej" – stosowane wówczas, gdy Zamawiającemu zależy na uzyskaniu jak najniższych wartości (np. termin wykonania robót budowlanych, okres zawarcia umowy koncesji, czas na usunięcie awarii);
- 2) Kryterium rosnące – wzór "więcej – lepiej" – stosowane wtedy, gdy Zamawiający premiuje osiągnięcie jak najwyższych wartości (np. liczba dodatkowych godzin udostępnienia obiektu Użytkownikom, wydłużenie pracy infolinii lub helpdesku, większe upusty cenowe na rzecz określonych grup Użytkowników obiektu).

PRZYKŁAD



W projekcie dotyczącym budowy i utrzymania dróg można zastosować następujący sposób punktowania Kryteriów Oceny Ofert.

Lp.	Kryterium "Czas"	Czas zgodnie ze standardem utrzymania wymaganym przez Podmiot Publiczny	Zaoferowany przez Partnera Prywatnego czas reakcji	Przyznana liczba punktów
1	czas na usuwanie ubytków w jezdni	48 godzin	24 godziny	10
2	czas na usuwanie wybojów w jezdni	24 godziny	6 godzin	20

Sposób przyznawania punktacji w ramach kryterium:			
Lp.	Kryterium "Czas"	Możliwa do uzyskania punktacja	
1	czas na usuwanie ubytków w jezdni - 48 godzin	0	
2	czas na usuwanie ubytków w jezdni - 24 godziny	10	
3	czas na usuwanie ubytków w jezdni - 12 godzin	20	

Lp.	Kryterium "Czas"	Możliwa do uzyskania punktacja	
1	czas na usuwanie wybojów w jezdni – 24 godziny	0	
2	czas na usuwanie wybojów w jezdni – 12 godziny	10	
3	czas na usuwanie wybojów w jezdni – 6 godzin	20	

Podobnie, w przypadku stosowania kryteriów niemierzalnych, na Podmiocie Publicznym spoczywa obowiązek ich kwantyfikacji i ustalenia liczby punktów przyznawanych w ramach danego Kryterium Oceny Ofert. Przykładowo, Zamawiający może ustalić przedziały, w ramach których przyznawał będzie punkty za spełnienie określonych wymogów wskazanych w danym Kryterium Oceny Ofert.

PRZYKŁAD	
Kryterium: jakość rozwiązań funkcjonalnych i architektonicznych (waga: 15%, liczba punktów do uzyskania: 15): 1) zagospodarowanie powierzchni wewnętrznych (w tym pomieszczenia, przejścia, łączniki): 0 – 5 pkt; 2) funkcjonalność zaproponowanych rozwiązań: 0 – 5 pkt; 3) architektoniczna jakość przestrzeni: 0 – 5 pkt.	

Formalnie możliwe jest również posługiwanie się przez Zamawiającego opisowym (a nie matematycznym) określeniem sposobu przyznawania punktacji w ramach Kryteriów Oceny Ofert. Taka metoda, z uwagi na ryzyko dokonania nieprecyzyjnego – a przez to – niejednoznacznego opisu, nie jest jedną rekomendowana.

W odniesieniu do niektórych Kryteriów Oceny Ofert Zamawiający nie będą w ogóle stosowali stopniowania skali punktowej, przyznając określoną liczbę punktów za spełnienie danego Kryterium Oceny Ofert (np. przejście przez Partnera Prywatnego ryzyka protestów społecznych: 10 pkt, brak przejścia tego ryzyka: 0 pkt; zastosowanie standardu *Building Information Modeling* do projektowania i zarządzania obiektem: 5 pkt, niezastosowanie tego standardu: 0 pkt).

Po dokonaniu doprecyzowania, szczegółowego opisu i zasad przyznawania punktacji w ramach Kryteriów Oceny Ofert, Zamawiający zamieszcza tę informację w SWZ.



PRZYKŁAD

W Postępowaniu PPP dotyczącym budowy i utrzymania obiektu urzędu (np. ministerstwa, urzędu centralnego, ratusza miejskiego), można sformułować następujące Kryteria Oceny Ofert oraz opis sposobu dokonywania ich oceny.

"Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny (wynagrodzenia Partnera Prywatnego) i pozostałych Kryteriów Oceny Ofert odnoszących się do Przedsięwzięcia, tj. uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie ze wszystkich Kryteriów Oceny Ofert.

Kryteriami Oceny Ofert są:

Lp.	Kryterium	Waga
1.	Opłata za Dostępność (OzD)	90 %
2.	Skrócenie czasów reakcji na wystąpienie awarii	5 %
3.	Termin wykonania robót budowlanych	5 %
RAZEM:		100 %

Punkty przyznawane za podane wyżej Kryteria Oceny Ofert będą liczone według następujących wzorów:

KRYTERIUM 1 - "OzD" - 90%

W ramach kryterium "OzD" Zamawiający dokona oceny zaoferowanej przez wykonawców łącznej ceny brutto realizacji Zamówienia określonego zgodnie z poniższym opisem.

Wykonawca podaje w ofercie OzD w kwocie brutto. OzD ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót budowlanych objętych dokumentacją projektową oraz zapewnienia przez Partnera Prywatnego dostępności obiektu, w tym w szczególności ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy o PPP, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wysokości łącznej kwoty wynagrodzenia określonej w ofercie.

OzD należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ i załączniku do formularza ofertowego.

Na łączną OzD brutto składa się:

- wynagrodzenie za etap robót brutto;
- opłata z tytułu rozłożenia płatności w czasie wynagrodzenia za etap robót brutto;
- wynagrodzenie za etap utrzymania brutto.

OzD = wynagrodzenie za etap robót brutto + opłata z tytułu rozłożenia w czasie płatności wynagrodzenia za etap robót brutto + wynagrodzenie za etap utrzymania brutto.

Wynagrodzenie za etap robót brutto należy podać jako cenę ryczałtową brutto. Cena ta powinna być wyliczona na podstawie opisu przedmiotu zamówienia Umowy o PPP.

Opłatę z tytułu rozłożenia w czasie płatności wynagrodzenia za etap robót brutto należy podać jako cenę za wykonanie obowiązków wykonawcy związanych z zapewnieniem finansowania za okres od dnia zawarcia Umowy o PPP do dnia zakończenia Umowy o PPP.

Wynagrodzenie za etap utrzymania brutto należy podać jako cenę za wykonanie obowiązków określonych w załączniku do Umowy o PPP.

Zasady waloryzacji wynagrodzenia za etap utrzymania oraz sposób kalkulacji opłaty z tytułu rozłożenia w czasie płatności wynagrodzenia za etap robót brutto określa Umowa o PPP.

OzD musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), niezależnie od wchodzących w jej skład elementów z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować VAT. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN).

Wykonawca winien łączną OzD brutto realizacji zamówienia zamieścić we wskazanym polu w formularzu ofertowym oraz dokonać szczegółowej kalkulacji cenowej w załączniku formularza ofertowego.

Oferta o najniższej łącznej OzD brutto uzyska 90 punktów przy założeniu, że 1% = 1 pkt.

Metodologia punktacji:

$$X1 = R * (OzDn/Ozdb)$$

gdzie:

X1 – wartość punktowa

R – ranga = 90

OzDn – najniższa cena ofertowa

OzDb – cena badanej oferty

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

KRYTERIUM 2 - "SKRÓCENIE CZASÓW REAKCJI na WYSTĄPIENIE AWARII" - 5%

W ramach kryterium ocenie poddane zostanie deklarowany czas reakcji na wystąpienie awarii (X2)

X2 – wartość punktowa

	Wartość punktowa
Skrócenie czasów reakcji na wystąpienie awarii o 30%	5 pkt
Skrócenie czasów reakcji na wystąpienie awarii o 20%	3 pkt
Skrócenie czasów reakcji na wystąpienie awarii o 10%	2 pkt

Wykonawca otrzyma odpowiednio 5, 3 lub 2 punkty za wybór jednego ze wskazanych czasów reakcji. Jeśli wykonawca nie dokona wyboru żadnego z ww. czasów reakcji, otrzyma 0 pkt.

KRYTERIUM 3 - "TERMIN WYKONANIA ETAPU ROBÓT" - 5%

W ramach kryterium "Termin wykonania etapu robót" ocenie poddane zostanie ryzyko ukończenia etapu robót przed maksymalnym terminem 24 miesięcy.

Maksymalny termin wykonania etapu robót	Wartość punktowa
24 miesiące	0 pkt
20 miesięcy	2 pkt
16 miesięcy	5 pkt

Oferta wykonawcy, który zaoferuje realizację etapu robót w terminie dłuższym niż 24 miesiące lub krótszym niż 16 miesięcy lub w niepełnych miesiącach, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP jako oferta, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

X3 – wartość punktowa

Oferta o najkrótszym terminie wykonania etapu robót uzyska maksymalnie 5 punktów przy założeniu, że 1% = 1 pkt.

Oferty zostaną ocenione zgodnie z poniższym wzorem:

$$SO = X1 + X2 + X3$$

gdzie:

SO – łączna suma punktów oferty

X1 – liczba punktów uzyskana przez wykonawcę w ramach Kryterium 1

X2 – liczba punktów uzyskana przez wykonawcę w ramach Kryterium 2

X3 – liczba punktów uzyskana przez wykonawcę w ramach Kryterium 3

Jeśli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie oferty przedstawiają taki sam bilans OzD i innych Kryteriów Oceny Ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą OzD.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający może żądać od wykonawców sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym, że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz zmian wymagań zawartych w SWZ".

W Postępowaniach Koncesyjnych stosowane są takie same zasady oceny Kryteriów Oceny Ofert, jak w Postępowaniach PZP.

PRZYKŁAD



W Postępowaniu PPP dotyczącym budowy i eksploatacji parkingu podziemnego, można sformułować następujące Kryteria Oceny Ofert oraz opis sposobu dokonywania ich oceny.

"Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny (wynagrodzenia Partnera Prywatnego) i pozostałych Kryteriów Oceny Ofert odnoszących się

do Przedsięwzięcia, tj. uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie ze wszystkich Kryteriów Oceny Ofert.

Kryteriami Oceny Ofert są:

Lp.	Kryterium	Waga
1.	Opłaty od Użytkowników	750 %
2.	Rozwiązania funkcjonalne	150 %
3.	Elektromobilność	10 %
RAZEM:		100 %

Punkty przyznawane za podane wyżej Kryteria Oceny Ofert będą liczone według następujących wzorów:

KRYTERIUM 1 - "Opłaty od Użytkowników" - 750%

W ramach kryterium "Opłaty od Użytkowników" Zamawiający dokona oceny zaoferowanej przez wykonawców maksymalnej ceny brutto za jedną godzinę parkowania na parkingu podziemnym.

Oferta o najniższej łącznej cenie brutto uzyska 75 punktów przy założeniu, że 1% = 1 pkt.

Metodologia punktacji:

$$X1 = R * (Cn/Cb)$$

gdzie:

X1 – wartość punktowa

R – ranga = 75

Cn – najniższa cena OoU

Cb – cena OoU badanej oferty

Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

KRYTERIUM 2 - "PODZIAŁ ZADAŃ I RYZYK" - 15%

W ramach kryterium "Podział zadań i ryzyk" ocenie poddane zostaną następujące kryteria (X2)

X2 – wartość punktowa

Rozwiązania funkcjonalne	Wartość punktowa
Zagospodarowanie i utrzymywanie terenów zielonych na powierzchni parkingu	10 pkt
Zapewnienie sanitariatów, w tym dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodziców z małymi dziećmi	5 pkt

Wykonawca otrzyma odpowiednio 10 oraz 5 punktów za wykonanie każdego ze wskazanych zadań (łącznie nie więcej niż 15 punktów). Jeśli wykonawca nie wskaże w ofercie przejęcia żadnego z ww. zadań otrzyma 0 pkt.

KRYTERIUM 3 – "ELEKTROMOBILNOŚĆ" – 10%

W ramach kryterium "Elektromobilność" ocenie poddana zostanie liczba stacji ładowania samochodów elektrycznych zainstalowanych na parkingu przez wykonawcę.

Liczba zainstalowanych stacji ładowania samochodów elektrycznych

Wartość punktowa

1 sztuka	0 pkt
3 sztuki	5 pkt
5 sztuk	10 pkt

Oferta wykonawcy, który zaoferuje mniejszą niż 1 lub większą niż 5 sztuk stacji ładowania samochodów elektrycznych, zostanie odrzucona na podstawie pkt [...] Dokumentów Koncesji, jako oferta, której treść nie odpowiada treści Dokumentów Koncesji.

X3 – wartość punktowa

Oferta o najwyższej liczbie zainstalowanych stacji ładowania samochodów elektrycznych uzyska maksymalnie 10 punktów przy założeniu, że 1% = 1 pkt.

Oferty zostaną ocenione zgodnie z poniższym wzorem:

$$SO = X1 + X2 + X3$$

Gdzie:

SO – łączna suma punktów oferty

X1 – liczba punktów uzyskana przez wykonawcę w ramach Kryterium 1

X2 – liczba punktów uzyskana przez wykonawcę w ramach Kryterium 2

X3 – liczba punktów uzyskana przez wykonawcę w ramach Kryterium 3

Jeśli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie oferty przedstawiają taki sam bilans Opłaty od Użytkowników i innych Kryteriów Oceny Ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą OoU.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, a także sprecyzowania lub dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, zgodnie z pkt [...] Dokumentów Koncesji".

ŹRÓDŁA INFORMACJI



Kryteria oceny ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – przykłady i zastosowanie, pod red. J. Sadowego, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2011.

Należy zwrócić uwagę, iż ocena ofert może zostać również dokonana w oparciu o wartość bieżącą przepływów pieniężnych (NPV) wskazaną przez Partnerów Prywatnych. W celu zapewnienia porównywalności ofert Podmiot Publiczny powinien wskazać Partnerom Prywatnym założenia dotyczące wysokości stopy dyskonta.

Niemniej jednak w Projektach PPP, w których wynagrodzenie stanowi Opłata za Dostępność ze strony Podmiotu Publicznego właściwsze jest podanie jednej wartości niż poleganie na wartości bieżącej.

6.5.4 Istotne postanowienia Umowy o PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom III: Część I Punkt 2.1 – Warunki konieczne Umowy o PPP

Tom III: Część I Punkt 2.2 – Istotne warunki Umowy o PPP

Tom III: Część I Punkt 2.6 – Zakres zastosowania Ustawy PZP do Umowy o PPP

Tom IV: Część I Punkt 1 – Charakterystyka i znaczenie Zarządzania Umową o PPP

Tom IV: Część II Punkt 1.3 – Umowa o PPP – proces negocjacyjny i postanowienia istotne z punktu widzenia Zarządzania Umową o PPP

6.5.4.1 Zagadnienia wspólne

Przepisy Ustawy o PZP wskazują na PPU jako element SWZ (w przeciwieństwie do Ustawy o Umowie Koncesji, choć w praktyce PPU stanowią w tym przypadku jeden z Dokumentów Koncesji). W Postępowaniach PPP postanowienia Umowy kształtowane są w toku Negocjacji i po ich zakończeniu stanowią gotowe PPU.

Należy podkreślić, że PPU, a docelowo – Umowa o PPP wraz z załącznikami, stanowiąca zasadniczy element Dokumentacji Postępowania, decydować będzie o powodzeniu Projektu PPP (szerzej na ten temat patrz Punkt 1.4 Wysoka jakość Dokumentacji Postępowania). Z tego względu zaleca się najwyższą staranność w konstruowaniu jej postanowień. W przypadku PPP błędem jest dążenie do jak najszybszego opracowania ostatecznej wersji PPU kosztem jakości tego dokumentu.

Szersze informacje o postanowieniach Umowy o PPP w formule Opłaty za Dostępność zostały zawarte w Wytycznych Tom III – Umowa o PPP.

Układ treści PPU z załącznikami może ulec pewnej zmianie na etapie Zamknięcia Komercyjnego. Przykładowo, jeśli w PPU nie uwzględniono oferty Partnera Prywatnego lub warunków finansowania, dokumenty te będą musiały zostać załączone do Umowy o PPP, co wpłynie na zmianę kolejności załączników. Z tego powodu zaleca się przy opracowywaniu PPU uwzględniać docelową strukturę Umowy o PPP. Wówczas nie trzeba będzie modyfikować układu Umowy.

Co do zasady zakres merytoryczny Umowy Koncesji oraz spis załączników będzie zbliżony do Umowy o PPP. Oczywiście szczegółowe regulacje będą się różnić, chociażby z uwagi na inne regulacje dotyczące wynagrodzenia, którym w przypadku umowy koncesji na roboty budowlane jest prawo do eksploatacji Infrastruktury Publicznej.

6.5.4.2 Ustawa o PPP

Ustawa o PPP wskazuje określony zakres postanowień kształtujących Umowę o PPP w przepisie art. 7 (*essentialia negotii*).

Umowa o PPP określa zobowiązanie Partnera Prywatnego do realizacji Projektu PPP za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a Podmiot Publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu Przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego. Wynagrodzenie Partnera Prywatnego zależy przy tym od rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej dostępności Infrastruktury Publicznej albo usługi publicznej, co stanowi istotną różnicę pomiędzy PPP, a tradycyjnymi zamówieniami publicznymi (szerzej na ten temat patrz Wytyczne Tom I).

Ustawa o PPP wymaga, aby Umowa o PPP określała skutki nienależytego wykonania i niewykonania zobowiązania, w szczególności kary umowne lub obniżenie wynagrodzenia Partnera Prywatnego.

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 Ustawy o PPP, w przypadku, gdy wybór Partnera Prywatnego następować będzie w Postępowaniu PZP, wówczas również do Umowy o PPP stosować się będzie przepisy Ustawy PZP w zakresie nieuregulowanym w Ustawie o PPP. Analogiczny przepis dotyczy Ustawy o Umowie Koncesji, stosowanej jako regulacja proceduralna do wyboru Partnera Prywatnego, w myśl art. 4 ust. 2 Ustawy o PPP (na temat podstaw prawnych i procedury wyboru Partnera Prywatnego zob. Punkt 2 Podstawy prawne oraz tryby wyboru Partnera Prywatnego). W efekcie, o ile Ustawa o PPP nie stanowi inaczej, Umowa o PPP podlegać będzie odpowiednio reżimowi Ustawy PZP albo Ustawy o Umowie Koncesji.

W kontekście Negocjacji projektu Umowy o PPP, a następnie przygotowania PPU i ich ewentualnych zmian na etapie pytań do SWZ, warto zwrócić szczególną uwagę na trzy następujące przepisy Ustawy o PPP:

- 1) art. 1 ust. 2, wyrażający definicję PPP, zgodnie z którą Partnerstwo Publiczno-Prywatne polega na wspólnej realizacji Przedsięwzięcia opartej na podziale zadań i ryzyk pomiędzy Podmiotem Publicznym i Partnerem Prywatnym;
- 2) art. 7 ust. 2, zgodnie z którym wynagrodzenie Partnera Prywatnego zależy przede wszystkim od rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej dostępności przedmiotu Przedsięwzięcia;
- 3) art. 18a ust. 1, który stanowi, że zobowiązania wynikające z Umów PPP nie wpływają na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych w sytuacji, gdy Partner Prywatny ponosi większość ryzyka budowy oraz większość ryzyka dostępności lub ryzyka popytu – z uwzględnieniem wpływu na wymienione ryzyka czynników takich jak gwarancje i finansowanie przez Podmiot Publiczny oraz alokacja aktywów po zakończeniu trwania Umowy o PPP.

W powyższych regulacjach zawarta jest bowiem istota współpracy w ramach PPP. Współpraca ta z jednej strony ma się opierać o podział zadań i ryzyk pomiędzy stronami Umowy o PPP, z drugiej zaś – podział ten powinien zostać dokonany w taki sposób, aby ryzyko budowy i dostępności (lub popytu) w większej części spoczywało na Partnerze Prywatnym, a w każdym przypadku – żeby wynagrodzenie Partnera Prywatnego stanowiło funkcję zaangażowania tego podmiotu w eksploatację Infrastruktury Publicznej. Ma to szczególne znaczenie w Projektach PPP opartych o Opłatę za Dostępność. Faktyczna dostępność przedmiotu Przedsięwzięcia oznacza, że zakres odpowiedzialności Partnera Prywatnego, regulowany Umową o PPP, musi obejmować

zapewnienie używania stronie publicznej obiektu w sposób niezakłócony. W sytuacji zaś, gdy wynagrodzenie stanowią Opłaty od Użytkowników, konstrukcja PPU nie powinna pozostawiać wątpliwości co do mechanizmu ich naliczania i zmiany.

6.5.4.3 Ustawa o Umowie Koncesji

Ustawa o Umowie Koncesji zawiera przepisy dotyczące przedmiotu Umowy, świadczeń objętych jej zakresem, czasu zawarcia, pewnych zasad jej wykonywania, zmian, unieważnienia i rozwiązania (rozdział 7 ustawy). Zgodnie z art. 3 Ustawy o Umowie Koncesji Podmiot Publiczny powierza Partnerowi Prywatnemu wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług i zarządzanie tymi usługami za wynagrodzeniem, które w przypadku robót budowlanych stanowi wyłącznie prawo do eksploatacji Infrastruktury Publicznej z ewentualną płatnością ze strony Podmiotu Publicznego, a w przypadku usług publicznych – wyłącznie prawo do wykonywania tych usług wraz z ewentualną płatnością Podmiotu Publicznego.

Ustawa o Umowie Koncesji zawiera również wymóg jej zawarcia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że odrębne przepisy wymagają do jej zawarcia formy szczególnej (art. 44 Ustawy o Umowie Koncesji).

Umowę koncesji zawiera się na czas oznaczony, a w przypadku umowy koncesji zawieranej na czas dłuższy niż 5 lat czas trwania umowy koncesji nie może przekraczać okresu, w którym Koncesjonariusz może zasadnie oczekiwać odzyskania nakładów inwestycyjnych za wykonanie robót budowlanych lub świadczenie usług wraz ze zwrotem zainwestowanego kapitału, z uwzględnieniem inwestycji początkowych i inwestycji dokonanych w czasie trwania koncesji.

Do umowy koncesji nie mają zastosowania przepisy Ustawy PZP. W zakresie nieuregulowanym przepisami Ustawy o Umowie Koncesji stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego.

6.5.5 Dokumentacja techniczna

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część II Punkt 1.2 – Przygotowanie informacji o Projekcie PPP

Tom I: Część II Punkt 3.2 – Analizy Techniczne

Tom III: Część II Punkt 1.11 – Raportowanie i kontrola wykonywania Umowy o PPP

Tom III: Część II Punkt 2.1 – Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Projektowania

Tom III: Część II Punkt 2.5 – Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Robót

Tom III: Część II Punkt 2.3 – Procedura monitorowania i kontroli Prac Projektowych

Tom III: Część II Punkt 2.3 – Procedura monitorowania i kontroli Robót

Tom III: Część II Punkt 3.2 – Zobowiązania Partnera Prywatnego w zakresie Utrzymania i Zarządzania

Tom IV: Część II Punkt 1.7 – Monitorowanie Dostępności i jakości świadczonych usług

Tom IV: Część II Punkt 2.7 – Wstępne określenie Standardów Utrzymania

Tom IV: Część II Punkt 3.1 – Terminowość Prac Projektowych i zgodność z przepisami prawa oraz PFU

Tom IV: Część II Punkt 3.3 – Zgodność robót budowlanych z PFU i ich jakość

Tom IV: Część II Punkt 4.1 – Weryfikacja jakości świadczonych usług oraz Dostępności Infrastruktury Publicznej

Dokumentacja techniczna, obok PPU, stanowi kluczowy element Dokumentacji Postępowania. Warto przypomnieć, że co do zasady Projekty PPP realizowane są w systemie "zaprojektuj i wybuduj" co oznacza, że na etapie zaproszenia do składania ofert Podmiot Publiczny dysponuje Programem Funkcjonalno-Użytkowym (lub podobnym dokumentem w przypadku Postępowania Koncesyjnego) uszczegółowionym i doprecyzowanym w trakcie Negocjacji.

Dokumentacja techniczna składa się najczęściej z następujących elementów:

- 1) Programu Funkcjonalno-Użytkowego (w Postępowaniu PZP) albo Specyfikacji Techniczno-Funkcjonalnej (w Postępowaniu Koncesyjnym), oraz
- 2) dokumentu opisującego standardy utrzymania/zarządzania/świadczenia usług/zwrotu Infrastruktury Publicznej.

Oba dokumenty, tj. PFU i standardy utrzymania, składają się na komplet oczekiwań Podmiotu Publicznego względem robót oraz usług jakie ma świadczyć Partner Prywatny.

Zamawiający opracowuje ww. dokumenty w celu umożliwienia Partnerom Prywatnym skalkulowania swoich ofert i wskazuje w nich wymagania, wedle których należy wycenić zakres prac.

6.5.5.1 Postępowanie PZP – Program Funkcjonalno-Użytkowy

Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi konieczny element wszystkich Projektów PPP, w których Partner Prywatny wybierany jest w Postępowaniu PZP, a przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.

UWAGA



Zgodnie z art. 27 ust. 1 Ustawy PZP, jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie usługi i roboty budowlane, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy dotyczące głównego przedmiotu zamówienia. W przypadku Projektów PPP taka sytuacja zwykle będzie mieć miejsce, tzn. obejmować będą one zarówno zamówienie na roboty budowlane, jak i na usługi. Z uwagi na fakt, iż usługi świadczone będą przez długi okres (na ogół 20-30 lat), ich wartość może być wyższa niż wartość robót budowlanych. Ponadto, głównym celem Projektu PPP może nie być zapewnienie samej infrastruktury, lecz wysokiej jakości usługi publicznej, a wówczas element robót budowlanych stanowi środek do tego celu. Dlatego Projekty PPP mogą być kwalifikowane albo jako zamówienia na usługi, albo jako zamówienia na roboty budowlane w zależności od tego, który z tych elementów jest w ocenie zamawiającego głównym przedmiotem zamówienia. Niezależnie od kwalifikacji Podmiot Publiczny będzie miał obowiązek opracowania PFU przy zastosowaniu wszystkich wymagań wynikających z odpowiednich przepisów wykonawczych. Przepisy te nie znajdują jednak zastosowania w przypadku Postępowania Koncesyjnego. W takich przypadkach Podmiot Publiczny powinien

jednak posłużyć się Specyfikacją Techniczno-Funkcjonalną celem określenia swoich wymagań w zakresie robót budowlanych i może posiłkowo w tym celu posługiwać się wytycznymi wynikającymi z rozporządzenia wykonawczego wydanego dla Postępowania PZP na podstawie art. 103 ust. 4 Ustawy PZP, traktując je jako wskazówkę.

Jak wskazano powyżej, w przypadku uznania, że Projekt PPP obejmuje roboty budowlane Podmiot Publiczny opisuje za pomocą PFU zakres i funkcje planowanej Infrastruktury Publicznej. Na podstawie PFU wykonywana jest przez Partnera Prywatnego również dokumentacja projektowa.

Program Funkcjonalno-Użytkowy

Służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. PFU stanowi zatem nie tylko element analiz w ramach Oceny Efektywności, ale również dokument do prowadzenia Negocjacji, wprowadzania zmian i uszczegółowień dokonanych na etapie Negocjacji, a w efekcie końcowym – stanowi podstawę do złożenia ofert w Postępowaniu PPP.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, Program Funkcjonalno-Użytkowy składa się z trzech części: strony tytułowej, części opisowej i części informacyjnej. Ich zakres przedstawia się następująco.

Tabela 9. Zakres Programu Funkcjonalno-Użytkowego

STRONA TYTUŁOWA	
1) nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego; 2) adres obiektu budowlanego, którego dotyczy PFU; 3) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót; 4) nazwa Zamawiającego oraz jego adres; 5) imiona i nazwiska osób opracowujących PFU; 6) spis zawartości PFU.	
CZĘŚĆ OPISOWA	CZĘŚĆ INFORMACYJNA
Opis ogólny przedmiotu zamówienia, obejmujący: 1) charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych; 2) aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;	1) dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów; 2) oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

3) ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe; 4) szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 "Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych", jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego, w szczególności: • powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji; • wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto; • inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników; • określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, obejmujący – odpowiednio do specyfiki obiektu budowlanego – wymagania dotyczące: 1) przygotowania terenu budowy; 2) architektury; 3) konstrukcji; 4) instalacji; 5) wykończenia; 6) zagospodarowania terenu. Opis wymagań Zamawiającego obejmuje: 1) cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych; 2) warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości	3) przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego; 4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności: • kopię mapy zasadniczej; • wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów; • zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków; • inwentaryzację zieleni; • dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska; • pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości; • inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania Zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek; • porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych;
---	--

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (o których mowa w rozdziale 3 Rozporządzenia w sprawie Zakresu i Formy Dokumentacji).	• dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.
---	---

Ponadto, w praktyce w wyniku dyskusji nad finalnym kształtem PFU, które toczą się w trakcie Negocjacji, PFU jest czasem rozszerzany lub uzupełniany o elementy wyposażenia ruchomego lub stałego wchodzącego w zakres pierwszego wyposażenia w planowanych obiektach, a także inne funkcje lub zakresy, zgodnie z preferencjami Podmiotu Publicznego, uwzględniającymi często propozycje Partnerów Prywatnych.

UWAGA



PFU opracowywany dla Projektów PPP nie ma żadnych specyficznych uwarunkowań w porównaniu do PFU opracowywanych w zamówieniach publicznych. W celu opracowania optymalnego kształtu Programu Funkcjonalno-Użytkowego Podmiot Publiczny – we współpracy z Partnerami Prywatnymi – powinien sprecyzować swoje indywidualne wymagania dotyczące funkcji i walorów użytkowych planowanej Infrastruktury Publicznej.

Niemniej, z uwagi na obowiązek zapewnienia dostępności Infrastruktury Publicznej przez okres wieloletni, w Projektach PPP w praktyce Partnerzy Prywatni powinni proponować rozwiązania trwałe i gwarantujące jak najlepszą jakość wykonania Infrastruktury Publicznej. Dzięki temu łatwiejszy do osiągnięcia będzie standard utrzymania lub zarządzania Infrastrukturą Publiczną, zdefiniowany w odrębnym dokumencie Podmiotu Publicznego, określającym standardy utrzymania.

Częstym problemem dla Podmiotów Publicznych jest zbyt niski stopień szczegółowości PFU. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza w kontekście ryczałtowego (co do zasady) wynagrodzenia Partnera Prywatnego. Opracowanie na podstawie PFU prawidłowej wyceny ujmującej wykonanie zarówno kompletnej dokumentacji projektowej, jak i wszystkich niezbędnych robót budowlanych możliwe jest tylko wtedy, gdy Podmiot Publiczny dokładnie określi swoje wymagania.

Zbyt niski stopień szczegółowości PFU może uniemożliwić prawidłowe oszacowanie kosztów. Może doprowadzić do przyjęcia ich przez Partnera Prywatnego na najniższym poziomie w celu spełnienia niezbędnego minimum i złożenia najkorzystniejszej cenowo oferty.

PRZYKŁAD



Podmiot Publiczny, po przeprowadzonych Negocjacjach dotyczących budowy obiektu ratusza miejskiego dochodzi do wniosku, że PFU nadal będzie posiadał charakter bardzo ogólny, uwzględniając minimalną treść wymaganą przepisami Rozporządzenia w sprawie Zakresu i Formy Dokumentacji. Jednym z elementów Projektu PPP jest dostarczenie przez Partnera Prywatnego wyposażenia ruchomego, obejmującego m.in. biurka, fotele, sprzęt komputerowy, dla 200 urzędników pracujących w ratuszu. Podmiot Publiczny ogranicza się w PFU do stwierdzenia, że wyposażenie ruchome powinno być "trwałe, funkcjonalne i odpowiadające standardom tego typu wyposażenia stosowanym w obiektach biurowych". W takiej sytuacji, jest

niemał pewne, że na etapie realizacji Umowy o PPP dojdzie do sporów z Partnerem Prywatnym dotyczących zakresu i jakości dostarczanego sprzętu.

Istotna z tej perspektywy jest okoliczność, iż w Projektach PPP to Partner Prywatny zarówno projektuje, wykonuje zaprojektowane przez siebie roboty budowlane, utrzymuje Infrastrukturę Publiczną, a dodatkowo zapewnia finansowanie dla całego Przedsięwzięcia PPP.

Jego wynagrodzenie zależne jest od zapewnienia dostępności Infrastruktury Publicznej o określonej jakości (posiadającej wskazane minimalne parametry techniczne itp.), a nie wyłącznie wykonanie robót budowlanych.

W sferze dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia oznacza to, że na etapie Postępowania powinny być wskazane jedynie ogólne, koncepcyjne rozwiązania projektowe lub technologiczne oczekiwane przez Podmiot Publiczny. W oparciu o nie, już na etapie realizacji Umowy o PPP, Partner Prywatny definiuje szczegółowe rozwiązania projektowe w ramach projektu budowlanego, którego zakres wynika z obowiązujących przepisów prawa (PZT, PAB i PT) i projektu wykonawczego, z uwzględnieniem zastosowania preferowanych przez siebie technologii, które umożliwią np. zoptymalizowanie utrzymania Infrastruktury Publicznej w dalszym okresie.

UWAGA



Za formalnie dopuszczalne należy uznać posługiwanie się przez Zamawiającego PFU o charakterze ogólnym, z uwzględnieniem minimum informacji wskazanych w wykonanych analizach technicznych - jak np. Koncepcji Projektowej (patrz Punkt 3.2 Tom I) i o ile tylko spełnione są wymagania formalne określone w przepisach wykonawczych.

PFU stanowi bowiem jedynie ogólny opis przeznaczenia ukończonych robót. PFU powinien pozwalać na zidentyfikowanie oczekiwanego przez Zamawiającego standardu i jakości obiektu mającego powstać w wyniku wykonania robót budowlanych oraz innych usług wymaganych do wykonania w trakcie ich prowadzenia (np. zakres i rodzaje opracowanej dokumentacji projektowej (m.in. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, projekt aranżacji wnętrz, dokumentacja dla potrzeb zarządzania wytworzonym majątkiem, projekt zieleni, dokumentacja BIM, specyfikacje pierwszego wyposażenia, działania informacyjno-promocyjne)).

Może się wydawać, że im bardziej szczegółowe PFU, tym sytuacja jest korzystniejsza dla Partnerów Prywatnych, ponieważ mogą oni w sposób bardziej precyzyjny określić zakres i koszty własnych prac. Ma to znaczenie w szczególności w przypadku Projektów PPP, których zakres jest trudny lub wymaga specyficznych instalacji, systemów lub wyposażenia np. zamówienia wyposażenia biurowego dla pracowników czy niezbędnych sprzętów medycznych do szpitala. Jednakże w odniesieniu do infrastrukturalnych Projektów PPP np. przebudowy dróg, zbyt szczegółowe określenie rozwiązań projektowych w PFU lub jego załącznikach (np. w dołączonym projekcie budowlanym) może nie być rozwiązaniem optymalnym, zwłaszcza jeśli ryzyka projektowania przeniesione są w całości na Partnera Prywatnego. W takiej sytuacji może dochodzić np. do sporów na etapie realizacji prac projektowych. Może się bowiem okazać, że w wyniku pozyskiwania poszczególnych Decyzji Administracyjnych konieczne będzie zastosowanie innych rozwiązań projektowych, niż wskazane w PFU (np. droższych w realizacji). Poza tym projektanci opracowujący projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekty techniczne) i wykonawczy, jako osoby wykonujące

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, odpowiadają – zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane – za zastosowane rozwiązania.

Może się więc okazać w trakcie opracowywania projektu technicznego lub projektu wykonawczego przez Partnera Prywatnego, że trzeba dokonać zmian w projekcie budowlanym (będącym podstawą wydania Decyzji Administracyjnych) przekazanym przez Podmiot Publiczny. W takim przypadku do PFU zaleca się dołączać Koncepcję Projektową lub analizę chłonności (w przypadku obiektów kubaturowych) określającą wymagania Podmiotu Publicznego oraz, w sposób ogólny, zakres prac budowlanych.

UWAGA



PFU nie musi przewidywać wszystkich elementów kosztotwórczych.

W orzecznictwie KIO można znaleźć pogląd, zgodnie z którym w Projektach PPP typu "projektuj i buduj" nieujęcie wszystkich elementów kosztotwórczych w opisie przedmiotu zamówienia, nie musi pozostawać w sprzeczności z art. 99 ust. 1 Ustawy PZP. W formule "projektuj i buduj", wobec możliwości przyjęcia różnych koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia, w ramach jego opisu wynikającego z PFU [...] wspólnym mianownikiem będzie cel, który ma zostać osiągnięty, ale już niekoniecznie metody jego osiągnięcia. Nie oznacza to jednak wadliwości PFU. Trudno bowiem zarzucić Podmiotowi Publicznemu wadliwość Postępowania z uwagi na to, że PFU, które przygotowuje, charakteryzuje się dość dużym stopniem ogólności. W orzecznictwie KIO należy zauważyć pogląd, że co do zasady pewne rozwiązania techniczne, projektowe czy technologiczne mogą być jedynie sugerowane przez Zamawiającego. To wykonawca będzie zobowiązany do wykonania projektu budowlanego, na podstawie którego będzie zobowiązany uzyskać pozwolenie na budowę i to dopiero na tym etapie, tj. wykonywania projektu budowlanego będzie on zobowiązany do określenia m.in. dokładnych parametrów, rozwiązań technologicznych oraz do uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji i pozwoleń (vide: wyrok KIO z dnia 8 grudnia 2016 r., KIO 2164/16; wyrok KIO z dnia 14 sierpnia 2012 r., KIO 1529/12, 1535/12, KIO 1546/12).

W Postępowaniach, w których projektowanie jest zadaniem wykonawcy, a tym bardziej w Projektach PPP, w ramach których Partner Prywatny projektuje, buduje, finansuje, a dodatkowo eksploatuje Infrastrukturę Publiczną i otrzymuje z tego tytułu zapłatę, Podmiot Publiczny co do zasady ma za zadanie określić ogólne wytyczne, a ryzyko projektowania powinno być po stronie Partnera Prywatnego. W ślad za wyżej wskazanym orzecznictwem KIO należy stwierdzić, że opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą PFU zakłada pewną niedookreśloność tego opisu, wynikającą z uprawnienia wykonawcy do określenia szczegółowych rozwiązań technicznych na etapie sporządzania projektu budowlanego. Odpowiedzialność Zamawiającego ogranicza się zatem do przygotowania PFU w zgodzie z przepisami wykonawczymi do Ustawy PZP.

Niewątpliwie zakres PFU przygotowywanego na potrzeby Postępowania w Projektach PPP powinien co najmniej umożliwiać określenie zakresu prac niezbędnych do wykonania przez Partnerów Prywatnych tak, ażeby mogli oni je należycie wycenić na potrzeby oferty.

6.5.5.2 Postępowanie Koncesyjne – Specyfikacja Techniczno-Funkcjonalna

W przypadku Projektów Koncesyjnych, pomimo że Ustawa o Umowie Koncesji nie narzuca na Podmiot Publiczny konieczności posługiwania się określonymi dokumentami technicznymi,

zaleca się wykorzystanie w Dokumentacji Postępowania dokumentu o charakterze zbliżonym do PFU, dzięki czemu możliwe będzie wyznaczenie zakresu Projektu PPP.

Na potrzeby Wytycznych Tom II dokument ten nazwano Specyfikacją Techniczno-Funkcjonalną. Jednakże w celu wypracowania na potrzeby Projektów PPP określonych standardów należy rekomendować, ażeby Specyfikacja Techniczno-Funkcjonalna miała zakres zbliżony do PFU.

Natomiast poziom szczegółowości Specyfikacji Techniczno-Funkcjonalnej w Projekcie Koncesyjnym, podobnie zresztą jak w PFU, może być różny w zależności od poziomu i szczegółowego podejścia do oczekiwań Podmiotu Publicznego oraz zakresu swobody, jaka jest potrzebna Partnerowi Prywatnemu w ramach konkretnego Przedsięwzięcia.

W Projektach Koncesyjnych ryzyko ekonomiczne ulokowane jest po stronie Partnera Prywatnego. Tym samym Partner Prywatny, projektując i wykonując roboty budowlane, dążyć będzie do maksymalizacji przyszłych przychodów od Użytkowników, co niekoniecznie uwzględniłby Podmiot Publiczny, określając zakres niezbędnych robót budowlanych.

Dlatego też narzucanie Partnerowi Prywatnemu uszczegółowionych rozwiązań i dokładnego zakresu robót (w postaci np. rozwiązań technologicznych lub gotowych rozwiązań projektu wykonawczego) może ograniczyć możliwość wykorzystania know-how Partnera Prywatnego w celu przygotowania Infrastruktury Publicznej tak, aby przynosiła jak najwięcej przychodów od Użytkowników. Takie elementy doprecyzowujące (np. uszczegółowienia rozwiązań projektowych czy technologii), które są kluczowe dla Podmiotu Publicznego, powinny być ustalone przez Podmiot Publiczny na etapie Negocjacji.

W przypadku koncesji Podmiot Publiczny powinien jednak określić co najmniej swoje brzegowe warunki i oczekiwania (np. minimalną liczbę miejsc parkingowych, minimalne parametry dotyczące przepustowości oczyszczalni ścieków), a w pozostałym zakresie pozostawić znaczną swobodę Partnerowi Prywatnemu. W niektórych Projektach Koncesyjnych Podmiot Publiczny może mieć bardziej precyzyjne oczekiwania co do Infrastruktury Publicznej, z uwagi na jej charakter i potrzeby Podmiotu Publicznego (np. w projekcie budowy pływalni miejskiej Podmiot Publiczny może oczekiwać określonych parametrów basenu, żeby móc wykorzystać Infrastrukturę Publiczną na potrzeby organizowania określonych imprez sportowych). Każdy Projekt Koncesyjny powinien być zatem pod tym kątem rozpatrywany indywidualnie.

6.5.5.3 Standardy utrzymania, zarządzania, zasady dostępności

Standardy utrzymania, zarządzania oraz zasady dostępności powinny przedstawiać całokształt oczekiwań Podmiotu Publicznego względem zakresu robót oraz rodzajów i jakości usług, które ma świadczyć Partner Prywatny w okresie utrzymania Infrastruktury Publicznej.

W zależności od Projektu PPP zakres świadczeń Partnera Prywatnego będzie się różnił. W okresie utrzymania Partner Prywatny świadczyć będzie:

- 1) usługi związane z zarządzaniem Infrastrukturą Publiczną (ang. *facility management, asset management*);
- 2) usługi związane z utrzymaniem należytego stanu technicznego Infrastruktury Publicznej (ang. *heavy maintenance*);
- 3) usługi związane z utrzymaniem elementów wyposażenia Infrastruktury Publicznej, zieleni (ang. *light maintenance*);
- 4) ewentualnie - usługi miękkie takie jak sprząatanie, catering, ochrona (ang. *soft services*).

Powyższa próba katalogowania rodzaju usług Partnera Prywatnego nie wynika z jakiegokolwiek powszechnie uznanego podziału usług Partnera Prywatnego, ani też nie stanowi katalogu zamkniętego. Uznaje się, że usługi zarządzania stanowią kategorię pojemniejszą od usług utrzymania i obejmują wszelkie usługi o charakterze zarządczym świadczone nie tylko w celu zapewnienia należytego wykonania pozostałych usług przez Partnera Prywatnego, ale też optymalnego wykorzystania Infrastruktury Publicznej pod kątem zarówno technicznym jak i finansowym. W ramach usług Zarządzania Partner Prywatny odpowiedzialny będzie na przykład za skoordynowanie działań pomiędzy wszystkimi podwykonawcami, optymalizację usług utrzymania, realizację planów remontowych, umożliwienie wykonywania kontroli przez Podmiot Publiczny itd.

W niektórych Projektach PPP można spotkać się z terminem "eksploatacja". Termin ten właściwszy jest dla Projektów PPP, w których z samej Infrastruktury Publicznej generowany jest przychód (np. autostrady płatne).

W Przedsięwzięciach opartych o Opłatę za Dostępność, strony również ustalają zasady dostępności, czyli odpowiedzialności Partnera Prywatnego za zapewnienie funkcjonowania Infrastruktury Publicznej. Nienależyte świadczenie takich usług oznaczać będzie ograniczoną dostępność Infrastruktury Publicznej i spowoduje obniżenie wynagrodzenia Partnera Prywatnego.

PRZYKŁAD



Z brakiem dostępności w drogowych Projektach PPP mamy do czynienia w przypadku wyłączenia pasa ruchu w celu prowadzenia prac remontowych. W przypadku budynku użyteczności publicznej brak dostępności oznaczać będzie niemożność korzystania z części lub wszystkich pomieszczeń budynku zgodnie z ich przeznaczeniem. Zdarzyć się może, iż brak dostępności części Infrastruktury Publicznej oznaczać będzie *de facto* całkowity brak dostępności (np. brak dostępności sal rozpraw w sądzie oznaczać może całkowitą nieprzydatność Infrastruktury Publicznej w tym czasie, brak dostępności sal operacyjnych uznaje się za brak dostępności szpitala).

Dokument obejmujący standardy utrzymania, zarządzania i zasady dostępności, powinien zostać opracowany zarówno w Postępowaniach PZP, jak i w Postępowaniach Koncesyjnych.

W przeciwieństwie do dokumentacji dotyczącej budowy, przepisy prawa nie przewidują zasad tworzenia zakresu standardów, utrzymania zasad dostępności czy eksploatacji Infrastruktury Publicznej.

Szczególnie istotne jest opracowanie takich standardów z należytą starannością ze względu na kluczowy charakter tego dokumentu. Definiuje on standardy utrzymania, jak i dostępności Infrastruktury Publicznej, które w rzeczywistości determinują jakość i koszt wykonawstwa, a w późniejszym okresie – decydują o potencjalnej niedostępności i ryzykach z tym związanych (w szczególności finansowych).

Standardy utrzymania i/lub zarządzania mają szczególne znaczenie z punktu widzenia rozliczania Partnera Prywatnego z przyjętych na siebie zobowiązań w zakresie dostępności Infrastruktury Publicznej i w konsekwencji - z punktu widzenia rozliczeń z Partnerem Prywatnym. Naruszenie określonego Umową o PPP standardu utrzymania Infrastruktury Publicznej, zasad jej dostępności oraz zasad wykonywania usług publicznych powinno być podstawą do obniżenia wynagrodzenia

należnego Partnerowi Prywatnemu (powtarzające się naruszenia ustalonych standardów mogą doprowadzić nawet do wypowiedzenia Umowy o PPP).

Podmiot Publiczny powinien określić wszystkie standardy utrzymania i zarządzania oraz zasady dostępności, do których zobowiązany będzie Partner Prywatny, oraz wskaźniki oceny jakości tych standardów albo częstotliwość wykonywania określonych czynności w ramach zarządzania, tam, gdzie wskaźnik jakości jest trudny lub niemożliwy do zastosowania.

Wynagrodzenie Partnera Prywatnego powinno być uzależnione od dotrzymania standardów utrzymania i zarządzania, rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej dostępności Infrastruktury Publicznej albo usługi publicznej i powinno być obniżone proporcjonalnie do braku dostępności tej Infrastruktury Publicznej. Przy czym nienależyte wykonanie i niewykonanie zobowiązań skutkować będzie naliczeniem kar umownych lub obniżeniem wynagrodzenia Partnera Prywatnego.

Ponadto, precyzyjne określenie oczekiwań i zobowiązań stron w powyższych zakresach dotyczy wieloletniej perspektywy i ma kluczowe znaczenie dla oszacowania kosztów w okresie utrzymania.

Należy zauważyć, iż po stronie Podmiotów Publicznych nie ma należytego doświadczenia w kontroli i szacowaniu wydatków w okresie utrzymania, zwłaszcza w ujęciu łącznym, razem z projektowaniem i budową.

Część z obowiązków z zakresu utrzymania i terminów ich realizacji będzie wynikać z przepisów prawa (np. obowiązkowe kontrole techniczne Infrastruktury Publicznej), a część uzgadniana jest przez strony w ramach Negocjacji postanowień Umowy o PPP (np. zagadnienie jakości wyposażenia ruchomego, standardy utrzymania czystości pomieszczeń).

Nie wszystkie z czynności związane z utrzymaniem musi wykonywać Partner Prywatny. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Podmiot Publiczny przejął na siebie tzw. usługi miękkie (sprzątanie, ochronę, catering w budynku użyteczności publicznej), a Partner Prywatny odpowiadał przede wszystkim za remonty i konserwacje substancji budowlanej oraz odtworzenie lub wymianę elementów obiektu – w miarę postępującego zużycia.

W odniesieniu do Projektów Koncesyjnych większy nacisk należy położyć na zarządzanie obiektem oraz zasady świadczenia usług wobec Użytkowników przez Partnera Prywatnego.

Pomimo że mamy do czynienia z koncesją, tj. Projektem PPP, w którym ryzyko ekonomiczne jest po stronie Koncesjonariusza, to nie oznacza, iż Podmiot Publiczny nie powinien mieć oczekiwań co do standardu usług czy jakości lub dostępności Infrastruktury Publicznej. Ostatecznie przecież zostanie ona zwrócona Podmiotowi Publicznemu, a poza tym służy do realizacji zadań publicznych.

W przypadku koncesji nienależyte świadczenie usług dostępności oznaczać będzie ograniczoną dostępność Infrastruktury Publicznej i spowoduje również sankcje w postaci kar w określonej wysokości, naliczanych w przypadku niedotrzymania zasad dostępności.

PRZYKŁAD



Z brakiem dostępności w Projektach Koncesyjnych mamy najczęściej do czynienia w przypadku niemożności korzystania przez Użytkowników z części lub całej Infrastruktury Publicznej zgodnie z jej przeznaczeniem, na przykład brak możliwości korzystania z Infrastruktury Publicznej przez osoby z niepełnosprawnością z uwagi na niedziałające urządzenia do obsługi osób

z niepełnosprawnością. Należy pamiętać, że dla Koncesjonariusza brak dostępności oznaczać będzie brak uzyskiwania pożytków, niemniej nie wyklucza to dodatkowych sankcji, albowiem Zamawiający nie realizuje swoich zadań publicznych.

Standardy utrzymania i eksploatacji w większości przypadków Projektów PPP odgrywają znacznie większą rolę niż PFU/STF. Zasadniczo powinny one zabezpieczać interes Podmiotu Publicznego w dwóch generalnych kwestiach:

- 1) jakości świadczonej usługi;
- 2) ochrony przed nadmierną degradacją Infrastruktury Publicznej.

Jakość Usług

Standardy powinny opisywać wymagania jakie powinien realizować Partner Prywatny w zakresie jakości usługi, aby zaspokoić potrzeby Użytkowników. Należy mieć na względzie, iż zakres standardów utrzymania różnić będzie się w zależności od rodzaju Infrastruktury Publicznej. Do powyższych standardów usług powinny być przypisane tzw. Kluczowe Wskaźniki Efektywności wraz z czasem reakcji na określone zdarzenia powodujące niedotrzymanie standardów utrzymania (np. czas reakcji zależny od warunków pogodowych, liczba pojazdów w danej godzinie, które dostarczają odpady do zakładu termicznego przetwarzania itp.) oraz kary za ich niedotrzymanie.

Poniżej wskazano przykładowe Kluczowe Wskaźniki Efektywności.

PRZYKŁAD



- zapewnienie braku oddziaływania negatywnego zapachu z oczyszczalni ścieków (ponad dopuszczalny poziom uciążliwości) na mieszkańców;
- zapewnienie nieodpłatnego i nieograniczonego dostępu Użytkowników do parkingu urzędu;
- czas oczekiwania na rozładunek samochodu dostarczającego odpady do zakładu ich termicznego przetwarzania;
- częstotliwość czynności porządkowych na terenie Infrastruktury Publicznej.

Warunki monitoringu danego standardu (np. w jaki sposób mierzony jest czas reakcji np. od zgłoszenia telefonicznego uszkodzenia do kolejnej informacji telefonicznej o usunięciu tego uszkodzenia) powinny być opisane w dokumencie dotyczącym standardów utrzymania i zarządzania, jak również we wzorach raportów i sprawozdań w sposób czytelny i jednoznaczny oraz powinna istnieć możliwość rejestracji ich realizacji. W przypadku niektórych standardów należy określić częstotliwość ich monitoringu (np. kontrola czystości obiektu raz na dobę).

PRZYKŁAD



Przykładowo, ryzyko związane ze skróceniem czasu usunięcia awarii można opisać w następujący sposób:

- 1) W przypadku przejęcia tego ryzyka, Partner Prywatny zobowiązuje się do usuwania awarii w ciągu 24 godzin.

- 2) (W SWZ określono, że awarie usuwane będą przez Partnera Prywatnego w ciągu 48 godzin od ich stwierdzenia).

Należy dokładnie opisać, w jaki sposób kary są naliczane (np. stała kara dla zdarzenia lub kara za każdą godzinę opóźnienia w reakcji na zgłoszenie o awarii). Kary powinny spełniać dwie funkcje: pokrycie ewentualnych strat Podmiotu Publicznego wynikających z roszczeń odbiorców usługi oraz motywowanie Partnera Prywatnego do utrzymania wysokiego poziomu usług.

Jakość Infrastruktury Publicznej

Standardy eksploatacyjne powinny opisywać wymagania w zakresie utrzymania Infrastruktury Publicznej na takim poziomie, aby jej degradacja nie była wyższa niż zakładana w Projekcie PPP (w zależności od przyjętego rozwiązania dotyczącego jakości majątku na moment zwrotu tego majątku Podmiotowi Publicznemu na koniec Umowy o PPP). Zasadniczo standardy nie powinny narzucać Partnerowi Prywatnemu sposobu utrzymania jakości majątku (np. poprzez określenie częstotliwości oraz zakresu remontów), ale powinny przedstawiać, jakie parametry Infrastruktura Publiczna powinna spełniać na dany moment, w tym na zakończenie Umowy PPP.

W zależności od Projektu PPP określone wymagania co do jakości Infrastruktury Publicznej będą obowiązywać w sposób ciągły, a Partner Prywatny będzie zobowiązany do stałego monitorowania jakości Infrastruktury Publicznej (np. w projektach liniowych – drogi, kolej – stan oznakowania, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, sterowanie ruchem kolejowym).

Czasami stan Infrastruktury Publicznej kontrolowany jest z określoną częstotliwością podczas trwania Umowy o PPP (np. zakłady termicznego przetwarzania odpadów, gdzie kontrola jakości utrzymania instalacji odbywa się raz do roku).

Wykonywanie przez Partnera Prywatnego obowiązków wynikających z Umowy o PPP, w tym w zakresie utrzymania i zarządzania, powinno być monitorowane przez Podmiot Publiczny, nie tylko w ramach sprawozdawczości Partnera Prywatnego, lecz również w sposób aktywny, poprzez wykonywanie czynności kontrolnych. Dotyczy to w szczególności stanu technicznego Infrastruktury Publicznej, która wraz z zakończeniem Umowy o PPP wróci do Podmiotu Publicznego.

Z reguły Umowy o PPP opierają raportowanie i sprawozdawczość o raporty własne Partnera Prywatnego, z prawem Podmiotu Publicznego do monitorowania i kontroli tych raportów.

Ustawa o PPP wprost przewiduje uprawnienie Podmiotu Publicznego do bieżącej kontroli realizacji Przedsięwzięcia przez Partnera Prywatnego oraz kontroli składnika majątkowego wykorzystywanego do realizacji Przedsięwzięcia. Zgodnie z przepisem art. 8 Ustawy o PPP określenie zasad oraz trybu prowadzenia kontroli powinno nastąpić w postanowieniach Umowy o PPP.

Ustawa o PPP mówi o bieżącej kontroli, co nie oznacza, że Podmiot Publiczny powinien przeprowadzać ją w sposób ciągły lub bardzo często. Określając zakres uprawnień kontrolnych oraz tryb prowadzenia kontroli, należy mieć na względzie, aby działania Podmiotu Publicznego były, w możliwy sposób, jak najmniej uciążliwe dla prowadzonej przez Partnera Prywatnego działalności w ramach Umowy o PPP (szerzej na ten temat Wytyczne Tom III).

Raportowanie

Raportowanie stanowi jeden z ważniejszych obowiązków Partnera Prywatnego na etapie eksploatacji Infrastruktury Publicznej. Stosownie do art. 8 ust. 3 Ustawy o PPP, Partner Prywatny ma obowiązek bieżącego raportowania Podmiotowi Publicznemu o stanie realizacji

Przedsięwzięcia i stanie technicznym składnika majątkowego wykorzystywanego przez Partnera Prywatnego do realizacji Przedsięwzięcia. Zasady, szczegółowy tryb oraz częstotliwość raportowania określa Umowa o PPP. Pomimo że Ustawa o Umowie Koncesji nie zawiera takiej regulacji, należy uznać ją za dobrą praktykę również w Postępowaniach Koncesyjnych.

W celu oceny spełnienia określonych przez Podmiot Publiczny standardów eksploatacyjnych, Partner Prywatny powinien przedstawiać raporty (np. miesięczne), przedstawiające wszystkie zdarzenia awaryjne, które wystąpiły na eksploatowanym majątku. Na tej podstawie Podmiot Publiczny dokonuje oceny jakości prowadzonej eksploatacji (np. poprzez sprawdzenie, czy dana awaria się powtarza, jaki jest sposób jej usunięcia, w jakim czasie to usunięcie zostało przeprowadzone itp.).

Raport miesięczny powinien zawierać również szczegółowe informacje o wszystkich remontach wykonanych na majątku (w tym metody, użyte materiały, sposób odbioru itp.). Raport ten nie musi obejmować kosztów usuwania awarii czy remontu, ponieważ są to wartości wchodzące zwykle w skład Opłaty za Dostępność (trudna jest również weryfikacja, czy taki koszt jest racjonalny). Koszty remontów mogą być przedstawione w celach informacyjnych, jeśli oczekuje tego Podmiot Publiczny.

W celu motywowania Partnera Prywatnego do przekazywania kompletnego raportu należy ustalić jego zakres oraz karę (punkty karne) za jego niedostarczenie w oczekiwanym terminie lub dostarczenie raportu zawierającego niewłaściwe lub nieprawdziwe informacje. Merytoryczna ocena takiego raportu wymaga specyficznej wiedzy technicznej po stronie Podmiotu Publicznego (np. z wykorzystaniem danych statystycznych z podobnych obiektów).

Sposoby monitoringu i naliczania punktów karnych związanych z dotrzymaniem standardów utrzymania i eksploatacji można przedstawić w formie tabelarycznej jako Kluczowe Wskaźniki Efektywności.

Według najlepszych praktyk szczegółowy opis wymagań stawianych dla utrzymania, zarządzania czy eksploatacji powinien zostać umieszczony w osobnym dokumencie, a nie w PFU.

6.5.5.4 Inne dokumenty

Pozostałe dokumenty i informacje, składające się na dokumentację techniczną Dokumentacji Postępowania, obejmować mogą przede wszystkim Decyzje Administracyjne, w tym Decyzje Środowiskowe i opinie eksperckie lub uzgodnienia z właściwymi organami administracji publicznej.

Tabela 10. Przykładowe inne elementy dokumentacji technicznej

Określenie dokumentu	Komentarz
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	Decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego należy uzyskać, jeśli dla nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a ma być na niej realizowana inwestycja celu publicznego. Zaleca się, aby Podmiot Publiczny uzyskał taką decyzję przed zaproszeniem do składania ofert.
Decyzja o przekazaniu nieruchomości w trwałą	Trwały zarząd, własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa lub inne tytuły prawne stanowią podstawę do uzyskania statusu inwestora i realizacji procesu inwestycyjnego.

Określenie dokumentu	Komentarz
zarząd/umowa o dysponowaniu nieruchomością	Stan prawny nieruchomości musi być bezwzględnie uregulowany najpóźniej przed zaproszeniem do składania ofert.
Decyzje Środowiskowe	Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, podobnie jak decyzje lokalizacyjne, stanowią podstawę do pozyskania kolejnych Decyzji Administracyjnych na etapie projektowania Infrastruktury Publicznej. Zaleca się, aby Decyzje Środowiskowe (jeśli wymagane przepisami szczególnymi) pozyskane zostały przez Podmiot Publiczny przed zaproszeniem do składania ofert.
Opinia geotechniczna	Opinia ta dotyczy badań podłoża gruntowego dla obiektów budowlanych. Opinia określa budowę geologiczną podłoża gruntowego, zawiera ocenę warunków gruntowo-wodnych oraz ocenę przydatności gruntu dla potrzeb projektowania inwestycji. Co prawda, sporządza się ją do projektu budowlanego, ale z uwagi na przypisanie ryzyka budowy, w niektórych Przedsięwzięciach zalecane jest wykonanie opinii przed zaproszeniem Partnerów Prywatnych do składania ofert.
Uzgodnienia z organami administracji publicznej	W niektórych przypadkach na etapie przygotowania Przedsięwzięcia pożądane będzie pozyskanie opinii, wytycznych czy też wstępnych warunków technicznych m.in. w zakresie ochrony konserwatorskiej zabytków lub z władzami lokalnymi. Zasadnicza część zgód i opinii wydawana jest jednak na etapie projektowania.
Warunki techniczne przyłączenia do sieci	Najczęstszym rozwiązaniem i punktem spornym w projektach PPP jest przeniesienie ryzyka związanego z uzyskaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci i/lub przebudowy istniejącej infrastruktury wraz z projektowaną na Partnera Prywatnego. Przeniesienie ryzyka wprowadza konieczność rozpoznania przez Partnera Prywatnego możliwości przyłączenia do sieci, bez stosownego pełnomocnictwa do ich uzyskania. Podmiot Publiczny w takim przypadku winien wskazać granice obszaru, w ramach których Partner Prywatny jest zobowiązany do ujęcia zakresu przebudowy infrastruktury w swoich kosztach oraz wskazać, w jakich przypadkach zmiana tego zakresu będzie stanowić przypadek kompensacyjny. Podobna sytuacja jest w przypadku wykrycia na terenie budowy niezidentyfikowanej sieci uzbrojenia podziemnego. Jeśli Partner Prywatny pomimo dołożenia należytej

Określenie dokumentu	Komentarz
	staranności (w tym na podstawie dostępnych map do celów projektowych) na etapie przygotowywania oferty nie był w stanie wykryć tej infrastruktury, to koszty związane z przeniesieniem takiej infrastruktury ponosi Podmiot Publiczny na zasadach określonych w Umowie.
Wytyczne w zakresie przygotowania systemu zarządzania majątkiem	Dokument, który stanowi wytyczne Podmiotu Publicznego w zakresie przygotowania procedur i procesów biznesowych, pozwalający na zoptymalizowane zarządzanie majątkiem trwałym. System ten ułatwia pracę zespołów technicznych, jak i księgowych (np. w zakresie przypisywania zmiany wartości poszczególnych środków trwałych w trakcie zadań remontowych i inwestycyjnych). W systemie tym powinna być również możliwość identyfikacji konkretnych środków trwałych w podziale na pomniejsze urządzenia.
Wytyczne do działań promocyjno-informacyjnych	Wytyczne Podmiotu Publicznego odnośnie do prowadzenia przez Partnera Prywatnego działań promocyjno-informacyjnych. Zakres tych działań powinien być każdorazowo uzgodniony z działem PR lub komunikacji Podmiotu Publicznego. Działania takie wykraczają poza standardowe obowiązki Partnera Prywatnego, tym samym często pojawiają się komentarze z jego strony o konieczności wyłączenia tego zakresu z Umowy PPP.

6.5.6 Dokumentacja finansowa

Dokumentacja finansowa stanowi nie mniej ważny od dokumentacji prawnej i technicznej element Dokumentacji Postępowania.

Podmiot Publiczny przygotowuje w ramach Oceny Efektywności model finansowy, który służy mu przede wszystkim do weryfikacji wykonalności Projektu PPP. Następnie na etapie tworzenia SWZ i zapraszania Partnerów Prywatnych do składania ofert, istotne znaczenie mają przygotowywane przez Podmiot Publiczny wymagania do modelu finansowego.

Model finansowy wykorzystywany do finansowania pojedynczego Projektu PPP w oparciu o przepływy pieniężne stanowi podstawowe narzędzie służące w Projektach PPP przede wszystkim do pozyskania finansowania dłużnego od Instytucji Finansujących i kapitałów własnych od Sponsorów. Ponadto, taki model finansowy jest narzędziem do monitorowania realizacji Projektu PPP zgodnie z założeniami i Umową o PPP oraz rozliczaniem sytuacji wyjątkowych przewidzianych w Umowie o PPP (np. aktualizacja wynagrodzenia z uwagi na przypadek kompensacyjny) oraz przy refinansowaniu i podziale zysku z ewentualnej zmiany finansowania. Brak modelu finansowego może świadczyć o tym, że Partner Prywatny nie przeprowadził dogłębnej analizy realizacji Projektu PPP, co rodzi ryzyko poważnych problemów z zarządzaniem Umową o PPP.

Model finansowy aktualizowany jest w okresie obowiązywania Umowy, w okolicznościach w niej wskazanych, dlatego musi być funkcjonalny, czytelny i zrozumiały dla obu stron.

W przypadku Projektów Hybrydowych na dokumentację finansową składała się będzie również umowa o dofinansowanie lub wzór takiej umowy.

W niektórych Projektach PPP Zamawiający nie wymagają składania modeli finansowych wraz z ofertą, a jedynie rozbudowanego formularza ofertowego. W takich przypadkach wybrany Partner Prywatny dostarcza model finansowy w określonym terminie od zawarcia Umowy o PPP. Ewentualne rozbieżności pomiędzy formularzem ofertowym a modelem finansowym powinny stanowić ryzyko Partnera Prywatnego.

6.5.6.1 Wymagania dla modelu finansowego

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom III: Część II Punkt 4.2 – Model Finansowy

Tom IV: Część II Punkt 1.5 – Model Finansowy

Wymogi do modelu finansowego wskazane przez Podmiot Publiczny stanowią bazę do przygotowania modelu finansowego przez Partnera Prywatnego.

Poniżej przedstawiono przykładowy zakres takich wymagań.

PRZYKŁAD



Przykładowy zakres wymagań do modelu finansowego

Wymagania ogólne:

- Zakłada się, że Partner Prywatny będzie ponosił odpowiedzialność za zapewnienie finansowania Przedsięwzięcia;
- Model finansowy będzie stanowić załącznik do Umowy o PPP;
- Partner Prywatny jest odpowiedzialny za zapewnienie poprawności modelu finansowego i dokładnego odzwierciedlenia w nim finansowych i komercyjnych warunków złożonej oferty;
- Model finansowy powinien być przekazany w formie elektronicznej na określonym nośniku;
- Model finansowy nie może być zabezpieczony hasłem ani zawierać zabezpieczonych makr. Model finansowy powinien być zbudowany w sposób dynamiczny, umożliwiając zmianę przyjętych wartości i założeń. Wszystkie założenia powinny znajdować się w osobnej zakładce sterującej, umożliwiając dokonywanie zmian w zakresie najważniejszych z punktu widzenia Projektu PPP zmiennych bez konieczności przechodzenia do innych zakładek w modelu;
- Model finansowy powinien spełniać następujące warunki:
 - zgodność z formatem plików programu Microsoft Excel (w wersji aktualnej i dostępnej dla Zamawiającego - do określenia w konkretnym Postępowaniu);

- opis w języku polskim;
- brak ukrytych rzędów, kolumn, komórek lub arkuszy;
- brak odniesień cyklicznych albo kwot bilansujących;
- wszystkie wartości liczbowe powinny być wpisane do arkusza założeń, wartości liczbowe nie mogą być wpisywane do arkuszy obliczeniowych;
- spójne formuły w ramach wierszy bez wartości liczbowych w ramach formuły;
- niespójna formuła (w uzasadnionych przypadkach) powinna zostać oznaczona;
- zawierać oznaczenie jednostek, walut, wartości nominalnych i realnych;
- dany rok prognozy prezentowany jest w tej samej kolumnie w poszczególnych arkuszach;
- W modelu finansowym powinny być zawarte projekcje finansowe spełniające następujące wymogi:
 - w ujęciu rocznym od daty podpisania Umowy o PPP do końca okresu obowiązywania tej Umowy, w pełnych latach kalendarzowych, możliwe jest ujęcie projekcji finansowych w okresach kwartalnych lub miesięcznych;
 - w złotych polskich w wartościach nominalnych;
 - zgodne z polskimi przepisami prawa dotyczącymi rachunkowości oraz podatków oraz innymi przepisami aktualnymi na dzień złożenia oferty.

Założenia do modelu finansowego:

- Partner Prywatny przedstawi księgę założeń z pełnym opisem założeń dla projekcji finansowych zawartych w modelu finansowym,
- Założenia powinny obejmować następujące kategorie:
 - nakłady kapitałowe w cenach realnych i nominalnych, obejmujące całość nakładów inwestycyjnych;
 - koszty operacyjne w cenach realnych i nominalnych, w tym koszty utrzymania, zarządzania i administracji;
 - założenia makroekonomiczne (m.in. inflacja CPI, wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw (nominalnie), wskaźnik cen materiałów budowlanych, kursy walut (jeśli dotyczy), inne wskaźniki indeksacji, jeżeli są wykorzystywane);
 - wszystkie założenia dotyczące finansowania Projektu PPP, w tym źródła finansowania wraz z procentowym ich udziałem w finansowaniu oraz dla każdego źródła warunki finansowania, stopy procentowe, marże, opłaty dodatkowe, polityka wypłaty dywidendy i inne założenia wpływające na przepływy pieniężne Przedsięwzięcia oraz okres finansowania dłużnego wraz z harmonogramem spłaty tego finansowania;
 - rachunki obowiązkowe (w tym rachunek obsługi zadłużenia (ang. *Debt Service Reserve Account*) oraz rachunek rezerwowy na pokrycie kosztów utrzymania (ang. *Maintenance Reserve Account*) i inne rachunki, o ile będą wymagane);
 - zapotrzebowanie na kapitał obrotowy (w tym przepływy z tytułu podatku VAT) i związane z tym założenia dotyczące finansowania;

- założenia dotyczące amortyzacji, reguł rachunkowości oraz podatków (np. CIT, VAT).

Wyniki modelu finansowego:

- Model finansowy powinien prezentować co najmniej następujące rezultaty:
 - zestawienie podsumowujące źródła i wykorzystanie finansowania;
 - przepływy pieniężne i salda gotówki w całym okresie trwania Umowy o PPP;
 - sprawozdania finansowe (rachunek zysków i strat, bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych) w ujęciu nominalnym w oparciu o przepisy o rachunkowości w całym okresie trwania Umowy o PPP;
 - kaskadę płatności zgodnie z założeniami przyjętymi dla finansowania w całym okresie trwania Umowy o PPP;
 - wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) całości Projektu PPP z punktu widzenia Spółki Projektowej przed i po opodatkowaniu w ujęciu realnym i nominalnym;
 - wartość bieżącą przepływów dla całości Projektu PPP z punktu widzenia Spółki Projektowej;
 - wewnętrzną stopę zwrotu (IRR) przed i po opodatkowaniu w ujęciu realnym i nominalnym dla kapitału własnego wniesionego przez Partnera Prywatnego (np. kapitał własny, pożyczki podporządkowane);
 - wartość bieżącą przepływów (na kapitale własnym Partnera Prywatnego (np. kapitał własny, pożyczki podporządkowane));
 - podział wynagrodzenia na poszczególne elementy wynagrodzenia, zgodne z załącznikiem do Umowy o PPP, w okresie trwania Umowy o PPP (np. na wydatki majątkowe i bieżące w przypadku JST);
 - wskaźniki finansowe uznawane za istotne dla proponowanej struktury finansowej (których zachowanie na danym poziomie jest wymagane przez Instytucje Finansujące), np. DSCR, LLCR;
 - arkusz analizy wrażliwości na zmiany w:
 - wysokości nakładów kapitałowych;
 - wysokości kosztów utrzymania i/lub zarządzania;
 - stopach procentowych;
 - wskaźniku inflacji;
 - arkusz zawierający zebranie kontrolek sprawdzających poprawność przeliczeń (jeśli zaistnieje potrzeba), np. czy wypłata dywidendy nie powoduje spadku bilansu gotówki poniżej zera, sprawdzenie wskaźników finansowych uznawanych za istotne dla proponowanej struktury finansowej lub inne w zależności od potrzeb i architektury modelu.

Zaprezentowane powyżej założenia mają charakter przykładowy i powinny być indywidualnie dostosowywane do każdego Projektu PPP.

Przygotowanie przez Podmiot Publiczny wymogów co do modelu finansowego do zastosowania przez Partnerów Prywatnych jest praktyką rekomendowaną nawet w Małych Projektach.

MAŁE PROJEKTY



W Małych Projektach oczekiwany poziom szczegółowości modelu finansowego powinien być dostosowany do zakresu Projektu PPP. Może mieć zatem charakter uproszczony i zawierać zagregowane pozycje dotyczące nakładów i kosztów, niemniej jednak model musi obejmować wszystkie elementy wskazane w przykładowym zakresie założeń oraz wyników modelu finansowego, zaprezentowane w przykładzie powyżej. Ponadto model finansowy stanowi narzędzie do monitorowania wykonywania Umowy o PPP i w sytuacjach określonych w Umowie o PPP jest podstawowym narzędziem do weryfikacji lub zmiany wynagrodzenia Partnera Prywatnego.

W Małych Projektach zdarza się, że Podmiot Publiczny nie wymaga od Partnerów Prywatnych złożenia modelu finansowego wraz z ofertą, a polega jedynie na rozbudowanym formularzu ofertowym.

Model finansowy zazwyczaj objęty będzie tajemnicą przedsiębiorstwa Partnera Prywatnego.

6.5.6.2 Warunki finansowania

POWIĄZANE SEKCJE WYT CZNYCH PPP TOM I-IV



Tom III: Część II Punkt 1.9 – Finansowanie Przedsięwzięcia

Z punktu widzenia warunków finansowania Projektu PPP kluczowe znaczenie ma wysoka jakość Dokumentacji Postępowania, wiarygodność Projektu PPP, właściwy podział ryzyk oraz odpowiednio długi czas na złożenie ofert przez Partnerów Prywatnych.

W Postępowaniach PPP, na etapie składania ofert, od Partnerów Prywatnych zazwyczaj oczekuje się przedstawienia niewiążących warunków finansowania w odniesieniu do finansowania pozyskanego od Instytucji Finansujących w formie długoterminowych kredytów.

Należy zwrócić uwagę, że wiążące warunki finansowania (np. promesa kredytu) są wynikiem decyzji komitetu kredytowego Instytucji Finansującej, w związku z czym wymagają dodatkowego zaangażowania i czasu na przeprowadzenie przez Instytucję Finansującą badania Dokumentacji Postępowania.

Pozyskanie bezwarunkowych, wiążących warunków finansowania na etapie składania ofert może być bardzo trudne, a w wielu przypadkach wręcz niemożliwe. W toku Postępowania należy każdorazowo wyważyć oczekiwanie Podmiotu Publicznego zapewnienia przez Partnera Prywatnego jak największej pewności pozyskania finansowania zewnętrznego na etapie składania ofert, z oczekiwaniem Partnera Prywatnego do maksymalizacji zysków i optymalizacji kosztów Projektu PPP, co często jest możliwe dopiero po Zamknięciu Komercyjnym.

Z jednej bowiem strony Podmiot Publiczny, nie chcąc ryzykować nieosiągnięcia Zamknięcia Finansowego, oczekuje od Partnerów Prywatnych wiążących warunków finansowania wraz z ofertą. Z drugiej strony dla Instytucji Finansujących zaoferowanie i tym samym, dla Partnerów Prywatnych, pozyskanie wiążących warunków finansowania na etapie oferty może być utrudnione lub niemożliwe z uwagi przede wszystkim na:

- ograniczenie w zaoferowaniu wiążących warunków finansowania kilku Partnerom Prywatnym w jednym Postępowaniu, co dotyczy w szczególności Dużych Projektów;
- ryzyko reputacyjne – Instytucje Finansujące nie są skłonne zaoferować wiążących warunków finansowania warunkowanych pozytywnym wynikiem audytu Dokumentacji Postępowania oraz dokumentacji Partnera Prywatnego, z uwagi na negatywny wpływ na wizerunek banku w sytuacji nieudzielenia finansowania na wrażliwy społecznie Projekt PPP (np. szkoły, przedszkola, szpitale).

Pozyskanie wiążących warunków finansowania:

- znacząco uprawdopodobnia wykonanie Umowy o PPP, w tym rozpoczęcie etapu inwestycyjnego w zakładanym terminie;
- pozwala uwzględnić realne koszty finansowania w ofercie Partnera Prywatnego (Partner Prywatny nie ponosi ryzyka związanego ze zmianą warunków finansowania);
- wymaga od Partnera Prywatnego zaangażowania Instytucji Finansujących przed złożeniem oferty, co z kolei pozwala na wprowadzenie do Umowy elementów Bankowości jeszcze przed publikacją SWZ lub – najpóźniej – na etapie zadawania pytań.

Niewiążące warunki finansowania pozwalają na złożenie przez Partnera Prywatnego oferty z konkretną ceną, lecz bez gwarancji otrzymania finansowania na warunkach w nich określonych.

UWAGA



W przypadku Dużych Projektów, które co do zasady będą wymagać finansowania dłużnego pochodzącego od Instytucji Finansujących, Podmioty Publiczne nie powinny oczekiwać wiążących warunków finansowania, ze względu na fakt, że potencjalnym Instytucjom Finansującym trudniej jest zapewnić te warunki, nie mając pewności, że dana oferta będzie ofertą wygrywającą. Przygotowanie wiążących ofert finansowania przez Instytucje Finansujące równocześnie dla kilku Partnerów Prywatnych w jednym Projekcie PPP wymaga po stronie Instytucji Finansujących dysponowania odpowiednio dużymi zespołami tak, aby zapewnić zachowanie poufności i brak konfliktu interesów (oddzielny zespół dla każdego Partnera Prywatnego) oraz dodatkowego czasu na ocenę Projektu PPP. Takie podejście oznacza dodatkowe koszty przygotowania ofert dla Partnera Prywatnego i na rynkach rozwijających PPP nie ma zastosowania w praktyce.

MAŁE PROJEKTY



W przypadku Małych Projektów, w których wymagany poziom finansowania jest niższy i niejednokrotnie w większości osiągalny w ramach kapitałów własnych Partnerów Prywatnych, możliwe jest oczekiwanie na etapie składania ofert wiążących warunków finansowania, jednakże należy mieć na względzie, iż finansowanie ze środków własnych Partnera Prywatnego jest z reguły droższe niż finansowanie długiem.

6.5.6.3 Umowa Bezpośrednia

POWIĄZANE SEKCJE WYTICZNYCH PPP TOM I-IV



Tom III: Część II Punkt 1.10 – Umowa Bezpośrednia

Tom IV: Część II Punkt 1.6 – Umowa Bezpośrednia

Umowa Bezpośrednia stanowi nieznaną tradycyjnym zamówieniom publicznym (a z kolei typową w Projektach PPP i regulowaną w art. 10a ust. 1 Ustawy o PPP) umowę, zawieraną pomiędzy Podmiotem Publicznym, Partnerem Prywatnym i Instytucją Finansującą Projekt PPP. Celem Umowy Bezpośredniej jest przede wszystkim zabezpieczenie realizacji Projektu PPP, z uwzględnieniem warunków Instytucji Finansującej.

Umowa Bezpośrednia zawiera zasady współpracy Podmiotu Publicznego, Partnera Prywatnego i Instytucji Finansującej, dotyczące przede wszystkim sytuacji trudnych dla Projektu PPP, które wymagają podjęcia określonych działań naprawczych włącznie ze zmianą Partnera Prywatnego, np. w przypadku takich naruszeń Umowy o PPP, które mogą skutkować jej wypowiedzeniem przez Podmiot Publiczny. Umowa Bezpośrednia może również nakładać na stronę publiczną pewne obowiązki informacyjne względem Instytucji Finansującej, zawierać zasady przelewu wierzytelności przysługujących Partnerowi Prywatnemu wobec Podmiotu Publicznego lub regulować instytucję prawa interwencji.

Prawo interwencji (ang. *step-in rights*)

Zostało określone w art. 10a ust. 1 Ustawy o PPP i polega na tym, że na mocy Umowy Bezpośredniej, w przypadku poważnego zagrożenia realizacji Przedsięwzięcia, Podmiot Publiczny będzie mógł przenieść na Instytucję Finansującą całość lub część praw i obowiązków Partnera Prywatnego. Ponadto, na mocy art. 10a ust. 2 Ustawy o PPP, za zgodą Podmiotu Publicznego Instytucja Finansująca będzie mogła w takiej sytuacji powierzyć dalszą realizację Przedsięwzięcia innemu podmiotowi.

Tabela 11. Przykładowy zakres Umowy Bezpośredniej

Umowa Bezpośrednia może zawierać:

1. Zgodę Podmiotu Publicznego na ustanowienie instrumentów zabezpieczeń na rzecz Instytucji Finansujących w związku z finansowaniem głównym.
2. Sposób lub warunki dokonywania płatności z tytułu Umowy o PPP przez Podmiot Publiczny na rzecz Partnera Prywatnego i zobowiązanie Podmiotu Publicznego do poinformowania Instytucji Finansujących o każdej zmianie w przedmiotowym zakresie, uzgodnionej z Partnerem Prywatnym.
3. Obowiązki informacyjne Podmiotu Publicznego względem Instytucji Finansujących w zakresie:
 - wystąpienia zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę wypowiedzenia

Umowy o PPP;

- wyliczeniach stawek waloryzujących Opłatę za Dostępność;
- nałożenia kar umownych na Partnera Prywatnego (powyżej uzgodnionego progu kwotowego);
- zobowiązania Podmiotu Publicznego do zapłaty odsetek za opóźnienie (powyżej uzgodnionego progu kwotowego);
- zmiany Umowy o PPP;
- zamiaru odstąpienia od Umowy o PPP przez Podmiot Publiczny lub spełnienia w opinii Podmiotu Publicznego przesłanek upoważniających Podmiot Publiczny do wypowiedzenia Umowy o PPP.

4. Oświadczenia Podmiotu Publicznego o braku postępowań sądowych, administracyjnych lub arbitrażowych oraz braku wiedzy o istnieniu podstaw do wystąpienia takich postępowań w przyszłości, które dotyczą Podmiotu Publicznego, a które mogłyby wywrzeć istotny negatywny wpływ na zgodność z prawem lub ważność Umowy o PPP, Umowy Bezpośredniej lub innych umów związanych lub na możliwość wykonania zobowiązań przez Podmiot Publiczny.

5. Obowiązki informacyjne Podmiotu Publicznego, w przypadku zamiaru wykonania prawa interwencji zgodnie z Umową o PPP, w zakresie:

- działań jakie zamierza podjąć w ramach prawa interwencji;
- terminu w jakim zamierza rozpocząć działania w ramach prawa interwencji;
- okresu, podczas którego będzie wykonywać działania w ramach prawa interwencji.

6. Obowiązki informacyjne Instytucji Finansujących względem Podmiotu Publicznego, a w szczególności w zakresie powiadomień o:

- wszczęciu czynności zmierzających do zaspokojenia się Instytucji Finansujących z dowolnego instrumentu zabezpieczenia ustanowionego w związku z finansowaniem głównym lub transakcjami zabezpieczającymi;
- zamiarze przedterminowego rozwiązania umowy kredytowej lub transakcji zabezpieczającej przez Instytucje Finansujące (w przypadku poinformowania o takiej okoliczności Partnera Prywatnego);
- spełnieniu w opinii Instytucji Finansujących przesłanek upoważniających Instytucje Finansujące do rozwiązania umowy kredytowej (w przypadku poinformowania o takiej okoliczności Partnera Prywatnego).

7. Zakres prawa interwencji Instytucji Finansujących, w tym rozpoczęcia, zakończenia, biegu oraz długości okresu naprawczego, w czasie, którego Partner Prywatny lub Instytucje Finansujące będą mogły podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn dających

Podmiotowi Publicznemu prawo wypowiedzenia Umowy o PPP, jak również w zakresie sporządzenia, zakresu i wykonania odpowiedniego planu naprawczego.

8. W okresie naprawczym, w szczególności:

- Podmiot Publiczny na żądanie Instytucji Finansujących będzie zobowiązany do przedstawienia informacji o:
 - kwotach niespornych, które są wymagalne i płatne (i) przez Partnera Prywatnego na rzecz Podmiotu Publicznego oraz (ii) przez Podmiot Publiczny na rzecz Partnera Prywatnego, w związku z Umową o PPP lub które są należne i niewymagalne, lecz staną się wymagalne w okresie naprawczym,
 - rodzaju i kwocie spornych płatności pomiędzy Partnerem Prywatnym a Podmiotem Publicznym,
 - niewykonanych zobowiązaniach niepieniężnych przez Partnera Prywatnego na podstawie Umowy o PPP, co do których Partner Prywatny pozostaje w zwłoce oraz innych naruszeniach Partnera Prywatnego w związku z Umową o PPP, wraz z szacowaną wartością wynikających z nich roszczeń pieniężnych,
 - Podmiot Publiczny nie będzie mógł skorzystać z prawa do wypowiedzenia Umowy o PPP, nie dokona wszczęcia egzekucji skierowanej do majątku Partnera Prywatnego ani nie złoży wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego względem Partnera Prywatnego;
 - Podmiot Publiczny będzie wykonywać swoje zobowiązania wynikające z Umowy o PPP;
 - w przypadku terminowego sporządzenia i dostarczenia planu naprawczego, Podmiot Publiczny zawiesi naliczanie kar umownych należnych zgodnie z treścią Umowy o PPP, w okresie naprawczym;
 - Instytucje Finansujące nie będą prowadzić egzekucji z majątku Partnera Prywatnego.
-

9. Warunki kumulatywnego przystąpienia do długu Partnera Prywatnego przez podmioty trzecie z tytułu Umowy o PPP (z wyłączeniem takiej możliwości w stosunku do Podmiotu Publicznego) w okresie naprawczym lub w ramach wykonania odpowiedniego planu naprawczego. Zasady podjęcia przez Instytucję Finansującą działań zmierzających do zmiany kontroli Partnera Prywatnego (o ile taka zmiana wymaga zgody Podmiotu Publicznego zgodnie z Umową o PPP) poprzez:

- przejęcie tytułu do wszystkich udziałów w Partnerze Prywatnym (Spółce Projektowej) przez Instytucję Finansującą;
- przejęcie zarządzania przedsiębiorstwem Partnera Prywatnego wspólnie z innym podmiotem wskazanym przez Instytucję Finansującą (w tym poprzez wykonanie praw z zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie lub zbiorze składników majątkowych Partnera Prywatnego); lub

- o ile będzie to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy Prawa - wstąpienia innego podmiotu w prawa i obowiązki Partnera Prywatnego wynikające z Umowy o PPP, w przypadku, gdyby w okresie naprawczym nie udało się usunąć przyczyn wypowiedzenia Umowy o PPP.

10. Zasady przejęcia ryzyka ekspozycji na zmiany wysokości zmiennej stopy procentowej w odniesieniu do finansowania głównego przez Podmiot Publiczny.

UWAGA



Zaleca się uzgodnienie w ramach PPU ogólnego zakresu Umowy Bezpośredniej, który zostanie doprecyzowany po dokonaniu wyboru Partnera Prywatnego i Zamknięciu Komercyjnym, z konkretną Instytucją Finansującą. Natomiast nie jest zalecane dołączanie szczegółowego wzoru lub zamkniętego katalogu postanowień Umowy Bezpośredniej.

6.5.6.4 Umowa o dofinansowanie

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część I Punkt 4 – Formuła hybrydowa - łączenie PPP ze środkami UE

Tom III: Część II Punkt 1.9 – Finansowanie Przedsięwzięcia

W przypadku Projektów Hybrydowych istotnym elementem Dokumentacji Postępowania będzie umowa o dofinansowanie Projektu PPP.

Z uwagi na sposób rozliczania Projektów Hybrydowych, z punktu widzenia Partnerów Prywatnych i Instytucji Finansujących niezwykle istotne jest przejrzyste ujęcie w PPU obowiązków Partnera Prywatnego związanych z dokumentowaniem wydatków poniesionych na realizację Przedsięwzięcia oraz obowiązków stron Umowy o PPP w zakresie wykorzystania środków unijnych.

Warto dodać, że w każdym przypadku możliwość i szczegółowe zasady realizacji Projektu Hybrydowego powinny być uzgodnione z właściwą instytucją zarządzającą, i to na jak najwcześniejszym etapie Postępowania, a najlepiej – przed jego formalnym rozpoczęciem.

DOBRE PRAKTYKI



Do dobrych praktyk w zakresie Projektów Hybrydowych należy konsultowanie warunków dofinansowania ze wszystkimi uczestnikami Postępowania PPP. Ponadto, zakres i warunki techniczne Przedsięwzięcia należy ustalać na jak najwcześniejszym etapie Postępowania. Ustalony w ten sposób zakres Projektu PPP zawarty zostanie we wniosku o dofinansowanie i będzie stanowił podstawę oceny wniosku dokonywanej przez właściwą instytucję udzielającą dofinansowania.

UWAGA



Najczęściej na etapie Postępowania PPP beneficjent nie ma jeszcze zawartej umowy o dofinansowanie Projektu PPP. W takim przypadku - w miarę możliwości - należy dokonać uzgodnień (i koniecznych zmian dostosowawczych) wzoru umowy o dofinansowanie z instytucją zarządzającą. W przeciwnym razie Podmiot Publiczny i Partnerzy Prywatni – nie znając szczegółowych obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie w kontekście specyfiki konkretnego Projektu, nie będą w stanie oszacować ryzyka związanego z jego realizacją.

Należy także pamiętać, że zgodnie z art. 257 ust. 1 Ustawy PZP Zamawiający może unieważnić Postępowanie, jeżeli na realizację Przedsięwzięcia nie zostały mu przyznane środki finansowe, o ile możliwość unieważnienia Postępowania na tej podstawie przewidziana została w ogłoszeniu o zamówieniu. W przypadku Projektów Koncesyjnych Zamawiający samodzielnie określa przesłanki unieważnienia Postępowania.

6.5.7 Pozostałe dokumenty

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część I Punkt 2 – Otoczenie instytucjonalno-prawne Projektów PPP

Zasadniczo, SWZ/Dokumenty Koncesji, dokumentacja prawna, techniczna i finansowa wyczerpują zakres Dokumentacji Postępowania. W pewnych przypadkach Dokumentacja Postępowania może być także uzupełniana o inne jeszcze dokumenty, o ile mają w danym przypadku zastosowanie, takie jak np.:

- 1) opinia ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dotycząca zasadności realizacji Przedsięwzięcia (Opinia PPP - art. 3a Ustawy o PPP);
- 2) zgoda Ministra Finansów na finansowanie Przedsięwzięcia z budżetu państwa kwotą przekraczającą 100 000 000 zł (art. 18 ust. 1 Ustawy o PPP);
- 3) indywidualna interpretacja prawa podatkowego wydawana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej;
- 4) zgoda Prezesa Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej na rozporządzanie aktywami trwałymi zgodnie z przepisami Ustawy o Zasadach Zarządzania Mieniem Państwowym;
- 5) opinia prawna Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wydawana na rzecz podmiotu reprezentującego Skarb Państwa o projekcie Umowy, jeżeli jej wartość przekracza 50 mln zł oraz opinia prawna Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie wzoru Umowy, istotnych postanowień Umowy lub projektu Umowy o PPP zawieranych w oparciu o Ustawę PZP, jeżeli wartość przedmiotu zamówienia przekracza kwotę 50 mln zł, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
- 6) inne dokumenty związane z realizacją Przedsięwzięcia, mające znaczenie dla Dokumentacji Postępowania.

Funkcją ww. dokumentów jest przede wszystkim zapewnienie, że określone rozwiązania prawne przyjęte w Umowie o PPP mają swoje oparcie w oficjalnych stanowiskach organów kontroli i ochrony prawa. Ma to znaczenie nie tylko dla samych Podmiotów Publicznych, ale także dla Partnerów Prywatnych uczestniczących w Postępowaniu oraz dla Instytucji Finansujących, które mogą uzależnić udzielenie Projektowi PPP finansowania dłużnego od uzyskania przez Podmiot Publiczny (i Partnera Prywatnego) wszystkich wymaganych przepisami prawa zgód, opinii, decyzji itp.

7. Ocena ofert

7.1 Zaproszenie do składania ofert

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom III: Część I Punkt 2.3 – Strategia negocjacyjna

Tom IV: Część II Punkt 1.3 – Umowa o PPP – proces negocjacyjny i postanowienia istotne z punktu widzenia Zarządzania Umową o PPP

Tom IV: Część II Punkt 2.5 – Negocjacje

Zamawiający prowadzi Negocjacje do momentu, aż będzie w stanie określić rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby w wyniku porównania propozycji Partnerów Prywatnych. Negocjacje kończą się wraz z ostatnim spotkaniem z wykonawcami, ewentualnie – w przypadku, gdy po ostatniej sesji dialogowej Podmiot Publiczny przekazał wykonawcom Dokumentację Postępowania w celu wniesienia ostatecznych uwag i propozycji – po zakończeniu tej czynności.

O zakończeniu Negocjacji Zamawiający jednocześnie informuje uczestniczących w nim wykonawców (art. 184 ust. 2 Ustawy PZP; Ustawa o Umowie Koncesji nie przewiduje co prawda takiego obowiązku, niemniej jednak poinformowanie wykonawców o zakończeniu Negocjacji należy do dobrej praktyki). Po finalnym ustaleniu wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia, Zamawiający przekazuje Partnerom Prywatnym, którzy brali udział w Negocjacjach, zaproszenie do składania ofert. Wraz z tym dokumentem przekazywana jest im SWZ (albo Dokumenty Koncesji) w ostatecznej wersji sporządzonej przez Zamawiającego.

Konieczne elementy SWZ określono w art. 185 ust. 2 Ustawy PZP (informacje, o których mowa w art. 134 ust. 1 i ust. 2 pkt 1–10 i 12–18):

Zgodnie z art. 186 ust. 2 Ustawy PZP zaproszenie do składania ofert musi zawierać co najmniej następujące elementy:

- 1) nazwę oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego Postępowania;
- 2) adres strony internetowej, na której jest dostępna SWZ oraz jej ewentualne zmiany i wyjaśnienia treści SWZ, a także inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
- 3) informację o podmiotowych środkach dowodowych, które należy załączyć do oferty, jeżeli Zamawiający przewiduje wymóg składania wybranych lub wszystkich środków dowodowych na etapie składania ofert;
- 4) wagę poszczególnych Kryteriów Oceny Ofert, jeżeli nie została ona przypisana na wcześniejszym etapie postępowania o udzielenie zamówienia;
- 5) sposób i termin składania ofert oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone, oraz termin otwarcia ofert.

Analogiczny zakres elementów zawiera zaproszenie do składania ofert ostatecznych w Trybie Negocjacyjnym Podprogowym (art. 295 Ustawy PZP).

W przypadku Postępowań Koncesyjnych Zamawiający samodzielnie określa zasady, na jakich złożone zostaną oferty oraz kwestie organizacyjne z tym związane, z uwzględnieniem treści art. 21 ust. 2 Ustawy o Umowie Koncesji. Dokumenty Koncesji powinny gwarantować równe traktowanie wszystkich wykonawców również w odniesieniu do etapu zaproszenia do składania ofert.

Zamawiający wyznacza termin składania ofert, z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty. Ustawa PZP (Dialog Konkurencyjny) i Ustawa o Umowie Koncesji nie wskazują minimalnych terminów na składanie ofert, w związku z czym terminy te powinny być ustalane przez Zamawiających indywidualnie, z uwzględnieniem czasu, jaki będzie potrzebny wykonawcom na przygotowanie ofert. W przypadku Trybu Negocyjnego Podprogowego minimalny ustawowy termin na składanie ofert wynosi 10 dni (roboty budowlane) lub 5 dni (dostawy lub usługi).

UWAGA



Do zdecydowanie nagannych praktyk należy zaliczyć niebranie przez Zamawiających pod uwagę czasu niezbędnego na przygotowanie ofert przez Partnerów Prywatnych. Pod koniec Negocjacji wykonawcy informują zazwyczaj Podmiot Publiczny o pożądanym przez nich terminach na przygotowanie i złożenie ofert (ewentualnie, Podmiot Publiczny sam powinien uzgodnić tę kwestię z wykonawcami). Nie znaczy to, że w każdym przypadku trzeba czynić zadość takim oczekiwaniom, szczególnie jeżeli byłyby one przesadne i nieadekwatne do stopnia złożoności Dokumentacji Postępowania. Niemniej jednak, w odróżnieniu od tradycyjnych zamówień publicznych, w praktyce Postępowań PPP terminy te zwykle wynoszą ok. 3-6 miesięcy.

W przypadku Postępowań o wartości poniżej Progów Unijnych, terminy te są zazwyczaj krótsze i wynoszą ok. 1-3 miesiące.

Na tym etapie Partnerzy Prywatni poznają również wagi przypisane poszczególnym Kryteriom Oceny Ofert (jeżeli nie były znane wcześniej) oraz treść i zasady przyznawania punktów w ramach doprecyzowanych Kryteriów Oceny Ofert (szerzej na ten temat zob. Punkt 6.5.3 Doprecyzowanie Kryteriów Oceny Ofert).

Wraz z ofertą wykonawcy, jeśli Zamawiający tego żąda, składają wadium. Ustawa o Koncesji nie reguluje obowiązku wnoszenia wadium. Szerzej na ten temat zob. Punkt 4.6 Wadium.

7.2 Pytania do SWZ oraz Dokumentów Koncesji

SWZ/Dokumenty Koncesji to jeden z najważniejszych dokumentów sporządzanych przez Zamawiającego, stanowiący podstawę do składania ofert przez Partnerów Prywatnych. Należy podkreślić, że Dokumentacja Postępowania stanowi często wypadkową rozwiązań proponowanych przez Partnerów Prywatnych, dodatkowo modyfikowanych przez Podmiot Publiczny we współpracy z Zespołem Doradców, w związku z czym pewne elementy SWZ/Dokumentów Koncesji mogą rodzić dodatkowe pytania lub budzić wątpliwości wykonawców już po otrzymaniu zaproszenia do składania ofert.

Do wyjaśnień i zmian treści SWZ, w przypadku Dialogu Konkurencyjnego, przepisy art. 135, art. 136, art. 137 ust. 1–4 i 6 oraz art. 143 ust. 3 Ustawy PZP stosuje się odpowiednio (art. 185 ust. 3 Ustawy PZP). Do trybu podstawowego, w Postępowaniach o wartości Progów Unijnych, zastosowanie znajdzie przepis art. 284 Ustawy PZP.

Każdy wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ (art. 135 ust. 1 Ustawy PZP). Zamawiający ma obowiązek udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania, które wpłynęły do niego, nie później jednak niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert albo nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert w przypadku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku Postępowania o wartości poniżej Progów Unijnych terminy te są krótsze. Do wyjaśnień i zmian treści SWZ w przypadku Trybu Negocyjnego Podprogowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 284, art. 285 i art. 286 ust. 1, 3, 5, 7 i 8 Ustawy PZP.

Jednakże, jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w ww. terminach, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert (art. 135 ust. 2 i 3 i art. 284 ust. 3 Ustawy PZP).

Jeśli wykonawca zada pytanie po upływie ww. terminów, Zamawiający nie ma formalnego obowiązku udzielania na nie odpowiedzi oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

Minimalne terminy udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców są niezbędne do wprowadzenia w ofertach koniecznych zmian. W praktyce Postępowania PPP, z uwagi na złożoną materię przedmiotu zamówienia/koncesji, terminy te zazwyczaj są znacznie wydłużane (w skrajnych przypadkach, przy dużej liczbie wniosków i pytań – nawet o kilka tygodni) i dostosowywane do potrzeb wykonawców. Zamawiający powinien bowiem wydłużyć termin składania ofert o czas niezbędny do uwzględnienia wszelkich zmian w ofertach.

Ustawa o Umowie Koncesji zawiera analogiczne rozwiązanie (por. art. 25).

DOBRE PRAKTYKI



W Postępowaniach PPP dobrą praktyką jest udzielanie Partnerom Prywatnym odpowiedzi na pytania zadawane do SWZ/Dokumentów Koncesji nawet po upływie formalnych terminów na ich zadawanie. Umożliwia to złożenie przez Partnerów Prywatnych porównywalnych ofert wyższej jakości, uwzględniających w większym stopniu Dokumentację Postępowania.

Należy pamiętać, że wyjaśnienie treści SWZ/Dokumentów Koncesji nie może sprowadzać się wyłącznie do formalnego udzielenia jakiegokolwiek odpowiedzi, w szczególności odsyłającej do innych postanowień Dokumentacji Postępowania, lecz powinno być wyczerpujące i rzeczywiście wyjaśnić wątpliwości albo sprzeczności dostrzeżone przez wykonawców i wyrażone w sformułowanych wnioskach lub pytaniach. Głównym celem udzielania wyjaśnień jest doprecyzowanie treści SWZ/Dokumentów Koncesji w taki sposób, żeby wszelkie postanowienia Dokumentacji Postępowania pozwalały wykonawcom na złożenie rzetelnych, porównywalnych ofert, uwzględniających wszystkie wymagania Podmiotu Publicznego, pozwalając tym samym należycie wycenić wszelkie koszty i ryzyka spoczywające po stronie Partnerów Prywatnych.

Jeśli w wyniku pytań wykonawców okaże się, że konieczne jest dokonanie zmiany treści SWZ, w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dokonać tego przed upływem terminu składania ofert.

Treść pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania (podmiotu, który zadał pytanie) udostępniając ją na stronie internetowej prowadzonego

Postępowania (na której uprzednio udostępniono Opis Potrzeb i Wymagań, a następnie SWZ/Dokumenty Koncesji).

Warto zwrócić uwagę, że Podmiotowi Publicznemu przysługuje uprawnienie do zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SWZ (Dialog Konkurencyjny - art. 136 ust. 1 Ustawy PZP; Tryb Negocyjny Podprogowy – art. 285 ust. 1 Ustawy PZP; w przypadku Postępowań Koncesyjnych Zamawiający może przewidzieć takie zebranie w Dokumentach Koncesji). Zebranie wykonawców może być pożądane w przypadku, gdy rozwiązania zastosowane przez Zamawiającego budzą wątpliwości lub skutkują różnymi interpretacjami wykonawców, a Podmiot Publiczny chce w pogłębiony sposób wyjaśnić te kwestie wszystkim Partnerom Prywatnym.

Zamawiający sporządza informację zawierającą zgłoszone na zebraniu pytania o wyjaśnienie treści SWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania udostępnia się na stronie internetowej Postępowania.

DOBRE PRAKTYKI



Do dobrych praktyk PPP należy zaliczyć minimalizowanie ryzyka uzyskania dużej liczby pytań do SWZ/Dokumentów Koncesji poprzez efektywne zarządzanie procesem Negocjacji (patrz Punkt 6.2 Zaproszenie do Negocjacji) oraz przygotowanie Dokumentacji Postępowania wysokiej jakości (patrz Punkt 6.5 Opracowanie ostatecznej Dokumentacji Postępowania). Należy jednak pamiętać, że zadawanie pytań do SWZ stanowi uprawnienie Partnerów Prywatnych (w przypadku Postępowań Koncesyjnych jest to rozwiązanie pożądane, uzależnione jednak do woli Zamawiającego).

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego Postępowania. Jeżeli zmiana dotyczy części SWZ, które nie zostały udostępnione na stronie internetowej prowadzonego Postępowania, dokonaną zmianę treści SWZ przekazuje w inny sposób wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu.

Podkreślenia wymaga, że Zamawiający nie może dokonać w SWZ/Dokumentach Koncesji zmian, które prowadziłyby do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu/koncesji.

Odpowiedzi do SWZ stanowią jej integralną część i jako takie powinny być interpretowane na równi z pozostałymi elementami SWZ.

W ramach odpowiedzi na pytania wykonawców oraz zmian do SWZ/Dokumentów Koncesji, Zamawiający dokonuje szeregu zmian w Dokumentacji Postępowania, w tym w PPU wraz z załącznikami technicznymi. W przypadku bardzo dużej liczby pytań i odpowiedzi zaleca się sporządzenie jednolitego tekstu Dokumentacji Postępowania, w szczególności Umowy o PPP i PFU/Specyfikacji Techniczno-Funkcjonalnej. W celu efektywnego zarządzania tym procesem Zamawiający powinien przygotować tabelę z pytaniami, pogrupować pytania w odpowiednie bloki tematyczne oraz przypisać odpowiedzialność za przygotowanie odpowiedzi właściwym członkom Komisji Przetargowej. Stanowi to element zarządzania po stronie Zamawiającego procesem modyfikacji Dokumentacji Postępowania po zakończeniu Negocjacji.

Zamawiający powinien podchodzić do kwestii udzielania odpowiedzi na pytania Partnerów Prywatnych w sposób pragmatyczny. Nieścisłości w treści SWZ lub wątpliwości interpretacyjne mogą skutkować błędami ofert.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym postępowaniu w sektorze budownictwa komunalnego, Zamawiający wraz z zaproszeniem do składania ofert przedstawił wzór formularza ofertowego oraz szczegółową instrukcję dla wykonawców. Jednocześnie oczekiwaniem Podmiotu Publicznego było wypełnienie przez Partnera Prywatnego formularza w formie tabeli Excel zawierającej aktywne i nieaktywne komórki. W ramach formularza ofertowego Partner Prywatny miał wskazać łączne wynagrodzenie ryczałtowe. Jednocześnie w dokumencie zawierającym metodykę oceny ofert Zamawiający wskazał, że będzie oceniał oferty w kryterium "cena" przy pomocy konkretnej wartości wskazanej w tabeli Excel (wartość NPC). Spowodowało to wątpliwość po stronie wykonawców, jaką wartość zatem powinni wpisać do formularza ofertowego. Pomimo że pytania wpłynęły po terminie zobowiązującym Zamawiającego do udzielenia odpowiedzi, Podmiot Publiczny uznał za konieczne udzielić wyjaśnień w celu zapewnienia prawidłowości i porównywalności składanych ofert.

W przypadku, gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty.

7.3 Metodyka oceny ofert

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom III: Część II Punkt 4 – Wynagrodzenie

7.3.1 Zagadnienia wspólne

Po ustaleniu ostatecznej treści SWZ/Dokumentów Koncesji, Partnerzy Prywatni składają oferty w Postępowaniu. W przypadku Projektów z Opłatą za Dostępność lub Projektów Koncesyjnych, w których przewidywane są płatności na rzecz Partnera Prywatnego, Zamawiający powinien, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnić na stronie internetowej prowadzonego Postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (por. art. 222 ust. 4 Ustawy PZP; Ustawa o Umowie Koncesji nie zawiera analogicznego przepisu, w związku z czym podanie przez Zamawiającego kwoty na realizację Umowy należy uznać za dobrą praktykę).

Cena lub koszt w Projektach PPP

Podmioty Publiczne często nie przywiązują należytej wagi do elementów ceny lub kosztu w Projektach PPP. Oferta cenowa Partnera Prywatnego nie obejmuje bowiem wyłącznie – jak w tradycyjnych zamówieniach publicznych – wynagrodzenia za roboty budowlane, lecz również koszty finansowania, utrzymania lub zarządzania Przedsięwzięciem w perspektywie wieloletniej. Prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia i aktualizacja tego szacunku przed zaproszeniem wykonawców do składania ofert (szerzej na ten temat patrz

Punkt 3.1.4 Szacowanie wartości zamówienia oraz koncesji) stanowi podstawę do określenia kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Przedsięwzięcia.

Z kolei niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego Postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
- cenach lub kosztach zawartych w ofertach (patrz art. 222 ust. 5 Ustawy PZP).

W przypadku Postępowania Koncesyjnych, z uwagi na brak regulacji prawnej w tym zakresie, zaleca się co najmniej podanie nazw (firm) oraz adresów wykonawców oraz informacji dotyczących ceny (lub proponowanych stawek Opłat od Użytkowników) i terminu wykonania Umowy.

Następnie rozpoczyna się faza oceny ofert. Zasadniczo, dzieli się ona na część formalną i merytoryczną.

7.3.2 Ocena formalna ofert

W przypadku Postępowania PZP, Zamawiający - w ramach oceny ofert - sprawdza szereg aspektów formalnych, aby upewnić się, że nie zostały spełnione przesłanki ich odrzucenia, wskazane w art. 226 ust. 1 Ustawy PZP. W szczególności sprawdzane jest, czy oferta:

- 1) nie została złożona po terminie składania ofert;
- 2) nie została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z Postępowania lub niespełniającego warunków udziału w Postępowaniu, lub który nie złożył w przewidzianym terminie JEDZ lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w Postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń;
- 3) nie jest zgodna z przepisami ustawy;
- 4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
- 5) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
- 6) została sporządzona lub przekazana w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego;
- 7) nie została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 8) nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- 9) nie została złożona przez wykonawcę niezaproszonego do składania ofert;
- 10) nie zawiera błędów w obliczeniu ceny lub kosztu;
- 11) wykonawca w wyznaczonym terminie nie zakwestionował poprawienia omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3;
- 12) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;

- 13) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;
- 14) wykonawca nie wniósł wadium (jeżeli Zamawiający żądał jego wniesienia), lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3;
- 15) oferta wariantowa została złożona lub spełnia minimalne wymagania określone przez Zamawiającego, w przypadku, gdy Zamawiający wymagał jej złożenia;
- 16) jej przyjęcie nie naruszałoby bezpieczeństwa publicznego lub istotnego interesu bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
- 17) nie obejmuje ona urządzeń informatycznych lub oprogramowania wskazanego w rekomendacji, o której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, stwierdzającej ich negatywny wpływ na bezpieczeństwo publiczne lub bezpieczeństwo narodowe;
- 18) nie została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, w przypadku, gdy Zamawiający tego wymagał w dokumentach zamówienia.

W toku całego procesu oceny ofert, Zamawiający jest zobowiązany żądać od wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń (art. 223 ust. 1 Ustawy PZP).

Zamawiający (bez wezwania wykonawcy) poprawia w ofercie (art. 223 ust. 2 Ustawy PZP):

- 1) oczywiste omyłki pisarskie;
- 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. W takim przypadku Zamawiający wyznacza wykonawcy odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.

W przypadku ww. poprawek Zamawiający niezwłocznie zawiadamia o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Tabela 12. Wyjaśnianie treści ofert i poprawianie omyłek

Wyjaśnianie treści ofert (art. 223 ust. 1 Ustawy PZP)

Zamawiający, dokonując oceny ofert, weryfikuje, czy wykonawcy spełniają wymogi określone w ustawie i SWZ. W przypadku powzięcia wątpliwości, Zamawiający może również żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

Poprawianie omyłek (art. 223 ust. 2 Ustawy PZP)

Art. 223 ust. 2 Ustawy PZP przewiduje instytucję poprawiania omyłek występujących w ofercie.

Zamawiający jest zobowiązany do poprawienia w ofercie:

Wyjaśnianie treści ofert (art. 223 ust. 1 Ustawy PZP)

Co do zasady, nie jest dopuszczalne prowadzenie między Zamawiającym i wykonawcą Negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści poza poprawieniem oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych lub innych, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. W postępowaniu prowadzonym w trybie Dialogu Konkurencyjnego w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców uszczegółowienia, wyjaśnienia i ulepszenia treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz zmian wymagań zawartych w Opisie Potrzeb i Wymagań lub SWZ.

Zgodność treści oferty z zapisami SWZ musi być oceniana według stanu na dzień złożenia oferty. W wyniku zastosowania tej regulacji, nie może dojść do uzupełnienia jakiegokolwiek brakującego dokumentu.

Poprawienie omyłek (art. 223 ust. 2 Ustawy PZP)

- oczywistych omyłek pisarskich;
- oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
- innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, w tym SWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

Oczywistą omyłką pisarską jest przykładowo "widoczne, wbrew zamierzeniu, niewłaściwe użycie wyrazu, widocznie mylna pisownia albo widocznie niezamierzone opuszczenie jednego lub więcej wyrazów" (wyrok SO w Gdańsku z 21.05.2008 r., XII Ga 151/08), na tą definicję powołuje się także KIO w swoich nowych wyrokach, np. w wyroku z dnia 25 listopada 2022 r. sygn. KIO 2998/22). Może ona polegać na fizycznym wprowadzeniu omyłkowego zapisu w treści oferty, który nasuwa się samoczynnie, przez pierwszy ogląd danego dokumentu, a także pominięcie określonego zapisu, w szczególności przez techniczne, często komputerowe i automatyczne przesunięcie tekstu, czy też pominięcie fragmentu tekstu, który – jak wskazuje kontekst i całość dokumentu – powinien znaleźć się w danym dokumencie (por. wyrok KIO z 31.03.2009 r., KIO/UZP 319/09, KIO/UZP 320/09, KIO/UZP 321/09, wyrok KIO z 19 października 2019 r., sygn. KIO 1926/19, wyrok KIO z dnia 24 lutego 2023 r. sygn. KIO 382/23, wyrok KIO z dnia 29 lipca 2020 r. sygn. KIO 1527/20). Z kolei oczywista omyłka rachunkowa to błąd w zakresie działań arytmetycznych, która polega na uzyskaniu błędnego wyniku wyliczeń na podstawie przyjętego przez Zamawiającego wzoru (por. wyrok KIO z 12.01.2016 r., KIO 2834/15, wyrok KIO z dnia 28 lipca 2022 r. sygn. KIO 1886/22, wyrok KIO z dnia 3 października 2023 r. sygn. KIO 2788/23).

Wyjaśnianie treści ofert
(art. 223 ust. 1 Ustawy PZP)

Poprawienie omyłek
(art. 223 ust. 2 Ustawy PZP)

Co istotne, zarówno omyłka pisarska, jak i rachunkowa musi być oczywista, tzn. niebudząca wątpliwości i łatwa do dostrzeżenia bez specjalistycznej wiedzy.

"Inna omyłka" to omyłka polegająca na niezgodności oferty z SWZ, niepowodująca istotnych zmian w treści tej oferty. Może ona dotyczyć każdego merytorycznego elementu oferty, np. warunków realizacji, zakresu, jakości, ilości itp.

Zamawiający, poprawiając omyłki w ofercie, ma obowiązek zawiadomić o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Rażąco niska cena

Pomimo że zagadnienie rażąco niskiej ceny wiąże się z Kryteriami Oceny Ofert, to z uwagi na obowiązek odrzucenia oferty z rażąco niską ceną, zaliczyć je można do formalnych aspektów oceny. Jak stanowi art. 224 ust. 1 Ustawy PZP, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu lub ich istotnych części składowych. Wykonawcy mają zatem możliwość udowodnienia, że zaoferowana przez nich cena jest racjonalna.

W przypadku jednak, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem Postępowania lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1, 5 i 10, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

Jeśli natomiast cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu Postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień. Szczególnie ta druga sytuacja może mieć praktyczne znaczenie w Postępowaniach PPP, a to z uwagi na czas ich trwania.

Należy podkreślić, że obowiązek wykazania, iż oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Partnerze Prywatnym. Brak wyjaśnień lub ich nieprzyjęcie przez Zamawiającego skutkować będą odrzuceniem oferty wykonawcy.

Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza Progi Unijne, Zamawiający zawiadamia Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Komisję Europejską o odrzuceniu ofert, które według Zamawiającego zawierały rażąco niską cenę lub koszt z powodu udzielenia pomocy publicznej, a wykonawca, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie udowodnił, że pomoc ta jest

zgodna z prawem w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (art. 224 ust. 7 Ustawy PZP).

Sprecyzowanie treści ofert

Warto zauważyć, że na podstawie art. 187 Ustawy PZP, w Postępowaniu prowadzonym w trybie Dialogu Konkurencyjnego (i tylko w tym trybie), w toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców uszczegółowienia, wyjaśnienia i ulepszenia treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym, że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz zmian wymagań zawartych w Opisie Potrzeb i Wymagań lub SWZ. Jak wynika z powyższego, elastyczny charakter Dialogu Konkurencyjnego umożliwia na etapie oceny ofert dokonywanie przez Partnerów Prywatnych doprecyzowania ich treści, a nawet dokonywanie w nich pewnych zmian. To uprawnienie Zamawiającego może być bardzo przydatne w przypadku zastosowania przez niego Kryteriów Oceny Ofert o charakterze niewymiernym, takich jak np. funkcjonalność proponowanych rozwiązań albo jakość koncepcji architektonicznej.

Jeśli w wyniku przeprowadzenia czynności oceny oferty Zamawiający stwierdzi zaistnienie chociaż jednej z podstaw odrzucenia określonych w art. 226 ust. 1 Ustawy PZP (stanowiących katalog zamknięty), jest zobligowany do odrzucenia oferty wykonawcy. Odrzucenie oferty jest dotkliwą sankcją, dlatego uznaje się, że może nastąpić jedynie po wszechstronnym zweryfikowaniu przez Zamawiającego okoliczności stanowiących podstawę odrzucenia.

Z punktu widzenia oceny formalnej ofert znaczenie ma także czas trwania tej oceny. Przedłużająca się ocena ofert może spowodować bowiem upływ terminu związania ofertą przez wykonawców. Zgodnie z art. 220 ust. 3 Ustawy PZP, w przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający, przed upływem terminu związania ofertą, zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. W przypadku Postępowania o wartości poniżej Progów Unijnych termin ten wynosi 30 dni (art. 307 ust. 2 Ustawy PZP). Przedłużenie terminu związania ofertą, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

W przypadku, gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Należy dodać, że jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Jeśli termin związania ofertą upłynął przez wyborem oferty, Zamawiający jest zobowiązany do wezwania najwyższej ocenionego wykonawcy do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku tej zgody, Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia Postępowania (por. art. 252 ust. 2 i 3 Ustawy PZP).

W Postępowaniu Koncesyjnym, z uwagi na brak szczegółowych regulacji prawnych dotyczących sposobu oceny ofert, Zamawiający powinien przewidzieć w Dokumentach Koncesji procedurę i zasady oceny ofert, w tym możliwość wzywania do wyjaśnień i uzupełnień złożonych ofert, a także do doprecyzowywania ich treści. W tym celu można posłużyć się rozwiązaniami omówionymi wyżej dla Postępowania PZP.

7.3.3 Zgodność modelu finansowego z wymogami SWZ oraz Dokumentów Koncesji

Pomimo że uzyskanie Zamknięcia Finansowego w większości przypadków należy do zadań Partnera Prywatnego i to on jest odpowiedzialny za poprawne funkcjonowanie modelu finansowego na potrzeby pozyskania finansowania od Instytucji Finansujących, to jednak w praktyce Podmiot Publiczny określa w SWZ/Dokumentach Koncesji wymogi odnośnie do modelu finansowego, w celu zapewnienia porównywalności ofert.

Tym samym, w ramach oceny ofert, Podmiot Publiczny musi dokonać oceny modelu finansowego przedłożonego wraz z ofertą w odniesieniu do wymagań z SWZ/Dokumentów Koncesji. Ponieważ model finansowy nie może być zabezpieczony hasłem, Podmiot Publiczny jest w stanie zweryfikować czy wymagania postawione w SWZ/Dokumentach Koncesji zostały uwzględnione przy konstruowaniu modelu finansowego. Zadaniem Podmiotu Publicznego nie jest przeprowadzanie przeglądu poprawności działania modelu ani też weryfikacja prawidłowości założeń.

Ocenę zgodności modelu należy przeprowadzić w formie tabeli, zawierającej w rzędach wymogi z SWZ/Dokumentów Koncesji, a w kolumnach nazwę Partnera Prywatnego, zgodnie z poniższym przykładem.

PRZYKŁAD 					
Wybrane wymogi	Partner Prywatny 1	Partner Prywatny 2	Partner Prywatny 3	Partner Prywatny 4	Partner Prywatny 5
Nakłady kapitałowe w ujęciu rocznym w wartościach nominalnych i realnych w całym okresie obowiązywania Umowy	Tak	Tak	Tak	Nie	Tak
Sprawozdania finansowe (rachunek zysków i strat, bilans oraz rachunek przepływów pieniężnych) w ujęciu nominalnym	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Przepływy pieniężne i salda gotówki w całym okresie trwania Umowy o PPP	Tak	Nie	Tak	Tak	Tak

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) całości Projektu PPP przed opodatkowaniem w ujęciu realnym	Tak	Tak	Tak	Nie	Tak
--	-----	-----	-----	-----	-----

W przypadku stwierdzenia niezgodności z wymogami SWZ/Dokumentami Koncesji Podmiot Publiczny może zwrócić się do Partnerów Prywatnych o wyjaśnienia, a w przypadku nieotrzymania wyjaśnień lub ich niezaakceptowania, odrzucić ofertę, która nie spełnia wymogów SWZ/Dokumentów Koncesji.

7.3.4 Ocena w ramach Kryteriów Oceny Ofert

Ocena w ramach Kryteriów Oceny Ofert ustanowionych przez Zamawiającego dokonywana jest w sposób omówiony w Punkcie 6.5.3 Doprecyzowanie Kryteriów Oceny Ofert (odnośnie do rodzajów Kryteriów Oceny Ofert zob. także Punkt 4.5 Kryteria Oceny Ofert).

Zamawiający, określając Kryteria Oceny Ofert w ogłoszeniu o zamówieniu/koncesji, związany jest nimi przez cały okres toczącego się Postępowania. Mając na uwadze zasadę równego traktowania wykonawców i zasadę uczciwej konkurencji, trzeba pamiętać, iż dokonując oceny ofert w ramach poszczególnych Kryteriów Oceny Ofert, Zamawiający musi kierować się literalnym brzmieniem postanowień ogłoszenia i SWZ/Dokumentów Koncesji, a nie dokonywać arbitralnej oceny ich spełniania.

Opis sposobu oceny tych kryteriów określony przez Zamawiającego powinien być związany z kształtem przyszłej Umowy o PPP. Przykładowo - jeśli Kryteria Oceny Ofert dotyczą czasu trwania Umowy o PPP, Zamawiający określając sposób dokonywania ich oceny wskazuje, ile punktów przyzna za określony czas trwania Umowy. Jeżeli natomiast Partner Prywatny zadeklarował w ofercie przejęcie określonego zadania lub ryzyka, będzie to skutkowało koniecznością dokonania zmian w PPU. Z tego względu, na etapie opracowywania ostatecznej Dokumentacji Postępowania (zob. Punkt 6.5 Opracowanie ostatecznej Dokumentacji Postępowania) powinno się wyróżnić w dokumentacji fragmenty, które mogą ulec zmianom po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej i od razu określić treść przyszłych zmian. Zmiany takie mają na celu wyłącznie dostosowanie Umowy o PPP do oferty Partnera Prywatnego. W szczególności nie mogą one prowadzić do nieuprawnionej modyfikacji Umowy o PPP.

Obliczanie OzD w Postępowaniach PPP

Z uwagi na specyfikę Projektów PPP, w ramach której wynagrodzenie Partnera Prywatnego nie stanowi wyłącznie cena za wykonanie robót budowlanych (szerzej patrz na ten temat Punkcie 7.3.1 Zagadnienia wspólne) należy zwrócić uwagę na metodykę obliczania tego Kryterium Oceny Ofert.

Punkty w kryterium "OzD" przyznawane są poprzez dokonanie porównania ceny badanej oferty z ceną oferty najniższej, a następnie przemnożenie przez wagę określoną dla kryterium "OzD".

Podmiot Publiczny dokonuje porównania cen brutto w złożonych ofertach. Ocena może zostać przeprowadzona według poniższego wzoru:

$$X = (\text{najniższa wartość OzD brutto}) / (\text{wartość OzD brutto badanej oferty}) * \text{waga przypisana kryterium "OzD"}$$

W przypadku, gdy kryterium "OzD" składa się z kilku komponentów (np. OzD jest podzielone na trzy elementy: opłatę za usługę projektową i budowlaną, opłatę za usługę finansową i opłatę za utrzymanie i/lub zarządzanie), wówczas każde z tych podkryteriów może być też wyliczane i punktowane oddzielnie, a następnie wszystkie punkty są sumowane i stanowią składową oceny całkowitej, obejmującej także kryteria pozacenowe.

W odniesieniu do metodyki obliczania ceny w Postępowaniach PPP rekomenduje się jednak traktowanie zbiorczo wszystkich komponentów składających się na cenę oferty.

Przykład obliczania Opłaty za Dostępność oraz Opłaty od Użytkowników zawarty został w Punkcie 6.5.3 Doprecyzowanie Kryteriów Oceny Ofert.

Ustawodawca nie określił konkretnego terminu, w którym ma zakończyć się czynność oceny ofert. Przyjmuje się, iż powinno to nastąpić bez zbędnej zwłoki. Z uwagi na złożony charakter Postępowania PPP ocena ofert zajmuje zwykle ok. 1-2 miesiące, w zależności od zróżnicowania i skomplikowania Kryteriów Oceny Ofert, a także ewentualnego wyjaśniania lub doprecyzowywania ich treści. W przypadku stosowania Kryteriów Oceny Ofert wymagających od Zamawiającego np. zatrudnienia dodatkowych ekspertów, termin ten może być również dłuższy.

W przypadku Dialogu Konkurencyjnego przed wyborem najkorzystniejszej oferty Zamawiający może, w celu potwierdzenia zobowiązań finansowych lub innych warunków zawartych w ofercie, negocjować z wykonawcą, którego oferta została najwyżej oceniona, ostateczne warunki Umowy, o ile nie skutkuje to zmianami istotnych elementów oferty lub zmianami potrzeb i wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Opisie Potrzeb i Wymagań ani nie prowadzi do zakłócenia konkurencji lub nierównego traktowania wykonawców (art. 188 Ustawy PZP). Podobna regulacja nie została przewidziana dla Trybu Negocjacyjnego Podprogowego.

W odniesieniu do Ustawy o Umowie Koncesji należy wskazać, że Zamawiający dysponuje znacznie większą swobodą w określaniu Kryteriów Oceny Ofert oraz ich stosowaniu. Niemniej jednak, tak samo jak przy poprzednich zagadnieniach, zaleca się korzystanie z rozwiązań przewidzianych Ustawą PZP, z zachowaniem elastyczności Postępowania Koncesyjnego.

7.4 Wybór oferty najkorzystniejszej

W wyniku czynności badania i oceny ofert, Podmiot Publiczny dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej. Z uwagi na zasadę jawności Postępowania, o dokonaniu tej czynności należy poinformować wszystkich wykonawców biorących udział w Postępowaniu, aby mieli możliwość zapoznania się informacjami stanowiącymi podstawę tej decyzji, jej weryfikację i rozważenie możliwości wniesienia środków ochrony prawnej (zob. Punkt 8 Środki ochrony prawnej). Jeżeli zachodzą okoliczności opisane w Punkcie 6.3.4 Aktualizacja Oceny Efektywności, należy w ramach czynności i badania oceny ofert, dokonać także aktualizacji Oceny Efektywności, w tym VfM.

Zamawiający, stosownie do przepisu art. 253 ust. 1 Ustawy PZP, informuje niezwłocznie (ustawodawca nie przewidział konkretnego terminu, w którym ma to nastąpić) wszystkich wykonawców o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania

i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym Kryterium Oceny Ofert i łączną punktację;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone.

Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej prowadzonego Postępowania.

Zamawiający musi podać uzasadnienie faktyczne i prawne powyższych okoliczności (art. 253 ust. 1 Ustawy PZP). Precyzyjne, wyczerpujące i niebudzące wątpliwości uzasadnienie ma znaczenie nie tylko z punktu widzenia zasad Postępowania PZP, ale także z uwagi na prawo wykonawców do skorzystania ze środków ochrony prawnej (zob. Punkt 8 Środki ochrony prawnej), warunkując ich zakres i rozpoznanie przez Krajową Izbę Odwoławczą.

W zakresie obowiązków Zamawiającego związanych z wyborem najkorzystniejszej oferty, Ustawa o Umowie Koncesji zawiera bardzo zbliżone zasady do tych przedstawionych powyżej (por. art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy o Umowie Koncesji).

UWAGA



W praktyce realizacji inwestycji infrastrukturalnych zdarza się, że wskutek znacznego upływu czasu, jaki mija od złożenia ofert do wyboru oferty najkorzystniejszej (np. z uwagi na przedłużający się proces oceny ofert, korzystanie przez wykonawców ze środków ochrony prawnej, opieszałość Zamawiającego), przy jednoczesnej zmianie warunków gospodarczych (np. istotny wzrost cen materiałów budowlanych lub kosztów pracowniczych), wykonawca woli stracić wadium, niż wykonać Umowę, której skutkiem będą dla niego duże straty finansowe. Ani w Postępowaniu PZP, ani w Postępowaniu Koncesyjnym nie zostały przewidziane mechanizmy umożliwiające przeciwdziałanie takim sytuacjom. Z tego powodu w Postępowaniach PPP zaleca się dokonanie oceny ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej w najszybszym możliwym terminie oraz zawarcie w postanowieniach Umowy o PPP klauzul waloryzacyjnych, które umożliwią dostosowanie wynagrodzenia Partnera Prywatnego do ewentualnych zmian rynkowych poczynwszy od daty składania ofert.

Ustawa o Umowie Koncesji nie reguluje instytucji wadium (zob. na ten temat Punkt 4.6.2 Postępowanie Koncesyjne), zatem w przypadku ustanowienia wadium, zasady jego zwrotu i zatrzymania Zamawiający powinien ustalić w Dokumentach Koncesji samodzielnie, o ile w ogóle zdecyduje się na zastosowanie instytucji wadium.

UWAGA



Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty skutkuje zobowiązaniem Podmiotu Publicznego do zawarcia Umowy o PPP z Partnerem Prywatnym. Wykonawca może dochodzić zawarcia Umowy na drodze sądowej, jeżeli Zamawiający będzie uchylał się od jej zawarcia. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej pociąga za sobą również konieczność zabezpieczenia przez Podmiot Publiczny środków finansowych na płatności wobec Partnera Prywatnego (jeżeli Podmiot Publiczny nie uczynił tego wcześniej, co jest rekomendowaną praktyką – zob. Punkt 9.1 Przygotowanie do zawarcia Umowy o PPP). Natomiast sankcją dla Partnera Prywatnego

za uchylanie się od zawarcia Umowy o PPP z Podmiotem Publicznym może być jedynie utrata wadium.

W przypadku, gdy cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Podmiot Publiczny zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Podmiot Publiczny unieważnia Postępowanie PPP, chyba że może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

PRZYKŁAD



W hipotetycznym Projekcie z sektora transportu, Podmiot Publiczny przygotowuje Ocenę Efektywności bez wsparcia zewnętrznego doradcy technicznego i finansowego. Nie wspierał się ww. doradztwem również na etapie Postępowania PPP. W trakcie dialogu jeden z wykonawców zgłaszał pisemne uwagi do przedstawianej przez Zamawiającego dokumentacji, w tym treści Umowy o PPP oraz wysokości zakładanego przez Podmiot Publiczny budżetu Przedsięwzięcia. Partner Prywatny także, w celu oszacowania możliwych przychodów z Przedsięwzięcia i w rezultacie dokładnej wyceny oferty, prowadził analizy techniczne i finansowe Przedsięwzięcia. Doświadczenie Partnera Prywatnego w realizacji Projektów PPP sprawiło, że Partner Prywatny, w celu jak najlepszego przygotowania oferty ostatecznej, zatrudnił doradców specjalizujących się w doradztwie przy projektach realizowanych w formule PPP. Partner Prywatny poniósł także koszt zlecenia wykonania analiz biznesowych oraz przygotowania modelu finansowego celem obliczenia ostatecznej ceny ofertowej i przygotowania oraz złożenia oferty w Postępowaniu.

Oferty złożyło trzech Partnerów Prywatnych i każda z nich przekraczała kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z tego powodu Podmiot Publiczny unieważnił Postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 PZP.

Partner Prywatny podnosił, że Podmiot Publiczny błędnie oszacował koszty projektu i nie dochował należytej staranności, ponieważ nie zaangażował doradców – technicznych i finansowych, którzy posiadają adekwatne doświadczenie. Jednocześnie Podmiot Publiczny nie posiadał własnych zasobów, ani też doświadczenia w realizacji jakiegokolwiek projektu PPP.

Partner Prywatny wezwał Podmiot Publiczny do zwrotu kosztów przygotowania oferty na podstawie przepisu art. 261 PZP. Strony zdecydowały się na przeprowadzenie postępowania concyliacyjnego przed Prokuratorią Generalną, w wyniku, którego została pomiędzy Stronami zawarta ugoda, na podstawie której Podmiot Publiczny zwrócił Partnerowi Prywatnemu część kosztów przygotowania oferty.

7.5 Unieważnienie Postępowania

Po złożeniu ofert może się zdarzyć, że Zamawiający nie dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, ale będzie musiał unieważnić Postępowanie. Postępowania PPP mogą być unieważniane wyłącznie z przyczyn określonych na podstawie przepisów Ustawy PZP lub Ustawy o Umowie Koncesji.

W praktyce, na etapie składania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej, a przed zawarciem Umowy o PPP, Ustawa PZP przewiduje następujące, obligatoryjne, przesłanki unieważnienia Postępowania (por. przepis art. 255 Ustawy PZP).

Tabela 13. Przesłanki unieważnienia Postępowania

Przesłanka unieważnienia Postępowania	Wyjaśnienie
Nie złożono żadnej oferty albo wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.	W Postępowaniu nie złożono żadnej oferty albo wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu z przyczyn formalnych, jako niespełniające warunków określonych w SWZ.
Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Przedsięwzięcia.	Jest to najczęstsza podstawa do unieważnienia Postępowania. Należy pamiętać, że Zamawiający zawsze może zwiększyć kwotę przeznaczoną na sfinansowanie Przedsięwzięcia do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
W przypadkach, o których mowa w art. 248 ust. 3, art. 249 i art. 250 ust. 2, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie.	Przesłanka dotyczy przypadków, w których złożone oferty przedstawiają taki sam bilans ceny lub kosztu i innych Kryteriów Oceny Ofert, zaś złożone przez wykonawców oferty dodatkowe zawierają taką samą cenę lub koszt.
Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie Postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.	Zmiana okoliczności musi mieć charakter obiektywnie nieprzewidywalny, istotny oraz powinna faktycznie zaistnieć. Ponadto musi ona powodować upadek potrzeby udzielenia zamówienia lub kontynuowania Postępowania w świetle interesu publicznego. Interes publiczny oznacza korzyści społeczne, nie zaś indywidualny interes Zamawiającego. W szczególności, zastosowania tej przesłanki nie usprawiedliwia brak środków na sfinansowanie Przedsięwzięcia.
Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu Umowy o PPP.	Wada taka musi mieć charakter nieusuwalny, w związku z czym zaistniałe uchybienia proceduralne nie mogą zostać skorygowane przez Zamawiającego.
Wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy o PPP lub uchylił się od zawarcia Umowy, z uwzględnieniem art. 263.	Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia Umowy o PPP lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w Postępowaniu

wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić Postępowanie.

Ponadto, w przepisie art. 256 Ustawy PZP wprowadzono fakultatywną przesłankę unieważnienia Postępowania, dotyczącą wystąpienia okoliczności powodujących, że dalsze prowadzenie Postępowania jest nieuzasadnione. Innymi słowy, muszą wystąpić zdarzenia powodujące, że kontynuowanie Postępowania jest bezcelowe. W przypadku Projektów PPP prowadzonych w trybie Dialogu Konkurencyjnego unieważnienie Postępowania może nastąpić tylko przed upływem terminu na składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu.

UWAGA



W trybie Dialogu Konkurencyjnego, stosownie do przepisu art. 257 Ustawy PZP, Zamawiający może unieważnić Postępowanie, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części Przedsięwzięcia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia Postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu.

Przypadek ten dotyczy przede wszystkim Projektów Hybrydowych lub Projektów PPP z innym dofinansowaniem zewnętrznym, o które ubiega się Podmiot Publiczny. Przesłanki tej nie można wykorzystać w przypadku, gdy Zamawiający dokona zmiany planu finansowego (np. wieloletniej prognozy finansowej JST lub programu wieloletniego uchwalonego przez Radę Ministrów).

Obowiązkiem Zamawiającego jest również niezwłoczne poinformowanie wykonawców uczestniczących w Postępowaniu o jego unieważnieniu, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego, a następnie zamieszczenie tej informacji na stronie prowadzonego Postępowania (art. 260 Ustawy PZP).

ŹRÓDŁA INFORMACJI



Prawo zamówień publicznych. Komentarz, pod red. H. Nowaka i M. Winiarza, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa 2021

<https://www.gov.pl/web/uzp/komentarz-do-prawa-zamowien-publicznych>

Należy pamiętać, że w przypadku unieważnienia Postępowania z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w Postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty (art. 261 Ustawy PZP).

PRZYKŁAD



W hipotetycznej sytuacji Podmiot Publiczny prowadził Postępowanie dotyczące budowy i eksploatacji parkingu podziemnego. Z uwagi na stosunkowo niski potencjał dochodowy Przedsięwzięcia, już w ogłoszeniu o zamówieniu założono, że część wynagrodzenia Partnera Prywatnego oparta zostanie o Oplatę za Dostępność. Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na ten cel była wielokrotnie niższa niż oczekiwana wartość dopłat wynikająca ze złożonych ofert.

Nie budziło wątpliwości, że Podmiot Publiczny nienależycie oszacował wartość Opłaty za Dostępność. W efekcie Partnerzy Prywatni wystąpili z uzasadnionym roszczeniem o zwrot kosztów uczestnictwa w Postępowaniu. Koszty te obejmowały m.in. wynagrodzenia członków zespołów Partnerów Prywatnych, zaangażowania zewnętrznych doradców oraz opracowania koncepcji architektonicznej, której oczekiwał w toku Negocjacji Podmiot Publiczny.

Podobne do omówionych wyżej przesłanki unieważnienia Postępowania występują w Postępowaniach Koncesyjnych (por. przepis art. 39 Ustawy o Umowie Koncesji). Postępowanie Koncesyjne nie przewiduje jednak wprost przesłanki dotyczącej zbyt niskiej kwoty przeznaczonej na sfinansowanie Przedsięwzięcia, a to z uwagi na konstrukcję wynagrodzenia Koncesjonariusza, która oparta jest o Opłaty od Użytkowników.

8. Środki ochrony prawnej

W trakcie Postępowania PPP wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX Ustawy PZP, jeżeli mają oni lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia (rozumiany jako interes prawny lub faktyczny) oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy PZP. Środki ochrony prawnej stanowią instrumenty, za pomocą których podmioty do tego uprawnione mogą bronić swoich interesów w razie dostrzeżenia nieprawidłowości w działaniach lub zaniechaniach Zamawiającego. Środki ochrony prawnej mogą być wnoszone już od ogłoszenia Postępowania. Wykonawcy korzystają z nich także na etapie oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu oraz na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Środkami ochrony prawnej są:

- 1) odwołanie wnoszone do Krajowej Izby Odwoławczej;
- 2) skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie (sądu zamówień publicznych).

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w Postępowaniu lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy PZP (np. od czynności wyboru oferty najkorzystniejszej, wykluczenia wykonawcy, odrzucenia jego oferty, zaniechania wykluczenia wykonawcy, zaniechania odrzucenia oferty itp.).

W art. 515 Ustawy PZP określono terminy wnoszenia odwołań w zależności od wartości zamówienia oraz rodzaju czynności Zamawiającego.

W Postępowaniach o wartości zamówienia równej lub przekraczającej Progi Unijne, odwołania wnosi się:

- 1) w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego, która stanowi podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo
- 2) w terminie 15 dni, jeżeli zostały przekazane w inny sposób.

Natomiast w Postępowaniach, których wartość zamówienia nie przekracza Progów Unijnych, odwołanie wnosi się:

- 1) w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego, która stanowi podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo
- 2) w terminie 10 dni, jeżeli zostały przekazane w inny sposób.

Z kolei odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się:

- 1) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w DUUE – w przypadku Postępowań o wartości zamówienia równej lub przekraczającej Progi Unijne;
- 2) w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w BZP – w przypadku zamówień o wartości poniżej Progów Unijnych.

Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem

elektronicznym. Zagadnienia proceduralne dotyczące wnoszenia i rozpoznawania odwołań zostały określone przede wszystkim w art. 513-521 Ustawy PZP.

Co istotne, w przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć Umowy o PPP do czasu ogłoszenia przez KIO wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze (art. 577 Ustawy PZP). Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o uchylenie zakazu zawarcia Umowy, a KIO może go uchylić, jeżeli niezawarcie Umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez Zamawiającego w Postępowaniu PPP oraz jeżeli Zamawiający uprawdopodobnił, że odwołanie wnoszone jest wyłącznie w celu uniemożliwienia zawarcia Umowy.

Orzeczenie KIO, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu.

Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu (art. 579 Ustawy PZP). Wnosi się ją do Sądu Okręgowego w Warszawie, za pośrednictwem Prezesa KIO, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Podkreślenia wymaga, że w postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. Szczegółowe regulacje dotyczące zasad wnoszenia skargi na orzeczenie KIO zostały określone w art. 579 – 590 Ustawy PZP.

W przeciwieństwie do wniesienia odwołania do KIO, złożenie skargi do sądu okręgowego nie tamuje możliwości zawarcia Umowy o PPP przez Podmiot Publiczny.

Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego (art. 590 Ustawy PZP).

Odnosnie do Postępowania Koncesyjnego należy stwierdzić, że Ustawa o Umowie Koncesji w zakresie wnoszenia i rozpoznawania odwołań oraz skarg do sądu okręgowego odsyła do unormowań Ustawy PZP. Niewielkie odrębności, dotyczące przede wszystkim terminów na wnoszenie odwołań do KIO, zawarte zostały w art. 55 Ustawy o Umowie Koncesji.

9. Zawarcie Umowy o PPP

9.1 Przygotowanie do zawarcia Umowy o PPP

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część II Punkt 3.8.5 – Analiza dostępności finansowej

Tom III: Część I Punkt 2.9 – Wpływ zobowiązań z Umowy o PPP na państwowy dług publiczny i deficyt sektora finansów publicznych

Tom III: Część II Punkt 1.2 – Definicje i interpretacja

Tom III: Część II Punkt 1.8 – Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy o PPP

Tom IV: Część II Punkt 2.6 – Zamknięcie Komercyjne

Po przeprowadzeniu oceny ofert i dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej oraz upływie terminów na wniesienie przez wykonawców środków ochrony prawnej, Podmiot Publiczny może przystąpić do opracowania finalnej wersji istotnych postanowień Umowy, przygotowując się do jej zawarcia. Na tym etapie mogą bowiem istnieć pewne obszary Umowy o PPP konieczne do doprecyzowania lub uzupełnienia. Pomijając kwestie oczywiste, takie jak wstawienie oznaczenia firmy Partnera Prywatnego i osób uprawnionych do reprezentowania oraz uzupełnienie daty podpisania Umowy o PPP, moment kształtowania ostatecznej treści Umowy o PPP daje możliwość usunięcia i poprawienia oczywistych omyłek oraz uzupełnienie Umowy o PPP o postanowienia niezbędne w celu doprowadzenia do jej kompletności.

Podstawowe różnice pomiędzy PPU na etapie zaproszenia do składania ofert, a PPU po dokonaniu wyboru oferty są następujące:

- 1) wersja PPU stanowiąca element Dokumentacji Postępowania zostaje przekazana Partnerom Prywatnym wraz z zaproszeniem do składania ofert w kształcie opracowanym po przeprowadzonych Negocjacjach;
- 2) na etapie składania ofert PPU mogą zostać zmienione wskutek zmian SWZ wprowadzonych na wniosek Partnerów Prywatnych, przez Podmiot Publiczny samodzielnie lub jako skutek odwołań składanych przez Partnerów Prywatnych lub inne uprawnione do tego podmioty;
- 3) po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej PPU doprecyzowane zostają w zakresie ceny lub kosztu realizacji Przedsięwzięcia, a także zadań lub ryzyk, które Partner Prywatny zobowiązał się wziąć na siebie w ramach złożonej oferty;
- 4) w PPU wpisany zostanie precyzyjnie (daty dzienne) okres, na jaki zawarta zostanie Umowa o PPP;
- 5) uzupełnione zostaną także niektóre załączniki do PPU, jak np. harmonogram płatności;
- 6) PPU uzupełnione zostają także o dane wybranego Partnera Prywatnego, sposób reprezentacji, odpis z właściwego rejestru, dane osób wyznaczonych do kontaktu i współpracy, adresy korespondencyjne.

Uzupełniając Umowę o PPP o dodatkowe postanowienia lub modyfikując Projektowane Postanowienia Umowy należy mieć na względzie konieczność dokonywania tych zmian

z poszanowaniem zasad zamówień publicznych lub koncesji, w tym zasady równego traktowania Partnerów Prywatnych i zasad uczciwej konkurencji.

Niedopuszczalne jest zatem modyfikowanie postanowień wrażliwych z punktu widzenia konkurencyjności ofert, takich jak np. kary umowne, zakresy odpowiedzialności, terminy wykonania zobowiązań itp. Natomiast za dopuszczalne można uznać uzupełnianie PPU o dodatkowe, niezbędne oświadczenia stron (np. co do koniecznych do uzyskania zgód korporacyjnych na zawarcie Umowy o PPP).

W przypadku, gdy niektóre dokumenty stanowiły załączniki do SWZ (np. Program Funkcjonalno-Użytkowy, wypis z rejestru gruntów, mapy i szkice lokalizacyjne), staną się one załącznikami do uzupełnianych PPU. Podobnie, do PPU załączone zostaną niektóre dokumenty podmiotowe Partnera Prywatnego (np. odpis z KRS), a także dokumenty złożone przez niego wraz z ofertą (np. warunki finansowania, model finansowy) lub inne (np. pełnomocnictwa). W ten sposób wypracowany zostanie układ treści Umowy o PPP wraz z załącznikami. Załącznikiem będzie również oferta Partnera Prywatnego.

Szczególna formuła negocjowania ostatecznych warunków umowy przed dokonaniem wyboru oferty została przewidziana dla wyboru Partnera Prywatnego w trybie Dialogu Konkurencyjnego. Zgodnie z art. 188 Ustawy PZP:

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty może, w celu potwierdzenia zobowiązań finansowych lub innych warunków zawartych w ofercie, negocjować z wykonawcą, którego oferta została najwyżej oceniona, ostateczne warunki Umowy, o ile nie skutkuje to zmianami istotnych elementów oferty lub zmianami potrzeb i wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Opisie Potrzeb i Wymagań ani nie prowadzi do zakłócenia konkurencji lub nierównego traktowania wykonawców.

Oznacza to, że z Partnerem Prywatnym, którego oferta została najwyżej oceniona (jednak przed ostatecznym jej wyborem) można przeprowadzić dodatkowe negocjacje dotyczące treści ostatecznej Umowy o PPP, które jednak:

- nie będą skutkować zmianami istotnych elementów oferty lub zmianami potrzeb i wymagań określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w OPIW;
- nie doprowadzą do zakłócenia konkurencji lub nierównego traktowania wykonawców.

W konsekwencji zakres negocjowanych zmian w żadnym wypadku nie może stwarzać zagrożenia, że oferta wybranego wykonawcy przestanie być ofertą najkorzystniejszą. Absolutnie niedopuszczalna jest też taka zmiana warunków zamówienia, której wprowadzenie na etapie Postępowania mogłoby z dużym prawdopodobieństwem skutkować złożeniem istotnie korzystniejszych ofert przez innych wykonawców lub zwiększeniem kręgu potencjalnych oferentów.

Prowadzenie negocjacji dot. treści Umowy o PPP na powyższych zasadach dopuszczalne jest dla zamówień klasycznych o wartości równej Progom Unijnym lub wyższej od nich oraz dla zamówień sektorowych (na mocy odesłania zawartego w art. 382 Ustawy PZP). Nie ma natomiast takiej możliwości w przypadku zamówień klasycznych o wartości poniżej Progów Unijnych, dla których Ustawa PZP nie przewiduje trybu Dialogu Konkurencyjnego.

Z kolei Ustawa o Umowie Koncesji nie zawiera żadnych szczególnych postanowień w tym zakresie. O ile Zamawiający przewidzi możliwość dalszych negocjacji Umowy o PPP, nic nie stoi na przeszkodzie, aby przed zawarciem Umowy o PPP odbyły się takie negocjacje z wybranym

wykonawcą. Bezwzględnie należy przy tym zadbać o zachowanie ogólnych zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji. W praktyce pociąga to za sobą zwłaszcza zakaz dokonywania takich zmian warunków umownych, które prowadziłyby do wypaczenia wyników Postępowania Koncesyjnego, np. prowadząc do takiej zmiany wybranej oferty, że nie byłaby ona już ofertą najkorzystniejszą. Należy także mieć na uwadze, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy koncesji musi być tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie (art. 42 Ustawy o Umowie Koncesji).

Niewątpliwie jedną z najistotniejszych kwestii z punktu widzenia zawarcia Umowy o PPP jest zabezpieczenie środków przez Podmiot Publiczny na zapłatę wynagrodzenia Partnera Prywatnego (ewentualnie – na dokonywanie innych płatności w związku z Przedsięwzięciem). Nie ma przy tym znaczenia, czy Umowa zawierana będzie pod warunkiem (rozwiązującym lub zawieszającym). Zabezpieczenie takie musi zostać zapewnione najpóźniej przed podjęciem zobowiązania finansowego, tj. zawarciem Umowy o PPP. Nie ma jednak przeszkód (a nawet jest to wskazane), żeby środki finansowe Podmiot Publiczny zabezpieczył na wcześniejszym etapie.

DOBRE PRAKTYKI



Zabezpieczenie środków na realizację Przedsięwzięcia

Za dobrą praktykę należy uznać zabezpieczenie przez Podmiot Publiczny środków finansowych na realizację Projektu PPP przed zaproszeniem Partnerów Prywatnych do złożenia ofert. Takie podejście nie tylko daje stronie publicznej gwarancję posiadanych środków już w tej dacie, ale sprzyja również Bankowości Projektu PPP. Partnerzy Prywatni, składając swoje oferty, mają bowiem pewność, że Podmiot Publiczny jest zdolny do zapłaty wynagrodzenia wynikającego z planowanej Umowy o PPP. Brak zabezpieczenia środków przed zaproszeniem do składania ofert może powodować ryzyko, że niektórzy wykonawcy w ogóle nie zdecydują się na złożenie ofert.

Nie ma natomiast sensu zabezpieczania środków przed wszczęciem Postępowania PPP lub w jego wczesnej fazie. W toku Negocjacji zmiana może ulec zarówno zakres Projektu PPP, jak też warunki jego realizacji, co może przełożyć się na istotną zmianę wysokości wynagrodzenia Partnera Prywatnego.

Zabezpieczenie środków na realizację zamówienia odbywa się zgodnie z procedurami właściwymi dla danego Podmiotu Publicznego, dotyczącymi zobowiązań wieloletnich. Przykładowo, w przypadku JST będzie to zazwyczaj uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, zaś na poziomie administracji rządowej zobowiązania z tytułu Opłaty za Dostępność będą ustalane corocznie w budżecie państwa i przekazywane właściwym dysponentom części budżetowych w celu włączania w plany finansowe Podmiotów Publicznych będących stronami Umów o PPP; w tym celu mogą też być uchwalane przez Radę Ministrów programy wieloletnie, których wykaz stanowi załącznik do ustawy budżetowej.

DOBRE PRAKTYKI



Klasyfikacja zobowiązań z Umów o PPP

Przed Zamknięciem Komercyjnym dobrą praktykę stanowi przeprowadzenie szczegółowej analizy podziału kluczowych ryzyk z Umowy o PPP w kontekście wpływu zobowiązań z Umowy na państwowy dług publiczny. W tym celu Podmiot Publiczny powinien zastosować metodykę określoną w art. 18a Ustawy o PPP, posilając się przepisami Rozporządzenia w sprawie Ryzyka.

Zgodnie z art. 18a ust. 1 Ustawy o PPP, zobowiązania wynikające z Umów o PPP nie wpływają na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych w sytuacji, gdy Partner Prywatny ponosi większość ryzyka budowy oraz większość ryzyka dostępności lub ryzyka popytu – z uwzględnieniem wpływu na wymienione ryzyka czynników takich jak gwarancje i finansowanie przez Podmiot Publiczny oraz alokacja aktywów po zakończeniu trwania Umowy.

Analiza powinna być aktualizowana w przypadku zmian Umowy wpływających na zmianę podziału ryzyk z daty Zamknięcia Komercyjnego lub Zamknięcia Finansowego.

Zamknięcie Komercyjne stanowi zwieńczenie Postępowania PPP. Obie strony kontraktu muszą przygotować swoich uprawnionych przedstawicieli do podpisania Umowy. Bezpośrednio przed jej zawarciem należy upewnić się, że przedstawiciele ci są prawidłowo umocowani (posiadają stosowne pełnomocnictwa lub umocowanie z urzędu) i czy organy stanowiące lub właścicielskie wydały uprzednio odpowiednie zgody (np. podjęły stosowne uchwały).

Jeżeli Umowa o PPP przewiduje określone warunki zawieszające jej wejście w życie albo rozwiązujące umowę w przypadku nieziszczenia się warunku (co może mieć miejsce np. w Projektach Hybrydowych), muszą zostać precyzyjnie wskazane terminy, od których zależeć będzie skuteczność obowiązywania Umowy o PPP i ewentualne możliwości ich wydłużenia.

Warto podkreślić, że na etapie zawarcia Umowy lub w niedługim czasie następującym po Zamknięciu Komercyjnym, Umowa może zostać rozbudowana o kolejne załączniki, takie jak np. koncepcja projektowa przedstawiana przez Partnera Prywatnego, szczegółowy harmonogram realizacji robót budowlanych, Umowa Bezpośrednia.

Należy dodać, że po dokonaniu Zamknięcia Komercyjnego, Podmiot Publiczny powinien dokonać na rzecz Partnera Prywatnego zwrotu wadium, chyba że wadium przeniesione zostanie na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy o PPP (por. Punkt 4 Ogłoszenie o zamówieniu oraz koncesji).

9.2 Zamknięcie Finansowe

POWIĄZANE SEKCJE WYTYCZNYCH PPP TOM I-IV



Tom I: Część I Punkt 4 – Formuła hybrydowa - łączenie PPP ze środkami UE

Tom I: Część II Punkt 3.8.5 – Analiza dostępności finansowej

Tom I: Część II Punkt 3.8.6 – Projekty z dofinansowaniem UE

Tom III: Część II Punkt 1.9 – Finansowanie Przedsięwzięcia

Tom III: Część II Punkt 1.10 – Umowa Bezpośrednia

Tom IV: Część II Punkt 1.6 – Umowa Bezpośrednia

Tom IV: Część II Punkt 2.7 – Zamknięcie Finansowe

Należy pamiętać, że samo Zamknięcie Komercyjne nie gwarantuje jeszcze realizacji Projektu PPP. W większości przypadków, na potrzeby Projektów PPP, wykorzystywana jest Spółka Projektowa, tworzona specjalnie w tym celu.

Środki pieniężne na realizację Projektu PPP pozyskiwane są głównie z dwóch rodzajów źródeł: wkładów kapitałowych od Sponsorów oraz finansowania pozyskiwanego od osób trzecich – najczęściej Instytucji Finansujących (banków) lub innych inwestorów instytucjonalnych.

W większości przypadków finansowanie Projektu PPP jest realizowane w formule finansowania pojedynczego projektu (ang. *project finance*). Umowa o PPP zawierana jest zazwyczaj ze Spółką Projektową, która od początku bierze udział w Postępowaniu albo zawiązywana jest przez Partnera Prywatnego po dokonaniu wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej, na zasadzie art. 7a ust. 1 Ustawy o PPP. Z kolei Instytucje Finansujące zawierają z Partnerem Prywatnym umowę kredytu, a z Podmiotem Publicznym i ewentualnie z Partnerem Prywatnym - Umowę Bezpośrednią.

Dlatego też Umowa o PPP powinna zawierać postanowienia mające na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa sytuacji, w której pomimo zakończenia procedury o udzielenie zamówienia i wyboru Partnera Prywatnego, nie dochodzi do pozyskania przez niego finansowania zewnętrznego niezbędnego do realizacji Projektu PPP lub takie finansowanie jest uzyskane na warunkach gorszych niż deklarowane w ofercie (przyjętych do bazowego modelu finansowego) – co w konsekwencji uniemożliwia lub znacznie opóźnia realizację Projektu PPP.

Przede wszystkim Umowa o PPP powinna w sposób wyważony i właściwy dla danego Projektu PPP alokować ryzyka związane z Przedsięwzięciem, jak również zawierać mechanizmy sprzyjające Zamknięciu Finansowemu, w tym obowiązek Podmiotu Publicznego do zawarcia Umowy Bezpośredniej. Poza tym Umowa o PPP powinna określać rozsądne terminy na Zamknięcie Finansowe oraz być elastyczna w zakresie możliwości przedłużenia tych terminów. Możliwe jest pozyskanie warunkowych wiążących warunków finansowania, tj. z zastrzeżeniem uzyskania pozytywnego raportu z audytu w szczególności Dokumentacji Postępowania oraz dokumentacji Partnera Prywatnego, którego przeprowadzenie jest niezbędne w procesie Zamknięcia Finansowego, co Podmioty Publiczne powinny dopuszczać, wymagając od Partnerów Prywatnych wiążących warunków finansowania na etapie ofert.

Pojęcie Zamknięcia Finansowego w praktyce realizacji Projektów PPP definiowane jest zwykle jako podpisanie umów dotyczących uzyskania przez Partnera Prywatnego finansowania w wysokości wystarczającej do realizacji Projektu PPP.

Warto jednak zwrócić uwagę, że pojęcie Zamknięcia Finansowego może być definiowane szerzej, i oznaczać także spełnienie przez Partnera Prywatnego warunków zawieszających rzeczywiste uruchomienie finansowania. Do takich warunków można w szczególności zaliczyć:

- 1) zawarcie Umowy o PPP;
- 2) zawarcie pełnej dokumentacji finansowej, w tym skuteczne ustanowienie zabezpieczeń;
- 3) zawarcie Umowy Bezpośredniej;

- 4) uzyskanie przez Partnera Prywatnego Decyzji Administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych;
- 5) zawarcie przez Partnera Prywatnego umów z wykonawcami/podwykonawcami, takich jak umowa o projektowanie, umowa o roboty budowlane, umowa o utrzymanie lub zarządzanie;
- 6) pozytywną ocenę Projektu PPP przez Instytucję Finansującą wskutek przeprowadzonego audytu prawnego, finansowego, technicznego i ubezpieczeniowego Projektu PPP, Spółki Projektowej, sytuacji finansowej (standingu) Sponsorów, modelu finansowego oraz dokumentacji projektowej i wykonawczej.

Poziom skomplikowania dokumentacji finansowej dotyczącej Projektu PPP oraz czas niezbędny na przeprowadzenie audytu przez Instytucję Finansującą może być na tyle znaczny, że dokonanie Zamknięcia Finansowego wymagało będzie kilku miesięcy intensywnego zaangażowania uczestników Przedsięwzięcia. Należy mieć to na uwadze planując harmonogram realizacji Projektu PPP.

Umowa o PPP powinna przewidywać więc okres kilku miesięcy na dokonanie przez Partnera Prywatnego Zamknięcia Finansowego oraz dodatkowy okres w celu spełnienia warunków zawieszających uruchomienie finansowania.

Brak Zamknięcia Finansowego albo brak uruchomienia finansowania w uzgodnionych terminach końcowych powinien wiązać się z automatycznym rozwiązaniem Umowy o PPP lub nieważnością jej w życie w określonym zakresie. O ile nie jest to skutek pożądaný przez żadną ze stron, pozwala on Podmiotowi Publicznemu na wyjście z impasu i potencjalnie rozpoczęcie kolejnego Postępowania.

Warto zwrócić uwagę, że obecnie Ustawa o PZP nie przewiduje na tym etapie instytucji tzw. zwycięzcy rezerwowego (czyli podmiotu, który w Postępowaniu złożył drugą najlepszą ofertę z punktu widzenia ich konkurencyjności), który w takich sytuacjach na wniosek Podmiotu Publicznego mógłby z mocy prawa wstąpić w miejsce dotychczasowego Partnera Prywatnego bez konieczności powtarzania całego Postępowania (takie rozwiązania są znane np. w Wielkiej Brytanii).

Małe Projekty mogą być realizowane według modelu finansowania ze środków własnych lub finansowania korporacyjnego. Finansowanie ze środków własnych cechuje się strukturą, w której Projekt PPP jest realizowany bezpośrednio przez podmiot, który prowadzi już działalność gospodarczą w odpowiednim zakresie oraz posiada zaplecze techniczne i majątek w rozmiarze wystarczającym do realizacji Projektu PPP w całości lub w przeważającej części ze środków własnych. Alternatywnie, Projekt PPP może być realizowany przez dedykowaną Spółkę Projektową, niemniej w całości lub w przeważającej części finansowaną przez Sponsorów lub podmiot od nich zależny.

UWAGA



Model finansowania ze środków własnych lub finansowania korporacyjnego dotyczy przede wszystkim Małych Projektów lub Przedsięwzięć, które ze względu na swoją wyjątkową specyfikę nie będą spełniać kryteriów Bankowości Projektu PPP w początkowym etapie ich realizacji.

Z punktu widzenia Umowy o PPP, finansowanie ze środków własnych lub korporacyjnych cechuje się prostszą strukturą, ze względu na brak inwestorów stricte kapitałowych w strukturze finansowania.

W konsekwencji, w przypadku wyboru oferty najkorzystniejszej Partnera Prywatnego, który będzie finansował Projekt PPP ze środków własnych, istotne postanowienia Umowy zostaną zmodyfikowane w ten sposób, że strony zrezygnują z obowiązku zawarcia Umowy Bezpośredniej (szerzej na temat Umowy Bezpośredniej zob. Punkt 6 Negocjacje oraz Wytyczne Tom III).

Elementem "Zamknięcia Finansowego", może być podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu Hybrydowego.

W przypadku Projektów Hybrydowych – w odróżnieniu od komercyjnego finansowania dłużnego – szczegółowe warunki udzielenia dofinansowania zazwyczaj znane są na bardzo wczesnym etapie (dokumentacja konkursowa lub inne wymogi instytucji zarządzającej), co umożliwia uwzględnienie ich w Dokumentacji Postępowania, na etapie Zamknięcia Komercyjnego i Zamknięcia Finansowego. Niemniej jednak, z uwagi na "mieszany" charakter Projektów Hybrydowych, należy zadbać o możliwie precyzyjne ustalenie postanowień Umowy o PPP, szczególnie w odniesieniu do zasad rozliczania Projektu Hybrydowego, dokumentowania wydatków ponoszonych przez Partnera Prywatnego i obowiązków, jakie musi przyjąć na siebie Partner Prywatny względem instytucji zarządzającej, Podmiotu Publicznego oraz organów uprawnionych do kontroli Projektów PPP dofinansowanych ze środków unijnych. Kwestia ta może mieć istotne znaczenie dla Zamknięcia Finansowego Projektu PPP, stąd zaleca się, aby dokumentacja związana z pozyskaniem środków UE została przekazana właściwej Instytucji Finansującej jeszcze przed dokonaniem Zamknięcia Komercyjnego, nie później jednak niż przed Zamknięciem Finansowym.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku Projektów Hybrydowych, w których wartość zamówienia dla robót budowlanych jest równa lub przekracza równowartość kwoty 20 mln euro (a dla dostaw lub usług – 10 mln euro), Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przeprowadza z urzędu kontrolę Postępowania (por. art. 613 i nast. Ustawy PZP). Na wniosek instytucji zarządzającej Prezes UZP może także odstąpić od przeprowadzenia kontroli uprzedniej, jeżeli w ocenie tej instytucji Postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zgodny z przepisami Ustawy PZP.

Po zakończeniu kontroli Zamawiającemu doręczana jest informacji o wyniku kontroli, która zawiera w szczególności:

- 1) określenie Postępowania, które było przedmiotem kontroli;
- 2) informację o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku;
- 3) zalecenia pokontrolne – jeżeli w toku kontroli stwierdzono, że jest zasadne unieważnienie Postępowania lub usunięcie stwierdzonych naruszeń.

Do czasu doręczenia informacji o wyniku kontroli nie jest możliwe zawarcie Umowy o PPP.

Ustawa o Umowie Koncesji nie zawiera przepisów obligujących Prezesa UZP do przeprowadzania kontroli uprzedniej Postępowania Koncesyjnych, w tym dotyczących Projektów Hybrydowych realizowanych na podstawie Ustawy o Umowie Koncesji.

W niektórych przypadkach – choć nie stanowi to powszechnej praktyki w Postępowaniach PPP – Zamknięcie Finansowe dokonywane jest już na etapie Zamknięcia Komercyjnego. Dzieje się tak najczęściej w sytuacjach, gdy Podmiotowi Publicznemu zależy na jak najszybszym rozpoczęciu realizacji Projektu PPP i uniknięcia ryzyka wygaśnięcia Umowy o PPP z uwagi na brak pozyskania środków finansowych.

W takiej sytuacji Podmiot Publiczny powinien umożliwić szczegółowe zapoznanie się z Dokumentacją Postępowania przez Instytucje Finansujące, czyli odpowiednio wydłużyć okres na składanie ofert (np. do 6-8 miesięcy), w zależności od stopnia złożoności Projektu PPP.

Warto podkreślić, że oczekiwanie połączenia Zamknięcia Komercyjnego i Zamknięcia Finansowego powinno być zaprezentowane przez Podmiot Publiczny na jak najwcześniejszym etapie Negocjacji, w celu umożliwienia niezwłocznego rozpoczęcia rozmów przez Partnerów Prywatnych z Instytucjami Finansującymi. Natomiast w trakcie Zamknięcia Finansowego Podmiot Publiczny powinien wspierać Partnera Prywatnego, udzielając niezwłocznie niezbędnych wyjaśnień i zawierając Umowę Bezpośrednią.

Połączenie Zamknięcia Komercyjnego i Zamknięcia Finansowego oznacza jednak, że Instytucje Finansujące muszą przeprowadzić audyt (prawny, finansowy i techniczny) Projektu PPP, w tym Dokumentacji Postępowania i sytuacji Partnerów Prywatnych przed Zamknięciem Komercyjnym, co wymaga znacznego nakładu czasu i kosztów po ich stronie. Ponadto, biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania rynku finansowań, oczekiwanie Zamknięcia Finansowego na etapie Zamknięcia Komercyjnego należy uznać za wymagające, a to z uwagi na ograniczone możliwości Instytucji Finansujących do zaangażowania po stronie kilku Partnerów Prywatnych jednocześnie w trakcie Negocjacji. Z tego powodu, Instytucje Finansujące nie zawsze będą zainteresowane jednoczesnym Zamknięciem Komercyjnym i Zamknięciem Finansowym, szczególnie jeśli w grę wchodzi Duże Projekty.

Warto zwrócić uwagę, że na rozwiniętych rynkach PPP często organizowane są tzw. sesje negocjacyjne z udziałem Instytucji Finansujących (ang. *debt competition*), Podmiotu Publicznego i Partnera Prywatnego, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w celu obniżenia kosztów finansowania, a tym samym obniżenia kosztów Projektu PPP dla Podmiotu Publicznego.

10. Zakończenie Postępowania PPP

Wybór oferty najkorzystniejszej oraz następujące po nim Zamknięcie Komercyjne kończą udane Postępowanie PPP.

Z punktu widzenia Postępowania PZP i Postępowania Koncesyjnego nie są to jeszcze wszystkie czynności formalne, jakie Zamawiający musi wykonać w związku z zawartą Umową.

W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy o PPP Podmiot Publiczny zobowiązany jest do:

- przekazania do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zawierającego informację o wynikach tego Postępowania (jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza Progi Unijne) - art. 265 ust. 1 Ustawy PZP albo
- zamieszczenia w BZP ogłoszenia o wyniku Postępowania zawierającego informację o udzieleniu zamówienia lub unieważnieniu Postępowania (jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż Progi Unijne) – art. 309 ust. 1 Ustawy PZP.

Ustawa o Umowie Koncesji (art. 23 ust. 1) przewiduje na dokonanie tej czynności termin 48 dni.

Postępowania PPP realizowane na podstawie Ustawy PZP wymagały będą sporządzenia protokołu z Postępowania (art. 71 Ustawy PZP). Jego zakres nie pokrywa się z protokołem z Negocjacji, dotyczy bowiem wyłącznie formalnych aspektów procedury udzielania zamówienia w ramach PPP.

Protokół z Postępowania powinien być prowadzony na bieżąco i zawierać m.in.:

- 1) nazwę i adres Zamawiającego;
- 2) wskazanie przedmiotu i wartości zamówienia;
- 3) informację o trybie udzielenia zamówienia i wskazanie okoliczności uzasadniających zastosowanie wybranego trybu, jeżeli przepisy ustawy przewidują przesłanki zastosowania tego trybu;
- 4) wartość umowy w sprawie zamówienia publicznego;
- 5) powody odstąpienia od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu lub ofert, podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych;
- 6) wyniki badania i oceny ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu, wraz z podaniem imion, nazwisk albo nazw wykonawców, numerów identyfikacji podatkowej (NIP) lub numerów identyfikacyjnych REGON;
- 7) powody odrzucenia ofert;
- 8) powody unieważnienia Postępowania;
- 9) informacje o istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 2 i 3 Ustawy PZP;
- 10) informacje o złożonych oświadczeniach, o których mowa w art. 56 ust. 4 Ustawy PZP;
- 11) imię i nazwisko albo nazwę wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, oraz powody wyboru jego oferty, a także, jeśli jest to wiadome, wskazanie części zamówienia lub umowy ramowej, którą ten wykonawca zamierza powierzyć

podwykonawcom, a także imiona i nazwiska albo nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani;

12) imiona i nazwiska członków komisji przetargowej i innych osób, które wykonywały czynności w prowadzonym Postępowaniu.

Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacja z zebrania z wykonawcami, zawiadomienia, wnioski, dowód przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego stanowią załączniki do protokołu Postępowania.

Jeżeli przed wszczęciem Postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono wstępne konsultacje rynkowe, informację o przeprowadzeniu tych konsultacji, o podmiotach, które w nich uczestniczyły, Zamawiający podaje w protokole Postępowania.

W przypadku zwrotu wykonawcom złożonych przez nich planów, projektów, rysunków, modeli, próbek, wzorów, programów komputerowych i innych podobnych materiałów, informacja o zwrocie stanowi załącznik do protokołu Postępowania.

Protokół wraz z załącznikami jest jawny i udostępniany na wniosek. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu Postępowania, z tym, że oferty wraz z załącznikami udostępnia się niezwłocznie po otwarciu ofert, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia otwarcia ofert, z uwzględnieniem art. 166 ust. 3 lub art. 291 ust. 2 zdanie drugie Ustawy PZP. Wnioski o dopuszczenie do udziału w Postępowaniu wraz z załącznikami udostępnia się od dnia poinformowania o wynikach oceny tych wniosków, przy czym nie udostępnia się informacji, które mają charakter poufny, w tym przekazywanych w toku Negocjacji lub Dialogu Konkurencyjnego.

Pomimo że w Ustawie o Umowie Koncesji nie zawarto wymogu sporządzania protokołu z Postępowania, Podmiot Publiczny powinien zastosować podobne rozwiązanie i sporządzić stosowny protokół. Z punktu widzenia Zamawiających najwygodniejsze będzie zastosowanie wzoru formularza protokołu zawartego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Obowiązkiem Zamawiających jest również przechowywanie Dokumentacji Postępowania przez cały okres obowiązywania Umowy o PPP (por. art. 78 Ustawy PZP i art. 13a Ustawy o Umowie Koncesji).

Podmiot Publiczny, na podstawie art. 16b ust. 1 pkt 2 i 4 oraz ust. 2 Ustawy o PPP, w terminie 30 dni od dnia Zamknięcia Komercyjnego, zobowiązany jest również do przekazania ministrowi właściwemu ds. rozwoju regionalnego informacji o zawarciu Umowy o PPP (a na etapie jej wykonywania – także o zmianie Umowy), obejmującej:

- 1) nazwę Przedsięwzięcia;
- 2) tryb wyboru Partnera Prywatnego;
- 3) datę podpisania Umowy i okres jej obowiązywania;
- 4) datę rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia realizacji Przedsięwzięcia;
- 5) wartości inwestycji, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, rozumianej jako nakłady inwestycyjne, które mają być poniesione na realizację Przedsięwzięcia;

- 6) wartości usług, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, które mają być świadczone w ramach Przedsięwzięcia;
- 7) wartości Umowy, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, rozumianej jako suma przewidywanych wydatków koniecznych do poniesienia przy realizacji Przedsięwzięcia;
- 8) zastosowane Mechanizmy Wynagradzania Partnera Prywatnego, w tym wysokości Opłat od Użytkowników, jeżeli takie opłaty są planowane, oraz warunki ich zmiany;
- 9) zawarcia Umowy Bezpośredniej, o której mowa w art. 10a Ustawy o PPP.

Podmiot Publiczny zobowiązany jest także do przedstawienia informacji na temat zawiązania i wpisu do rejestru przedsiębiorców Spółki Projektowej oraz Spółki PPP (por. art. 16b ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 Ustawy o PPP).

Analogiczne obowiązki spoczywają na Podmiotach Publicznych prowadzących Postępowania PPP w oparciu o art. 4 ust. 2 Ustawy o PPP, tj. na podstawie Ustawy o Umowie Koncesji.